

ARAKEN DE ASSIS

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE **XIII** PROCESSO CIVIL

ARTIGOS 797 AO 823

LUIZ GUILHERME MARINONI

DIRETOR

SÉRGIO CRUZ ARENHART

DANIEL MITIDIERO

COORDENADORES



THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS**

2019 - 12 - 02

Comentários ao CPC - v. XIII - Marinoni - Ed. 2018

EXPEDIENTE

Expediente

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

Juliana Mayumi Ono

Editorial: Andréia Regina Schneider Nunes, Cristiane Gonzalez Basile de Faria, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo,

Marcella Pâmela da Costa Silva e Thiago César Gonçalves de Souza

Assistente Editorial: Francisca Lucélia Carvalho de Sena

Produção Editorial

Coordenação

Iviê A. M. Loureiro Gomes

Líder Técnica de Qualidade Editorial: Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Felipe Augusto da Costa Souza, Gabriele Lais Sant'Anna

dos Santos, Maria Eduarda Silva Rocha, Mayara Macioni Pinto, Patrícia Melhado Navarra, Rafaella Araujo Akiyama e Thaís Rodrigues Sampaio

Analistas de Qualidade Editorial: Carina Xavier e Daniela Medeiros Gonçalves Melo

Estagiários: Angélica Andrade, Miriam da Costa Leite, Nicolas Eugênio Almeida Bueno e Sthefany Moreira Barros

Capa: Chrisley Figueiredo

Adaptação de capa: Linotec

Projeto gráfico: Carla Lemos

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

Marcello Antonio Mastrorosa Pedro

Analistas: Ana Paula Cavalcanti, Jonatan Souza, Luciano Guimarães e Rafael Ribeiro

Administrativo e Produção Gráfica

Coordenação

Mauricio Alves Monte

Analista de Produção Gráfica: Aline Ferrarezi Regis

© desta edição [2018]

2019 - 12 - 02

Comentários ao CPC - v. XIII - Marinoni - Ed. 2018

SOBRE O AUTOR

Sobre o Autor

Araken de Assis

Professor Emérito da PUC/RS. Doutor em Direito pela PUC-SP. Mestre e Especialista em Direito pela PUC-RS. Membro efetivo do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto de Direito Privado, do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (IARGS) e do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. Diretor da Revista Forense (Rio de Janeiro).

Integra o Conselho Editorial da Revista de Processo (São Paulo), da Revista da Ajuris (Porto Alegre), Revista Jurídica e de outras publicações especializadas. Foi Conselheiro, Corregedor e Secretário da OAB-RS, antes de ingressar no extinto TA-RS. Ex-Diretor da Escola Superior da Advocacia da OAB-RS. Desembargador (aposentado) do TJRS e Professor Titular (aposentado) da PUC-RS, instituição na qual lecionou nos cursos de Graduação e de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado). Comendador – “Jurista Eminente” – pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Advogado em Porto Alegre, São Paulo e Brasília.

© desta edição [2018]

Apresentação

Desde a formação da ciência jurídica como a conhecemos, a prática do direito orientou-se pela doutrina formada em torno de textos dotados de autoridade – primeiro com a *Glosa* e logo em seguida com os *Comentários*. Esse hábito de argumentar invocando a *communis opinio doctorum* é particularmente tão arraigado na tradição luso-brasileira que a glosa de Accursio e opinião de Bartolus constituíam fonte subsidiária do direito nas Ordenações Afonsinas e Manuelinas, tendo inclusive mantido esse mesmo patamar nas Ordenações Filipinas – com a única diferença de que a glosa de Accursio e a opinião de Bartolus não poderiam ser contrárias à *communis opinio doctorum* para então figurarem como fonte do direito.

Nesse cenário, em que se refletem as mais fundas raízes da cultura jurídica brasileira, é natural que os *Comentários* tenham tido grande proeminência na conformação da prática do direito brasileiro. Especialmente no campo do processo civil, não só o Código de 1939 despertou a atenção para a redação de textos com intenção sistemática, mas também o Código de 1973 experimentou idêntico interesse.

Atenta à tradição – e ao mesmo tempo ciente de seu compromisso em renová-la à luz das necessidades atuais – a Editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters organizou não só duas coleções de *Comentários ao Código de 1973* (a primeira organizada por Sérgio Bermudes e a segunda por Ovídio Baptista da Silva), mas igualmente se preocupou em convidar-nos para coordenar estes *Comentários*, os primeiros a constituírem uma coleção completa entregue à cultura jurídica nacional a respeito do Código de 2015. A fim de que o seu conteúdo pudesse espelhar os diferentes fios que se entrelaçam para dar sustentação ao processo civil brasileiro, a coleção é composta de autores do mais alto nível de formação acadêmica, atuantes em diferentes segmentos da prática jurídica e pertencentes a todos os quadrantes do nosso país.

Estes *Comentários* estão voltados a todos aqueles que trabalham diariamente com o Código de Processo Civil. É por essa razão que é uma grande alegria apresentar esta coleção de *Comentários ao Código de Processo Civil de 2015*, ao mesmo tempo em que agradecemos a confiança depositada pela Editora em nosso trabalho, pelos nossos coautores em nossa capacidade de levar adiante o projeto e pelo público interessado em torná-los seus instrumentos de trabalho. Enredar-se na tradição a fim de torná-la sempre viva e comprometida com a prática do direito é motivo de enorme felicidade para nós – ainda mais quando o seu objeto é o processo civil, ramo das leis mais rente à vida, sem o qual a tutela dos direitos não passa de uma mal-acabada impressão.

Luiz Guilherme Marinoni

Sérgio Cruz Arenhart

Daniel Mitidiero

ÍNDICE

TÍTULO II - DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO II - DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA

CAPÍTULO III - DA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER OU DE NÃO FAZER

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO

TÍTULO II - DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO

Capítulo I. Das Disposições Gerais

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará seu título de preferência.

1. Princípio do interesse do exequente – A localização do art. 797, situado na abertura do Título II – Das Diversas Espécies de Execução – e integrando suas disposições gerais, embora trate do princípio da prevenção, ou preferência decorrente da penhora, justifica-se pela sua cláusula intermediária: “realiza-se a execução no interesse do exequente”. Essa disposição consagra a diretriz ideológica da realização dos créditos, autêntico princípio heurístico da execução marcadamente individualista, e explica o princípio da prevenção. Não é, porém, a única disposição a refletir a ideologia da lei. O exequente tem ilimitada faculdade de desistir da execução (art. 775, caput). O ato atentatório à dignidade da Justiça constitui, segundo o art. 774, conduta do executado, embora ao exequente seja dado, por igual, descumprir deveres processuais de idêntica estatura.

Como quer que seja, o princípio da prevenção evidencia, mais do que qualquer outra regra, a ideologia dominante da execução por créditos.

2. Princípio da prevenção – O CPC de 1973 instituiu, no direito brasileiro, a máxima *prior tempore, potior jure*, ou princípio da prevenção, relativamente à penhora realizada pelo credor quirografário, e, naquela altura, promoveu autêntica revolução.¹ Essa regra revelava inequívoca opção ideológica pelo individualismo na atividade executiva. Por esse motivo, a execução realiza-se no interesse do exequente.

Em síntese, o art. 797, *caput*, excepciona, quanto ao credor comum ou quirografário, a diretriz do art. 957 do CC/2002, segundo o qual, inexistindo título legal de preferência, “terão os credores igual direito sobre os bens do devedor comum”, ou seja, o princípio da igualdade (*par conditio creditorum*) entre credores da mesma classe, no caso a dos credores comuns ou quirografários. O titular da primeira penhora, concorrendo com outros credores comuns, mas observado o princípio da prevenção, receberá seu crédito por inteiro, comportando o bem penhorado, ficando os demais credores penhorantes com o direito às sobras, salvo preexistência de prelação de direito material (v. g., o titular da penhora sobre o mesmo bem, a teor do art. 797, parágrafo único, é credor real).

O princípio da prevenção era da tradição luso-brasileira até as leis de 22.12.1761 e 20.06.1774,² e vigora no direito alemão,³ contrapondo-se ao princípio da igualdade, cuja índole é francesa, no qual há ponderação o interesse coletivo dos credores, repartindo entre eles os ônus e os bônus, na contingência de multiplicidade de penhoras sobre idêntico bem (art. 797, parágrafo único). A marca individualista do sistema evidencia-se na contraposição ao ideal de justiça, pois esta

corresponde à isonomia no tratamento dos credores (princípio da igualdade ou *par conditio creditorum*).⁴ O concurso de credores, no direito português, abrange só os credores com prelação de direito material, parecendo mais “equilibrado”.⁵ Ao contrário, na perspectiva individualista, prestigiando o exequente expedito, vigora o aforismo *vigilantibus jura*, ou seja, recebe primeiro quem penhorar primeiro (*prior tempore, potior jure*), porque representa indício firme de diligência. Nesta perspectiva, as críticas de que a norma convida à intolerância com o devedor,⁶ e estimula execuções imediatas,⁷ atacam seus efeitos mais evidentes, em lugar de questionarem o cabimento da ideologia intrínseca à regra.

O princípio da prevenção pressupõe a solvência do executado (art. 797, *caput*: “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal...”). Não se aplica, portanto, na insolvência civil – as disposições do CPC/1973 a esse respeito continuam vigentes, a teor do art. 1.052 do CPC/2015) – e na falência. É o contrapeso ao individualismo: os credores retardatários, desprovidos do atributo institucional da eficiência, na hipótese de o produto da alienação dos bens não solver as respectivas dívidas (ar. 905, I), e houver impossibilidade de promover nova penhora (art. 851, II), podem pleitear o concurso universal, a insolvência ou a falência, conforme se trate de devedor empresário, ou não, cuja execução governa-se pelo princípio antagônico da igualdade ou do *par conditio creditorum*.

Implicitamente, a preferência ou prevenção conferida pelo art. 797, *caput*, pressupõe a admissibilidade de duas ou mais penhoras sobre o mesmo bem, hipótese chancelada no art. 797, parágrafo único. Este evento somente origina a presunção de insolvabilidade (art. 750, I, do CPC/1973 c/c art. 1.052 do CPC/2015). Ao contrário do que sucedia perante o art. 947 CPC/1939, “a incidência de nova(s) penhora(s) sobre bem já penhorado não importa, de pleno direito... em resolver-se em concurso de credores”.⁸ Realmente, a instauração do mencionado concurso universal (art. 751, III, do CPC/1973 c/c art. 1.052 do CPC/2015), fitando o caso da insolvência, e a eliminação da vantagem decorrente da penhora pioneira, subordinar-se-ão à iniciativa nesse sentido dos credores em posição desvantajosa.⁹ À falta da abertura da execução coletiva, ainda que insuficiente o bem penhorado, o devedor “continua a ser tratado como solvente, muito embora já se note desequilíbrio em sua situação patrimonial”.¹⁰ Neste particular, salvo engano, avulta a vantagem prática do regime da preferência. O titular da penhora realizada em segundo lugar, fazendo as contas, talvez projete a insuficiência das sobras do primeiro lugar para atender, no todo ou em parte, o respectivo crédito, e, nada obstante, ficará pouco estimulado a provocar a execução universal (falência ou insolvência), porque, então, ocorrerá o chamamento de todos os credores, reduzindo ainda mais seu bônus.

Não apelando um dos credores à insolvência civil ou, conforme o caso, à falência, a coexistência de duas ou mais penhoras (art. 797, parágrafo único), ou a penhora do bem gravado com direito real de garantia ou obrigação *propter rem*, originará outra espécie de concurso, chamado de concurso especial,¹¹ ou de concurso particular. Duas características presidem o concurso especial (art. 908): (a) não envolve a totalidade dos credores do executado; (b) não abrange todos os bens do devedor comum. Ao contrário, o concurso universal aludido no art. 797, *caput*, apresenta essas duas características. Portanto, parece preferível designar o concurso do art. 908 como “especial”, em virtude da preferência instituída para os quirografários ou credores comuns, e da contraposição ao caráter universal da execução coletiva.¹² Entre os quirografários, a tônica desta execução coletiva é a preferência, segundo torna claro o já mencionado art. 908, conquanto sejam atendíveis outros privilégios e prelações dos créditos.

3. Natureza da preferência – A preferência outorgada pelo art. 797, *caput*, passa-se no plano da eficácia. Em particular, não erigiu a penhora em direito real anômalo,¹³ à semelhança do *pignus judiciale* do direito comum. É um efeito, dentre outros, da constrição patrimonial.¹⁴

4. Pressupostos do princípio da prevenção – Dois requisitos, extrínsecos à própria penhora do credor quirografário, governam a utilidade da preferência a ele atribuída pelo art. 797, *caput*: (a) a solvência formal do executado; e (b) a inexistência de prelação ou preferência de direito material outorgada a outro crédito.

A despeito de o art. 905, I, dispor que, movida só a benefício do exequente singular, a este exequente caberá, por força da penhora, direito de preferência, este último não opera plenamente na hipótese da existência de pluralidade de penhoras (art. 797, parágrafo único). A prioridade resultante da anterioridade da penhora só interessa quando houver a participação de outro credor quirografário. Instalando-se o concurso especial, porque o bem penhorado se encontra gravado por direito real de garantia, nenhuma influência exercerá o art. 797, *caput*, ou seja, não outorgará vantagem concreta ao exequente na distribuição do dinheiro depositado para segurar o juízo, objeto de penhora ou do produto dos bens alienados (art. 905, *caput*): o titular do crédito garantido por penhor, pela hipoteca ou pela anticrese, prefere ao credor quirografário penhorante, porque sua prelação deriva do direito material.

Em última análise, a preferência do art. 797, *caput*, somente atua quando concorrem, no dinheiro penhorado ou no produto da arrematação do bem penhorado, dois ou mais credores quirografários e penhorantes.

Entre credores trabalhistas, que movem execuções singulares contra o mesmo executado, vigorará o princípio da igualdade (*par conditio creditorum*), a teor dos arts. 957 e 962 do CC.

É preciso, então, examinar os pressupostos de incidência plena do art. 797, *caput*.

4.1. Solvência do executado – A prevenção ou preferência instituída no art. 797, *caput*, opera na expropriação comum mediante presunção da solvência do executado.¹⁵ Excedendo o valor conjunto dos bens penhoráveis ao montante das dívidas, ou seja, inexistindo insolvência nos termos do art. 748 do CPC/1973 c/c art. 1.052 do CPC/2015, em tese o patrimônio do executado garante todos os créditos em execução. Por isso, admitem-se penhoras sucessivas (art. 797, *caput*), seja porque o valor do bem penhorado comporta todas as restrições, seja porque sempre restará a possibilidade de realizar segunda penhora (art. 851, II). “O privilégio da penhora, ora assegurado”, explicava um dos maiores comentadores da lei processual anterior,

é, portanto, condicional e eventual, dependendo, exclusivamente, da solvência do devedor, única situação capaz de assegurar o adimplemento de todas as suas obrigações quirografárias.¹⁶

Típicas questões de fato, a insuficiência do bem e a insolvência do executado, surgirão durante os trâmites executivos, principalmente após a avaliação e perante a necessidade de ampliar a penhora. Na hipótese de as dívidas, então, excederem ao conjunto do patrimônio disponível do executado, a qualquer credor quirografário abre-se oportunidade de requerer o concurso universal (art. 753, I, do CPC/1973 c/c art. 1.052 do CPC/2015). Eventualmente, nenhum dos credores, titulares de penhora sobre o mesmo bem, atreve-se a provocar a insolvência civil ou falência, porque atrairiam a totalidade dos credores do obrigado comum, diminuindo sua eventual participação na distribuição do dinheiro em vez de ampliá-la por força do princípio da igualdade (*par conditio creditorum*).

Em tese, o princípio da prevenção nenhum prejuízo provoca aos credores. Os credores situados, no rateio do concurso especial de credores (art. 908, § 2.º), em posição secundária e desvantajosa, desfrutam da expectativa de receber todo o crédito, porque solvente o devedor comum – e, na pior das hipóteses, pleitearão segunda penhora, a teor do art. 851, II –, e da alternativa de provocar o concurso universal, desfazendo as prioridades na classe dos quirografários. Na insolvência civil, como resulta do art. 769 do CPC/1973 c/c art. 1.052 do CPC/2015, vigora o *par conditio creditorum*. Razões econômicas, já explicadas, desestimulam iniciativa nesse sentido. E talvez sequer haja interesse em abrir a execução universal, seja porque é inútil, seja porque é isolado e único o quirografário.¹⁷

4.2. Inexistência de prelação – À preferência do art. 797, *caput*, conferida apenas ao credor quirografário, mostram-se indiferentes os créditos privilegiados. É uma decorrência implícita da remissão ao concurso especial de credores, e, ademais, previsão explícita do art. 908, *caput*. Os credores munidos de título legal de preferência são, consoante o art. 958 do CC, (a) os créditos privilegiados – v.g., o do crédito fiscal (art. 186 do CTN) – e (b) o crédito garantido por direito real. O crédito garantido com direito real “prefere o pessoal de qualquer espécie” (art. 961 do CC). Em

consequência, no rateio final do concurso especial, os credores receberão seus créditos na “ordem das respectivas prelações”; inexistindo título legal de preferência, acrescenta o art. 908, § 2.º, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, “observando-se a anterioridade de cada penhora”.

Em relação aos títulos legais de preferência, cabem duas observações, respectivamente quanto à desnecessidade de execução do credor real e a necessidade de execução de outros credores privilegiados.

4.2.1. Posição do credor real – O titular do direito real envolver-se-á no concurso especial de credores, necessariamente, porque a penhora recai sobre o bem gravado, e, em caso de alienação, transmitir-se-á a coisa purgada do gravame real. Por conseguinte, o credor real prescinde de execução própria, e, *a fortiori*, da realização de penhora sobre o bem gravado, bastando a existência de registro para haver respeito ao seu privilégio.¹⁸ Controvertem-se as condições nas quais é lícito ao credor quirografário penhorar o bem gravado, porque a subsequente alienação, extinguindo o gravame, obriga o credor real a receber antecipadamente seu crédito. Da conjugação do art. 848, IV, pré-excluindo a penhora de bem gravado, em princípio, e do art. 1.477 do CC, segundo o qual, “salvo no caso de insolvência”, o credor de segunda hipoteca, posto que vencida, “não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira”, e do art. 1.425, II, do CC, prevendo o vencimento antecipado da dívida garantida por direito real, insolvente ou falido o devedor, infere-se que só cabe a penhora no caso de inexistirem outros bens livres e desembaraçados,¹⁹ ou seja, no caso de insolvência “de fato” (= não declarada como tal pelo órgão judiciário).²⁰ E há casos em que o bem gravado é impenhorável para outros credores (v.g., art. 69 do Dec.-lei 167/1967), salvo no caso de preferência superior (art. 1.422, parágrafo único, do CC).

A insolvência exigida para o credor quirografário penhorar o bem gravado não era aquela declarada (art. 761 do CPC/1973), mas a presumida pela inexistência de outros bens (art. 750, I, do CPC/1973). Esta solução se harmoniza com o sistema geral: não só vale o argumento de que a decretação do concurso universal se atrela à iniciativa soberana do credor, como o valor do bem gravado talvez supere a soma dos créditos, nada obstante o gravame.

Por isso, mantida a penhora, realizada pelo quirografário, em decorrência da inércia do titular do direito real de garantia, ou porque os embargos de terceiro foram desacolhidos, todos concorrem ao rateio, segundo a ordem do art. 908, *caput*, desde que se habilite o credor real, instado a tanto por força das intimações previstas nos arts. 799, I, e 899, V, sob pena de ineficácia da alienação do bem (art. 804, *caput*). Omisso que seja em receber o crédito, através da habilitação, o respectivo dividendo ficará à sua disposição, pois o bem se transmitirá livre do gravame.

4.2.2. Posição dos credores privilegiados – Do concurso especial de credores participam os credores que penhoram idêntico bem (art. 797, parágrafo único) e, porque previamente gravado esse bem, o titular do gravame real. Por conseguinte, quem não executou o devedor comum, considerando solvente até deliberação em contrário, e penhorou o mesmo bem dos demais, simplesmente não participa da distribuição do dinheiro. O STJ exige da autarquia previdenciária federal, por exemplo, prévia penhora.²¹ Posteriormente, essa necessidade decorre da parte final do verbete 497 da Súmula do STJ (“... desde que coexistiam sobre o mesmo bem”), fixando-se a tese da preferência dos créditos dessa autarquia perante a Fazenda Pública dos Estados-membros. Outro julgado, muito bem fundamentado, reafirmou a necessidade de prévia constrição para participar do concurso especial.²² Por igual, o credor trabalhista há de executar seu crédito e penhorar o bem objeto da alienação para satisfazer seu crédito,²³ apesar de outro credor promover a alienação do bem. Não é firme, porém, a jurisprudência do STJ nesse último sentido, prevalecendo entendimento contrário, ou seja, predomina a orientação de que o credor trabalhista não necessita penhorar o bem alienado.²⁴

5. Efeitos da sucessividade de penhoras – Ocorrendo a penhora do mesmo bem por vários credores, consoante autoriza o art. 797, parágrafo único, ou se encontrando ele gravado com direito real de garantia, estabelecer-se-á, objetivamente, um vínculo entre processos executivos autônomos. É digno de nota que o liame surge de modo superveniente à tramitação das execuções. Até a penhora do mesmo bem ou do bem gravado, não há vínculo juridicamente relevante entre os

credores, porque a circunstância de dois ou mais credores executarem o obrigado comum não assume particular relevância no plano processual. Mas, verificando-se multiplicidade de penhoras, ou a penhora do bem gravado com direito real de garantia, os processos passam a relacionar-se por modalidade de conexão.²⁵

É lacunosa a disciplina do concurso especial de credores entre a fase inicial, objeto do art. 797, e a fase final, consistente na distribuição do dinheiro (arts. 908 e 909). Nada se dispõe acerca da coordenação das execuções singulares entre um estágio e outro. Por óbvio, subsistem autônomos os processos, cabendo a cada exequente impulsionar a respectiva execução. Presumivelmente, omitiu a lei regra especial, prevendo a reunião dos processos e deixando a prática construir soluções, em virtude da dificuldade de reunir processos executivos que tramitassem na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho e na Justiça Ordinária. Com efeito, nada impede que o mesmo bem seja penhorado numa execução trabalhista e pela Fazenda Pública Federal, a competência de jurisdição, que é absoluta, pré-excluindo a reunião dos processos e, conseqüentemente, a convergência e economia de resultados para obter a finalidade comum. O certo é que, como já estabelecia o art. 1.018 do CPC/1939, a distribuição do dinheiro, independentemente da execução que realize a alienação do bem, é do juízo no qual ocorreu a penhora “preventora”. A esse respeito, impõe abrir item específico.

À diferença do concurso universal, o particular não extingue as obrigações do executado, ressalva feita aos créditos dos participantes, integralmente satisfeitos com o produto da alienação do(s) bem(ns) penhorado(s), ou o dinheiro depositado ou produzido pela penhora de bem frutífero, nem abrange a totalidade dos seus bens.

6. Casos especiais de preferência. Existem situações em que a existência da preferência do art. 797, *caput*, ou o momento em que ela aparece, provocam dúvidas.

6.1. Preferência na pré-penhora – A pré-penhora ou “arresto” (art. 830) concede preferência, a despeito de o STJ admitir a prevalência de penhora posterior.²⁶ Tem natureza executiva tal constrição, à diferença do arresto cautelar,²⁷ e, portanto, revela-se desprovido de preferência. Justifica-se o entendimento, ademais, ante o disposto no art. 851, III, autorizando a desistência da penhora preexistindo constrição judicial anterior. Esta possibilidade revelar-se-ia inútil se a pré-penhora não concedesse preferência, motivo pelo qual o credor, avaliando sua posição futura no concurso, desiste da penhora para realizar outra mais vantajosa. Nenhum reparo merece, portanto, a interpretação de outro julgado do STJ,²⁸ no sentido aqui exposto.

6.2. Preferência da penhora registrada – Realizado o registro da penhora (art. 843), feita em segundo lugar, o credor penhorante passa à frente do titular da primeira penhora. Antes da vigência de regra equivalente no direito anterior, o registro subsequente da penhora se mostrava irrelevante no terreno da preferência.²⁹ No entanto, o registro destina-se a operar no plano da eficácia e perante terceiros, a exemplo dos outros credores que penhoraram idêntico bem. Assim, o registro da penhora há de surtir os efeitos que lhes são próprios, tornando a ordem cronológica das penhoras secundárias, consoante já se sustentou no regime anterior.³⁰ A orientação prevalecente no STJ é no sentido de averbação não alterar a ordem do exequente no concurso.³¹

6.3. Preferência na substituição da penhora – Os arts. 847 e 848 autorizam as partes a requerer, sob determinadas condições, a substituição do bem originariamente penhorado. Em consequência do deferimento da substituição, liberar-se-á o objeto da constrição inicial, passando a penhora a incidir sobre o novo objeto da constrição. Cada exequente preservará sua preferência, na posição anterior, admitida a troca que a ninguém prejudica.

6.4. Preferência na penhora de crédito – A preferência na penhora de crédito se origina na data em que o terceiro devedor (*debitor debitoris*) recebe a intimação do art. 855, I, nada importando, para esse efeito, a data em que o executado é, de seu turno, intimado da constrição (art. 841, *caput*). E isso, porque a constrição do bem se materializa naquela primeira providência, ou da apreensão da cártula (art. 856, *caput*), a partir do que já existe penhora sobre o crédito.

6.5. Preferência na penhora de direito a coisa determinada – A penhora de direito a coisa

determinada (art. 859) é subespécie da penhora de crédito, e, conseqüentemente, a preferência decorre da intimação do terceiro devedor (art. 855, I).

7. Pluralidade de penhoras sobre idêntico bem – O art. 797, parágrafo único, autoriza dois ou mais exequentes a penhorar o mesmo bem, conservando cada qual, neste caso, seu “título de preferência”, ou seja, a preferência concedida pela anterioridade da penhora (art. 797, *caput*) e a prelação determinada pelo direito material.

Em princípio, a circunstância de várias penhoras atingirem bem único não torna qualquer delas inválida,³² exceto se existir infração a regra diversa (v.g., o art. 67 do Dec.-lei 167/1967). O art. 797, parágrafo único derroga o princípio *pignoratium super pignorationem non admittitur*, transformado em simples possibilidade, aliás determinada pelas conveniências do exequente (art. 851, II).

E a multiplicidade de penhoras não provocará, fatalmente, o concurso universal, presidido pela igualdade de tratamento dos credores. Ela importará o concurso especial, em que os quirografários perceberão integralmente seus créditos na ordem cronológica das penhoras e até o esgotamento das forças do bem penhorado, sem prejuízo da participação de credores titulares de prelação de direito material, perante os quais, como tantas vezes enfatizado, mostra-se irrelevante a data da penhora.

Os credores penhorantes têm direito, no concurso de especial de credores, ao valor remanescente ou ao quociente,³³ após a satisfação dos credores com prelação de direito material ou do titular da penhora anterior, na devida ordem, ou seja, deverão se conformar com as sobras da solução do crédito do penhorante que ostentar a preferência.

Mesmo o executado insolvente, sem prejuízo desta condição e da abertura, até a distribuição do dinheiro, do concurso universal, pode ser tratado como solvente até o fim, porque esta última modalidade de execução coletiva não se decreta de ofício.³⁴

Como quer que seja, a simples possibilidade de se sucederem diversas penhoras sobre idêntico bem suscita uma série de questões de elevado interesse.

Objetivando a execução, na hipótese de obrigação pecuniária, expropriar bens do executado para satisfazer o exequente (art. 824), em geral através da transferência do domínio, os atos de expropriação, sujeitos à iniciativa concorrente de os exequentes penhorantes, realizar-se-á uma só vez.³⁵ Feita vitoriosamente a adjudicação ou a alienação, há transferência do bem ao adquirente, descabendo a renovação do ato por algum dos credores remanescentes.

E não é de bom alvitre renovar inútil, dispendiosa e cansativamente os atos que medram entre a penhora e a alienação forçada, porque isso representaria perda de tempo, de dinheiro e de trabalho para os exequentes, e gravame ao executado comum, a quem, a teor do art. 805, *caput*, o juiz protegerá desta consequência nociva.

Eis o motivo por que convém reunir as execuções, por força de fenômeno chamado de acessão. Ele é assim explicado:

Credores que executam coisa, sobre a qual já existe instância expropriativa por conta de outro credor, acedem ao procedimento pendente; o primeiro credor se diz estante ou precedente, os demais, acedentes.³⁶

A reunião visa alcançar o objetivo comum dos credores, que é a distribuição do dinheiro, sem retardamentos e controvérsias.

Quanto à indispensabilidade da reunião dos processos, na hipótese de ocorrer mais de uma penhora em bem único, nenhuma influência exerce o regime da distribuição do dinheiro. Ela também se mostraria necessária no império do *par conditio creditorum*. A causa do vínculo superveniente entre as execuções reside na multiplicidade de penhoras.

As dificuldades apenas aumentam de grau com a óbvia constatação. O legislador pátrio previu o rateio, no art. 908, mas olvidou o percurso para atingir esse estágio.³⁷

Realmente, várias dúvidas dignas de registro surgem neste ponto: a obrigatoriedade da reunião, sua oportunidade, a forma pela qual os exequentes tomarão ciência da(s) penhora(s) preexistentes, as consequências da inércia do exequente em participar do rateio, dentre outras questões. Qual a consequência da inércia? Existirá sanção para o depositário que permite a alienação da coisa sem aviso ao juiz da “sua” execução? Supondo a diligência das partes (e melhor se aludiria aos seus advogados), pouco se reduzem as perplexidades. Qual o juízo competente para a reunião? Quais os ônus dos participantes? A inércia do credor preferente confere o impulso a algum outro? Qual o destino de execuções instrumentalmente ligadas ante os percalços e os azares gerados pelos embargos do executado, talvez dotados de conteúdos discrepantes e encerrados mediante resultados contraditórios? E se há execução por carta ou algum dos credores acedentes goza de competência absoluta?

Essas questões não têm tratamento explícito e reclamam, a olhos vistos, segura solução.

8. Reunião das execuções – A menção a concurso de credores evoca prontamente a imagem, utilizada por antigos autores, do risco de adentrar num labirinto.³⁸ Embora a tônica do concurso de preferências respeite ao rateio, e as culminâncias do assunto aí se incluam, até lá se impõe trilhar certo procedimento racional. Como se disse linhas antes, a reunião dos processos, “recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem” (art. 797, parágrafo único), atende ao interesse dos exequentes e do executado, evitando atos dispersivos, contraditórios e custos elevados; abreviam-se transtornos, impedindo a duplicidade dos atos de alienação; e, por fim, facilita-se o trabalho dos credores concorrentes, doravante simples expectadores da operação do mecanismo expropriatório. Eis os caminhos da acessão.

8.1. Pressupostos da reunião das execuções – Dois requisitos apresentam a reunião das execuções: (a) a solvência, *ipso jure*, do executado, sem a qual se instalará outra forma de execução coletiva (insolvência ou falência, conforme a qualidade do devedor); (b) a sobreposição de penhoras sobre o mesmo bem ou bens, objeto dos atos de alienação coativa que se deseja coordenar.

É indispensável que para todas as execuções seja competente, relativamente, o mesmo juízo. O art. 516, parágrafo único, facilita a reunião de várias execuções baseadas em títulos judiciais. Tramitando as execuções em juízos de diversa competência de jurisdição, a exemplo do trabalhista e do federal, todavia, tornar-se-á impossível reunir os processos.

Admissível que seja a partir da segunda penhora, os credores somente decaem da faculdade de postular a reunião dos processos após o encerramento do rateio contemplado no art. 909.

8.2. Obrigatoriedade da reunião das execuções – A despeito de eventual reunião das execuções singulares, haja vista a multiplicidade de penhoras no mesmo bem, todas conservam sua individualidade e independência. Assim, a expropriação promovida por um dos credores se revela eficaz, até porque a ineficácia beneficia o Estado.³⁹ Aos interessados incumbe o ônus de controlar o andamento das execuções e, *opportuno tempore*, intervir na formar do art. 909.

Seja como for, o art. 889, V, exige a intimação do credor “com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso o credor não seja, de qualquer modo, parte na execução”. Antes de se instituir essa intimação, no direito anterior, alienado o bem penhorado e satisfeito algum credor em desacordo com a gradação legal, o preterido não exibia pretensão a anular a hasta pública, restando a possibilidade de reclamar seu crédito de quem recebera indevidamente. Neste sentido, proclamou o STJ:

A eventual desatenção a direito de preferência, resultante de ter-se penhorado em primeiro lugar, de nenhum modo afeta a regularidade da arrematação. Diz apenas com a distribuição do produto da alienação judicial.⁴⁰

Esta orientação há de se entender modificada, em parte, em virtude do dever de intimar os titulares de penhora averbada (art. 889, V). Nessa contingência, preterida a intimação mostrar-se-á nula a distribuição realizada, e a renovação do ato ensejará a participação no rateio. Para os credores que, indiferentes à eficácia da averbação e ao ônus do art. 799, IX, omitiram a averbação do art. 849, a situação permanece idêntica: a distribuição do dinheiro se revela imune a controvérsias provocadas pelo preterido, cujo prejuízo econômico decorre da própria negligência.

No entanto, a redação do art. 889, V, está longe da perfeição. Em primeiro lugar, limita a averbação, aparentemente, ao titular de penhora “anteriormente averbada”, pressupondo, talvez, a iniciativa do titular de outra penhora, averbada posteriormente ou não averbada. Ora, intimar quaisquer exequentes que hajam averbado a penhora, assegurando-lhes a participação no concurso, é imperioso, embora a penhora preexistente haja de ser satisfeita em primeiro lugar (art. 908, § 1.º, 2.ª parte). E não é clara a expressão “caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução”. O art. 799, I, não contempla a prévia intimação do titular de penhora averbada, mas a dos credores fiduciário, hipotecário, pignoratício ou anticrético. Resta entender a cláusula alusiva à intervenção espontânea de quem penhorou o mesmo bem para participar do rateio, tornando-se, então, parte na execução alheia.

A reunião das execuções descansa antes na conveniência do que na obrigatoriedade.⁴¹ O concurso pode se realizar, na execução em que se promove a distribuição do dinheiro, sem que as outras lhe sejam reunidas, mediante a intervenção voluntária dos participantes. É até impossível essa reunião, concorrendo credores sujeitos à competência de jurisdição (v.g., o credor trabalhista). E cumpre realçar: existindo averbação da penhora, ou preterido o titular do direito real de garantia, há ineficácia da alienação e da distribuição do dinheiro, respondendo ainda o bem pela realização dos respectivos créditos.⁴²

8.3. Conhecimento da penhora anterior – O conhecimento da existência de penhora anterior dependerá da intimação prevista no art. 889, V. Incumbe aos exequentes intimados, com cinco dias de antecedência, reclamarem seus créditos, bem como aos credores hipotecário, pignoratício ou anticrético que de já não houvessem sido intimados (art. 799, I), anteriormente, ou intervindo, voluntariamente, na execução pendente. A última possibilidade decorre da cláusula final do art. 889, V (“... caso seja de qualquer modo parte na execução”). Superaram-se, por essa via, inúmeras dificuldades, principalmente a anomalia decorrente da falta de apreensão efetiva da coisa penhorada, a despeito do art. 839, *caput*.⁴³

No que tange aos credores penhorantes que não averbarem a constrição, a sua participação do concurso dependerá do respectivo zelo, investigando a existência de outras execuções. Realizada a alienação forçada, e distribuído o dinheiro, não podem mais reclamar, incumbindo-lhes realizar nova penhora, se possível (art. 851, II).

8.4. Competência na reunião das execuções – A multiplicidade de penhoras enseja a reunião dos processos executivos através de conexão,⁴⁴ aqui tomada numa das suas múltiplas e atípicas modalidades,⁴⁵ em decorrência de as respectivas constrições recaírem em objeto comum.

Competente é o juízo que primeiro ultimou a penhora, por auto (art. 829, § 1.º, *in fine*) ou por termo (art. 849), ou a pré-penhora (art. 830).⁴⁶

O art. 1.018 do CPC/1939 consagrava, explicitamente, tal competência. Então, designava-se a primeira constrição, segundo o dado cronológico do auto ou do termo, de “penhora preventora”,⁴⁷ baseando a regra na ideia de prevenção.⁴⁸ Consoante a orientação da época, “pouco importa, assim, que em outro juízo haja sido feita a arrematação de alguns bens”.⁴⁹ No entanto, a ordem cronológica não decorre do registro ou da distribuição da petição inicial (art. 59), tornando o juízo preventivo competente para a reunião das ações (art. 58), mas de outro dado, fixando-se a competência para processar e julgar o concurso, distribuindo o dinheiro, no juízo que penhorou em primeiro lugar.

A prevenção modifica a competência em razão do valor e do território, a teor do art. 54 c/c art. 63, motivo por que a reunião dos processos, no juízo preventivo para o concurso especial – o da

primeira penhora –, em todo o caso dependerá da mesma competência de jurisdição de todos os juízos. Por exemplo, tratando-se de duas execuções que correm na Justiça Comum, mas em varas ou comarcas diferentes, mostra-se possível, e sumamente vantajoso, reunirem-se os processos executivos no juízo preventivo.

Segundo outra opinião,⁵⁰ o concurso especial ocorrerá no juízo que realizou a alienação forçada. É preciso recordar, naturalmente, que o bem penhorado jamais poderá ser alienado mais de uma vez, revelando ineficaz a segunda alienação. Por sinal, o direito do adquirente não pode ser dissolvido. E não há dúvida de que competirá ao juízo da alienação, em razão da custódia do produto da alienação forçada, expedir os respectivos mandados de levantamento (art. 906). Também não parece razoável impedir outro juízo, que não o da primeira penhora, de realizar a alienação do bem penhorado, haja vista a independência das execuções singulares, cuja tramitação autônoma assegura a qualquer uma chegar a esse estágio.⁵¹ Entretanto, a expedição do mandado de levantamento constitui simples ato material e, de resto, o exequente passará quitação ao devedor nos autos da respectiva execução. Logo, são atos diferentes, cabendo ao juízo que decidir o concurso comunicar ao que realizou a alienação forçada para que providencie o pagamento, consoante a devida classificação dos créditos. Eventualmente, a quota devida ao credor que realizou a primeira penhora, e que não pode recebê-la, porque tolhido por embargos, ficará retida até ulterior deliberação.

Resta resolver o problema provocado por diferentes competências de jurisdição. Por exemplo, *A* executa *B* na Justiça do Trabalho, mas *B* também é executado por *C* e por *D* na Justiça Comum, em juízos diferentes, pouco importando em qual execução realizou-se a primeira penhora. Inexiste motivo prático ou razão legal para reconhecer competência ao juízo da execução trabalhista, apenas porque tal crédito ostenta prelação sobre os demais, a despeito do julgado contrário do STJ.⁵² À Justiça do Trabalho não compete graduar créditos comuns de *C* e *D*,⁵³ nem sequer lhe ofende as atribuições definir a natureza trabalhista, ou não, do crédito sujeito a rateio no juízo civil. E as modificações supervenientes do estado de fato – outra penhora, desaparecimento da constrição originária –, nos termos do art. 43, afiguram-se irrelevantes.⁵⁴

Essas considerações acabaram aceitas por julgado do STJ:

Em princípio, havendo, em juízos diferentes, mais de uma penhora contra o mesmo devedor, o concurso efetuar-se-á naquele em que se houver feito a primeira. Essa regra, porém, comporta exceções, sua aplicabilidade se restringe às hipóteses de competência relativa, que se modificam pela conexão. Tramitando as diversas execuções em Justiças diversas, haverá manifesta incompatibilidade funcional entre os respectivos juízos, inerente à competência absoluta, inviabilizando a reunião dos processos.⁵⁵

Tampouco se altera o juízo competente se no concurso há de intervir a União, suas autarquias ou empresas públicas, consoante estabeleceu o Pleno do STF.⁵⁶ Discutível que seja a aplicação da regra então invocada, equivalente ao art. 45, I, pois no concurso de preferências, por definição, inexistente a “insolvência” nela mencionada, a solução mostra-se deveras razoável. Igualmente, o STJ reafirmou o princípio de que “a intervenção da União, suas autarquias e empresas públicas em concurso de credores ou de preferência não desloca a competência para a Justiça Federal”.⁵⁷

Apresentando-se a empresa pública federal, no concurso, como simples titular do direito real de garantia – hipótese das mais comuns, de resto: a Caixa Econômica Federal, amiúde, financia a casa própria e se resguarda com hipoteca –, a inexistência de demanda executória inviabiliza a remessa da(s) outra(s) execução(ões) à Justiça Federal, segundo o STJ.⁵⁸ Foi o que esclareceu, definitivamente, a Súmula do STJ, 270: “O protesto pela preferência de crédito, apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual, não desloca a competência para a Justiça Federal”. Ao nosso ver, a orientação há de ser mantida perante o art. 45 do CPC/2015.

Por outro lado, o critério para fixar a competência da Justiça Federal, ao contrário do que acontece com a Justiça do Trabalho, reside na qualidade da parte (art. 109, I, da CF/1988). Portanto, nenhum elemento impede sua competência para classificar os créditos e distribuir o dinheiro, realizando a Fazenda Pública Federal a primeira penhora, ainda que outras execuções tramitem

na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum. Se a Fazenda Pública Federal move várias execuções contra o mesmo devedor, não há concurso, recomendando o art. 28 da Lei 6.830/1980 a reunião de todos os processos no mesmo juízo, de resto simples faculdade (Súmula do STJ, 515).

Penhorado idêntico bem em execuções movidas por diferentes pessoas de direito público, enseja-se o chamado *concurso fiscalis* (art. 187, parágrafo único, do CTN; art. 29, parágrafo único, da Lei 6.830/1980), processando-se no juízo que realizou a alienação forçada.⁵⁹ Essa solução baseia-se no fato de que inexistente preferência decorrente da anterioridade da penhora.

Na alienação por carta (art. 845, § 2.º), o pagamento ocorrerá no juízo deprecante, que, havendo intercorrência de penhoras e não sendo o do credor preferente, repassará o produto ao juízo deste. Tutela-se o interesse do credor que penhorou primeiro e, conseqüentemente, primeiro há de receber. Não cabe ao juízo deprecado, em qualquer circunstância, distribuir o produto da alienação forçada. Basta imaginar a hipótese de serem vários os juízos deprecados, porque penhorados bens em localidades diferentes. Embora cada um deles realize a alienação forçada, recomenda-se a realização do rateio no juízo deprecante da primeira penhora, embora proveniente o dinheiro das diversas arrematações.⁶⁰

A qualquer exequente penhorante revela-se admissível pleitear a reunião. O próprio órgão judiciário, ao reconhecer a existência de primeira penhora noutra execução, e sendo isto admissível, remeterá, de ofício, a execução ao juízo competente.⁶¹ O ato enseja agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único).

8.5. Poderes das partes na reunião dos processos – No processo executivo brasileiro, participam do concurso os credores munidos de título e que, ademais, deduziram em juízo a correspondente pretensão a executar. Reunidas as execuções, todos continuam ostentando a condição de exequentes,⁶² partilhando, assim, os mesmos direitos e ônus,⁶³ principalmente o de promoverem os atos executivos cabíveis.

Legitima-se, por esse motivo, qualquer dos exequentes penhorantes a pleitear a reunião dos processos ou, não sendo possível, ante as diferentes competências de jurisdição, o rateio no juízo da primeira penhora. O próprio órgão judiciário, ao constatar a existência de penhora anterior, *ex officio*, remeterá a execução ao juízo competente.⁶⁴ Naturalmente, impõe-se respeitar a competência de jurisdição, porque a prevenção somente modifica a competência em razão do valor e do território.

Em geral, ao exequente dotado da preferência incumbe provocar os atos de expropriação. Manifestando interesse compatível com a anterior prestação, levando-o a penhorar primeiro, presume-se a persistência dos seus esforços, atingindo o momento propício à conversão forçada do bem penhorado e à distribuição do dinheiro.

Mas, se o cenário ideal não ocorrer, a qualquer dos concorrentes assiste, subsidiariamente, igual poder de iniciativa. Tanto se concebe real impedimento do titular da primeira penhora, travado por embargos (ou impugnação, cuidando-se de execução de título judicial) opostos pelo executado – atribuído efeito suspensivo, na forma do art. 919, § 1.º –, quanto inexplicável desinteresse superveniente, porque garantiu primazia: a causa da falta de impulso pouco importa na espécie.

Essa possibilidade de executar, atribuída aos titulares de penhoras de grau inferior, não altera a ordem do concurso. Tampouco o pedido de adjudicação numa das execuções modifica a ordem dos exequentes.⁶⁵

Desapareceu a dúvida anterior, pois a regra equivalente ao art. 908 declarava receber em primeiro lugar o credor “que promoveu a execução”, subentendendo a iniciativa na alienação coativo. O STJ interpretara a fórmula no sentido de que “o credor exequente tem preferência para receber o produto da arrematação, seguindo-se os demais, na ordem das respectivas penhoras”.⁶⁶

No entanto, parece sumamente injusto eliminar a preferência da primeira penhora só porque a

execução, em que ela se originou, permaneceu paralisada pelo advento de embargos suspensivos. Ademais, abrir-se-á larga janela à fraude, ficando fácil ao executado e a terceiro simularem processo executivo, desprovido de qualquer resistência daquele, cujo andamento, portanto, não sofrerá entraves, e, alienando antes do verdadeiro credor o bem, juntos embolsarem o produto da venda dos bens penhorados.

Neste sentido, de resto, já decidiu, com inteiro acerto, outro julgado do STJ.⁶⁷ Consequentemente, enquanto os embargos opostos à execução do titular da primeira penhora não forem julgados, seu crédito ficará retido para ulterior rateio, conforme o resultado deste julgamento.

Só na rara hipótese de existir “coincidência de dia e hora das penhoras” sustentava a preferência de quem realizou os atos de expropriação.⁶⁸ Porém, nessa hipótese, a solução é outra, procedendo-se a rateio em igualdade de condições entre os dois exequentes.

8.6. Despesas em proveito comum – Tomando a si o impulso dos atos expropriatórios, e não se alterando a ordem no concurso, o titular de segunda penhora fará jus ao reembolso das despesas, porventura por ele antecipadas (art. 82), antes da solução do crédito do primeiro credor penhorante. Do contrário, conforme o montante do produto da alienação e a posição do respectivo crédito, tal exequente, eventualmente, não receberia o reembolso das despesas realizadas em proveito comum, o que representaria grave injustiça. É o que ensinava, fitando o antigo concurso de credores, quem dele se ocupou com proficiência:

No concurso de credores de natureza civil

, os cargos resultantes da administração, conservação, guarda e realização do ativo não são objeto nem de habilitação nem de discussão. São despesas que se fizeram em benefício de todos e todos devem carregá-las.⁶⁹

Integram semelhante classe de despesas, exemplificativamente, a importância gasta na publicação dos editais do leilão presencial, na remoção do bem, com o pagamento das custas. Impende recordar que incumbe ao adquirente o pagamento da comissão do leiloeiro (art. 884, parágrafo único) e a comissão de corretagem mencionada no art. 880, § 1.º, *in fine*, razão por que, relativamente a essas verbas, inexistente necessidade de reembolsar o exequente.

8.7. Destino das execuções singulares – As execuções, reunidas pelo liame prático da acessão, preservam a respectiva autonomia e, até o rateio, toda sorte de percalços poderá atingi-las, do êxito do executado nos embargos à desistência do exequente.

Livre é o executado para embargar apenas uma ou algumas das execuções. Embasadas em títulos diferentes, discreparão os resultados dos embargos. De outro lado, o exequente dispõe do seu crédito como melhor lhe aprouver, desistindo da penhora realizada ou de toda a execução (art. 775, *caput*). Se a desistência ocorrer depois da alienação forçada, reorganiza-se a ordem de entrega do dinheiro; se ocorrer antes, o antigo exequente não participará da distribuição do dinheiro.

Se os embargos opostos à execução do titular da primeira penhora não receberem solução imediata e favorável, e, entretanto, outro concorrente levar o bem a leilão físico ou presencial, o valor correspondente ao respectivo crédito ficará retido até a solução do caso.

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I – instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

II – indicar:

a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada;

b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível;

Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I – o índice de correção monetária adotado;

II – a taxa de juros aplicada;

III – os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV – a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V – a especificação do desconto obrigatório realizado.

1. Demanda da parte na execução – A iniciativa da parte é indispensável para formar a relação processual executiva, cujo objeto consistirá na pretensão a executar derivada do título executivo extrajudicial. O ato postulatório principal do exequente chama-se demanda ou petição inicial. Traduz princípio assaz fundamental do processo civil constitucionalmente justo e equilibrado. A ele corresponde, na face reversa, o princípio da inércia da jurisdição, garantia de que o órgão do Estado só intervirá no litígio quando e se provocado pelo interessado.

O princípio da demanda constitui desdobramento do clássico princípio dispositivo. O processo informado por essa diretriz, e considerando a função de conhecimento, apresenta as seguintes características: (a) começa por iniciativa da parte, segundo o princípio da oportunidade (o autor escolhe o melhor momento para deduzir sua pretensão, obrigando-se a respeitar tão só prazos de decadência ou de prescrição fixados na lei substancial); (b) as partes predeterminam o objeto litigioso, realizando alegações de fato – a atividade principal é do autor, mas o réu, eventualmente, dilata o objeto litígio, invocando exceções ou objeções substanciais (defesa de mérito indireta), ou mérito, e, desse modo, estipulam limites para o futuro provimento do órgão judicial; (c) a atividade processual subordina-se ao impulso das partes, em particular tocando-lhes exclusividade, na função de conhecimento, de propor as provas adequadas à emissão do juízo de fato pelo órgão judicial e, conseqüentemente, à resolução do mérito (*iudex iudicare debet allegata et probata partium*). À disposição plena das partes no tocante à matéria e ao impulso do processo corresponde quase integral inércia do órgão judiciário.⁷⁰ Para esta concepção, o processo é, sobretudo, um mecanismo em que impera o domínio das partes. A ele corresponde, por assim dizer, um juiz espectador, reservado ao órgão judiciário apenas o poder de decisão e a liberdade de qualificar os fatos alegados (*iura novit curia*). É o modelo liberal de processo civil.

Esse modelo processual reflete, sobretudo, o espírito individualista do séc. XIX. Não se coaduna com as realidades social, econômica e política dos tempos modernos e entrou em crise no início do séc. XX. A alta significação social do processo, interessando ao Estado restaurar a paz e aplicar o direito objetivo, preservou o princípio da demanda, mas impôs expressivo aumento dos poderes do juiz em áreas tão diversas quanto à proposição dos meios de prova e a igualdade material dos litigantes. O órgão judicial dispõe, segundo o modelo autoritário, de poderes de direção formais (art. 2.º, *in fine*, do CPC/2015) e poderes de direção material (v.g., a iniciativa em matéria de prova e o poder de reconciliar os litigantes), tornando-se, basicamente, um juiz diretor do processo.

A divisão de trabalho entre partes e órgão judicial, enfraquecendo o domínio das partes e destacando a iniciativa oficial, iluminou aspecto do princípio dispositivo que, no modelo liberal do processo, ficava obscurecido por outros dados: a iniciativa da parte na provocação do processo. Ficava indistinta a iniciativa do autor na abertura da relação e o impulso no seu desenvolvimento ulterior, como se fossem incindíveis. Entretanto, restringidos os poderes dispositivos dos litigantes no desenvolvimento do processo, tornou-se mais visível a transcendência da iniciativa da parte na formação do processo.⁷¹ O direito processual brasileiro vigente permite a nítida identificação do princípio da demanda. Expressa-se esse princípio, na sua ofuscante nitidez, no art. 2.º do CPC/2015, que reza: “O processo civil começa por iniciativa da parte se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”.

Duas observações iniciais se impõem nesse ponto. Em primeiro lugar, o processo civil social, marcado pelos poderes do órgão judicial, preservou a característica fundamental da inércia da função jurisdicional. Em determinadas hipóteses, em virtude do caráter transindividual do objeto litigioso, ou a relevância social do litígio, a lei outorga capacidade de conduzir o processo a determinados órgãos estatais (v.g., o Ministério Público), mas, ao fim e ao cabo, preservou a inércia do órgão judicante mediante o artifício da divisão de competências (material) entre órgãos estatais. E, por outro lado, as exceções legais mencionadas na parte final do art. 2.º do CPC/2015, referem-se ao impulso, e não, à iniciativa na formação do processo. Em determinadas situações, a lei exige a iniciativa exclusiva da parte. Para ministrar exemplo afeiçoado aos domínios executivos, a indisponibilidade eletrônica de ativos financeiros do executado subordina-se a “requerimento do exequente” (art. 854, *caput*).

O processo autoritário não se livrou completamente de reminiscências do modelo liberal. Desinteressando-se as partes pelo andamento do processo, por mais de um ano (art. 485, II), ao órgão judiciário cumpre intimá-las para suprir a falta no prazo de cinco dias (art. 485, § 1.º), antes de extingui-lo. Ora, a imobilização do processo é, antes de mais nada, responsabilidade do órgão judicial, que dispõe dos poderes de impulso (direção formal do processo), dentre outros, enumerados no art. 139. Somente em casos muito particulares (v.g., a inércia do interessado em antecipar os honorários do perito particular) o poder oficial não logra sobrepujar a falta de iniciativa da parte.

Também a função jurisdicional executiva subordina-se à iniciativa da parte. Segundo proclamou o STJ, “a execução não pode iniciar sem provocação da parte”.⁷² Essa diretriz subsiste no CPC/2015. Em particular, no tocante aos pronunciamentos judiciais dependentes de execução para entregar o bem da vida ao vencedor, o art. 513, § 1.º, reza o seguinte: “O cumprimento de sentença que reconhecer o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente”. Não há, pois, cumprimento da sentença *ex officio*, tratando-se de créditos pecuniários. Assim decidiu a Corte Especial do STJ: “O cumprimento da sentença não se efetiva de forma automática, ou seja, logo após o trânsito em julgado da decisão”.⁷³ Como se observa no art. 515, I, entretanto, os provimentos judiciais exequíveis não se limitam às obrigações pecuniárias, incluindo as obrigações de entregar coisa certa e incerta e as obrigações de fazer e de não fazer, às quais equiparam-se, para efeitos práticos, as ordens do juiz (força mandamental), a teor do art. 536, § 5.º. É mais aparente do que real essa exceção, antes insinuada do que declarada no art. 513, § 1.º. Também nesses casos, havendo o dever de prestar do futuro executado, o princípio da oportunidade autoriza o vencedor a promover, ou não, a execução forçada. Essa função jurisdicional subordina-se a limitações políticas e práticas que, a mais das vezes, apresentam-se na execução de obrigações de dar ou de fazer. Assim, abstendo-se o vencido de entregar a coisa móvel no prazo estabelecido na sentença (art. 538, *caput*, c/c 498), e expedido o mandado de busca e apreensão, pode acontecer uma das situações antevistas do art. 809, *caput*, ensejando a conversão do procedimento executivo, passando o vencedor a executar o equivalente pecuniário. Tal evento talvez anteceda a expedição do mandado do art. 538, *caput*, hipótese em que é dado ao exequente requerer, desde logo, a execução por quantia certa.

Em princípio, subsiste a inércia do órgão judicial (art. 2.º do CPC/2015). Nenhuma particularidade da demanda, a exemplo da indisponibilidade do objeto litigioso ou vulnerabilidade do credor – elemento frisanse na execução de benefício da gratuidade –, mostra-se

suficientemente relevante para o órgão judiciário descer de sua posição de equidistância, abdicando da respectiva inércia, princípio fundamental do processo garantista. Até a antiga praxe de iniciar a liquidação, *ex officio*, contraria o princípio da demanda. Inova-se somente na surpreendente paridade da iniciativa oficial e da iniciativa das partes após a formação do processo. Nada obstante, exige-se inércia do órgão judiciário e a iniciativa exclusiva da parte para obter a vantagem, o proveito, a utilidade, o benefício ou bem da vida previsto no título executivo judicial ou extrajudicial.

Enquanto o princípio reponta inconcusso, no processo de conhecimento, já na execução surgem peculiaridades. Não há dúvida que a execução depende da provocação do exequente. Estabelece o art. 798, *caput*, que cabe ao exequente propor a execução. E, no âmbito do cumprimento, já se destacaram os dispositivos pertinentes: o art. 513, § 1.º reclama “requerimento” do vencedor para realizar o crédito.⁷⁴ Mas, ao mesmo tempo, dispõe o art. 797 que “realiza-se a execução no interesse do exequente”. Evidencia-se, no confronto dessas regras, o problema fundamental: a conciliação do interesse do exequente, a presidir a atividade executiva, e a iniciativa do juiz, concebida para a estrutura de cognição, em que as partes gozam de igualdade formal.

Exame sistemático da função executiva aponta a prevalência ideológica do interesse individual do credor. Basta rememorar a ilimitada faculdade de desistir da execução (art. 775, *caput*) ou a definição de ato atentatório à dignidade da Justiça como conduta do executado (art. 774). É claro que o exequente também poderá descumprir os deveres do art. 77 ou praticar ato subsumido ao art. 80. Em tal hipótese, reza o art. 777, a execução da sanção pecuniária porventura aplicada processar-se-á nos próprios autos, admitindo-se a compensação.

Se, portanto, no processo de conhecimento compete ao juiz formular regra jurídica concreta, vinculando os litigantes, e no qual as partes depositam suas expectativas de êxito, no processo executivo o órgão judiciário não possui análogo desembaraço, pois se atrela ao comando do título e à atuação prática do direito do exequente.

Fora da hipótese do controle do gravame excessivo ao executado, quando a execução pode realizar-se por mais de um meio executivo, (art. 805), o impulso oficial na demanda executória socorre ao interesse do exequente. Eis a norma heurística do processo executivo.

2. Iniciativa oficial na execução – Ao exequente compete deduzir a pretensão a executar, realizando-se as atividades processuais em seu proveito ou interesse (art. 797, *caput*), mas a iniciativa oficial autoriza ao órgão judicial determinar a marcha do procedimento.

Em geral, os poderes do órgão judiciário na prática dos atos executivos tendem a beneficiar o exequente. A lei prevê, abundantemente, determinações judiciais tendentes à satisfação do crédito e em proveito do exequente. Por exemplo, cabe ao juiz dar início aos atos de expropriação (art. 875), após a adequação da penhora, desembaraçado o procedimento da expropriação de eventual oposição do executado. E toca ao juiz designar o leiloeiro, embora o exequente também possa indicá-lo (art. 883). Essas iniciativas oficiais também ocorrem no cumprimento da sentença.

Em outros ritos, além da expropriação ordinária, verificam-se situações análogas. Alienada coisa litigiosa, o subadquirente fica sujeito à força da sentença (art. 808); porém, subordina-se iniciativa do exequente reclamar, ou não, a coisa integrada ao patrimônio dessa pessoa (art. 809, *caput*). Não poderá o juiz suprir semelhante iniciativa, quiçá emitindo juízo sobre a comodidade da opção, porque a alteração do bem da vida visado integra o domínio do exequente.

Cuidando-se de transformação, ao credor tocará deliberar sobre a conversão da obrigação originária no equivalente pecuniário (art. 816, *caput*) ou sua realização por meio de terceiro (art. 817, *caput*). Também aqui é vedado ao juiz substituir-se ao exequente, restando-lhe a possibilidade de controlar se a prestação pode ou não ser cumprida por terceiro às custas do executado.

Em todas as hipóteses, haja vista a preponderância do interesse do credor, descabe impulso oficioso contrário à iniciativa do exequente, sob pena de infringir ao princípio heurístico da execução, expresso no art. 797, *caput*. O pronunciamento judicial mostrar-se-á nulo.

Em determinadas hipóteses, a lei exige, expressamente, o contraditório das partes na execução. O diálogo dos litigantes com o órgão judicial é indispensável na formulação da regra jurídica concreta, objeto principal da função de conhecimento, e no CPC/2015 emprestou-lhe suma relevância, como revela o art. 9.º, *caput*, e parágrafo único, I e II, e, especialmente, a obrigatoriedade de o órgão judicial ouvir as partes previamente sobre as matérias que lhe é dado conhecer *ex officio* (art. 10). Em outras palavras, o princípio do contraditório não apresenta, na execução, a amplitude e a essencialidade inerentes à cognição,⁷⁵ porque aquela atividade não “é instaurada para saber quem tem razão, mas para concretizar um título”.⁷⁶ Mas, há exceções. Recaindo a penhora sobre bem perecível, por exemplo, há necessidade da alienação antecipada, impondo o art. 853 ao juiz colher “sempre” a manifestação da outra parte antes de decidir. Essa disposição aplica-se, outrossim, no caso de substituição da penhora por iniciativa do executado (art. 847) ou das partes (art. 848), bem como no caso do art. 850 (alteração significativa do preço de mercado do bem penhorado). Também ocorrerá nulidade nos casos em que o órgão judiciário despreze o contraditório.

3. Petição inicial no processo de execução – O processo de execução começa pelo ato postulatório principal do exequente chamado, no art. 798, I, de petição inicial. É a terminologia tradicional do direito processual civil brasileiro. Do emprego dos verbos “instruir” (art. 798, I), “indicar” (art. 798, II) e “requerer” (art. 799, I a XI) infere-se que as disposições se ocupam, basicamente da instrução da petição inicial e de alguns requerimentos eventuais do exequente, ressalva feita à identificação e qualificação das partes (art. 798, II, *b*), à escolha do meio executório (art. 798, II, *a*), havendo mais de um hábil a entregar o bem da vida em natura (execução específica), à dedução da pretensão à segurança ou à antecipação (art. 799, VIII), hipótese em que a lei emprega o verbo “pleitear”, e à instituição do ônus de proceder à averbação da propositura e de atos de constrição patrimonial em registro público (art. 799, IX). Este último não é assunto integrante da petição inicial, motivo por que nenhuma menção é necessária a seu respeito.

A estrutura da petição inicial na execução basear-se-á nos elementos arrolados no art. 319, doravante designados de requisitos gerais; por exemplo, o endereçamento da petição inicial (art. 319, I), envolvendo a resolução do problema de competência pelo exequente.

O art. 513, § 1.º, chama a iniciativa do exequente, pleiteando o cumprimento do título judicial, de “requerimento”. Já o art. 522, *caput*, não sendo eletrônico o processo, designa de “petição” idêntico ato postulatório. Se o texto desejou descaracterizar o rigor formal da petição inicial, empregando em seu lugar palavra que timbra pela neutralidade, inspirando-se no art. 810 do CPC português 1961,⁷⁷ hoje constante com a mesma rubrica – “requerimento executivo” – do art. 724 do CPC português de 2013, além dos limites aqui explicados, malogrou no seu intento. As palavras aleatoriamente escolhidas pouco mudam a natureza das coisas. No direito português, apesar da terminologia, os requisitos da petição inicial aplicam-se, subsidiariamente, ao “requerimento”.⁷⁸ E basta recordar a hipótese de o vitorioso requerer a execução no lugar do domicílio atual do executado (art. 516, parágrafo único), para justificar cuidados formais mínimos. Sem indicar, por exemplo, qual o título e o processo que o originou, o vitorioso jamais se fará compreender em outro juízo... Por essa razão, “formalmente, o tal ‘requerimento’ há de revestir-se dos requisitos arrolados nos artigos 798 e 799, conforme o caso, quanto à petição inicial” do processo de execução.⁷⁹

Uma das consequências de o vitorioso deduzir a pretensão a executar, através do requerimento, consiste na necessidade de realizar-se o devido registro na distribuição, assegurando o princípio da publicidade a transmissão dessa informação relevante aos terceiros.⁸⁰

É comum, entretanto, os exequentes desatenderem até o indispensável à compreensão da petição inicial na execução.

Esta petição, que representa a vontade do exequente e a reclamação da tutela jurídica do Estado – trata-se, consoante observação bem apanhada,

de pedido para a realização concreta de um direito já suficientemente reconhecido no título executivo judicial ou extrajudicial, de pedido de prática de atos jurisdicionais que se voltam à

satisfação do direito e não ao seu mero reconhecimento –,⁸¹

padece com extraordinária frequência do desmazelo e de mal disfarçado desprezo aos seus elementos, embora, se se tratasse de pretensão de outra natureza (v.g., a pretensão à declaração), jamais seriam olvidadas as prescrições do art. 319. E isto que a petição inicial é o ato postulatório fundamental de quem pleiteia a tutela jurídica do Estado, autônoma (processo de execução) ou incidentalmente (cumprimento da sentença), e, por isso, jamais pode faltar.⁸²

Sob determinados aspectos, os elementos da petição inicial são objeto de comentários a outras disposições. A solução do problema de competência informa a quem endereçar a petição inicial, mas o assunto é próprio do art. 781, ao qual se deve consultar. E esse ato, além disso, há de receber despacho de alguém investido na função jurisdicional. Toda a problemática concernente às partes, da mais abstrata (personalidade processual) à mais concreta (legitimidade), não esquecendo o patrocínio técnico (capacidade postulacional), recebe análise nos arts. 778 a 780. Por óbvio, a petição inicial identificará a pessoa que assume a condição de exequente e indicará o(s) executado(s). É indispensável indicar e manter atualizado o endereço das partes para os fins do art. 77, V,⁸³ presumindo-se válidas e eficazes as intimações endereçadas ao endereço profissional ou residencial indicado nessa peça. A *causa petendi* baseia-se na alegação de existência de crédito contemplado em título executivo e descumprido pelo executado. Logo, decompõem-se nos fatos constitutivos – fatos principais, fatos secundários e fatos relativos ao interesse – que lhes são naturais.⁸⁴ Em princípio, não basta a simples alusão ao título, impondo-se a indicação dos seus elementos (natureza, valor do crédito, atualidade). Resta acrescentar que, juntado o título (art. 798, I, *a*), se necessário, e a procuração, o exequente deverá alegar positivamente o inadimplemento, para expressar seu legítimo interesse na instauração do processo (art. 17), e juntar a memória de cálculo da dívida, em se cuidando de prestação pecuniária (arts. 524, I a VI, e 798, I, *b*, e parágrafo único).

Resta a examinar, sob os auspícios de comentários ao art. 798, outros aspectos: o pedido, o valor da causa, o requerimento de citação do executado e o respectivo meio técnico, e, por fim, a admissibilidade de meios de prova.

4. Requisitos gerais da petição inicial na execução – O exequente deduzirá pretensão a executar fundada em título extrajudicial, na petição inicial, ato postulatório de iniciativa (exclusiva) do credor, formando a relação processual executiva. Cumpre examinar o conjunto dos requisitos da petição inicial imprescindível para a instauração da execução autônoma, sem prejuízo de menção subsidiária, quando for o caso, ao “requerimento” mencionado no art. 513, § 1.º.

Abstraindo outras considerações sobre pressupostos processuais, na petição inicial da execução incidem os arts. 319 e 320 do CPC/2015.⁸⁵ Cuida-se de imperativo lógico e resultado indubitável da integração das normas processuais, tornando aplicáveis no processo de execução, no que couber, a Parte Geral do CPC/2015 e, inclusive, disposições do Livro I da Parte Especial. É interessante notar que, na execução fiscal, aplica-se subsidiariamente todo o CPC/2015, e não apenas as disposições gerais do processo de conhecimento,⁸⁶ com o fito de ensejar a incidência das regras do Livro II. Por outro lado, ao requerimento inicial do cumprimento também se aplicará, *mutatis mutantis*, tais requisitos. Sempre é bom lembrar que o vitorioso exerce nova pretensão – a pretensão a executar –, nascida do título, e, frequentemente, até inaugura novo processo (na execução dos títulos mencionados no art. 515, § 1.º).

Um dos requisitos específicos do “requerimento” consiste na indicação de bens passíveis de constrição (art. 514, VII). É uma faculdade do exequente, reproduzindo o que estabelecia o art. 53, *caput*, da Lei 8.212/1991.

E novidade digna de registro, útil para fins de tributação, reside no ônus de a parte informar, na petição inicial, o número no cadastro de pessoas físicas (CPF) ou jurídicas (CNPJ) na Receita Federal, a teor do art. 319, II, c/c art. 798, II, *b*, antes previsto no art. 15 da Lei 11.419, de 19.12.2006. Essa exigência facilitará a futura constrição de ativos financeiros (art. 854) e revela-se indispensável à averbação de que trata o art. 828.

Nos casos em que se configura obrigatória a intervenção do Ministério Público, a teor do art. 178 – por exemplo, na execução movida por incapaz para receber prestação alimentar –, incumbe ao exequente requerer a intervenção do respectivo agente.⁸⁷

Representando essa peça o ato postulatório principal do exequente, remarque-se a elementar observância do seu modelo técnico também na demanda executória. Em geral, o exequente despreza o modelo, considerado supérfluo, conquanto jamais se tolerasse essa animosidade na mais vulgar das ações visando à formulação da regra jurídica concreta. Na verdade, semelhante peça “exige cuidado, precisão, clareza, concisão e perfeição lógica e jurídica”.⁸⁸ Também a petição inicial da pretensão a executar reclama boa e ordenada exposição, inconfundível com repulsivo formalismo, cabendo ao juiz determinar as emendas adequadas (art. 801). Naturalmente, a petição inicial da execução é mais simples, no que tange à narração da causa de pedir. Limitar-se-á o exequente a declarar-se credor e a individualizar o crédito, indicando, por exemplo, o respectivo valor e vencimento. Esse caráter sucinto,⁸⁹ em geral realçado, não elimina as exigências técnicas, antes as pressupõe. Evidenciado o equívoco, não deve o juiz, quicá inspirado na instrumentalidade, aprovar peças ininteligíveis e excessivamente sumárias, impossibilitando ou dificultando o exercício ativo dos meios executórios e a defesa do executado. A falta de indicação do principal e dos acessórios do crédito pecuniário, por exemplo, na planilha anexa (art. 798, I, *b*, c/c parágrafo único) ou no próprio corpo da petição, impede o controle do órgão judiciário, para fins do art. 524, § 1.º, e, *a fortiori*, o oferecimento de oposição pelo executado baseada em excesso de execução (art. 525, § 1.º, V, c/c art. 917, § 2.º, I).

O art. 319 dispensa o autor de requerer a citação do réu. Cuida-se de ato reservado ao impulso oficial. Todavia, nada impede o exequente de requerer a citação, posto que ocioso o requerimento, indicando o meio técnico. Embora diversas disposições aludam ao mandado de citação, e, portanto, à citação por oficial de justiça (v.g., os arts. 806, § 2.º, e 829, § 2.º), nada pré-exclui outras modalidades (v.g., a citação por via eletrônica). Esse assunto receberá análise mais adiante.

Uma última observação impõe-se nessa seara. Não é incompatível com a função executiva o órgão judiciário, desincumbindo-se do dever do art. 139, IV, promover a tentativa de reconciliação das partes, auxiliado por conciliador ou por mediador. O CPC/2015 enfatizou essa função, no procedimento comum, tornando obrigatória a audiência de mediação e de conciliação (art. 334), salvo manifestação de mútuo desinteresse dos litigantes, oportunamente manifestada, cabendo ao autor manifestar seu desinteresse já na petição inicial, a teor do art. 319, VII. É comum a implementação de programas específicos e gerais, organizados pelo tribunal ou pelo CNJ, para alcançar a autocomposição judicial, razão bastante para suspender os prazos processuais (art. 221, parágrafo único). Nada impede iniciativa isolada do órgão judicial nesse sentido, no processo de execução ou no cumprimento da sentença, designando a audiência do art. 334, porém inexiste a necessidade de o exequente realizar a declaração de vontade prevista no art. 319, VII, na petição inicial ou no requerimento do art. 513, § 1.º. Concebe-se exatamente o contrário: inclinando-se o exequente a conceder prazo e condições vantajosas para o executado cumprir voluntariamente a obrigação, conforme antevê o art. 922, *caput*, requererá a designação de audiência para esse fim.

4.1. Endereçamento da petição inicial da execução – Apesar da omissão do art. 798, cumpre ao exequente endereçar a petição inicial ao juízo competente. A esse respeito, consulte-se os comentários ao art. 781, pois o endereçamento depende da resolução do problema de competência. Impende observar que o processo formar-se-á pela entrega da petição inicial no ofício judicial (art. 312), estabelecendo-se relação processual linear entre exequente e Estado, geralmente completada pela citação do executado (art. 238). Do registro do ato postulatório, ou da sua distribuição, havendo dois ou mais juízos de competência concorrente na comarca ou seção judiciária, já resultam determinados efeitos processuais (v.g., a prevenção, a teor do art. 59).

4.2. Identificação e qualificação das partes na petição inicial da execução – O art. 798, II, *b*, exige do exequente a indicação dos nomes completos do exequente e do executado, bem como dos números de inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), na Receita Federal. Essa providência já se encontrava prevista no art. 15 da Lei 11.419, de 19.12.2006, antes da desejável generalização introduzida no art. 319, II. É ainda mais importante o requisito na execução, relativamente ao procedimento comum do processo de

conhecimento, porquanto (a) facilitará a futura constrição de ativos financeiros, a teor do art. 838 (*infra*, 135); e (b) revela-se indispensável à averbação de que trata o art. 828.

É evidente que o exequente dispõe dos dados relativos à sua pessoa. Não se concebem dificuldades a esse respeito, inclusive quanto ao ônus da qualificação (estado civil, profissão e endereços físico e eletrônico). Porém, nem sempre o exequente conhece todos os dados relativos ao executado. Em tal hipótese, e fitando precipuamente o número de inscrição nos cadastros da Receita Federal, o exequente poderá requerer ao órgão judiciário a obtenção do dado faltante (art. 319, § 1.º), e, nada obstante, a petição inicial não será indeferida (a) se for possível a citação do executado (art. 319, § 2.º) e (b) a obtenção de maiores informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à Justiça (art. 319, § 3.º).

É imperiosa a identificação correta do executado. Eventual equívoco, havendo manifesta ilegitimidade passiva, ensejará o indeferimento da petição inicial (art. 330, II).

O art. 798, II, *b*, reclama a indicação dos nomes completos das partes. Já o art. 319, II, é mais explícito, exigindo os nomes e os prenomes. Essa fórmula não pode ser tomada ao pé da letra. É invulgar, entre nós, a indicação do nome antes do prenome (*v.g.*, Silva, João), sendo preferível o nome completo, incluindo todos os sobrenomes (*v.g.*, Silva, José João Silveira da.). No tocante às pessoas jurídicas, o nome envolve a firma ou denominação adotada para o exercício da empresa (art. 1.155, *caput*, do CC). E os nomes dos entes sem personificação seguem o costume (*v.g.*, Condomínio do Edifício Silva). Convém não olvidar, figurando como executado a União, o Estado-membro, o Distrito Federal, o Município, e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, o endereço do órgão da Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, porque aí realizar-se-á a citação por um dos meios admissíveis. E o endereço eletrônico das empresas públicas e privadas, constante de cadastro organizado na forma do art. 1.051, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte, no qual realizar-se-á preferentemente a citação (art. 246, § 1.º).

Pode acontecer de o exequente equivocar-se na identificação do executado. Razões heterogêneas induzem esse erro. Em algumas situações, o erro é escusável ou, no mínimo, não infringe a tábua de valores da lei processual. Confusões a respeito do nome empresarial, em virtude de modificações sociais (cisão, fusão e incorporação), acontecem usualmente e desorientam as pessoas. O STJ já decidiu que, apesar do equívoco da inicial, “se foi possível a sua precisa identificação e regular citação, tanto que apresentaram defesa”, inexistente necessidade de invalidar o processo.⁹⁰ A homonímia da pessoa natural é outra fonte de distúrbios. A troca do prenome da pessoa natural (*v.g.*, A em lugar de B), por lapso na redação da peça, ou a indicação incompleta do nome (*v.g.*, João da Silva, em vez de José João Silveira da Silva), não raro recebem emenda no próprio ato de registro da inicial, mediante ato de serventuário mais diligente e operoso. A imprecisão no nome da pessoa jurídica de direito público (*v.g.*, Prefeitura de São Carlos, em vez de Município de São Carlos), também passível de correção no registro do processo, não suscita maiores imprecisões. Toma-se o nome do prédio da sede, a Prefeitura, como sinônimo de “Município”, e o processo segue adiante.

Erros dessa natureza podem ser corrigidos no prazo para emendar a petição inicial (art. 801). A persistência do erro, após a citação, provocará a emissão de pronunciamento favorável ao réu, excluindo-o do processo.⁹¹

Cuidando-se de empresa integrante do mesmo grupo financeiro, a jurisprudência admite que a líder (*v.g.*, o Banco X) responda à demanda, embora seja outra a contratante do caso concreto (*v.g.*, a Seguradora X), em nome da teoria da aparência.⁹² A indicação da empresa líder no polo passivo da ação pode ser corrigida pelo órgão judiciário, ordenando a correção da denominação da parte.⁹³

O número expressivo de executados induz o exequente a indicar um deles e, quanto aos demais, rotulados na petição inicial como “outros”, individualizá-los em lista anexa. É tolerável, em termos, essa brutal simplificação. O registro e, *a fortiori*, a distribuição do processo precisam consignar todos os executados. Por óbvio, a citação de todos é imperiosa, no processo de execução,

e, constituindo procuradores distintos, incidirá o art. 229, e, principalmente, as intimações devem ser feitas corretamente. Faltando a individualização dos “outros”, ou seja, a simples menção a “outros” ofende o art. 798, II, *b*, c/c 319, II,⁹⁴ e há dois termos de alternativa para corrigir o defeito: (a) ou se restringe a pretensão à pessoa individualizada, ou às pessoas mencionadas; (b) ou o juiz manda o autor esclarecer o polo passivo, na forma do art. 801.⁹⁵

Em relação ao art. 319, II, o art. 798, II, *b*, não impõe ao exequente o ônus da qualificação, abrangendo (a) estado civil, incluindo a existência de união estável; (b) profissão; e (c) endereço físico e eletrônico. Ocioso frisar a existência do ônus de qualificação, arrolando tais dados, a respectiva importância, na execução mais do que alhures (v.g., o estado civil e a natureza do regime matrimonial interessa à aplicação do art. 842), e a dificuldade de o exequente conhecer o estado civil do executado, mormente a existência de união estável, e o seu endereço eletrônico. Aplicam-se os parágrafos do art. 319. O exequente poderá requerer ao juiz que localize, v.g., o endereço físico ou eletrônico do réu, valendo-se dos cadastros públicos, e, de toda sorte, o descumprimento desse requisito não provocará o fatal indeferimento da petição inicial, vencido o quinquênio do art. 801, se for possível a citação do executado (art. 319, § 2.º), malgrado a falta de um ou mais dados, ou o cabal cumprimento do art. 319 tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça (art. 319, § 3.º).

Nada obstante natural importância da identificação e da qualificação do executado, talvez a pertinência de quem inicia a execução seja posta em dúvida. Em determinados casos, o título é apenas fonte mediata de legitimação (v.g., titular do direito incorporado em título de crédito é o seu portador). Assim, na execução da sentença penal condenatória transitada em julgado (art. 515, VI), legitimam-se, ativamente, a vítima ou o lesado pelo ato contrário ao direito que, simultaneamente, incidiu na regra repressiva e no art. 186 do CC. Se os fundamentos da sentença penal revelam, geralmente, o nome da vítima, nem sempre acontecerá idêntica nitidez quanto ao lesado (v.g., o cônjuge ou o(a) companheiro(a) de quem faleceu em virtude do homicídio). Cumprirá ao exequente provar sua condição no requerimento do cumprimento da sentença.

4.3. Causa de pedir na petição inicial da execução – O art. 319, III, reclama do autor a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, fórmula que abrange a causa petendi.

Pois bem. Fundamenta-se o pedido de execução formulado pelo exequente por meio da exibição do título executivo extrajudicial (art. 798, I, *a*).⁹⁶ Impende ao exequente, ainda, (a) invocar os seus elementos (natureza, origem, valor do crédito) e (b) alegar ocorrência positiva de inadimplemento imputável. Não basta afirmar a existência do título e “reclamar do órgão judiciário o cumprimento do comando”.⁹⁷ Na execução baseada em título extrajudicial, além da causa originária representada pelo título, apresenta-se concausa, relativamente à incerteza quanto à futura realização do crédito, tornando a causa de pedir da demanda executória análoga à da ação condenatória.⁹⁸

Inconfundível que seja com o fundamento legal (v.g., a alegação de o documento exibido quadra-se no art. 784, III), o fundamento jurídico costuma ser implícito: da alegação que a pretensão se funda em título judicial ou extrajudicial (art. 783), deriva a pretensão a executar; não se mostram necessárias maiores digressões a respeito.

Existem frisantes diferenças entre o inadimplemento verificado no crédito constante no título extrajudicial comparado ao judicial. No primeiro caso, à atualidade do crédito bastará o descumprimento imputável ao obrigado (art. 786, *caput*) e, eventualmente, o exequente ministrará prova de que se verificou o termo (v.g., a morte, termo impróprio, no caso do art. 784, VI) ou ocorreu a condição, mas a obrigação é líquida ou não existirá título extrajudicial; no segundo, porém, havendo condenação genérica, a iliquidez impede a ocorrência de inadimplemento (*in illiquidis mora non fit*), motivo por que o vitorioso há de promover a prévia liquidação (art. 509).⁹⁹ Líquida que seja a obrigação, impende intimar o executado para cumpri-la, a teor do art. 513, § 2.º, variando o destinatário (advogado ou a parte) e o meio técnico empregado para essa finalidade, mas esse tema é marginal nos comentários ao art. 798.

4.4. Formulação do pedido na petição inicial da execução – Segundo o art. 319, IV, incumbe

ao autor deduzir o pedido acompanhado das suas especificações. Impõe-se considerar, aqui, as acepções mediata e imediata de pedido, transportando os resultados para a petição inicial da execução.

De maneira mediata o exequente pleiteia o bem jurídico assegurado no título executivo (*corpus, genus e facere*), ou seja, o objeto da prestação inadimplida. É o que, no primeiro momento, precisa pedir ao órgão judiciário, definindo-o exaustivamente. Na execução das dívidas em dinheiro, a planilha ou demonstrativo presta-se para tal finalidade magnificamente (art. 524, I a VI e art. 798, I, b, c/c parágrafo único), mas não se pode olvidar, por exemplo, a cabal individualização da coisa objeto da entrega (art. 806, *caput*).

O pedido vincula o órgão judiciário na execução. Assim, se o credor A pede comissão de permanência de B, ao executar cédula de crédito bancário, em vez de correção e juros, sucederá adstrição do juiz ao pedido da parte: não é admissível, *ex officio*, conceder juros, porque inadmissível a comissão de permanência. E, por outro lado, o exequente deve evitar excesso de execução, a exemplo da ilegal cumulação de comissão de permanência com correção monetária, vetada pela Súmula do STJ, 30.

Conforme o art. 322, *caput*, o pedido há de ser certo, englobando, porém, os juros legais e a correção monetária, incluindo, ainda, os encargos da sucumbência (art. 322, § 1.º). Cabem honorários sucumbenciais no processo de execução e no cumprimento da sentença (art. 85, § 1.º). Não é necessária, entretanto, qualquer manifestação do exequente nesse sentido. Eventual reclamação de percentual maior do que o previsto (v.g., os dez por cento do art. 827, *caput*) constitui simples *obiter dictum*.

A interpretação do pedido, acrescenta o art. 322, § 2.º, compreenderá o conjunto da postulação (v.g., o exequente referiu a cláusula penal, ao descrever o crédito, mas a ela não se referiu no tópico específico da petição inicial) e o princípio da boa-fé (art. 5.º). Por exemplo, a alusão genérica a encargos legais não ensejará o acréscimo de acessório não especificado na petição inicial.

O art. 323 aplica-se à pretensão a executar, consoante decidiu o STJ no direito anterior: “Tratando-se de obrigações periódicas, consideram-se elas incluídas no pedido, sem mais formalidades, enquanto durar a obrigação”.¹⁰⁰ É o que acontece na execução de alimentos. Limitada que seja a individualização do pedido mediato às últimas três prestações anteriores ao ajuizamento (Súmula do STJ, 309), na execução através de coerção pessoal (art. 528), compreender-se-ão no débito as prestações que se vencerem posteriormente (art. 528, § 7.º), motivo por que o executado só se livra da prisão com o depósito do valor integral das prestações vencidas até a data da decisão do juiz.

Não há nenhuma dificuldade em aplicar a regra, ademais, à execução baseada em provimento condenatório civil (art. 515, I).¹⁰¹ Basta considerar que o sistema jurídico brasileiro reconhece a condenação de dívida sujeita a termo (art. 514). Desse modo, presumindo-se que as prestações periódicas sejam tão duradouras que superem o tempo de tramitação do processo de conhecimento, o que já representaria proeza significativa, incluir-se-ão, à medida que vencerem, no valor do crédito em execução. Fica atendido, neste particular, o pressuposto da exigibilidade (art. 786). Por óbvio, o pedido inicial não abrangerá as prestações (ainda) não vencidas. Por isso, a penhora não precisa abrangê-las; porém, mostrando-se insuficiente a constrição inicial, na oportunidade em que o juiz der início aos atos de expropriação (art. 875), o exequente poderá requerer a ampliação da penhora (art. 874, II) – hipótese em que se assegurará ao executado nova impugnação, limitada aos aspectos formais (v.g., fundada em penhora incorreta, a teor do art. 518 c/c art. 525, § 1.º, IV). Finalmente, quanto à preferência da penhora (art. 797, *caput*), ela respeita ao crédito, e, portanto, há que se considerar abrangidas as prestações que se venceram após o início da execução, comportando o bem inicialmente penhorado; sendo insuficiente, e ampliada a penhora (art. 784, II), outra será a preferência sobre o novo bem.¹⁰²

Em relação às obrigações alternativas, incidirá o art. 800, cujo alcance receberá análise mais adiante.

E, ademais, para alcançar o objetivo visado (*corpus, genus e facere*), há o exequente de pedir, imediatamente, a atuação de determinado meio executório (pedido imediato). Este pedido se diferencia do formulado no processo de conhecimento porque, na execução, toda ela inclinada à realização prática de direitos, a providência jurisdicional reclamada não se esgota na construção intelectual do provimento final, cuja função é outra, consistindo em declarar a satisfação do exequente ou o desaparecimento da pretensão a executar por qualquer motivo (v.g., remissão da dívida). O pedido de execução envolve a prática dos atos executivos próprios do meio executório hábil à satisfação do exequente.

A indicação pelo credor do meio executório, na inicial, reveste-se da maior importância. Existem obrigações que admitem mais de um meio (art. 798, II, *a*), a exemplo da alimentar, e os atos que o exequente ao juiz requererá, no desconto ou na coerção pessoal, não se identificam entre si e não podem ser confundidos. Na execução de uma dívida comum de dinheiro, basta ao exequente pleitear a expropriação dos bens suficientes à satisfação do crédito, promovendo a citação do executado. A opção pelo ato expropriatório concreto, dentre os mencionados no rol do art. 825, respectivamente a adjudicação, a alienação coativa (particular e em leilão presencial ou eletrônico) e a apropriação de frutos e de rendimentos, dependerá da natureza do bem penhorado (ressalva feita aos casos em que a constrição é predeterminada pelo negócio jurídico das partes – v.g., art. 835, § 3.º), da oportuna iniciativa do exequente (art. 875, *caput*, e art. 880) e das respectivas conveniências – por exemplo, a penhora em objeto de arte despertará o interesse do exequente colecionador em adjudicá-lo. É neste sentido restrito que se deve compreender a afirmativa de que os meios tendentes à obtenção do pedido mediato “não integram a pretensão executiva deduzida em juízo”.¹⁰³ Às vezes, porém, o meio precisa ser expressamente indicado, como exige o art. 798, II, *a*, a exemplo da execução de prestação alimentar, cabendo ao exequente observar os pressupostos que lhe ensejam opção por um e outro meio executório.

É curial que, outrossim, para a execução de obrigação de fazer fungível, haja vista comportar tanto a coerção patrimonial, quanto a transformação, e um meio executório excluir o outro, *in simultaneo processu*, ao exequente incumbe esclarecer qual deles utilizará, sob pena de inépcia da inicial.

Essas diferenças, existentes no âmbito do pedido imediato, derivam do regime dos meios executórios. O credor atento encontrará na sua disciplina a solução de quaisquer problemas.

4.5. Valor da causa na petição inicial da execução – Consoante o art. 291, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não exiba conteúdo econômico imediatamente mensurável – de regra hipótese estranha aos domínios da execução, porque todo crédito tem valor –, e, para vários fins, o art. 319, V, determina seja explicitado o valor da causa na inicial.¹⁰⁴

Aplica-se à pretensão a executar o art. 292, I, por analogia, porquanto não se cuida, a rigor, de “ação de cobrança de dívida”. O valor da causa na execução equivale ao valor total do crédito – o principal corrigido, os juros e os demais consectários –, conforme dispõe, aliás, o art. 6.º, § 4.º, da Lei 6.830/1980, na execução fiscal. É de notar que, exigindo-se crédito líquido (art. 786, parágrafo único), “este *quantum* será o próprio valor da causa”.¹⁰⁵ Também incidirá o art. 292, § 1.º, abrangendo o valor da causa as prestações vencidas e vincendas, com a explicitação do art. 292, § 2.º: o valor das prestações vincendas será a soma de um ano, se for por tempo indeterminado ou por prazo superior a um ano, ou será a soma das prestações, se por tempo inferior.

Todavia, em alguns casos o valor se apresenta inestimável na ocasião da propositura, sem embargo do preenchimento do requisito da liquidez. É o caso, p. ex., de obrigações de fazer: às vezes, o comportamento exigido do executado não se encontra avaliado financeiramente. Em tal contingência, o exequente fixará o valor do crédito, considerando o benefício econômico mirado pelo processo.

É natural que ao órgão jurisdicional caiba corrigir de ofício o valor erroneamente atribuído à causa, não se cuidando de livre atribuição pelo exequente.¹⁰⁶ Em vários casos, decorrentes de descuido ou da malícia do credor, o engano se ostentará inobscurecível. Incumbe ao juiz corrigi-lo, e prontamente, a fim de que o demandante satisfaça a diferença no recolhimento das custas

judiciais, a teor do art. 292, § 3.º. Não o fazendo, o órgão judiciário intimará o exequente, pessoalmente, para fazê-lo em cinco dias, sob pena de extinção (art. 485, III e § 1.º).

Na hipótese de falta de pagamento das custas, o juiz corrigirá o valor e ordenará a complementação do pagamento das custas iniciais, intimando o exequente na pessoa do seu advogado para depositá-las no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290). No entanto, ocorrida a citação do devedor, não mais se aplica o art. 290.¹⁰⁷

Ao executado, igualmente, afigura-se lícito impugnar o valor da causa, por meio dos embargos à execução (art. 917, VI, c/c art. 293), sendo na execução fiscal impugnável o valor errôneo na forma art. 16, § 2.º, da Lei 6.830/1980, cuja aplicação nos demais procedimentos, por analogia, também é defendida.¹⁰⁸

O requerimento previsto no art. 513, § 1.º, reclama a indicação do valor da causa. É valor indispensável para a aplicação de sanções ao executado (art. 774, parágrafo único; art. 77, IV, c/c § 2.º) e para a elaboração da certidão necessária à averbação de que cuida o art. 828, ao protesto do título judicial (art. 517) e à inclusão do nome do executado no cadastro dos inadimplentes (art. 782, § 3.º) e, conforme a lei de organização judiciária, também para o cálculo das custas iniciais. Se o exequente negligenciar tal requisito, desarmará o órgão judiciário na aplicação do valioso mecanismo contemplado no art. 77, IV e § 2.º, talvez o emprego do valor desatualizado do processo de conhecimento. Assinale-se que, na hipótese do art. 828, § 5.º, c/c art. 81, *caput*, o valor da causa também servirá para arbitrar a indenização devida ao executado pela averbação “manifestamente indevida” ou no caso de não cancelar as averbações nos termos do art. 828, § 2.º.

4.6. Indicação de meios de prova na petição inicial da execução – É frequente dizer-se impróprio ou supérfluo o requerimento de produção de provas na petição inicial da execução. Em termos gerais, a asserção revela-se improcedente. Lícito se mostra ao órgão judiciário ordenar e ao exequente requerer, se for o caso, o comparecimento das partes, designando audiência para essa finalidade (art. 772, I).

Ademais, outras situações que exigem prova se verificam na demanda executória.¹⁰⁹ Assim, é possível ter o exequente de provar, sumariamente, o domínio do executado quanto aos bens, não se desincumbindo o devedor do ônus que lhe compete, a teor do art. 774, § 4.º, ou de que o imóvel não lhe serve de residência, razão por que inadmissível a incidência do art. 1.º da Lei 8.009, de 29.03.1990. Exequente surpreso com a juntada de quitação falsa poderá suscitar o incidente de falsidade, de cuja resolução cabe agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único).¹¹⁰

O art. 798, I, ocupa-se da instrução da petição inicial da execução, abstraindo esses problemas e fitando prova documental pré-constituída. O assunto merece item próprio.

5. Instrução da petição inicial da execução – O art. 798, I, exige a produção de prova documental, relativamente ao título executivo extrajudicial, à verificação do termo ou ocorrência da condição e à contraprestação a cargo do exequente.

5.1. Ônus de exibição do título executivo – O art. 798, I, *a*, erige o ônus de o exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial do qual deriva a pretensão a executar. Em princípio, cuida-se do original, especialmente no caso de títulos destinados à circulação (art. 784, I); por exceção, admite-se cópia autêntica. E não importa, especialmente no processo eletrônico, o suporte físico ou eletrônico do documento; por exemplo, exequível é a duplicata virtual, acompanhada do instrumento de protesto por indicação e do comprovante da remessa e da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço.¹¹¹

O ônus de exhibir o título executivo também cabe em algumas situações do cumprimento da sentença. É ônus do exequente, ao requerer o cumprimento provisório, instruir a petição – e, não, “requerimento” – com a decisão exequenda, a teor do art. 522, parágrafo único, I. Por óbvio, formando-se relação processual autônoma na execução dos títulos previstos no art. 515, VI a IX, conforme estipula o art. 515, § 1.º, o exequente exhibirá certidão, respectivamente, da aprovação judicial do crédito do serventário da justiça, da sentença penal condenatória, da sentença

arbitral, da sentença estrangeira homologada e do *exequatur* passado à decisão interlocutória estrangeira. Em todos os casos, ademais, que a execução incidental processar-se-á em autos autônomos ou apartados, o exequente assumirá o ônus de exhibir o título judicial (v.g., a execução de decisão ou de sentença não transitada em julgado, fixando alimentos provisórios ou definitivos, a teor do art. 531, § 1.º).

5.2. Prova do termo ou da condição – É ônus do exequente, conforme o art. 798, I, c, instruir a petição inicial com a prova de que se verificou o termo ou ocorreu a condição. Idêntico ônus grava o exequente no cumprimento da sentença. O art. 514 estabelece que, decidida relação jurídica sujeita a condição ou termo, “o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo”.

Termo corresponde a evento futuro e inevitável. Em geral, trata-se de fato natural, inferido pelo órgão judiciário segundo regra de experiência, e, portanto, prescinde de prova (art. 374, I). Assim, proposta a execução no dia 30, nenhuma prova o exequente exhibirá de que a dívida, vencida no dia 20, tornou-se exigível. Basta o órgão judiciário conferir os dados cronológicos do título com o calendário gregoriano. Excetuam-se o termo impróprio – a morte, fato que torna exigível o seguro de vida, previsto no art. 784, VI –, ¹¹² e as cambiais, nos casos em que a falta de pagamento provar-se-á mediante protesto obrigatório. ¹¹³ O art. 47, II e § 1.º, da Lei 7.357, de 02.09.1985, torna as declarações do sacado e a da câmara de compensação equivalentes ao protesto, no caso do cheque (art. 784, I), dispensando, por conseguinte, o ato extrajudicial que restringiria o crédito do obrigado. ¹¹⁴ O inadimplemento decorre do vencimento do termo, a teor do art. 397, *caput*, do CC, salvo nos casos, expressamente estipulados, em que haja necessidade de prévia interpelação; por exemplo, o crédito garantido por alienação fiduciária, a teor do art. 2.º, § 2.º, c/c art. 5.º do Dec.-lei 911/1969, na redação da Lei 13.043/2014.

Condição é evento futuro e incerto. Daí a necessidade ingente de provar sua ocorrência (art. 798, I, c, c/c 514). Um exemplo frisante de obrigação pecuniária subordinada a condição consiste no capítulo condenatório nas verbas da sucumbência na demanda em que acabou vencido o beneficiário da gratuidade. De acordo com o art. 98, § 3.º, vencido o beneficiário da gratuidade, a condenação nesse capítulo ficará suspensa, no prazo de cinco anos, no curso do qual o vencedor poderá provar o superveniente desaparecimento da “situação de insuficiência” financeira, e, findo este interregno, extinguir-se-á o crédito. Logo, a pretensão a executar tal rubrica do vencedor se subordinará à prova da possibilidade do vencido, que é um evento futuro, em relação ao momento da concessão do benefício, e incerto, proclamando o STJ:

Em tema de execução dos ônus da sucumbência, sendo o executado beneficiário da justiça gratuita, incumbe ao exequente a demonstração de que aquele teria condições de suportar o pagamento, estando a viabilidade da execução condicionada a essa prova. ¹¹⁵

Nada exclui, entretanto, título extrajudicial vinculado a condição (v.g., por instrumento particular, *A obriga-se a pagar X a B quando realizar a messe na área Y*).

A prova da ocorrência da condição há de se constituir previamente à demanda executória e acompanhá-la, obrigatoriamente (art. 801). Concebem-se duas soluções para o exequente desincumbir-se desse ônus particular: (a) ou o credor possui prova documental, *tout court*, desincumbindo-se do ônus; (b) ou o credor não dispõe dessa espécie de prova. Nesta última hipótese, o credor deverá assegurar a prova da ocorrência da condição, pelos meios lícitos (art. 369), através da pretensão do art. 381.

5.3. Prova da prestação nas obrigações bilaterais – O inadimplemento nas obrigações bilaterais recíprocas ou sucessivas importa problema específico. Em síntese, se as obrigações bilaterais são sucessivas, a própria estrutura da relação obrigacional revela qual dos parceiros há de prestar em primeiro lugar, predeterminando quem pode tomar a iniciativa de executar o outro, provando que adimpliu e que assegura, desde logo, o seu próprio cumprimento mediante a prestação que lhe corresponde para os fins do art. 798, I, d. Cuidando-se de prestações recíprocas simultâneas, entretanto, o quadro muda de figura, não sendo possível, *a priori*, debitar ao executado o inadimplemento. Ao contrário, sucede de o próprio exequente não ter adimplido sua

prestação e dado causa, portanto, à inércia do outro figurante. O problema encontra-se versado nos artigos 787 e 798, I, *d*, não sem contradições dignas de registro.

Inicialmente, considere-se a proposição do art. 787, *caput*, que reza o seguinte:

Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo.

Não se pode supor a interferência do regime processual na estrutura do negócio jurídico. Se as prestações são simultâneas, ou trato a trato, mostrar-se-á descabida a exigência de o futuro exequente prestar antes de receber a contraprestação, principalmente à luz do art. 787, parágrafo único, que veda o exequente receber a prestação do executado depositada em juízo sem a contraprestação do exequente. E, de resto, semelhante interpretação literal dissipa-se mediante a leitura do art. 798, I, *d*, segundo o qual incumbe ao exequente ministrar na petição inicial

a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde, ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente.

Logo, o art. 787, *caput*, aplica-se às prestações recíprocas sucessivas, traduzindo a impossibilidade de o inadimplente executar a prestação do outro parceiro, desde que ambas, evidentemente, estejam previstas em título executivo.

O art. 798, I, *d*, onera o credor com a prova, companheira da inicial, do adimplemento da contraprestação, ou a assecuração do seu cumprimento, “se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente”. Na primeira hipótese, destarte, não se procederá à execução, cabendo ao juiz extinguir o processo.

Se o exequente *A* pretende executar o preço do contrato de compra e venda, via expropriação (art. 824), e tem a seu cargo, concomitantemente, o dever de entregar a coisa ao executado *B*, e de modo prévio deposita-a em juízo ao propor a pretensão a executar, segue o comando do art. 798, I, *d*. Não tem cabimento o levantamento da coisa até a satisfação do crédito pecuniário, aplicando-se, por analogia, o art. 787, parágrafo único.

Tomando o alienante a iniciativa de inaugurar a execução sem depositar a coisa ou assegurar-lhe o depósito, como impõe o art. 798, I, *d*, abre-se ao executado dois termos de alternativa: (a) ou requer, simplesmente, a prestação do credor mediante a promessa de satisfazer a própria prestação, mercê da apresentação de meios idôneos para esse fim, a critério do juiz; ou vai além e (b) deposita o preço. Na primeira hipótese alvitrada, decorrente da recusa do executado e na promessa de pagamento futuro, das duas uma: (aa) ou o exequente realiza a prestação (entrega a coisa), ou (ab) não a deposita em juízo. Realizada a entrega da coisa, o passo seguinte consiste no adimplemento do executado, extinguindo a execução, ou no prosseguimento da execução, se a promessa do executado se revelar, afinal, falsa e os meios acenados, inidôneos. Ao invés, se o exequente não realiza o depósito da coisa, parece contraproducente extinguir a execução, como se infere do art. 787, *caput*, convindo suspendê-la até o cumprimento. No tocante à segunda hipótese – o depósito do preço pelo executado –, no plano do direito substancial a vantagem consiste na circunstância de o obrigado liberar-se dos riscos (art. 337 do CC), procedendo-se da mesma forma: ou o exequente realiza a sua prestação, *ipso facto* extinguindo a execução; ou não o faz e, respectivamente, impede-se o levantamento do preço (art. 787, parágrafo único, do CPC/2015).

5.4. Ônus de exibição do demonstrativo do débito – Deixou-se para o fecho desse item o ônus instituído em segundo lugar do art. 798, I, *b*, em razão do seu relevo: a exibição do demonstrativo de débito.

Fundando-se a execução em título judicial, cujo valor seja apurado mediante simples operações aritméticas, o credor poderá promover, desde logo, a execução (art. 509, § 2.º), porque líquida a obrigação. Idêntica proposição localiza-se, quanto aos títulos extrajudiciais, no art. 786, parágrafo único. Eis o fundamento do ônus de o exequente instruir a petição inicial com o demonstrativo

atualizado do crédito até a data da propositura da pretensão a executar, almejando o exequente realizar prestação pecuniária, segundo os arts. 798, I, *b*, e 524, *caput*.

Em princípio, a exigência do art. 798, I, *b*, aplica-se às execuções de créditos pecuniários, independentemente da especialidade do procedimento ou do meio executório; porém, o STJ estimou desnecessária a planilha na inicial da execução fiscal.¹¹⁶

Desaparecida a liquidação por cálculo do contador, substituída pelo cálculo do exequente, as normas apresentam sentido unívoco, cabendo ao exequente, instruir a inicial com memória de cálculo. Toda a controvérsia sobre o *quantum debeatur*, portanto, fica reservada aos embargos (art. 917, § 1.º, III, c/c § 2.º, I) ou à impugnação (art. 525, § 1.º, V), sob a rubrica de excesso de execução.

O art. 798, parágrafo único, houve por bem reproduzir os requisitos exigidos pelo art. 28, § 2.º, da Lei 10.931/2004, quanto à cédula de crédito bancário. Desse modo, não basta o exequente instruir a petição com planilha, pois impende que o demonstrativo contenha, a par do principal na data do vencimento, os seguintes elementos expressos: (a) o índice de correção monetária adotado (inc. I); (b) a taxa de juros aplicada (inc. II); (c) os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados (inc. III); (d) a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso (inc. IV); (e) a especificação do desconto obrigatório realizado (inc. V). Ocioso frisar a importância desses elementos. A troca do índice de correção monetária, ou a aplicação do índice do mês anterior no mês posterior, provocam alterações significativas no montante da dívida.

Eventualmente, a complexidade do cálculo, apesar de não afetar a liquidez (art. 786, parágrafo único), exigirá o concurso de contabilista. Também incumbe ao exequente indicar, na rubrica dos acessórios do principal, o valor cobrado pelo contador para elaborar a planilha, tratando-se de cálculo complexo, pretendendo ressarcir-se da despesa. Nada obstante, a Corte Especial do STJ considerou tal despesa desnecessária e, por conseguinte, insuscetível de ressarcimento na execução.¹¹⁷ O entendimento mostra-se assaz discutível, porque não integra os deveres próprios ao ofício do advogado do exequente realizar cálculos, nem se pode presumir o domínio do conhecimento técnico exigido para tais misteres pelo próprio credor, mas firmou-se essa errônea tese na jurisprudência do STJ.¹¹⁸

A falta de apresentação da planilha, demonstrativo ou memória de cálculo, porque documento necessário (art. 320) à instrução da inicial, provocará a incidência do art. 801, hipótese em que o juiz ordenará a emenda da inicial. Em visão mais liberal, decidiu o STJ que a falta da planilha “não é causa de nulidade do processo de execução, que pode prosseguir pelo débito expresso no título”,¹¹⁹ subentendendo-se, então, limitação do pedido mediato. Seja como for, não pode o órgão judiciário extinguir a execução.¹²⁰ Como esclareceu outro julgado do STJ, feita a correção na pendência dos embargos, admite-se o respectivo aditamento.¹²¹ Tampouco há necessidade de documento anexo. Em casos mais simples, o próprio corpo da petição inicial ou do requerimento explicitará os requisitos do art. 524, I a VI, e 798, parágrafo único, aliás de teor convergente quanto aos elementos necessários ao demonstrativo hábil.

6. Requisitos especiais da petição inicial da execução – Em determinadas situações, o exequente obriga-se a formular pedidos específicos ou requerimentos para obter providências reclamadas tanto pela pretensão a executar, no caso concreto, quanto para satisfazer determinadas condições de procedibilidade (v.g., isentar-se das custas iniciais, mediante benefício da gratuidade). Não é muito rigoroso o arranjo do assunto nos arts. 798 e 799 a esse propósito. Por exemplo, o art. 798, II, *a*, exige a indicação da espécie de execução, na verdade a explicitação do meio executório e, conseqüentemente, ponto respeitante à formulação do pedido imediato. Eventuais são os requerimentos previstos no art. 799, I a XI, antevendo o exequente a natureza ou a condição jurídica do bem a ser objeto da futura constrição, ou porque predestinados à futura execução (v.g., o bem gravado por direito real de garantia, a teor do art. 799, I, c/c art. 835, § 3.º) ou porque objeto de gravame de outra natureza. Flagrantemente, esses requerimentos atrelam-se, em alguma medida, aos bens indicados na petição inicial ou no requerimento como passíveis de penhora, facultado ao exequente nos termos do art. 798, II, *c*, e, no cumprimento da sentença, do art. 524, VII. Por sinal, ainda mais estranha é a localização dessa última regra, meio perdida no

contexto do art. 524, atinente aos requisitos do demonstrativo do débito (liquidação por cálculo do credor).

A análise desses requisitos especiais envolve, no atinente à petição inicial da execução, a indicação da espécie de execução (art. 798, II, *a*); eventual requerimento de citação do executado por meio técnico específico; a indicação pelo exequente de bens passíveis de penhora (art. 798, II, *c*);

6.1. Indicação da espécie de execução – O art. 798, II, *a*, manda ao credor explicitar a “espécie” de execução que prefere, se ela por mais de um modo puder ser efetuada. O sentido da norma parece obscuro, mas resolve o problema da cumulação de meios executórios para realizar prestações que dispõem de vários mecanismos.

A “espécie” alude ao meio executório. Por sua vez, o exequente expressa o meio executório hábil para conseguir o bem da vida no pedido imediato.

Em primeiro lugar, o campo de aplicação do art. 798, II, *a*, cinge-se a aspecto específico da execução das obrigações de fazer. Não basta o título judicial obrigar o devedor a levantar o muro e a esculpir a pedra: é preciso, ainda, estipular como, onde e quando fazer. Ora, na execução fundada em título extrajudicial, o art. 815 prevê resolução do juiz sobre o “quando”, mas o “onde” e, principalmente, o “como” não se encontram explicitados. Presume-se remissão ao título. Pois bem: raras vezes o título contém tais pormenores e, ademais, o *facere* se move “em limites muitas vezes insuscetíveis de completa determinação no título”.¹²²

Essa característica de relativa indeterminabilidade da obrigação de fazer, que não lhe descaracteriza a liquidez. É o que se infere do art. 798, II, *a*. Ajuizando a inicial, seja qual for o meio executório escolhido, cumpre ao credor indicar suficientemente o “onde” e o “como” do cumprimento satisfatório da obrigação, a fim de que, no prazo assinado pelo art. 815, o executado cumpra a obrigação satisfatoriamente.

Não é muito diferente o caso do título judicial. Segundo o art. 536, o órgão judiciário, *ex officio* (força mandamental ou executiva) ou a requerimento do exequente (força condenatória), determinará as medidas necessárias à satisfação do exequente, a fim de obter a tutela específica ou resultado prático equivalente. Por exemplo, condenado o vencido não realizar emissões poluentes, ao órgão judiciário cabe interditar o uso de determinados equipamentos ou ordenar sua alteração, de modo a impedir tais emissões. O art. 536, § 1.º, contempla quaisquer medidas tendentes a obter esse resultado.

Fundamentalmente, o art. 798, II, *a*, impõe ao exequente a necessidade de optar por um dos meios executórios cabíveis para realizar determinada obrigação. É o caso da prestação alimentar, que dispõe de três mecanismos concorrentes: o desconto (art. 912), a coerção pessoal (art. 911) e a expropriação (art. 913). Em tal situação se encontra, a prestação para entrega de coisa, pois concorrem o emprego da *astreinte* (art. 806, § 1.º) e o desapossamento (art. 806, § 2.º), quiçá mecanismos empregados simultaneamente. Por óbvio, a conjugação de dois meios executórios, *in simultaneo processu*, afigura-se admissível em termos. Portanto, constitui ônus do exequente indicar aquele que prefere para executar a prestação, existindo mais de um.

Claro está que ao juiz compete controlar as especificações da inicial, haja vista os amplos poderes de modelagem, atribuídos a ele no controle do ato executivo, e eventuais condições legais. Em determinados casos, a opção do exequente é condicionada ao preenchimento de requisitos: (*a*) a coerção pessoal é inadmissível em relação às prestações vencidas anteriormente às três últimas (art. 911, parágrafo único, *c/c* art. 528, § 7.º); (*b*) o desconto pressupõe fonte pagadora (art. 912); e assim por diante.

6.2. Requerimento de citação do executado – Desenvolvendo-se o processo por iniciativa oficial (art. 2.º), após o ato postulatório inicial do exequente, inexistente a necessidade de requerer a citação do executado na petição inicial. Esse requisito não se localiza no art. 319.

Nada obstante a inexistência desse ônus gravando o exequente, salvo quando requerer determinada modalidade (v.g., a preterição da citação pelos correios, a teor do art. 247, V), na execução de título extrajudicial a convocação do executado a juízo é indispensável à validade dos atos subsequentes, nos termos do art. 238, com o fito de integrar a relação processual. Esse dispositivo menciona, *expressis verbis*, a figura do executado e, surpreendentemente, a natureza jurídica do processo: relação processual. Pode-se dizer, então, firme o entendimento de que o processo constitui relação jurídica entre o Estado e as partes.

No cumprimento da sentença, há necessidade de citação inicial formando-se processo autônomo, nos casos do art. 515, § 1.º, aí incluída, por analogia, a decisão homologatória da autocomposição extrajudicial (art. 515, III). Fundando-se a execução na decisão prevista no art. 515, I, não há citação, mas intimação para o executado cumprir o julgado, nos termos do art. 513, § 2.º, respeitadas as variantes quanto ao destinatário e o meio técnico empregado para esse efeito.

Os meios técnicos da citação encontram-se arrolados no art. 246. Aplica-se, naturalmente, e *in totum*, a disciplina da citação constante na Parte Geral do CPC/2015. Dos modos de citação, são admissíveis no processo executivo, a citação por oficial de justiça, a citação pelo correio, a citação por edital e citação por meio eletrônico. A citação por edital e a citação por oficial de justiça desconhecem objeções no âmbito da execução, preenchidos os respectivos pressupostos, e da menção ao mandado de citação e ao oficial de justiça subentende-se que este é o meio preferencial, senão o único admissível em determinados casos (v.g., art. 829, § 1.º). Porém, nada impede a citação eletrônica, nos termos do art. 246, § 1.º, em lugar da citação por oficial de justiça; por sinal, no processo integralmente eletrônico realizar-se-á a citação por esse meio, razão bastante para também admiti-la no processo físico.

Ocorrendo expedição de mandado de citação, a citação por hora certa, *ex vi* do art. 253, somente se dará na hipótese de o oficial, havendo suspeita de ocultação, deixar de localizar bens penhoráveis, porque, isto se verificando, deverá apreendê-los, na forma do art. 830. Admissível que seja a citação por hora certa no processo executivo, conforme decidiu outro julgado do STJ,¹²³ seguindo a orientação da doutrina,¹²⁴ e mencionada na Súmula do STJ, 196,¹²⁵ mostra-se indispensável o oficial de justiça consignar o horário em que realizou as diligências e, ademais, o escrivão remeter a comunicação do art. 254, sob pena de nulidade. Essa modalidade é prevista, havendo suspeita de ocultação, na pré-penhora (art. 830, § 1.º). Encontrava-se implícita, no verbete indicado da súmula do STJ, a possibilidade de citação por hora certa.¹²⁶

E, quanto à citação por edital, eventualmente indispensável quando se desconhecer o domicílio do executado, porque encontra-se em lugar ignorado, cumpre assinalar que, na execução fiscal, o seu emprego fica condicionado à frustração da citação postal e da citação por oficial de justiça.¹²⁷

Logo após a vigência do CPC de 1973 surgiram dúvidas quanto à admissibilidade da citação pelo correio, inovação do diploma – antes já a previra o CPC de Minas Gerais –, sob o argumento de que o executado podia cumprir no ato do chamamento e as mãos do carteiro se revelariam inidôneas ou despreparadas para semelhantes misteres.¹²⁸ Naquela oportunidade, opinião intermediária alvitrava o cabimento limitado dessa espécie de citação, excluindo-a sempre que, a par do chamamento, o mandado contivesse providências outras (v.g., a possibilidade de pagamento).¹²⁹ Ficava a citação limitada, pois, à coerção pessoal, à coerção patrimonial e à transformação.

Essas limitações à admissibilidade, e preconceitos contra essa modalidade de citação, ficaram superadas à luz do art. 8.º, I, da Lei 6.830/1980. Segundo o dispositivo, na execução do crédito da Fazenda Pública a citação do correio se tornou prioritária. Todos os modos do art. 246, conseqüentemente, são admissíveis no processo executivo, ressalvados os casos gerais de admissibilidade da citação pelos correios (art. 247). Avulta que esse dispositivo eliminou a restrição à citação pelos correios “nos processos de execução”, constante no direito anterior.

O art. 222, letra *d*, do CPC/1973, excluía “nos processos de execução” a citação pelo correio, rendendo-se ao preconceito. Tal norma, ante seu caráter geral, aplicava-se a todas as execuções, exceto a fiscal (art. 8.º, I, da Lei 6.830/1980). É diferente o sistema do CPC/2015, felizmente.

Lícito ao exequente possível requerer diligências a fim de localizar o executado se a própria parte, no âmbito da autonomia privada, não puder obter a informação ou lograr insucesso, a teor do art. 319, § 1.º.¹³⁰

Figurando vários devedores no polo passivo da demanda, todos hão de ser citados, não se justificando a dispensa do chamamento quanto a qualquer deles, e a execução prosseguirá quanto aos já citados.¹³¹

6.3. Indicação dos bens penhoráveis – De costume haurido do direito comum a versão originária do CPC/1973 assegurava ao executado a faculdade de nomear bens à penhora, ensejando incidente específico resolvido pelo órgão judiciário. Desapareceu semelhante faculdade nas ulteriores reformas processuais. O art. 829, § 2.º, adotou meio termo: a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, objeto do art. 798, II, c, na execução de título executivo extrajudicial, “salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante a demonstração que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”. Essa última parte harmoniza-se com o art. 805, mas não deixa de reintroduzir a nomeação do executado e sem o contraditório do exequente.

Como quer que seja, o art. 798, II, c, autoriza, no processo de execução, e o art. 524, VII, no cumprimento da sentença definitivo ou provisório, sempre que possível, o exequente indicar bens para a futura constrição. A cláusula “sempre que possível” funda-se no prévio conhecimento pelo exequente do patrimônio do executado. É uma faculdade do credor e, no terreno prático, dependerá das informações acerca da situação patrimonial do devedor e dos dados constantes dos registros públicos. Não é aleatória a indicação, mas jungida à ordem do art. 835, todavia preferencial. Em primeiro lugar, no catálogo do art. 835, situa-se o dinheiro, “em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” (inc. I). Ora, raros se mostrarão os casos (p. ex., na execução de alimentos – o ex-cônjuge sabe quase tudo...) em que o exequente disporá de dados precisos acerca da situação financeira do executado, acobertados pelo sigilo bancário e fiscal. Para tal arte, o art. 854 regulou a investigação dos ativos financeiros, na verdade autêntica quebra do sigilo bancário por ordem judicial.

A indicação pode ocorrer posteriormente à propositura, mediante petição dirigida ao juízo da execução, ou de modo verbal, diretamente ao oficial de justiça.

6.4. Requerimento de investigação de ativos financeiros – Ao exequente incumbirá, desconhecendo dados precisos acerca dos ativos financeiros do executado, como em geral acontece, e mirando a execução em natura (ou específica) do crédito pecuniário, requerer a providência do art. 854. O êxito da execução dependerá, em grande parte, do conhecimento do patrimônio do executado, sem o qual a expropriação não atingirá seu objetivo.¹³² Por isso, o art. 854 oficializou medida introduzida pela prática, fundada em convênio com a autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.¹³³

É expresso o art. 854, *caput*, ao exigir a iniciativa da parte. Não cabe, portanto, ao juiz ordenar a medida *ex officio*.¹³⁴ Formulado o pedido, o juiz não pode, em princípio, condicioná-lo à inexistência de outros bens penhoráveis,¹³⁵ haja vista a natural preferência do dinheiro (art. 835, I).¹³⁶ Firmou-se a jurisprudência do STJ nesse sentido, relativamente às execuções iniciadas após a vigência da regra equivalente no ao art. 854 no direito anterior.¹³⁷

No entanto, impõe-se alguma cautela no uso dessa medida. O bloqueio talvez subtraia os meios de subsistência da pessoa natural ou, no cenário ainda mais desvantajoso, perturbe ou paralise a atividade normal da empresa. O ideal é colher as informações e, somente após, ordenar o bloqueio parcial das contas bancárias e investimentos. Parece ser a medida adequada à realização dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, exigidos neste ponto delicado.¹³⁸

Ao propósito, convém recordar as agruras do Barão de Mauá, cujo banco de credor passou a devedor, em decorrência de julgamento errôneo, e a penhora de dinheiro em caixa acabou por levar a empresa à falência.¹³⁹

E, conforme percebeu-se com clareza,¹⁴⁰ não é fácil, nem sequer expedito o movimento oposto, visando ao desbloqueio dos ativos financeiros. O art. 854, § 1.º, conjura o problema, fixando o prazo de vinte quatro horas para a autoridade supervisora do sistema financeiro nacional desbloquear o ativo financeiro, por ordem do juiz. Resta aguardar agilidade no cumprimento do ato.

Deferido o pedido baseado no art. 854, o juiz requisitará a indisponibilidade à autoridade supervisora do sistema financeiro nacional. Desse ato não se dará conhecimento ao executado, evitando a frustração da medida, e deverá ser por meio eletrônico (art. 854, § 7.º), mediante o sistema franqueado às autoridades judiciárias, ou por ofício, e, na mesma oportunidade, decretará a indisponibilidade do dinheiro “até o valor indicado na execução”. Trata-se de medida que antecipa a eficácia da penhora.

Para evitar o caráter de devassa ampla e geral na vida do executado, e afastar suspeitas de inconstitucionalidade – o caso é de “quebra” do sigilo bancário, apesar da relutância em admiti-lo com franqueza –,¹⁴¹ fica subentendido que a constrição se limitará ao ativo financeiro em nome do executado. Idêntica finalidade tem o art. 854, § 9.º, limitando a requisição das informações tão só do órgão partidário (municipal, estadual ou nacional) responsável pela dívida em execução, nos termos do art. 15-A da Lei 9.096/1995.

Feita a constrição, chamada de indisponibilidade no art. 854, ato contínuo será o executado intimado na pessoa do seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2.º), incumbindo-lhe, nos termos do art. 854, § 3.º, no prazo de cinco dias, ministrar prova: (a) da impenhorabilidade do ativo financeiro (inc. I); (b) excesso de constrição (inc. II). Se o órgão judicial acolher essas alegações, determinará, *incontinenti*, o cancelamento da indisponibilidade, no todo ou em parte, devendo a ordem ser cumprida pela instituição financeira em vinte e quatro horas (art. 854, § 4.º). Rejeitada a impugnação do executado, será a indisponibilidade controvertida em penhora e o juiz determinará a transferência, em vinte e quatro horas, para conta vinculada ao juízo (art. 854, § 5.º). Realizado o pagamento, e, *a fortiori*, substituída a penhora por outro bem, o juiz ordenará o cancelamento da indisponibilidade ou da penhora, liberando o dinheiro em vinte e quatro horas (art. 854, § 6.º). E, por fim, o art. 854, § 8.º, responsabiliza a instituição financeira pelos danos no caso de indisponibilidade de valores superiores ao crédito em execução ou por não cumprir os prazos determinados para cancelamento em vinte e quatro horas. Faltou explicitar o essencial: a responsabilidade pela constrição de dinheiro impenhorável, ou seja, da retribuição pecuniária da pessoa natural (art. 833, IV). Responderá o exequente, aplicando-se o art. 766, por analogia, vez que requereu constrição ilegal.

Figurando empresa no polo passivo da execução, a penhora recairá sobre percentual do faturamento, implicando a nomeação de depositário (art. 866, § 2.º). É importante realçar que a noção de faturamento se encontrava prevista no revogado art. 3.º, § 1.º, da Lei 9.718/1998, abrangendo “a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas”.¹⁴² Não desapareceu, porém, o princípio subentendido na regra, relacionando o faturamento à totalidade da receita da empresa (receita “bruta”). O executado submeterá ao juiz o percentual passível de constrição, sem comprometer a existência da empresa, e prestará contas das quantias recebidas, mensalmente, “a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida”.

O art. 834 não previu, explicitamente, a possibilidade de a investigação revelar-se infrutífera ou de a autoridade competente, por alguma razão, deixar de fornecer as informações requisitadas, e, *a fortiori*, bloquear as quantias disponíveis. Em outros sistemas, como o francês, fixa-se o prazo de três meses, após o qual o exequente extrairá todas as consequências concebíveis da omissão.¹⁴³ Entre nós, para a primeira hipótese, e vencido prazo razoável para a medida administrativa, a inexistência de bens implicará a suspensão da execução, a teor do art. 921, III. Nos casos de falha imputável à autoridade competente, ou de manifesta negligência, o juiz tomará as providências cabíveis perante o respectivo superior hierárquico, sem prejuízo de eventual remessa de cópias ao Ministério Público.

Não pode o órgão judiciário deixar de aplicar o art. 854, porque não se cadastrou no sistema. É

dever do seu ofício. Logo, se parece excessivo o afastamento imediato do magistrado,¹⁴⁴ no mínimo ficará exposto ao procedimento administrativo cabível.

É verdade que a constrição *on line* enfrenta algumas resistências, devidamente recenseadas,¹⁴⁵ e oferece enormes riscos de transformar-se em mecanismo de asfixia financeira. A condição de instrumento poderoso se presta a abusos, servindo, em alguns casos, a retirar quantias elevadas de empresas solventes, realizando créditos duvidosos. No entanto, parece impróprio traçar um cenário desvantajoso baseado em casos anômalos. Infelizmente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já afastou alguns magistrados em razão de atos reprováveis dessa natureza. Eles constituem exceção no conjunto da qualificada e proba magistratura brasileira. E há formas de controle hábeis para coibir deslizes, equívocos e até a má-fé, justamente porque os órgãos judiciais guardam respeito à lei e à ética. Assim, o art. 854 é bem-vindo, aprimorou a disciplina do assunto, e deve ser utilizado com o comedimento próprio do magistrado profissional.

6.5. Requerimento do benefício da gratuidade – O exequente requererá na petição inicial ou no requerimento, se for esse o caso, a concessão do benefício da gratuidade, pois essa é a primeira oportunidade (art. 99, § 1.º). Cumpre distinguir entre as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. A pessoa natural basta alegar a inexistência de recursos, sem prejuízo da própria subsistência, para arcar com a antecipação das despesas do processo, presumindo-se verdadeira a alegação, a teor do art. 99, § 1.º, mas o juiz poderá indeferir o benefício com base em presunção judicial (art. 99, § 2.º), a exemplo do caso do profissional liberal de êxito notório em sua atividade, hipótese em que caber-lhe-á provar o contrário. O benefício é personalíssimo (art. 99, § 6.º), não se estendendo a terceiros ou aos sucessores do beneficiário, salvo requerimento e decisão expressa. Apesar de o art. 105, *caput*, prever a necessidade de poderes especiais para o advogado firmar declaração de hipossuficiência, inexistente a necessidade de documento anexo para essa finalidade.

Já as pessoas jurídicas necessitarão de prova hábil da situação conjuntural que lhes impossibilite antecipar as despesas do processo de execução ou do cumprimento da sentença, nesse último caso se o benefício não lhe tiver sido concedido anteriormente.

O objeto da gratuidade encontra-se previsto no art. 98, I a IX, frisando-se essa última hipótese, relativa aos emolumentos da averbação de constrições, e pode ser parcial (art. 98, § 5.º), limitada a ato ou atos específicos, ou parcelada a despesa, a teor do art. 98, § 6.º.

7. Requisitos formais da petição inicial na execução – A petição inicial constitui ato postulatório a cargo do exequente e, naturalmente, subordina-se aos requisitos gerais dos atos processuais. São vários aspectos envolvidos.

7.1. Forma da petição inicial na execução – A petição inicial é endereçada ao juízo competente em peça única e escrita, no mínimo em duas laudas, numeradas ou não, e impressas mecanicamente no caso do processo físico. Será obrigatoriamente redigida na língua portuguesa. Os trechos redigidos em língua estrangeira, concebíveis no caso de a pretensão a executar fundar-se em título estrangeiro (art. 784, § 2.º), não de ser traduzidos, bem como as expressões latinas, todavia toleradas por força da tradição e sua irrelevância no contexto. Não há, nem pode haver, limitações ao conteúdo e à sua extensão. Fatores vários, começando pelo estilo do redator e as facilidades dos processadores de texto, contribuem nesse último particular, mas seria inútil, senão abertamente inconstitucional, mandar o exequente reduzir a petição inicial ao essencial. Em tema de execução, por sinal, a brevidade é natural, pois a narrativa da causa de pedir simplifica-se à luz do título executivo, duvidando-se da necessidade de maiores exposições.

Em caso da expedição da petição por fax, deverá acompanhá-las os anexos, relativos aos documentos indispensáveis, e grava o exequente o ônus de exibir o original no prazo do art. 2.º da Lei 9.800/1999. Esse meio exige muito comedimento, pois há falhas intermitentes na transmissão, obrigando o exequente a provar a falha do serviço.

7.2. Datação da petição inicial na execução – A petição inicial e, *a fortiori*, o requerimento do art. 513, § 1.º, não de ser datados antes da autenticação. Acontecem equívocos nessa informação, porém constituem simples irregularidade sem relevância: a inserção da peça nos autos (execução

de título judicial) ou o protocolo no ofício judicial (art. 312), formando-se novo processo, indicam a data relevante. Seja como for, o erro ou a omissão da data constituem simples irregularidades. Descumprimento de requisito útil do ato processual dispensa suprimimento ou correção. Existindo mais de um exequente, e havendo procuradores diferentes, impõe-se a subscrição por ao menos um dos advogados constituídos.

7.3. Autenticação da petição inicial na execução – Ao contrário da data, a autenticação da peça é requisito necessário à validade do ato processual. A petição inicial (ou o requerimento do art. 513, § 1.º) é ato privativo do advogado inscrito no quadro próprio do órgão de classe.

É comum assinalar o lugar, reservando-se espaço próprio para a assinatura e a indicação do número de inscrição do advogado na OAB, necessitando-se correspondência entre o subscritor e quem figura na procuração. Admite-se a assinatura de próprio punho ou eletrônica no fecho da petição. E faculta-se a rubrica das demais páginas (art. 207, parágrafo único). Porém, a assinatura há de ser inteligível, porque rabiscos e garatujas não se prestam a autenticar a peça.

Implausível que seja, admite-se a alegação de falsidade da subscrição. Tal acontecendo, e acolhida a alegação, a consequência consiste no suprimimento do defeito pelo procurador constituído.

Faltando autenticação, por lapso, cumpre ao juiz abrir o quindênio do art. 801 para a correção do defeito. Em determinadas condições, porque a petição inicial consta de papel timbrado do advogado ou do escritório de advocacia, releva-se o vício, não se desconhecendo casos de processos que tramitam até estágio avançado sem a subscrição da petição inicial.

7.4. Indicação do endereço do advogado na petição inicial da execução – O art. 77, V, exige a indicação do endereço físico, profissional ou residencial, da parte e do advogado, bem como o eletrônico, eventualmente constantes da procuração (art. 287, *caput*), inclusive no caso de postulação em casa própria (art. 106, I), hipótese comum na execução em nome próprio do capítulo acessório da sucumbência (art. 85, *caput*). Esse ônus grava os advogados privados e públicos, o Defensor Público e o agente do Ministério Público, pois o objetivo é facilitar a intimação postal ou eletrônica (art. 274, parágrafo único).

Eventual omissão desses dados ensejará a incidência do art. 801.

7.5. Produção dos documentos indispensáveis na petição inicial da execução – Do ônus instituído no art. 798, I, resulta que ao exequente incumbe produzir com a petição inicial e, eventualmente, com o requerimento, nos casos do art. 513, § 1.º, o título executivo, o demonstrativo atualizado do débito, a prova do vencimento do termo ou da ocorrência da condição e a prova, nas obrigações bilaterais, da prestação ao seu cargo.

Porém, o rol não é completo. Cumpre ao exequente instruir a petição inicial da execução com a procuração, e a prova da regularidade da representação legal da parte (v.g., investidura da pessoa natural no órgão de apresentação da pessoa jurídica). Também aqui a omissão ensejará a incidência do art. 801, abrindo-se prazo de quinze dias para emendar a petição inicial.

7.6. Duplicação da petição inicial na execução – O exequente não entregará a petição inicial em via única. Compete ao exequente produzir tantas vias quantas forem os citandos. Essas cópias acompanharão o mandado de citação (art. 250, V) e a carta de citação (art. 248, *caput*). Chamam-se essas cópias de duplicados legais no direito português.¹⁴⁶

Descumprido esse ônus, geralmente desconhecido pelo juiz, pois as cópias não integram os autos principais, na oportunidade da emissão do provimento liminar, a consequência é simples: o processo não vai adiante, apesar de deferida a petição inicial. O escrivão intimará o advogado do exequente, independentemente de despacho (art. 203, § 4.º), para que providencie as cópias. Se o exequente for beneficiário da gratuidade, as cópias serão tiradas pelo setor competente do foro e seu custo debitado ao Poder Judiciário.

Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:

I – requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados com penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária;

II – requerer a intimação do titular do usufruto, uso ou habitação, quando a penhora recair sobre bem gravado por usufruto, uso ou habitação;

III – requerer a intimação do promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada;

IV – requerer a intimação do promitente vendedor, quando a penhora recair sobre o direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada;

V – requerer a intimação do superficiário, enfiteuta ou concessionário, em caso de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre imóvel submetido ao regime do direito de superfície, enfiteuse ou concessão;

VI – requerer a intimação do proprietário de terreno com regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre direitos do superficiário, do enfiteuta ou do concessionário;

VII – requerer a intimação da sociedade, no caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, para o fim previsto no art. 876, § 7.º;

VIII – pleitear, se for o caso, medidas urgentes;

IX – proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros.

X – requerer a intimação do titular da construção-base, bem como, se for o caso, do titular de lajes anteriores, quando a penhora recair sobre o direito real de laje;

XI – requerer a intimação do titular das lajes, quando a penhora recair sobre a construção-base.

1. Intimação de terceiro titular de direito real – O art. 799, I a XI, prevê a intimação de terceiros, titulares de direito real sobre o bem penhorado, conforme o objeto da penhora. São terceiros, em sentido técnico, porque (a) não figuram como partes na execução, e (b) não tem responsabilidade patrimonial no cumprimento do débito exequendo. Porém, eventual direito que lhes assista, em decorrência da penhora ou da ulterior alienação coativa do bem penhora, ficaria prejudicado. É emblemático o caso do direito real de garantia (art. 799, I). Respeitadas as condições fixadas na lei material para a penhora do bem gravado por outro exequente, assunto analisado nos comentários ao art. 797, receberá antecipadamente seu crédito, participando do concurso especial de credores; porém, preterida a intimação prevista no art. 799, I, e a do art. 889, V, caso não haja intervenção anterior, poderá reagir contra a alienação por meio de embargos de terceiro (art. 674, § 2.º, IV). Por conseguinte, as intimações do art. 799, I a XI, permitem ao terceiro exercer o direito porventura atribuído no direito substancial, a exemplo do direito de preferência assegurado aos sócios no caso de penhora de quota social ou de ação de companhia de capital fechado no art. 876, § 7.º, razão por que obrigatória a intimação da pessoa jurídica (art. 799, VII).

O extenso catálogo do art. 799, I a XI, repercute disposições de leis extravagantes. Por exemplo, o art. 18, § 8.º, da Lei 10.931/2004 exige que o credor da cédula de crédito imobiliário “deverá ser imediatamente intimado de constrição judicial que recai sobre a garantia real do crédito imobiliário”.

O art. 799, I a XI, institui ônus ao exequente, cumprindo-lhe tomar iniciativa a seu respeito, uma vez configurada a hipótese legal, velando pela validade das atividades executivas. Como sói ocorrer nos ônus processuais, o exequente sofrerá as consequências da preterição da formalidade (v.g., tornar-se-á real nos embargos de terceiro opostos pelo titular de gravame real, na forma do art. 674, § 2.º, IV).

2. Momento e forma da intimação do terceiro titular do direito real – É natural que o exequente, antevendo a ausência de bens livres e desonerados, ou indicando bem objeto de direito real previsto no art. 799, I a XI, na petição inicial (art. 798, II, c), requeira a intimação do terceiro, desde logo. Essa circunstância justifica a localização do art. 799 em seguida à disposição concernente aos requisitos da petição inicial na execução.

Porém, a oportunidade de requerer a intimação do terceiro não se cinge absolutamente à petição inicial. Pode acontecer de a penhora recair sobre bem gravado ou de o exequente só tomar conhecimento do direito do terceiro mediante a exibição da prova hábil – esta, a cargo do executado, conforme o art. 774, IV. Logo que tomar ciência do direito do terceiro, providenciará na respectiva intimação.

O art. 799 não ministra pormenores quanto à identificação e localização do terceiro, nem sequer menciona a forma desse ato. Visão sistemática recomenda a aplicação do art. 899, I, *in fine*, intimando-se o terceiro, naturalmente sem representação técnica no processo, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo (v.g., intimação por via eletrônica). Avulta, no caso das empresas públicas e privadas, a preferência do meio eletrônico (art. 246, § 1.º), encontrando-se o endereço eletrônico previamente cadastrado. Por outro lado, a localização do endereço físico ou eletrônico do terceiro subordina-se à iniciativa do exequente, à luz da prova hábil da preexistência do direito de terceiro. Em casos extremos, invocará o art. 319, § 1.º, por analogia, reclamando providências do órgão judiciário (v.g., ofício à Receita Federal).

3. Terceiros destinatários da intimação – O art. 799 arrola as seguintes pessoas como destinatárias da intimação por um dos meios legalmente admissíveis, a saber: (a) o titular de direito real de garantia, ou seja, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário (inc. I); (b) o titular de direito de usufruto, de uso ou de habitação (inc. II); (c) o promitente comprador, havendo promessa de compra e venda registrada (inc. III); (d) o promitente vendedor, recaindo a penhora sobre os direitos de promessa de compra e venda registrada (inc. IV); (e) o superficiário, o enfiteuta, o concessionário, em caso de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para moradia e concessão de uso, quando a penhora recair sobre imóvel gravado (inc. V); (f) o proprietário de terreno com regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para moradia e concessão de uso, recaindo a penhora sobre imóvel gravado com tais direitos (inc. VI); (g) a sociedade, recaindo a penhora sobre quota social ou ação de sociedade anônima de capital fechado (inc. VII); ; (h) o titular da construção-base, bem como os titulares das lajes anteriores, recaindo a penhora sobre o direito real de laje (inc. X); (i) requerer a intimação dos titulares das lajes, quando a penhora recair sobre a construção-base (inc. XI).

O rol não é completo. O art. 889, I, alude, ainda, ao coproprietário do bem indivisível e o art. 889, V, ao credor comum que averbou constrição. Este último não é titular de direito real, segundo a interpretação prevalecente da preferência conferida pela penhora (art. 797, *caput*), mas tem direito de participar do concurso especial de credores. É necessário requerer na inicial, ademais, a intimação do terceiro e dono do bem gravado com direito real de garantia a favor do exequente, a teor do art. 835, § 3.º, segunda parte. Como já assinalado, a falta dessas intimações torna ineficaz a alienação do bem gravado (art. 804) e, no caso do credor penhorante, ineficaz a distribuição do produto da arrematação no concurso especial de credores (art. 908). Realizadas tais intimações, na abertura do processo, inexistente necessidade de outra intimação, antes da adjudicação ou da alienação do bem penhorado. O terceiro assumirá o ônus de participar do certame e, se for o caso, do concurso especial de credores.

O art. 799 atualizou o catálogo dos destinatários da intimação, porque titulares de direito real, ou de direitos obrigacionais, mas o direito desses terceiros é heterogêneo. Ademais, o art. 791 prevê a forma da penhora e delimita a responsabilidade patrimonial de cada titular do direito real parciário nos casos de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia e à concessão de direito real de uso. Eram conhecidas as situações do titular de direito real de garantia (hipoteca, penhor e anticrese) e do titular do usufruto. A atualização reclama explicações adicionais, portanto, relativamente aos direitos reais anteriormente negligenciados.

3.1. Intimação do titular do direito real de garantia e do credor fiduciário – Ao ensejo de

comentar o art. 797, parágrafo único, e a obrigatória participação do titular de direito de garantia no concurso especial de credores, porque a alienação forçada transmitirá o bem purgado do gravame ao adquirente, já se assinalou os dois aspectos pertinentes: (a) as condições em que se afigura lícito ao credor quirografário penhorar o bem gravado (inexistência de outros bens livres e desembaraçados do devedor comum); (b) a finalidade da intimação do credor real, prevista no art. 799, I, ou a do art. 889, V, ainda não figurando como parte na execução na oportunidade da alienação: o recebimento do crédito antecipadamente. Resta realçar, outra vez, os efeitos da preterição do credor real: de um lado, como declara o art. 804, *caput*, a alienação é ineficaz, significando que o bem subsiste gravado e respondendo pela dívida; e, de outro, a possibilidade de o credor impedir a alienação, reagindo através de embargos de terceiro (art. 674, § 2.º, IV). Essa situação é bem conhecida e não há maiores dificuldades na aplicação do Código de Processo Civil de 2015.

É peculiar a condição do bem alienado fiduciariamente. Por definição, não integra o patrimônio do devedor fiduciante, mas o do credor fiduciário, razão por que é impenhorável por dívida contraída pelo devedor fiduciante. Nesse pormenor é que reside a vantagem da propriedade fiduciária. A intimação aludida no art. 799, I, há de ser do devedor fiduciante, e não do credor fiduciário, na execução contra este movida pelo exequente.

3.2. Intimação do titular do bem gravado por direito real de usufruto, de uso ou de habitação – O art. 799, II, prevê a intimação do titular do direito real de usufruto, de uso ou de habitação, recaindo a penhora sobre bens gravados com esses direitos reais limitados. O objetivo é assegurar a consolidação da propriedade, assegurando-se preferência ao titular do direito real limitado.

Não se ocupou o art. 799 da intimação do proprietário, se houver penhora do direito real limitado, porque estimou impenhoráveis esses direitos reais limitados. O assunto comporta distinções.

O direito real de uso aproveita o usuário e sua família, satisfazendo as respectivas necessidades de habitação e alimentação (art. 1.412 do CC), e o direito real de habitação assegura, *tout court*, morada ao seu titular (art. 1.414 do CC). Em ambas as hipóteses, o direito real limitado entra no campo de incidência do art. 1.º da Lei 8.009/1990 (impenhorabilidade da residência familiar).

É peculiar o caso do usufruto. Segundo o art. 1.393, 1.ª parte, do CC, “não se pode transferir o usufruto por alienação”, e bens inalienáveis são impenhoráveis. Ora, o exercício do usufruto pode ser cedido a título gratuito ou oneroso, continua o art. 1.393 do CC, e nesse caso, havendo valor econômico, penhorável é o exercício do direito.¹⁴⁷ Porém, se o usufruto oferece residência para o usufrutuário e família até esse exercício é impenhorável, por força do art. 1.º da Lei 8.009/1990.¹⁴⁸

Em tal conjuntura, prever-se a intimação do respectivo titular representaria convite indireto ao exequente para promover ato objetivamente ilegal, criando armadilha injustificável. Se houver penhora do exercício do direito pelo usufrutuário, porque repelida a finalidade residencial do usufruto, forçoso admitir a intimação do proprietário do bem gravado, porque uma das modalidades de extinção do usufruto é a consolidação da propriedade (art. 1.440, VI, do CC) e, por meio dessa intimação, o nu proprietário poderá adquirir a coisa, consolidando a propriedade, embora não haja direito de preferência.

3.3. Intimação do promitente vendedor e do promitente comprador da promessa de compra e venda registrada – Registrado o contrato preliminar de compra e venda de imóvel no álbum imobiliário, ou, como geralmente conhecido, promessa de compra e venda, o promitente comprador adquire direito real à aquisição (art. 1.417 do CC). Em virtude do registro, o imóvel destaca-se do conjunto do patrimônio do promitente vendedor, porque afetado ao destino de o domínio transferir-se, *opportuno tempore*, geralmente após o pagamento do preço, para o promitente comprador.

Nesse interregno, por dívida do promitente vendedor e do promitente comprador, respectivamente, comportam penhora (a) o crédito do promitente vendedor quanto ao preço, no

todo ou em parte, e (b) o direito real de aquisição do promitente comprador (art. 799, IV: “(...) direito real aquisitivo derivado da promessa de compra e venda registrada”), salvo se residencial o imóvel, por força do art. 1.º da Lei 8.009/1990. Embora integrando o patrimônio do promitente vendedor, por dívidas deste o imóvel não pode ser penhorado, porque o promitente comprador tem direito real oponível ao exequente. Em tal hipótese, a intimação prevista no art. 799, III, por sinal especificação do dever geral do órgão judiciário de mandar intimar terceiros, verificando a existência de interesse em embargar (art. 675, parágrafo único), permitirá ao promitente comprador reagir, por meio de embargos de terceiro, e livrar o bem da constrição. As intimações do art. 799, III e IV, também cabem no caso de promessa de cessão (art. 804, §§ 1.º e 3.º).

Não parece sensato extrair do art. 799, III, qualquer ilação no sentido de encontrar-se desamparado o promitente comprador no caso de a promessa não se encontrar registrada. Em primeiro lugar, também deverá ser intimado, em atenção ao disposto no art. 675, parágrafo único. Ademais, não é totalmente exato que, titular de direito pessoal, não lhe caiba atacar a penhora do imóvel integrante do patrimônio do promitente vendedor, embora possuidor, “como não o poderiam o comodatário, o locatário, o depositário, também possuidores e titulares de mero direito pessoal com relação à coisa penhora”, conforme entendeu o Supremo Tribunal Federal.¹⁴⁹ Essa orientação firmou-se na Súmula 621 do STF.

Ora, o promitente comprador de bem imóvel, haja ou não registrado a promessa, desde que investido na posse, legitima-se para propor a ação de embargos de terceiro. Exata se afigura a dicção da Súmula 84 do STJ, que reza: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.¹⁵⁰

Por óbvio, configurada a ressalva da cláusula final, ou seja, faltando à promessa o registro, e, genericamente, direito oponível ao credor – v.g., colusão entre o exequente e o executado (promitente vendedor); o reconhecimento pelo exequente de que o bem já não se encontrava no patrimônio do obrigado, e assim por diante –, os embargos se encontram fadados à improcedência. Este é um juízo *a posteriori*, situado no mérito da causa. Não pré-exclui a legitimidade ativa do compromissário. Em outras palavras, impõe-se distinguir a legitimidade do compromissário, consagrada na Súmula 84 do STJ, do eventual juízo de procedência dos embargos. Este último exige a análise do mérito e, *a priori*, o êxito do embargante não é fatal e automático. Aqui cabe um paralelo com a situação do locatário. Legitimado que esteja o locatário a defender sua posse, por via embargos de terceiro, em princípio (a) a constrição do bem locado não lhe afeta a posse imediata, que subsistirá incólume, e, portanto, faltar-lhe-á interesse processual em reagir contra a penhora; (b) não exhibe qualquer direito oponível ao exequente, respondendo o bem locado pelo cumprimento das dívidas do locador como qualquer outro. Eventual transmissão do bem locado, por meio de adjudicação ou de alienação, implicará a dissolução do vínculo contratual, nos termos da lei substancial, mas a penhora e a transmissão forçada do domínio do bem são válidas perante o locatário.¹⁵¹ Ora, a situação do promitente comprador não discrepa nos dois pontos essenciais. Para obter êxito nos embargos de terceiro, há de exigir direito oponível ao exequente – registro da promessa ou, v.g., prova da colusão.

3.4. Intimação do titular do terreno e de direito real limitado sobre coisa alheia – O art. 799, V, exige a intimação do proprietário do terreno e o art. 799, IV, a do titular de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para moradia e concessão de uso. Essas disposições conjugam-se com o art. 791.

O direito de superfície, previsto no art. 1.225, II, do CC, é direito real imobiliário, autônomo relativamente à propriedade, e limitado, porque outorga ao superficiário o direito de construir ou de plantar sobre o terreno urbano e rural (art. 1.369, *caput*, do CC), constituído por escritura pública registrada no álbum imobiliário. Controverte-se se é, ou não, direito real sobre coisa alheia, em razão das suas singularidades, mas esse parece ser o melhor enquadramento da figura.¹⁵² O direito de superfície é alienável por negócio entre vivos e transmissível *mortis causa* (art. 1.372 do CC). A partir da sua constituição, na forma do art. 1.369, *caput*, do CC, coexistirão dois direitos reais sobre o terreno: (a) a propriedade originária; e (b) a propriedade superficiária. O

superficiário adquire o domínio pleno da construção ou da plantação. Logo, excepciona a aquisição por acessão (*superficies solo cedit*), segundo a qual o acessório (v.g., o prédio) pertence ao titular do solo; porém, extinta a concessão, o proprietário “passa a ter a propriedade plena sobre o terreno, a construção ou plantação, independentemente de indenização”, salvo convenção em contrário (art. 1.375 do CC). É instituído por tempo determinado, cuidando-se de terreno rural, mas o art. 21 da Lei 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) permite a instituição por tempo indeterminado quanto a imóveis urbanos. E, no que aqui importa, no caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o art. 1.373 do CC assegura aos titulares desses direitos preferência na aquisição, em igualdade de condições a oferta de terceiro.

O art. 791, *caput*, delimitou a responsabilidade patrimonial do proprietário do terreno e do superficiário. Respondem, respectivamente, pelo direito real de que são titulares, recaindo “a penhora ou outros de constrição exclusivamente sobre o terreno no primeiro caso, ou sobre a construção e a plantação, no segundo caso”. Entende-se por “outros atos de constrição” a apropriação de frutos e rendimentos (art. 825, III, do CPC/2015) ou a entrega da própria acessão, no caso de transmissão (art. 1.372 do CC). Em qualquer hipótese, movida a execução contra um dos titulares do direito real, o outro será intimado da constrição (art. 799, V e VI, do CPC/2015).

Fixa o art. 791, *caput*, a diretriz aplicável à constrição dos bens gravados com direitos reais. Recairá sobre o respectivo direito (v.g., domínio direto e direito real de superfície), conforme responda o patrimônio do obrigado ou do responsável (v.g., o sócio, responsável na forma do art. 790, II, pode ser o titular do direito real de superfície).

Nada obstante essas disposições, há de se atentar para o regime da impenhorabilidade. Seguindo a interpretação do art. 1.º da Lei 8.009/1990 no emblemático caso do imóvel indivisível de dupla destinação (residencial e comercial), então o terreno é penhorável, *ipso facto* passível de alienação forçada, mas a construção edificada pelo superficiário, servindo de morada para o executado ou sua família, no amplíssimo sentido atual de família, impenhorável. As plantações são penhoráveis (art. 862, *caput*), exigindo a investidura de administrador, habilitado a zelar por seu desenvolvimento e proceder à messe.

O art. 791, § 2.º, manda aplicar o regime do art. 795, *caput*, e seu § 1.º, aos seguintes direitos reais: (a) enfiteuse; (b) concessão de uso especial para fins de moradia; e (c) direito real de uso. Cumpre distinguir esses direitos reais e determinar qual o âmbito da responsabilidade patrimonial dos respectivos titulares.

A enfiteuse (também chamada de empraçamento ou aforamento) é direito real limitado pelo qual o proprietário, designado de senhorio direto, transfere para outra pessoa, o enfiteuta ou foreiro, perpetuamente, os poderes inerentes ao domínio, mediante a obrigação de pagar uma renda anual, conhecida como foro (art. 678 do CC/1916).¹⁵³ Alienação do domínio útil, o enfiteuta obriga-se a pagar o laudêmio, um percentual sobre o preço do negócio jurídico, a título de compensação pelo não exercício do direito de preferência previsto no art. 684 do CC/1916.

O art. 2.038, *caput*, do CC em vigor proibiu a constituição de novas enfiteuses. Subsistiram as anteriores, disciplinadas no Código Civil de 1916, e, ademais, o regime dos terrenos de marinha – a variável faixa de terra medida da preamar máxima que abrigam as edificações mais valorizadas do extenso litoral brasileiro – é o da enfiteuse e, segundo o art. 2.038, § 2.º, disciplinado na legislação especial, no caso o Dec.-lei 9.760/1946 e a Lei 9.636/1998. Logo, não é ociosa a menção à enfiteuse no art. 791, § 2.º. Só convém recordar a impenhorabilidade do domínio direto nos terrenos de marinha, porque bem público dominical da União (art. 20, VII, da CF/1988).

Percebe-se nessa estrutura fundamental os bens passíveis de constrição: (a) o domínio útil pode ser penhorado, por dívida do enfiteuta; e (b) o domínio direto, bem como o direito à percepção do foro e do laudêmio, por dívida do senhorio direto. Eis o motivo da remissão do art. 791, § 2.º, ao regime de responsabilidade do direito de superfície, pois são bens diferentes, pertencendo a titulares distintos.

Recaindo a penhora sobre o domínio útil, por dívidas do enfiteuta, o art. 689 do CC de 1916

determina a “citação” do senhorio direito, para exercer seu direito de preferência, em igualdade de condições, perante os pretendentes, e, ainda no caso de adjudicação. Embora o art. 684 do CC de 1916 não se ocupe de alienações coativas, também consagra o direito de preferência do enfiteuta, “no caso de querer o senhorio direto vender o domínio direto ou dá-lo em pagamento”, mostrando-se razoável a interpretação de que a preferência do art. 689 do CC de 1916 abrange o enfiteuta.¹⁵⁴ O art. 799, V e VI, do CPC/2015, prevê a intimação do enfiteuta e do senhorio direito, respetivamente, para exercerem semelhante direito.

É bem de ver que tanto o domínio direto quanto o domínio útil podem ser objeto de outros direitos reais (v.g., a hipoteca), multiplicando as hipóteses de incidência do art. 799, *caput*, sem prejuízo das respectivas esferas de responsabilidade. A esse respeito, recorda-se o seguinte: “O objeto é sempre diferente em quaisquer desses negócios jurídicos, em quaisquer desses direitos reais limitados”.¹⁵⁵

Regulado pela MP 2.220, de 04.09.2001, a concessão de uso especial para moradia é o direito real limitado, passível de registro após decisão administrativa ou sentença judicial (art. 6.º, § 4.º, da MP 2.220/2001), que recai sobre imóveis da União e dos Estados-membros, concedidos para o homem ou a mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil (art. 1.º, § 1.º, da MP 2.220/2001), e tem por objeto terrenos urbanos de até duzentos e cinquenta metros quadrados, possuídos até 30.06.2001 como próprio, ininterruptamente e sem oposição (art. 1.º, *caput*, da MP 2.220/2001).¹⁵⁶ Terrenos de extensão superior a duzentos e cinquenta metros quadrados, ocupados por pessoas de baixa renda para sua moradia, nas mesmas condições, podem ser concedidos de forma coletiva (art. 2.º da MP 2.220/2001). Imóveis de até duzentos e cinquenta metros quadrados, na área urbana, mas utilizados para fins comerciais, são objeto de permissão de uso (art. 9.º da MP 2.220/2001).

É pouco compreensível, quando à concessão de uso especial, a remissão do art. 791, § 2.º, e, *a fortiori*, a previsão de intimação concessionário no art. 799, V, porque domínio direto é da União ou do Estado-membro. E bens públicos, incluindo os dominicais, não comportam penhora. De outro lado, a construção, seja a concessão individual ou coletiva, é impenhorável, porque serve para moradia do executado ou de sua família (art. 1.º da Lei 8.009/1990). Parece mais concebível a penhora do direito do concessionário de uso, titular de direito real resolúvel, para fins que não sejam o de moradia da entidade familiar (art. 7.º do Dec.-lei 271, de 28 de fevereiro de 1967, na redação da Lei 11.481/2007), a exemplo de acessão industrial e plantações. Nem sequer a autorização de uso para fins comerciais, de resto não mencionada no art. 791, § 2.º, outorga ao permissionário qualquer direito transmissível forçadamente a terceiro, porque ato administrativo de natureza precária e revogável a qualquer tempo, sem direito de indenização ao permissionário.¹⁵⁷

O direito real de uso (art. 1.412 do CC) suscita idêntico problema. É um direito real limitado, formado no âmbito da autonomia da vontade, por contrato ou testamento, autorizando o titular a usar a coisa para fins residenciais, percebendo seus frutos, na medida das necessidades próprias e familiares. O uso residencial pré-exclui a penhora do direito do usuário, mas permite a constrição do domínio direto do proprietário. É o regime, por igual, do direito real de habitação (art. 1.414 do CC), olvidado no art. 791, § 2.º, mas mencionado no art. 799, II, indicando a penhorabilidade do domínio direto e a necessidade de intimar o titular do direito real.

Em caso de constrição de bem gravado por direito real superfície, quer por dívida do titular da propriedade, quer por dívida do superficiário, do enfiteuta, do concessionário e do usuário (art. 791, § 2.º), bem como no caso de outros direitos reais limitados (v.g., usufruto e habitação), quando penhorável o respectivo direito, o registro far-se-á separadamente, na matrícula do imóvel, “com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto sobre o qual recai o gravame”, destacando o bem constricto (terreno, acessão ou fruição), assegurando a publicidade da responsabilidade patrimonial limitada (art. 791, § 1.º).

A eficácia do registro da penhora opera *erga omnes*. Segundo o art. 844, para presunção absoluta de conhecimento pelos terceiros, cabe ao exequente o ônus de averbar a penhora ou o arresto no álbum imobiliário, mediante a apresentação do auto ou do termo que documentam o

ato de constrição, independentemente de mandado judicial.

3.5. Intimação da sociedade limitada e da companhia de capital fechado – Penhoradas quotas de sociedade limitada ou ações de companhia de capital fechado, há preferência dos demais sócios e da própria sociedade na respectiva aquisição, mediante liquidação do respectivo valor, utilizando para essa finalidade as reservas mantidas na tesouraria e sem redução do capital (art. 861, § 1.º). Não sendo esse o caso, o juiz determinará o leilão das quotas e das ações (art. 861, § 7.º), como acontece com as ações das companhias de capital aberto (art. 861, § 2.º), subsistindo a preferência dos sócios, e para esses efeitos o art. 799, VII, manda intimar da penhora a sociedade simples ou empresária, na pessoa do representante legal, a fim de que os sócios sejam informados da constrição e exerçam a preferência (art. 861, II).

3.6. Intimação do titular da construção-base e da laje – A Lei 13.465, de 11.07.2017, instituiu o direito real de laje (art. 1.225, XIII, do CC), disciplinado nos arts. 1.510-A a 1.510-E do CC, ao propósito de ensejar a regularização fundiária urbana. Em consequência da autonomia da(s) laje(s) no tocante à construção inicial, porque autônomos os pisos que a ela se acresceram, o art. 799, X e XI passou a prever a intimação dos respectivos titulares de direito real, conforme a constrição recaia sobre a construção-base ou a laje, sendo necessária, neste último caso, também a intimação dos titulares das lajes anteriores, se for o caso. A finalidade da intimação é o de assegurar o direito de preferência previsto no art. 1.510-D do CC, que cabe ao titular da construção-base e ao titular da laje, nessa ordem, e, havendo várias lajes, primeiro aos titulares das lajes ascendentes e depois aos titulares das lajes descendentes, sucessivamente (art. 1.510-D, § 2.º).

4. Efeitos da preterição da intimação do terceiro titular de direito real – O art. 804, qualquer que seja a origem e a natureza do gravame, declara ineficaz a alienação coativa, relativamente aos respectivos titulares do direito real limitado. É a orientação do Superior Tribunal de Justiça, ainda no direito anterior,¹⁵⁸ ressalvado os casos em que o interesse tutelado se cinge ao direito de preferência outorgado na lei material para adquirir o bem. Por decorrência da ineficácia, o direito do terceiro subsiste e poderá ser deduzido em ação própria (v.g., a ação de preferência).

Por igual, a alienação forçada é ineficaz perante o arrematante (art. 903, II, c/c art. 804). Vale realçar a hipótese do credor real (art. 799, I, c/c art. 804, *caput*). Segundo o princípio da cobertura, o bem gravado é avaliado sem a detração do valor correspondente aos gravames reais, e, consequentemente, transmitido livre e desembaraçado ao arrematante. Por sinal, o art. 25 da Lei 10.931/2004, veda a averbação da cédula de crédito imobiliário com garantia real se já houver prenotação ou registro de gravame sobre o bem, incluindo a penhora. Inexistindo intimação, e a purgação do gravame, satisfazendo o credor real seu crédito no preço, no todo ou em parte, o arrematante pagou mais do que o devido, sofrendo prejuízo econômico, assegurando-lhe o art. 903, § 5.º, I, a dissolução do negócio, no prazo de dez dias após a assinatura do auto (art. 903, § 2.º), e, após esse prazo, por meio de ação autônoma (art. 903, § 4.º). Segundo o STJ, a alegação de ineficácia cumpre ao credor preterido, não cabendo ao executado.¹⁵⁹ Não é razoável impedir o executado de apontar o vício ao órgão judiciário, a fim de que promova a intimação do adquirente para se manifestar.

5. Pedido de medidas de urgência – O art. 799, VIII, autoriza ao exequente pleitear medidas urgentes na petição inicial da execução fundada em título extrajudicial.

5.1. Objeto das medidas de urgência – O art. 799, VIII, autoriza a concessão de duas espécies de providências próprias da jurisdição de urgência: (a) medidas cautelares (segurança para execução); e (b) medidas satisfativas (execução para segurança), ou tutela provisória antecipada.¹⁶⁰ Representando extensão do poder geral da tutela de urgência, e, portanto, não depende da iniciativa do exequente, embora, na prática, incumba-lhe comunicar a situação de perigo no processo. Resta aquilatar o receio de dano, para os fins do art. 300, *caput*, porque o título executivo preenche, satisfatoriamente, o requisito da plausibilidade do direito invocado.¹⁶¹ É irrelevante o emprego da expressão “medidas de urgência” em lugar de “tutela provisória”. Se há ambiguidade terminológica, reside antes nessa última expressão – medidas cautelares são temporárias, jamais

provisórias – do que no denominador comum da urgência da medida.

São variadas as medidas de urgência abrigadas no art. 799, VIII. A indisponibilidade do ativo financeiro do executado, na forma do art. 854, *caput*, constitui medida cautelar cabível na órbita do art. 799, VIII, se o exequente pretende antecipá-la à citação do executado (art. 829, *caput*). Em certa oportunidade, o STJ admitiu a averbação, no prontuário de veículo, de impedimento à sua alienação.¹⁶²

Para evitar a necessidade de provimento judicial, o art. 828 criou a possibilidade de o próprio exequente obter certidão do deferimento da execução pelo juiz e providenciar os registros porventura necessários, consoante seu diagnóstico do comportamento do executado, com o fito de prevenir a fraude contra a execução.

A alienação de uma partida de bens perecíveis, enquanto não se realiza a penhora e há o risco de perda do lote, ou, ainda, a urgência na sua comercialização para aproveitar condições favoráveis e sazonais de mercado, exemplifica medida de caráter satisfativo. É comum identificar-se, como modalidades de tutela de urgência na execução das prestações pecuniárias, além dessa alienação antecipada (art. 852), também a pré-penhora do art. 830 – que antecipa a eficácia da penhora, e, portanto, constitui medida satisfativa –, a execução provisória e o bloqueio de ativos financeiros.¹⁶³

Em determinada oportunidade, o obrigado por mútuo hipotecário, executado extrajudicialmente, empregou ação cautelar inominada para impedir a imissão de posse do credor (art. 37, § 2.º, do Dec.-lei 70, de 21.11.1966) até o julgamento de ação anulatória do procedimento.¹⁶⁴

As duas situações – execução para segurança e segurança para execução – merecem tutela (de urgência) rápida e efetiva do órgão judicial, mas possuem natureza diferente e efeitos radicalmente opostos. Vale o princípio de que, no primeiro exemplo, nenhum dano, ainda que hipotético, atingirá o executado, e, no segundo, o desfazimento do ato e a restituição das partes ao estado anterior, *in natura*, mostrar-se difícil e, no caso dos alimentos provisionais, impossível.

5.2. Medidas de urgência do executado – O art. 799, VIII, induz o exame da pretensão à segurança pelo exequente. Porém, ao executado também cabe recorrer à jurisdição de urgência, incidentalmente no processo executivo, preenchidos os requisitos legais. Lícito ao executado pleitear a suspensão cautelar da execução na pendência de ação rescisória contra o título judicial. Admite-se, ainda, a suspensão cautelar da execução enquanto se apura o nexo entre a posição subjetiva do credor e o título executivo. E o STJ já teve ocasião de proclamar a inadmissibilidade de ação cautelar, empregada com o fito de opor-se à execução, ajuizada pelo executado em substituição aos embargos.¹⁶⁵

5.3. Momento da concessão das medidas de urgência – O art. 799, VIII, aparentemente atrela a concessão das medidas antecipatórias, cautelares ou satisfativas a pedido do credor e à ocasião do ajuizamento inicial. As averbações cogitadas no art. 828 não dependem de prévia autorização do juiz, mas exigem ulterior comunicação (art. 828, § 1.º), no prazo de dez dias. Também é providência passível de ser concedida com fundamento no art. 799, VIII.¹⁶⁶ Essa medida previne a fraude contra a execução (art. 792, III). E, ao restringir o crédito do executado, tem efeitos similares ao protesto do título judicial (art. 517) e a inscrição no cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3.º).

Em realidade, o art. 799, VIII, representa extensão do poder geral de tutela de urgência do juiz,¹⁶⁷ e, portanto, não depende da iniciativa do exequente. O juiz pode ordená-las *ex officio*.¹⁶⁸ Na prática, todavia, a informação de que o executado tende a praticar esta ou aquela fraude, alienando ou ocultando bens, revela-se virtualmente inacessível ao órgão judiciário sem a denúncia do exequente. Claro está que nada impede a cautela de ofício.

Tampouco as medidas repressivas tomadas pelo juiz para garantir o bom êxito da realização do crédito se cingem ao momento temporal do ajuizamento da pretensão a executar. Elas podem

ocorrer no curso do procedimento e em estágio mais adiantado dele, toda vez que concorram os respectivos pressupostos e se verifique alguma situação de perigo.

O pedido do credor não se limita à petição inicial. Em petição avulsa, a qualquer momento, é-lhe lícito arrolar os fatos e definir a natureza da medida mais apropriada para o caso. Ao juiz é lícito deferir a medida, comprovados seus requisitos, sem audiência do executado (art. 300, § 2.º), porque o contraditório atual, propiciando o conhecimento prévio da futura medida, talvez frustre a execução (“efetivação”) da cautela. Excepcionalmente, ao executado competirá requerer providência acautelatória do seu interesse.

5.4. Recurso próprio contra as medidas de urgência – Da decisão que defere ou não medidas cautelares ou satisfativas, incidentalmente pleiteadas no cumprimento da sentença ou no processo de execução, cabe agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único).

6. Ônus de averbação da propositura da execução e da constrição patrimonial – O art. 799, IX, institui o ônus de o exequente (a) averbar a propositura da execução, deferida a petição inicial pelo órgão judiciário, providência prevista no art. 828, e (b) averbar os atos de constrição, providência contemplada, quanto à pré-penhora e a penhora, no art. 844. Feitas essas averbações, surgirá presunção absoluta (*jure et de jure*) de ineficácia dos negócios jurídicos dispositivos do executado com terceiro, relativamente aos bens averbados (art. 792, II e III). Descumprido o ônus do art. 799, IX, incumbirá ao exequente, ocorrendo negócio dispositivo do executado, alegar e provar a ciência da litispendência (art. 799, IV), ou seja, da má-fé do terceiro adquirente, consoante a diretriz esponsada pela Súmula 375 do STJ.

O art. 799, IV, institui o ônus do exequente quanto aos bens sujeitos a “registro público”. Logo acode à mente os bens imóveis. No entanto, há outros bens registráveis: (a) os veículos automotores, obrigatoriamente registrados, a teor do art. 120, *caput*, da Lei 9.503/1997, e providos Certificado de Registro de Veículo (CRV), previsto no art. 121 da Lei 9.503/1997, permitindo a averbação da penhora e de outras constrições; (b) as embarcações (art. 2.º da Lei 7.652, de 03.02.1988); (c) aeronaves (art. 72 da Lei 7.565, de 19.12.1986); (d) as ações das companhias também comportam registro de eventual constrição do livro próprio. Em todos esses casos, incidirá o art. 799, IX.

Existem bens registrados em organizações privadas e que, portanto, escapam à incidência do art. 799, IX. Por exemplo, os semoventes são registrados (v.g., caninos e equinos), por organizações privadas, todavia sem generalidade e obrigatoriedade, como acontece com antigo e venerando *Stud Book* (registro genealógico de cavalos de corrida ou *thoroughbred*) e a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC).

É mais duvidosa, abstraída a incidência do art. 54 da Lei 13.097/2015, a possibilidade de registrar a constrição das coisas móveis, em geral, e para o efeito do art. 792, III, no cartório de títulos e documentos. O art. 129 da Lei 6.015/1973 não arrola essa hipótese como passível de registro para “surtir efeitos em relação a terceiros” (art. 129, *caput*, da Lei 6.015/1973).

Para efeitos de fraude contra a execução, se a penhora recair sobre bem não passível de registro público (v.g., os semoventes e outros bens móveis, em geral), o art. 792, § 2.º, atribui ao terceiro adquirente o ônus de exhibir as certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no “local onde se encontra o bem”, demonstrado que adotou “as cautelas necessárias para a aquisição”.

Flagrantemente, o dispositivo inspirou-se nos negócios imobiliários, pois recomenda certidões do domicílio do vendedor e do “local onde se encontra o bem”. Por definição, o local de situações das coisas móveis é variável e não tem o menor sentido, em muitos casos, obter certidão no lugar atual e, de resto, inadmissível o adquirente certificar-se em todas as comarcas do nosso vasto país. Por exemplo, *A* pretende vender a *B* a obra de arte *X*, domiciliado *A* em São Paulo e localizada *X* em Campinas, mas entregue a *B* no Rio de Janeiro. Ora, nem sempre o adquirente sabe exatamente qual é o local da transeunte situação da coisa (Campinas ou São Paulo), e, no fundo, pouco lhe importa, bastando-lhe certificar-se da idoneidade do alienante. Enfim, a mais das vezes o ônus do

adquirente se cinge às certidões – mais de uma, de fato: da Justiça Comum, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho – obtidas no domicílio do vendedor, porque impraticável identificar a exata localização da coisa móvel antes do acordo de transmissão.

Não é apenas no âmbito da fraude a repercussão da averbação cogitada no art. 799, IX. Destinando-se a opera no plano da eficácia, e *erga omnes*, também atinge os demais credores penhorados do mesmo bem (art. 797, parágrafo único), passando o titular da penhora averbada à frente no concurso especial de credores, justamente porque sua constrição é oponível a terceiros. Entretanto, não é este o entendimento prevalecente no STJ.¹⁶⁹

Art. 800. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 (dez) dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou contrato.

§ 1.º Devolver-se-á ao credor a opção, se o devedor não a exercer no prazo determinado.

§ 2.º A escolha será indicada na petição inicial da execução quando couber ao credor exercê-la.

1. Classificação das obrigações na lei processual – O Título II da Parte Especial do novo Código de Processo Civil classifica as obrigações consoante o objeto da prestação, mas visa a correlacionar esse objeto com o meio executório, e, portanto, utiliza critério menos complexo do que o utilizado no direito material.¹⁷⁰

Essa relação instrumental descansa nos dois grandes e tradicionais grupos: (a) obrigações de dar; (b) obrigações de fazer. Da análise dos capítulos iniciados pelos arts. 806, 814 e 824 depreende-se o arranjo legislativo.

As obrigações de fazer separam-se em duas classes, conforme o comportamento comissivo ou omissivo reclamado do executado: (a) fazer; e (b) não fazer. Exemplos: (a) A contrata com B para no dia X, festa de aniversário de C, entreter os convidados com truques de prestidigitação, B assumiu obrigação de fazer positiva, e, ademais, o dia X é termo essencial, porque é inútil a prestação tardia; (b) A adquiriu de B a marca X, fabricante de perfumes, assumindo B a obrigação de abster-se de concorrer com A, direta ou indiretamente, pelo período de cinco anos. As obrigações negativas suscitam vários problemas no âmbito executivo.¹⁷¹ Embora o art. 822 equipare os direitos legais de abstenção às obrigações negativas, o art. 823, *caput*, ocupa-se do desfazimento dos atos materiais decorrentes do inadimplemento, a título de execução específica, e caso seja impossível, confere ao exequente a prestação pecuniária equivalente (art. 823, parágrafo único). Positiva ou negativa a obrigação, a respectiva tônica, evidenciada nos exemplos ministrados, consiste na atividade pessoal do devedor, ainda que dela resulte a dação de coisas.

A distinção das obrigações de fazer das obrigações de dar, quando as prestações envolvem, como não raro acontece, a prestação de fatos e de coisas, reside no interesse do credor.¹⁷² Por exemplo, A contrata com B a confecção da paisagem X, fiando-se na maestria do pintor: a obrigação que incumbe a B é de fazer, embora resulte na dação do quadro; ao invés, se C comparece na exposição das obras de B e escolhe a paisagem X, a obrigação assumida por B é de entregar coisa. Por óbvio, ocorrendo inadimplemento de B, e constando a obrigação de título executivo, os meios técnicos para A e C obter a execução específica, ou seja, obter o objeto da prestação em natura, não serão os mesmos: no primeiro caso, o meio preferencial é a pressão psicológica, por meio da cominação de multa pecuniária (*astreinte*), a teor do 814, *caput*; no segundo, o meio hábil é o desapossamento (art. 806, § 2.º), sem prejuízo da cumulação de multa pecuniária (art. 806, § 1.º). Em qualquer caso, o crédito é um comportamento do obrigado.¹⁷³

Uma ulterior distinção, apesar de o fazer positivo ou negativo encontrarem-se previstos em seções próprias, descansa na fungibilidade subjetiva, ou não, da prestação. Infungível é o fazer dependente em altíssimo grau das aptidões pessoais do obrigado e “só por ele exequível”, como dispõe a parte final do art. 247 do CC. Por exemplo, A contrata com B, célebre cirurgião, a modificação estética das pálpebras, eliminando bolsas de gordura. Em tal caso, a “execução” voluntária ou a sub-rogação do executado B pelo seu assistente C não satisfazem,

presumivelmente, o credor, em cujo proveito, assevera o art. 797, *caput* (“... realiza-se a execução no interesse do exequente...”), desenvolve-se a execução.

Em que pesem possíveis dúvidas, a única maneira segura de reputar infungível o objeto da prestação radica na avaliação do interesse do credor. Ele deverá ser avaliado e ponderado em termos análogos ao juízo que compete ao órgão judiciário para apurar se ocorreu, ou não, cumprimento satisfatório da obrigação fungível (art. 818, *caput*).¹⁷⁴ Também se respalda o controle judiciário no art. 249, *caput*, do CC, pois, ocorrendo controvérsia das partes, somente a autoridade judiciária poderá resolver se o fato pode “ser executado por terceiro”. E, de fato, a par de harmoniza-se o alvitre com o cunho marcadamente individualista da execução de créditos, inexistente outra solução concebível para os casos em que as aptidões do obrigado, apesar de excepcionais, não se mostrarem singularmente exclusivas. Por exemplo, se *A* nada obstante tenha escolhido o célebre cirurgião *B* para corrigir anomalia insignificante na pálpebra, talvez se conforme, na última hora, com a arte menor de *C*, o assistente principal do esculápio, uma vez internado na clínica do mestre. Em tal hipótese, o interesse do cliente presidirá a fungibilidade da obrigação.

A diferença entre obrigações de fazer fungíveis e infungíveis apresenta repercussão de vulto no campo executivo. A execução das obrigações de fazer fungíveis comporta sub-rogação de terceiro. Em outras palavras, a conduta do obrigado, objetivo primário do vínculo, enseja substituição satisfatória por outrem, escolhido mediante convite à apresentação de propostas (art. 817, *caput*).

Em relação às obrigações de dar, distinguidas anteriormente das obrigações de fazer, a lei processual promove divisão entre dar coisa, determinada ou determinável, e dar pecúnia. O legislador desprezou outras subdivisões sob a desculpa da utilidade das grandes generalizações.¹⁷⁵ No sistema da lei processual, portanto, obrigação de dar coisa certa (*corpus certum*) é a que o objeto é individualizado, *a priori*, por sinais característicos que nenhuma das outras coisas têm;¹⁷⁶ de dar coisa incerta (determinável), a que o objeto da dação determinar-se-á, *a posteriori*, pelo gênero e pela quantidade, segundo o art. 811, *caput*, do CPC/2015. A coisa incerta não é, necessariamente, coisa fungível.¹⁷⁷ Fungível é a coisa que pode ser substituída por outra da mesma espécie, quantidade e qualidade, sem prejuízo do interesse do credor.

A coisa determinável, enquanto tal, não comporta execução. Em ocasião anterior ao desencadeamento do meio executório respectivo – desapossamento, a teor do art. 806, § 1.º –, a obrigação excutida submeter-se-á ao incidente de individuação, também chamado de concentração ou de escolha (arts. 811 e 812).¹⁷⁸ No que tange ao título judicial, o art. 498 almeja evitar o incidente de concentração, concedendo o juiz tutela específica (= entrega de coisa certa), razão por que incumbe ao autor realizar a escolha na petição inicial (art. 498, *caput*), se lhe couber, e o réu no prazo que o juiz lhe assinar para entregá-la individualizada. Nesse último caso, entregando coisa a coisa em desacordo com os ditames da lei substancial, inevitável a controvérsia a esse respeito.

Por fim, exequíveis afiguram-se as obrigações pecuniárias, seja a dívida de (a) simples quantia,¹⁷⁹ seja a dívida (b) impropriamente pecuniária, porque, contraída em moeda estrangeira, nos casos legalmente admissíveis (art. 318 do CC), incumbe ao exequente convertê-la em moeda nacional.¹⁸⁰ É que o pagamento, e, *a fortiori*, a satisfação da obrigação pelo meio executivo próprio – expropriação, a teor do art. 824 do CPC/2015 –, far-se-á obrigatoriamente em moeda nacional (art. 315 do CC). Entre particulares, não havendo disposição legal específica que autorize a contratação em moeda estrangeira (art. 2.º do Dec.-lei 857/1969), o STJ entende o seguinte:

Quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira não permitem indexação. Sendo assim, havendo previsão de pagamento futuro, tais dívidas deverão, na data da quitação, ser convertidas para a moeda nacional com base na cotação da data da contratação e, a partir daí, atualizadas com base em índice de correção monetária admitida pela legislação pátria.¹⁸¹

No comércio jurídico, preponderam as obrigações pecuniárias e esse fato repercute no âmbito executivo. Importantes que sejam os comportamentos do obrigado e os deveres legais de

abstenção, somente em épocas mais recentes essas situações reclamam tutela em juízo.

São vários os fatores determinantes da preponderância das obrigações pecuniárias ou o equivalente pecuniário de obrigações de outra espécie. Em primeiro lugar, a sociedade de massa, ao mesmo tempo em que diversifica as condutas juridicamente tuteladas, convive com a incoercível tendência de tudo converter em dinheiro; então, como já sublinhado, prevalece o interesse do credor, satisfazendo-se mediante a substituição da prestação *faciendi* primitiva no seu equivalente pecuniário. Existem casos em que a prestação se vincula a termo essencial (v.g., o caso da apresentação de truques de prestidigitação na festa de aniversário de C), tornando inútil a prestação em natura após seu vencimento. Não é de se desprezar os problemas próprios dos meios executórios predispostos à obtenção da obrigação em natura. E, por fim, a necessidade de o credor obter provimento judicial, quanto aos direitos legais de abstenção, parece meta inatingível.¹⁸²

Os meios executivos das obrigações de fazer se ostentam insuficientes e precários porque, reconhecida a intangibilidade física do obrigado,¹⁸³ o mecanismo da pressão psicológica, único aplicável ao fazer infungível, nem sempre conduz ao êxito.¹⁸⁴ Não raro a obstinação do executado revela-se inquebrantável. Nem sequer é fatal a capitulação de quem possui patrimônio para suportar multas de valor elevado. Também sucede o contrário: a insuficiência patrimonial torna inócua semelhante coerção. Em ambas as hipóteses, o meio executório não produz resultados concretos.

O panorama não se altera significativamente no caso das obrigações de fazer fungíveis. O meio executório de transformação, destinado à execução do fazer fungível, previsto no art. 817 do CPC/2015, não é isento de dificuldades (v.g., o recrutamento do terceiro, o atendimento dos custos da execução, e assim por diante), apesar das simplificações nele introduzidas (v.g., a dispensa de licitação do terceiro para realizar a prestação).

Essas dificuldades conduzem ao credor, desprovido de título executivo extrajudicial, a pleitear o equivalente pecuniário, conforme observou-se agudamente.¹⁸⁵

2. Obrigação alternativa – Existem obrigações que contêm prestações múltiplas (*dare* ou *facere*), uniformes ou não (*dare* e *facere*),¹⁸⁶ exequíveis *in simultaneo processu* se idênticas as prestações (v.g., pelo mesmo ou diferentes títulos judiciais, o executado se obrigara a construir um muro e a reformar o telhado da moradia do credor). Discrepantes as prestações, a diversidade de meios executórios reclama o ajuizamento de demandas autônomas.¹⁸⁷

Na obrigação conjuntiva, o obrigado libera-se prestando integralmente o objeto múltiplo; na obrigação alternativa, a prestação de um dos objetos libera o obrigado, subsistindo a obrigação caso das prestações se torne inexequível (art. 253 do CC).

Dessa última hipótese ocupa-se o art. 800 do CPC/2015, regulando o incidente de concentração.¹⁸⁸

3. Incidente de escolha – Em princípio, a escolha cabe ao obrigado, a teor do art. 252, *caput*, do CC, salvo convenção em contrário. O art. 800 do CPC/2015 regula a espécie.

Se a escolha entre uma ou outra prestação compete ao credor, o exequente a realizará na petição inicial (art. 800, § 2.º). Por conseguinte, e coerentemente, o exequente deduzirá sua pretensão a executar pelo procedimento *in executivis* adequado, indicando o meio executório apropriado ao objeto da prestação (expropriação, transformação, desapossamento, coerção patrimonial e pessoal), a teor do art. 798, II, *a*. Ao invés, cabendo ao devedor a eleição – que é a regra, *ex vi* do art. 252, *caput*, do CC –, o órgão judiciário mandará citá-lo para “realizar a opção e realizar a prestação” no prazo de dez dias, se outro prazo não for previsto na lei ou no contrato.¹⁸⁹ Impende ressaltar que, nesse caso, o procedimento ulterior encontra-se indefinido, caso o executado não realize a opção e não satisfaça a obrigação, prestando um dos objetos.

O art. 800, § 1.º, prevê o efeito da inércia do executado no prazo que lhe for designado: a escolha reverterá ao exequente. Também se concebe que, em vez de escolher, o executado desde

logo preste, caso em que não há reversão da escolha, mas cumprimento, passando-se ao seu controle, conforme a natureza da prestação.

Esse incidente mostra-se análogo ao de concentração que antecede a execução para entrega de coisa incerta, e, portanto, suas regras se aplicam por analogia.¹⁹⁰ No entanto, existem várias particularidades dignas de registro. Em primeiro lugar, como o objeto da prestação pode ser desigual (*dare* ou *facere*), depois de ultimada a escolha pelo obrigado é que se determinará o procedimento. É certo que, segundo o art. 252, § 1.º, não é obrigado o credor a receber parte da prestação por um objeto e a outra parte por outro. Logo, a escolha é indivisível. Ademais, a escolha poderá tocar a terceiro, a teor do art. 252, § 4.º, do CC, a pluralidade de optantes (art. 252, § 3.º, do CC) ou, ainda, depender de sorteio.

Cabendo a escolha a terceiro, nenhuma diretriz há no estatuto do processo quanto à forma de intervenção desse terceiro. Fica subentendido que o exequente requererá sua intimação para realizar a escolha, no prazo de dez dias, salvo disposição em contrário do título, e, no caso de inércia, há dois termos de alternativa: (a) ou a opção passa ao devedor;¹⁹¹ (b) ou a escolha passa ao órgão judiciário. O art. 252, § 4.º, do CC, indica essa última solução, mas se cuida de direito dispositivo, admitindo-se convenção em contrário no título. Incumbindo a escolha a duas ou mais pessoas, e inexistindo acordo, o juiz deliberará sobre o assunto, a teor do art. 252, § 3.º, do CC. Se a convenção das partes prevê sorteio, após a citação do executado, o juiz designará audiência (art. 772, I) e procederá ao sorteio, através de qualquer expediente adequado para tal finalidade.

Concebe-se, igualmente, da escolha incumbirem-se dois ou mais devedores. Em tal hipótese, todos hão de ser citados, acolhendo-se a opção da maioria e, em caso de empate, reputando-se como não realizada a escolha.¹⁹² É exato o alvitre de que, na execução futura, o credor poderá exigir a prestação individualizada de todos ou de algum dos devedores.¹⁹³

4. Casos particulares de escolha – Ilíquida que seja uma das prestações, ou todas, antes de realizar a liquidação,¹⁹⁴ o princípio da economia impõe que se realize o incidente de escolha.¹⁹⁵ Prescindir-se-á da própria liquidação no caso de o devedor escolher a prestação líquida.

Em se tratando de prestação negativa, sua escolha acompanhada de cumprimento implica a extinção do procedimento *in executivis*; descumprida, o credor executará segundo o disposto no art. 822.

Consistindo um dos termos de alternativa “prestação de declarar vontade”, sua escolha eliminará a necessidade de executar, pois a sentença produzirá o efeito jurídico previsto no art. 501.¹⁹⁶ Porém, nesse caso o credor não deduzirá pretensão a executar, segundo o Livro II da Parte Especial do Código de Processo Civil de 2015, mas pretensão à obtenção da sentença substitutiva.

Sujeitando-se a prestação a termo ou a condição, o interesse de o credor provocar a escolha nasce com o primeiro vencimento ou no implemento da primeira condição, cuja prova, neste campo, não discrepa das regras comuns; escolhida a prestação que ainda não se tornou exigível, porque não se verificou o termo ou a condição, a execução não poderá se iniciar antes disto (art. 788). Em caso de prestações periódicas, renovar-se-á a escolha a cada vencimento (art. 252, § 2.º, do CC).

Apresentando as prestações alternativas objetos múltiplos, se a escolha couber ao credor, não poderá ele executar, *in simultaneo processu*, a parcela pecuniária e a obrigação de fazer, por exemplo, restando-lhe propor execução autônoma, observado o meio executório adequado a cada classe. Ao invés, incumbindo ao obrigado a escolha, tudo dependerá de seu comportamento. Feita a escolha, adimplindo o devedor a todas, extingue-se a execução; a apenas uma delas, o credor executará a prestação restante; a nenhuma, toca ao credor ajuizar execuções autônomas.

Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

1. Correção da petição inicial – A época em que surgiu o CPC/1973, a regra predecessora do art. 801 consistiu em notável e salutar inovação.¹⁹⁷ Representava sólida investida contra o formalismo.¹⁹⁸ Essa diretriz segue vigente. Segundo preceitua o art. 801,

verificando o juiz que a petição inicial está incompleta, ou não se acha acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, determinará que o exequente a corrija, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento.

Ressalva feita à troca da palavra “credor” por “exequente” – na terminologia do CPC/2015, não sem vacilações, chama-se “exequente” à parte ativa; “credor”, ao titular da relação de direito substancial –, a dilatação do prazo para quinze dias, e ligeira modificação na redação da parte final, uma das tantas modificações redacionais desnecessárias (e de autoria obscura), o dispositivo manteve seus propósitos benéficos.

Em relação ao art. 321, verifica-se a omissão, presumivelmente porque redigida a regra por outra pessoa, do dever de o órgão judiciário apontar, clara e especificamente, o defeito porventura constatado na petição inicial. Parece evidente a necessidade de o órgão judicial indicar o defeito e orientar o exequente, haja vista o princípio da cooperação (art. 6.º), nesse aspecto realizável, porque é dever da autoridade judiciária esclarecer as partes.

Nada obstante a importância do combate ao espírito caviloso incutido pela forma, não se prescinde da exata obediência aos requisitos do art. 319 c/c art. 798, pois o repúdio total à forma, segundo célebre fórmula, “carreia a desordem, a confusão e a incerteza”.¹⁹⁹ A petição inicial desguarnecida dos elementos do art. 319, complementados pelo art. 798, não atingirá sua finalidade própria.

O art. 801 emprega duas expressões, uma em sentido amplo e outra em sentido restrito. Desacompanhada a inicial de documentos indispensáveis (art. 320 c/c art. 798, I) – a exemplo do título executivo, da prova do inadimplemento, da procuração outorgada ao advogado do exequente, da prova do oferecimento da contraprestação, e, principalmente, do demonstrativo do débito –, revelar-se-á incompleta. Em tal contingência, caberá ao juiz, antes de indeferi-la, abrir prazo para correções, “em proveito da função instrumental do processo”.²⁰⁰ Não se encontrará “completa” a petição inicial, de resto, desprovida da elementar estrutura do art. 319. Também neste caso toca ao exequente, sob determinação do juiz, o ônus de emendar a petição, esmerando-a e adequando-a ao gabarito legal. Tais exigências se aplicam, obviamente, ao cumprimento da sentença. Figure-se a hipótese de o vitorioso requerer a execução sem juntar a planilha (art. 524, *caput*). Impõe-se assinar o prazo de quinze dias para corrigir esse defeito. Também os vícios formais se inserem na órbita do art. 801 (v.g., falta de assinatura do advogado do exequente).

Suscitada pelo art. 801, a questão da inicial “incompleta” reclama interpretação descomprometida com eras passadas. Apesar da opinião contrária da doutrina tradicional,²⁰¹ desatenta às mudanças legislativas, os casos de inépcia, previstos no art. 330, § 1.º, e aplicáveis ao processo executivo, comportam correção. Por exemplo, a gravíssima falta de causa de pedir (art. 330, § 1.º, I) admite suprimento, tranquilamente, através da transcrição de simples parágrafo na petição. E talvez o defeito se deva a simples lapso no arranjo das vias que compõem a petição inicial. O indeferimento imediato justifica-se somente naquelas hipóteses em que o autor nada pode alterar, a exemplo da própria e manifesta ilegitimidade (art. 330, II).

O deferimento provisório da inicial, através do ato pelo qual o juiz ordena a citação do executado (art. 802), à semelhança do que sucede no procedimento comum do processo de conhecimento, não produz preclusão. Continua lícito ao executado suscitar as questões pertinentes à aptidão da peça vestibular, nos embargos ou mediante o controle incidental (art. 518), caso a matéria seja conhecível de ofício. A partir do oferecimento da oposição do executado, nenhum reparo revelar-se-á admissível, a exemplo da juntada do título executivo suprindo sua falta, até então despercebida.²⁰²

Em princípio, o ato do juiz que ordena ao exequente emendar a petição inicial não produz qualquer gravame, e, portanto, mostra-se irrecorrível. A jurisprudência do STJ inclinou-se pelo

cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que ordena a juntada da planilha (art. 798, I, b, e parágrafo único),²⁰³ quando desnecessário o esclarecimento do demonstrativo do débito. Não há dúvida que, nessa linha, o agravo de instrumento continua cabível (art. 1.015, parágrafo único).

Apenas nas hipóteses teratológicas, inviabilizado completamente o poder de emendar e de corrigir a inicial, calha o indeferimento liminar. Esse ato de extinção também é imperioso quando o credor não cumpre as providências determinadas no prazo improrrogável de quinze dias. Nesta linha de raciocínio, entendendo suprível o defeito, já decidiu o STJ que não cabe extinguir a execução, de plano, porque o exequente não instruiu a petição inicial com o demonstrativo atualizado do débito.²⁰⁴

2. Indeferimento da petição inicial – A relação processual constitui-se e desenvolve-se válida e eficazmente quando preenchidos certos pressupostos.²⁰⁵ Com efeito, há elementos de existência, requisitos de validade e fatores de eficácia que influenciam a regularidade do processo. Organizou-se semelhante matéria sob o rótulo tradicional de pressupostos processuais, mas a terminologia não é a mais apropriada, porquanto os assuntos são heterogêneos e distribuem-se também nos planos da existência e da eficácia.

Em algumas hipóteses graves, os defeitos já se apresentam flagrantes e invencíveis desde a petição inicial. Ao juiz cumpre indeferir a inicial e extinguir o processo se apurar a ocorrência desta espécie de vício, via de regra excepcional, por força da aplicação subsidiária do art. 485, a teor do art. 924, I.²⁰⁶ O saneamento do processo começa neste momento e, quanto mais cedo, melhor.²⁰⁷ Incide o art. 485, cujo inc. IV, atinente aos “pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”, a rigor inclui as alegações de litispendência, perempção e coisa julgada (inc. V); os incs. II, III, VIII e IX aplicam-se, igualmente, à demanda executória, mas abrangem circunstâncias supervenientes à inicial; o inc. VII (convenção de arbitragem) dificilmente se apresentará na execução; restam, pois, os incs. I, VI e X, que cuidam do indeferimento da inicial, da legitimidade e do interesse processual e de outras hipóteses de extinção (v.g., a do art. 290, deixando o autor, intimado na pessoa do advogado, de recolher as custas iniciais da distribuição).

Do indeferimento da petição inicial trata o art. 330, aplicável subsidiariamente. Tal norma incide ao processo executivo, adaptando-se suas situações às peculiaridades da pretensão a executar:

(a) há inépcia da inicial (art. 330, I e parágrafo único, I a IV) quando o exequente: (aa) não formula pedido imediato, abstendo-se de especificar o crédito, ou o pedido imediato; (ab) não expõe a causa de pedir ou sua narrativa é incongruente – v.g., invoca determinado título, mas descreve outro;²⁰⁸ (ac) formula pedido em tese inadmissível (v.g., pretende executar crédito pecuniário comum por meio de coerção pessoal); (ad) cumula, indevidamente, duas ou mais pretensões a executar *in simultaneo processu*;

(b) pode suceder manifesta ilegitimidade de parte (art. 330, II), ativa ou passiva, sendo a legitimidade do próprio exequente impossível de corrigir no prazo do art. 801;

(c) há falta de interesse processual (art. 330, III) quando o exequente almeja executar crédito inexigível ou de valor insignificante;

(d) os defeitos formais da petição inicial (v.g., a falta de indicação dos endereços físico e eletrônico), postulando advogado em causa própria, ou não, subsistiram ao prazo assinado para corrigi-los (art. 330, IV, c/c arts. 106 e 801).

Não se descarta, absolutamente, a incidência do art. 332 nos domínios executivos, emitindo o órgão judiciário juízo de improcedência quanto à pretensão a executar ao primeiro contato com a inicial; por exemplo, (a) o exequente pretende realizar diferenças de correção monetária de crédito contemplado em título executivo, cuja admissibilidade o STJ rejeitou através de precedente haurido do julgamento de recurso especial repetitivo (art. 332, II) ou em súmula da sua jurisprudência dominante (art. 332, I); (b) o exequente deduz pretensão a executar prescrita,

assunto que ao órgão judiciário cabe conhecer *ex officio*, após prévio debate das partes (art. 487, II e parágrafo único), a teor do art. 332, § 1.º).

A ausência de legitimidade e de interesse processual, assuntos agrupados sob o equívoco rótulo de “condições” da ação no direito anterior, na verdade não obstam a formação do processo, mas podem ensejar a sua extinção (art. 485, VI), mediante indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III). Um caso peculiar de falta de interesse processual consiste na irremediável inexistência de bens penhoráveis na hipótese do art. 836, *caput*.

O ato decisório pelo qual o órgão judiciário indefere a inicial e extingue liminarmente o processo é sentença (art. 203, § 1.º). Da sentença cabe apelação (art. 1.009, *caput*). Interposta a apelação pelo exequente, ao juiz cabe retratar a sentença terminativa, no prazo de cinco dias, a teor do art. 331, *caput*, concebendo-se, então, duas hipóteses: (a) não ocorrendo a retratação, o órgão judiciário mandará citar o réu para contra-arrazoar o apelo (art. 331, § 1.º); (b) retratado o pronunciamento, prosseguirá a execução. Não interposta a apelação, o executado será intimado do trânsito em julgado (art. 331, § 3.º).

Vale ressaltar que precederá a extinção, ordinariamente, oportunidade para o demandante emendar a inicial defeituosa (art. 801). Se o exequente não corrigir a contento a peça, por exemplo, deixando de anexar documento indispensável,²⁰⁹ então o juiz prolatará a sentença extintiva. E, a despeito de cabíveis honorários advocatícios no processo de execução e no cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, a teor do art. 85, § 1.º, inexistirá condenação do exequente nessa rubrica, no caso de indeferimento da petição inicial, porque o advogado do executado, talvez ainda não constituído, por definição absteve-se de desenvolver qualquer atividade processual útil ao resultado.

3. Deferimento da petição inicial – Em geral, a petição inicial (ou o requerimento do art. 513, § 1.º), encontra-se em boa ordem, respeitados os requisitos gerais e formais, cabendo ao juiz, depois de examinar o ato postulatório e verificar o preenchimento do conjunto dos pressupostos processuais, deferi-la, mandando citar o executado. Se ocorrer pronunciamento explícito, resolvendo positivamente questão a favor do exequente (v.g., a legitimidade ativa), o ato constitui decisão interlocutória (art. 203, § 2.º) e dele caberá agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único).

Representará exagero formal exigir ato motivado, na forma do art. 489, § 1.º,²¹⁰ quanto aos requisitos da petição, valendo a ordem de citação como reconhecimento implícito da regularidade do ato postulatório do exequente.

Fixando o órgão judiciário honorários em proveito do advogado do exequente (art. 85, § 1.º), o provimento liminar positivo adquire conteúdo mais complexo, como na execução por quantia certa (art. 827, *caput*), em que o legislador adotou percentual rígido (dez por cento sobre o valor da dívida), abreviando a ponderação dos elementos objetivos e subjetivos desse provimento (art. 85, § 2.º), e, conseqüentemente, a necessidade de motivação suficiente. Segundo o STJ,²¹¹ o provimento não representa ilegalidade a justificar o emprego de mandado de segurança. Porém, a lição só pode ser acolhida com o clássico grão de sal: concebe-se ilegalidade manifesta nessa parte do provimento, a exemplo do caso de o juiz fixar os honorários em percentual inferior (v.g., cinco por cento) ou superior (v.g., vinte por cento) ao legal, contrariando o art. 827, *caput*. É agravável, de certo, a decisão proferida em desacordo com o art. 827, *caput*.

Do pronunciamento liminar positivo, a teor do art. 802, deriva o efeito interruptivo da prescrição, sob a condição de o exequente, quando couber a convocação do executado, como é regra no processo de execução (no cumprimento da sentença, nos casos do art. 515, § 1.º), tomar as providências que lhe incumbem para propiciar a realização do ato (v.g., a antecipação das despesas de condição do oficial de justiça; a entrega dos duplicados da petição inicial), outorgando-se exegese estrita ao dispositivo. Existem efeitos que decorrem do registro ou da distribuição da causa, para ambas as partes (v.g., a prevenção, a teor do art. 59 c/c art. 55, § 2.º, I e II) ou para o autor (v.g., a litispendência), e efeitos que decorrem da citação perante o réu (art. 240, *caput*).

O provimento liminar positivo do órgão judiciário é provisório.²¹² Mesmo após sua preclusão, ao juiz se mostra lícito revê-lo, de ofício ou a instâncias da parte, e indeferir a inicial.

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância do disposto no § 2.º do art. 240, interromperá a prescrição, ainda que proferida por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

1. Efeitos da litispendência – O art. 802, *caput*, atribui ao despacho ordenando a citação do executado, no processo de execução, o efeito de interrompe a prescrição da pretensão a executar, ainda que ordenada por juízo incompetente, retroagindo esses efeitos à data da propositura da ação, segundo reza o parágrafo único.

O processo civil brasileiro eliminou a antiga diferença entre ajuizamento e propositura da ação. A partir da noção de que processo constitui relação jurídica autônoma – por sinal, natureza reconhecida no art. 238, *in fine* –, e independentemente da real existência do direito alegado pelo autor perante o réu, relação litigiosa transformada em objeto litigioso, ou mérito, essa diferença não tem o menor sentido. Era clássica a distinção entre o ajuizamento, que se operava no instante da entrega da inicial e originava, exclusivamente, o vínculo do autor com o Estado-juiz; e a propositura, quando, enfim, a relação processual se completava, através do chamamento do réu. Ora, o art. 240 indica que o fim da citação consiste em integrar o executado ao processo. Nada obstante a tardia resistência de alguns,²¹³ os arts. 312 e 802 do claramente adotam solução oposta ao antigo critério.²¹⁴ No momento em que o juiz defere a inicial, ou simplesmente ela é entregue no ofício judicial, forma-se o processo, tanto que o ato de rejeição liminar o extinguirá (art. 330 c/c art. 485, I, e 924, I).

A pendência do processo, formada a relação processual, produz dois significativos efeitos: (a) prevenção; e (b) proibição de o autor renovar a pretensão deduzida. Da citação resultam outros efeitos, arrolados no art. 240, a exemplo (a) da litigiosidade e (b) da constituição em mora, mas o efeito interruptivo da prescrição decorre, consoante o art. 802, *caput*, do despacho liminar positivo, retroagindo à data da propositura. A esses efeitos, acrescenta-se efeito peculiar nos domínios executivos: a indisponibilidade relativa do patrimônio do executado (art. 792, IV). É admissível acrescentar, ainda, a averbação da propositura da execução, a teor do art. 828, mas a esse respeito urge consultar os comentários ao dispositivo. Cumpre, então, examiná-los separadamente.

2. Efeito interruptivo da prescrição – O art. 802, *caput*, manteve-se coerente ao disposto no art. 202, I, do CC, não bastando a propositura da pretensão a executar para interromper a prescrição, exigindo-se, ademais, a ordem de citação proferida pelo órgão judicial, obviamente proferida no caso de provimento liminar positivo. Também se alinhou a essa orientação o art. 240, § 1.º. A rigor, a disposição coloca o exequente na berlinda, não o isentando dos percalços ínsitos à complexa e deficiente administração da Justiça. Não é, absolutamente, fácil obter o provimento liminar positivo rapidamente, nas grandes e pequenas comarcas, porque o juiz competente encontra-se, quase sempre, às voltas com inúmeros quefazeres. Daí resulta que o credor previdente aviará sua pretensão a executar com alguma antecedência, relativamente ao termo final do prazo de prescrição, pois urge colher o despacho do juiz para livrar-se das ulteriores falhas de serviço (art. 240, § 3.º), tomadas as providências necessárias (v.g., adiantamento das despesas de condução do oficial de justiça) no prazo de dez dias (art. 240, § 2.º), hipótese em que, fictamente, embora realizada a citação após o vencimento do prazo, o efeito interruptivo retroagirá à data da propositura (art. 802, parágrafo único).

E, de fato, a disciplina do art. 802, *caput*, exhibe graves consequências práticas. Por exemplo: o exequente distribui a inicial alguns dias antes do vencimento do prazo de prescrição, mas olvidou a juntada do título, motivo por que o juiz ordena a emenda da inicial (art. 801). Se o exequente demora a fazê-lo, e o deferimento ocorre após o termo final do prazo prescricional, é forçoso entender extinta (= encoberta a eficácia) a pretensão a executar.

Nas demais hipóteses, arroladas no art. 240, *caput*, a produção de efeitos perante o executado dependerá da sua citação (art. 312, 2.^a parte). O ônus do exequente consiste em promover a citação – v.g., antecipando as despesas do oficial de justiça –, jamais em efetivá-la,²¹⁵ porque a preparação e a prática do ato encontram-se afetas ao auxiliar da justiça, respetivamente o escrivão ou chefe de secretaria (art. 152, I) e o oficial de justiça (art. 154, I).

Em face da gravidade da consequência, que consiste no vencimento do prazo prescricional, decadencial ou preclusivo, convém respeitar essa sistemática estritamente. Não se ignorava, contudo, a generosa tendência de debitar o atraso à burocracia judiciária, eximindo o autor, tenha ou não promovido a citação nos prazos legais, da perda dos efeitos antecipados.²¹⁶ Eis o motivo da ressalva do art. 240, § 2.º. Idêntica é a orientação da Súmula 106 do STJ. Convém rememorar que isso se aplica ao retardamento imputável à máquina judiciária. Inexistirá tal efeito se a demora for atribuível ao próprio exequente (v.g., deixando de fornecer cópia da inicial ou de administrar recursos ao oficial de justiça ou, como no caso julgado pelo STJ,²¹⁷ descurando providenciar a citação por carta, no prazo assinado pelo relator).

3. Prescrição da pretensão a executar – A análise do art. 802 não ficaria completa sem o esclarecimento do prazo de prescrição da pretensão a executar.

A pretensão de executar prescreve no prazo da ação (Súmula 150 do STF). Tal prazo varia conforme a natureza do título. Por exemplo, quanto ao cheque, veja-se o art. 59 da Lei 7.357, de 02.09.1985; tocante à nota promissória à vista, a pretensão a executar prescreve em três anos, contado o prazo, se o título não for apresentado, do término do prazo de apresentação de um ano.²¹⁸ O art. 206, § 3.º, VIII, do CC estipula o prazo de três anos para a prescrição da “pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial”. Assim, continua em vigor, relativamente ao cheque, o mencionado art. 59 da Lei 7.357/1985. Já em cinco anos prescreverá a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, a teor do art. 206, § 5.º, I, do CC. Enfim, há que consultar múltiplas e variadas disposições da lei material.

A regra de que a citação interrompe a prescrição aplica-se à execução fundada em título extrajudicial e nos títulos judiciais arrolados no art. 515, § 1.º. Em todas essas hipóteses, há citação no processo executivo, retroagindo o efeito interruptivo à data em que o juiz deferiu a petição inicial ou o “requerimento”.

Não há dúvida que, do título previsto no art. 515, I, surge uma nova pretensão, a pretensão a executar, que prescreverá em prazo idêntico ao previsto para a pretensão a condenar (Súmula 150 do STF). Tecnicamente, no cumprimento do provimento civil exequível, há cumulação sucessiva de pretensões, *in simultaneo processu*. Rejeita-se, firmemente, a noção simplista e errônea de que se cuida de “incidente”. Se a prescrição atinge a pretensão, a teor do art. 189 do CC, e incumbe ao executado alegar prescrição, desde que superveniente à sentença, conforme estabelece o art. 525, § 1.º, VII, então a prescrição atingirá uma nova pretensão – a mencionada pretensão a executar. Sucede que, no cumprimento da decisão proferida no processo civil, em sentido largo, a citação “inicial” ocorreu no processo que gerou o pronunciamento exequendo. No entanto, a pretensão a executar prescreve, e a execução pode não ser proposta muito tempo após a exigibilidade da obrigação, conforme antevê o art. 513, § 4.º, exigindo a intimação pessoal do executado por meio de carta com aviso de recebimento, presumindo-se a validade da entrega no endereço constante nos autos, pois é dever da parte mantê-lo atualizado (art. 77, V). Resta estabelecer com nitidez e segurança termo inicial do prazo prescricional.

Ora, nos termos do art. 189 do CC, a pretensão a executar surgirá na data em que o direito for violado. Nos direitos de crédito, então, a pretensão a executar surge com o inadimplemento. Não há inadimplemento antes da liquidação (*in illiquis mora non fit*). Logo, condenado o vencido a quantia líquida, ou promovida a liquidação da condenação genérica, há de ser intimado para cumprir a decisão, nos termos do art. 513, § 2.º, e, daí, fluirá o prazo previsto no art. 523, *caput* (e, acrescente-se, findo este fluirá o prazo para impugnar, a teor do art. 525, *caput*). Esse prazo de espera impede a prática dos atos executivos, salvo mediante tutela provisória. Assim, após o transcurso desse prazo sem pagamento, fluirá o prazo de prescrição estabelecido na lei

material.²¹⁹ No caso da pretensão de contas, vigoroso estudo sustenta a necessidade de não dissociar a pretensão inicial da declaração de prestar contas,²²⁰ o que representaria caso excepcional. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão a executar demonstra a superlativa importância do termo inicial do prazo de quinze dias previsto no art. 523, *caput*.

Estabelecido o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão a executar, no cumprimento da sentença, a literalidade do art. 802, *caput*, resolve a questão subsequente, justificando o exame do assunto nesse contexto. Considerar-se-á interrompida a prescrição na data da “propositura da execução, deferida pelo juiz”, ou seja, o deferimento do “requerimento”. Por exemplo: o art. 516, parágrafo único, permite a propositura da execução no lugar do domicílio atual do executado. Figure-se, então, a hipótese de o vitorioso propor a execução em São Paulo, embora o processo tramitasse no Rio de Janeiro. Deferida a execução pelo juízo de São Paulo, opera-se a interrupção.

A prescrição, que no crédito fiscal, a teor do art. 156, V, do CTN, alcançava a dignidade de causa extintiva do próprio direito, decreta-se de ofício, embora haja necessidade de prévio debate das partes (art. 487, II, e parágrafo único).

Em princípio, entendia-se inexistente a pretensão intercorrente, porque a demanda do processo executivo deriva dos entraves da máquina judiciária, à qual o credor é alheio, e, além disso, o credor exerceu sua pretensão *opportuno tempore*. Também não corria o prazo prescricional durante a suspensão processo, porque inexistentes bens penhoráveis.²²¹ Outro é o entendimento correto.

O direito pátrio já reconhecia, implicitamente, o encobrimento da pretensão a executar no curso da execução, de resto natural, porque nenhuma disposição consagrava o princípio da perpetuação da ação (*perpetuatio actionis*). Era intercorrente, indubitavelmente, a prescrição que o executado poderá alegar nos embargos à adjudicação ou à alienação coativa (art. 746, *caput*, do CPC/1973), porque fundado o remédio em causa extintiva da obrigação, “desde que superveniente à penhora”. E a Súmula 314 do STJ reconheceu, explicitamente, o fenômeno no caso de inexistência de constrição: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. O STJ mandou aplicar essa regra no caso de créditos de pequeno valor da Fazenda Pública, a teor do art. 20 da Lei 10.522/2002.²²² A ampliação do objeto da exceção de pré-executividade, passando-se a admitir a alegação de exceções substanciais dotadas de prova pré-constituída, baseou-se, justamente, na alegação da prescrição intercorrente, que hoje cabe ao órgão judiciário pronunciar *ex officio*.

O fundamento da fluência prescrição no curso do processo de execução imobilizado, isto é, da prescrição intercorrente, localiza-se na necessidade social de não expor o executado, indefinidamente, aos efeitos da litispendência no caso de execução infrutífera.²²³ E, ademais, essa fluência harmoniza-se com o direito fundamental processual à duração razoável do processo.²²⁴

Tais razões conduziram ao reconhecimento explícito da prescrição intercorrente. A última forma desse assunto resulta do art. 921, §§ 1.º, 4.º e 5.º, c/c art. 924, V. Inexistindo bens penhoráveis (art. 921, III), o juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano, reza o art. 921, § 1.º, no curso do qual não fluirá a prescrição intercorrente, e, findo este, determinará o arquivamento dos autos (art. 921, § 1.º), sem baixa na distribuição, podendo os autos serem desarquivados, a qualquer tempo, surgindo bens penhoráveis (art. 921, § 3.º). E uma vez transcorrido o prazo de um ano do art. 921, § 1.º, fluirá o prazo prescricional (v.g., no caso do cheque, é brevíssimo, a teor do art. 59 da Lei 7.357/1985). Vencido o prazo, ouvidas as partes (art. 921, § 5.º), o juiz extinguirá a execução com fundamento na prescrição intercorrente (art. 924, V). Retomar-se-á o assunto no capítulo da suspensão do processo de execução.

4. Prevenção no processo executivo – A prevenção fixa a competência de um órgão judiciário perante quaisquer outros quando todos, em tese, mostrarem-se competentes.²²⁵

Para essa finalidade, impõe-se investigar quando ocorreu a propositura, pois esta, e não a ulterior citação do executado, é que, comparada à do outro processo, fornecerá o dado temporal

que definirá a competência de certo órgão judiciário. Segundo o art. 59, o registro da causa, ou sua distribuição, onde houver mais de um juízo, torna prevendo o juízo. O CPC/ 2015 eliminou a antiga duplicidade de critérios quando os juízos se localizavam, ou não, na mesma comarca ou seção judiciária.

É no juízo prevento, definido pela propositura (art. 312, 1.^a parte), que se reunirão as demandas conexas (art. 58 c/c art. 55, *caput*), aplicando-se esse regime: (a) à execução de título extrajudicial e a demanda relativa ao mesmo ato (*rectius*: negócio) jurídico; (b) a duas ou mais execuções fundadas no mesmo título (art. 55, § 2.º, I e II). O regime também se aplica aos casos do art. 516, § 1.º (v.g., o ilícito penal provocou danos em A, que deduziu pretensão a executar no juízo X, e em B, que demandou no juízo Y, devendo as execuções reunirem-se no juízo pendente, o do primeiro registro ou distribuição, a teor do art. 59).

Considerando os vínculos mais ou menos próximos da demanda executória com outros processos, agrupados sob o rótulo de conexão, a prevenção se mostra particularmente importante.

5. Litispendência do processo executivo – O art. 240, *caput*, regula o fenômeno da litispendência no tocante à demanda executória. Duas observações se impõem: (a) chamada de litispendência, a rigor, um dos seus efeitos: a proibição de renovar demanda em curso (art. 337, § 1.º); (b) o veto à repetição da demanda em curso nasce para o exequente no momento da propositura, e, não, da citação do executado, como se subentende do art. 240, *caput*. A partir desse momento, com efeito, fica-lhe interdito repetir a pretensão a executar, quicá pretendendo escolher o juízo mais conveniente, desistindo da primeira execução. Nessa hipótese, haverá distribuição por dependência ao juízo prevento, nos termos do art. 286, II.

6. Litigiosidade e indisponibilidade patrimonial relativa – É comum relacionar litigiosidade e fraude à execução no âmbito do processo executivo. Entretanto, são coisas diferentes.²²⁶

Em primeiro lugar, o art. 109 aplica-se ao processo executivo, em virtude da integração das normas processuais. Fixada essa premissa, cabe extremar a alienação do direito litigioso da alienação dos bens sujeitos aos atos executivos. Litigioso, na execução, porque ainda insatisfeito, é o crédito objeto do processo. Tal objeto é cessível, e nesta hipótese incide o art. 109, autorizando o cessionário a pleitear seu ingresso na relação pendente, seja substituindo o cedente, se o executado anuir com a substituição, seja assistindo-o, no caso de ocorrer motivada recusa ao câmbio de partes. Ademais, créditos comportam cessão antes do início do processo executivo, legitimando o cessionário a executar, a teor do art. 778, § 1.º, III, c/c § 2.º.

Nada obstante esses eventos, por óbvio lícitos, poderá suceder fraude contra execução, ou seja, a subtração de algum bem sujeito a meio executório, que é ilícita. Um exemplo torna a distinção mais simples: o réu, derrotado na demanda condenatória, pode transmitir convencionalmente a obrigação de entregar o bem, conforme o comando da sentença, e, então, alienará (licitamente) objeto litigioso; se, porém, alienar a terceiro o próprio bem, frauda a execução na forma do art. 792, I.²²⁷

Importante é esclarecer que a litigiosidade, no processo executivo, analogamente ao que se passa no processo de cognição, inicia com a propositura perante o exequente e subordinam-se à citação no caso do executado (art. 240, *caput*). Ao invés, os atos caracterizadores da fraude à execução podem ser anteriores ou posteriores a este momento, em virtude da peculiar extensão assumida pelo art. 792, IV. Diz-se, então, existir indisponibilidade relativa do patrimônio do executado, porque atos fraudulentos se apresentam ineficazes perante o exequente, conquanto existentes, válidos e eficazes entre os figurantes do negócio.

7. Constituição em mora no processo executivo – Dentre os efeitos arrolados no art. 240, *caput*, encontra-se a constituição em mora do réu. Tal efeito não se aplica ao processo executivo. A pretensão a executar nasce do inadimplemento imputável seja qual for o título, judicial ou não, e, por essa razão, o art. 240, *caput*, ressalva o disposto nos artigos 397 e 398 do CC. Logo, antes da propositura da ação, mister o devedor inadimplir a obrigação ou, como reza o art. 788, 1.^a parte, “o credor não poderá iniciar a execução”. Em verdade, o art. 240, *caput*, incidirá nos casos em que

não há necessidade de prévio inadimplemento, consoante já se ensinava no direito anterior.²²⁸

No entanto, a citação suprirá eventual inércia do credor na constituição em mora, máxime nas hipóteses de mora *ex persona*.

Vale recordar que, nas dívidas em dinheiro, o inadimplemento rende juros moratórios (art. 404, *caput*, do CC), os quais não dependem de pedido explícito (art. 322, § 1.º). Ao invés, os juros compensatórios, decorrentes do uso do capital, porventura previstos no título executivo, necessitam de postulação expressa.²²⁹ Também exige pedido inequívoco a taxa de juros e a sua capitalização, consoante a forma legalmente aceita,²³⁰ assim como a indenização suplementar aos juros moratórios (art. 404, parágrafo único, do CC).

Art. 803. É nula a execução se:

I – o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II – o executado não for regularmente citado;

III – for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

1. Generalidades – Pouco discrepa da disciplina das invalidades no processo executivo do esquema geral. Entenda-se bem: invalidade é o estado subsequente à decretação do vício do ato processual, porque antes dessa pronúncia existe ato defeituoso.²³¹

Esse tema controverso, mas consideravelmente simplificado na concepção prevalecente, apresenta duas complicações adicionais, encarado na perspectiva mais ampla da atividade executiva, a saber: (a) a repercussão da invalidade do processo anterior ao surgimento da pretensão a executar (v.g., a inexistência ou invalidade da citação, ficando revel o réu, hipótese de oposição à execução fundada em título judicial, a teor do art. 525, § 1.º, I, e art. 535, I); (b) a circunstância de a execução fundar-se sempre em título executivo, trazendo à tona, embora assunto alheio à atividade processual,²³² heterogêneo regime dos vícios no plano material (v.g., a falta de data na nota promissória, título extrajudicial previsto no art. 784, I), tão amplo e variado quanto o catálogo do art. 784. É bem de ver que, no processo de execução do Livro II do da Parte Especial do CPC só este último problema assume relevo.

A problemática dos atos processuais defeituosos situa-se, sistematicamente, no âmbito dos pressupostos processuais objetivos intrínsecos à relação processual. Fórmula genérica, compreende nessa classe de pressupostos como “ausência de nulidades e vícios em geral dos atos processuais”.²³³ São os vícios formais, não importando os vícios atinentes aos sujeitos do processo (v.g., ato processual praticado por incapaz sem representação).²³⁴ Em tal hipótese, o processo é regular e isento de *errores in procedendo*.

2. Classificação das invalidades – Impende realizar algumas distinções e fixar determinadas premissas para chegar a um esquema classificatório adequado dos vícios dos atos processuais. Inicialmente, cumpre separar entre os planos da existência, da validade e da eficácia, porque o ato inexistente não é inválido. E, nesses planos, impõe-se identificar rigorosamente os elementos de existência, os requisitos de validade e os fatores de eficácia.

O ato inválido se distingue do ato inexistente, porque o ato inválido, embora viciado ou deficiente, existe (= ingressou no mundo jurídico, embora deficientemente) e produzirá os efeitos que lhe são próprios até sua desconstituição; ao invés, o ato inexistente não surte efeitos jurídicos. O ato deficiente se desconstitui e o ato inexistente se declara como tal.²³⁵

A inexistência representa tão-só dado referencial e nesse pormenor, embora evidente, residem todos os equívocos nesta matéria. A inexistência oferece o contraste preciso e imprescindível à

configuração dos atos inválidos. De modo algum desaparece ela na eventual primazia dada à tutela da aparência.²³⁶ Ocorre justamente o contrário: sem a subentendida existência jurídica, não caberia emprestar tutela aparente (ou não real).²³⁷

Inadmissível afigura-se equiparar inexistência e nulidade absoluta, misturando os planos, na suposição de que a inexistência “exprime não tanto a inidoneidade do ato para produzir efeito, quanto, ao contrário, a de recuperar tal efeito”.²³⁸ Mas, o defeito do ato inexistente é de tal ordem que nenhuma consideração merece do juiz.²³⁹

O processo de execução comporta atos inexistentes. O rascunho do auto de arrematação (art. 903), modelo ofertado ao serventuário para redigir o ato real, e por equívoco juntado ao processo, carece de elemento básico para existir e entrar no mundo jurídico, ainda que deficientemente.

Passando ao plano da validade, o primeiro passo consiste em distinguir o ato irregular do ato inválido. Todo ato processual reclama requisitos necessários e úteis para ingressar eficientemente no mundo jurídico. Requisito necessário é o tecnicamente indispensável à finalidade prática do ato; requisito útil somente auxilia tal objetivo.²⁴⁰ Exemplo de requisito útil, por sem dúvida aplicável à demanda executória, localiza-se no art. 211, que exige dos atos e termos processuais os requisitos da (a) completude (= inexistência de espaços em branco, salvo inutilizados) e da (b) limpeza (= inexistência de entrelinhas, emendas e rasuras).

A inobservância de requisito útil implica simples irregularidade do ato processual.²⁴¹ Cuida-se de vício não-essencial e, nessa contingência, a apuração do defeito prescinde de qualquer regularização do ato. Assim, a confecção do edital de hasta pública pelo leiloeiro (art. 886), rebelde à tarefa menor de publicá-lo (art. 885, I), emprestando-lhe a mais ampla divulgação (art. 887, *caput*), mas dotado o documento de todos os requisitos legais, constitui simples irregularidade, prescindindo de invalidação e repetição, porque representaria simples obséquio à forma pela forma.

Mas, o reconhecimento pelo juiz de que o ato processual praticado em desconformidade ao modelo legal desobedeceu a requisito necessário (vício essencial) acarretará sua invalidação. “A invalidade”, ensina a maior autoridade brasileira do tema,²⁴² “não se identifica com o vício, mas é o estado consequente à decretação judicial”. E rememore-se que atos viciados podem produzir efeitos. Dizer que o nulo não produz efeitos é mais que erro de perspectiva, antes é fantasia, a cada passo desmentida pela subsequente invalidação.

Essas considerações preparam a classificação dos vícios essenciais. Encontra-se satisfatoriamente explicada por esquema seguro, concebido e aplicado desde a vigência CPC/1939.²⁴³ Segundo esse esquema, o ato está acometido de (a) nulidade absoluta quando há violação da norma cogente,²⁴⁴ cujos fins abrigam interesse público; (b) nulidade relativa, se a norma infringida for cogente, porém tutela interesse da parte;²⁴⁵ e, por fim, se a norma violada for dispositiva, haverá (c) anulabilidade.²⁴⁶

Por conseguinte, as nulidades absoluta e relativa têm em comum o desrespeito à norma cogente; porém, distinguem-se quanto ao saneamento: infração a gabarito informado pelo interesse público jamais convalidará. Quando muito, superado o prazo da ação rescisória (art. 966),²⁴⁷ ficará encoberta a pretensão ao desfazimento do vício. Ao invés, tutelado o interesse da parte, há convalidação do ato. Por esse motivo, não se mostra aceitável a generalização de as nulidades na execução jamais precluírem.²⁴⁸

E há outra discriminação relevante quanto ao regime da iniciativa para invalidar o ato. Da nulidade absoluta, vício particularmente grave, e da nulidade relativa o juiz conhecerá de ofício. Em relação à última, entretanto, ocorre preclusão quanto à possibilidade de o interessado alegá-la (art. 278, *caput*). Por conseguinte, nenhum vínculo obrigatório há entre preclusão e o caráter absoluto da nulidade: aquele fenômeno só atinge as faculdades das partes, jamais os poderes do juiz. A anulabilidade dependerá de requerimento para ser pronunciada.

Essa distinção permite esclarecer, desde logo, o sentido e o alcance do art. 803, parágrafo único,

segundo o qual determinados vícios do processo de execução serão pronunciados pelo órgão judiciário ou a requerimento da parte. Tal circunstância isolada não enquadra necessariamente os vícios arrolados no art. 803 como nulidades absolutas, cabendo identificar, antes disso, o interesse público ou privado tutelado pela regra. Tampouco se infere que, nada requerendo o interessado, não ocorra preclusão – por óbvio, no tocante à iniciativa da parte.

O art. 803 exige uma distinção subsequente, identificando a nulidade (a) cominada e (b) não cominada. Parece evidente haver cominação de nulidade nas hipóteses do art. 803 – v.g., se o executado não foi regularmente citado no processo de execução.

Cominada é a nulidade em que regra explícita estipula a consequência do vício.²⁴⁹ Exemplo disso se observa no art. 279: nulo se mostrará processo no qual, apesar de devida nos casos do art. 178, inexistiu intervenção do Ministério Público, de resto, hipótese concebível na execução, demonstrando que o art. 803 não esgota, absolutamente, os casos de cominação de nulidade no âmbito executivo. E nulidade não cominada é todo vício destituído dessa previsão.

O critério classificatório difere substancialmente e, ainda, revela-se muito diverso do precedente, que identificou as espécies da nulidade absoluta, da nulidade relativa e da anulabilidade. E, com efeito, o caráter cogente da norma não implica cominação.²⁵⁰ Por isso mesmo, nulidades cominada e absoluta não se confundem,²⁵¹ embora, às vezes, concorram as hipóteses,²⁵² a exemplo do disposto no art. 64, § 4.º.

Às nulidades cominadas se aplicam, outrossim, os princípios da finalidade e do não prejuízo (art. 282). Cominando nulidades, o legislador emite juízo *a priori* de frustração do fim;²⁵³ porém, a verificação do prejuízo e da quebra de finalidade importa juízo *a posteriori*, e, por isso, “a invalidade só será inevitável, em processo, quando, além de cominada, for absoluta a nulidade”, e, ainda nesse caso, mais por absoluta do que por cominada.²⁵⁴

Essas precisões todas possuem tremenda importância na execução, pois o art. 803 do CPC/2015 comina nulidades.

3. Nulidades cominadas no processo de execução – O art. 803 comina nulidades na execução. Elas comportam controle de ofício e, como visto, significam presunção de falta de consecução do fim. Mas, só a existência e validade da citação tutelam interesse público, porque a convocação do executado ao juízo constitui expressão do direito fundamental processual à ampla defesa, inserindo-se, concomitantemente, na classe da nulidade absoluta. E isso porque a ampla defesa, ensejada pela citação válida, é informada por essa espécie de interesse.

3.1. Falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo – O art. 803, I, comina nulidade ao processo executivo fundado em título (que expressa a obrigação) despidos dos caracteres reclamados pelo art. 783: certeza, liquidez e exigibilidade.

Os atributos da obrigação prevista no título executivo “devem se verificar no momento inicial da execução forçada, não naquele em que se formou o título”.²⁵⁵ Essa assertiva é particularmente verdadeira para a exigibilidade e a liquidez, decorrentes de eventos supervenientes (v.g., o advento do termo e a liquidação, respectivamente), porque a certeza da obrigação, consistente na sua cabal individualização no título, há de ser intrínseca à formação do título.

É lícito ao executado arguir a nulidade do art. 803, I, a qualquer tempo e ao juiz pronunciá-la de ofício,²⁵⁶ na própria execução (art. 518) – por exemplo, a alegação de pagamento, mediante prova pré-constituída –,²⁵⁷ independentemente de embargos (art. 803, parágrafo único). Nada obsta, evidentemente, a alegação do vício no remédio hábil para o executado se opor à pretensão a executar, respectivamente a impugnação (art. 525), no cumprimento da sentença, e os embargos,²⁵⁸ no processo de execução.

Em geral, problemas relativos à certeza da obrigação envolvem a própria exequibilidade do título. A inexecutabilidade do contrato de abertura de crédito em conta corrente (Súmula 233 do STJ) envolveu antes um problema de existência da obrigação do que de liquidez, mas, igualmente,

o vício da execução fundada nesse título quadra-se na hipótese do art. 803, I. No que tange ao cumprimento da sentença, dentre outras hipóteses podem se mencionar: (a) pretensão a executar deduzida antes de a sentença condenatória emitida contra a Fazenda Pública submeter-se ao reexame necessário do art. 496; (b) a pretensão a executar deduzida, antes do respectivo trânsito em julgado, nos casos previstos no art. 2.º-B da Lei 9.494/1997, ou seja, quando tenha por objeto a inclusão de benefício pecuniário em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento e extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive das respectivas autarquias e fundações.²⁵⁹

E são variados os casos em que à obrigação falta liquidez. Exemplo corriqueiro é o de apuração do *quantum debeatur*, todavia adstrita a operações aritméticas (art. 786, parágrafo único) sob outros aspectos (v.g., juros moratórios e correção monetária), subordinar-se a dados não previstos no título (v.g., *A* obrigou-se a pagar a *B* o valor do terreno *X*, que seria avaliado mediante arbitramento de terceiro, engenheiro já designado ou que as partes se obrigaram a designar oportunamente).

Os problemas atinentes à exigibilidade decorrem (a) ou da iliquidez (*in illiquidis mora non fit*) (b) ou da falta de verificação do termo ou da ocorrência da condição, razão por que há relativa sobreposição entre os incisos I e III do art. 803.

Em virtude da colocação sistemática dessa matéria, respeitante aos pressupostos processuais objetivos intrínsecos à relação processual, sentença que pronuncie a nulidade da execução por vício do título extinguirá o processo de execução sem julgamento do mérito (art. 485, IV). Logo, em princípio inexistirá impedimento resultante da autoridade da coisa julgada para o credor ajuizar nova execução, suprida a omissão (art. 486, *caput*, e § 1.º).²⁶⁰ Em determinados casos, porém, a falta de atributos do título é definitiva, não comportando suprimento ulterior. Vale o exemplo do título em que a apuração do *quantum debeatur* depende de arbitramento por especialista.

3.2. Citação inexistente ou nula do executado – O processo de execução do Livro II da Parte Especial do CPC/2015 completa-se pela angulação obrigatória (art. 312). A relação linear exequente-Estado não alcança a esfera do executado, não produzindo os efeitos próprios do art. 240. Relação processual executória completa instaurar-se-á, pois, somente através da citação válida do executado.

O chamamento a que se refere o art. 803, II, é o da própria execução, realizado em conformidade a um dos modos admitidos, geralmente – a preferência é manifestada em diversas disposições, a exemplo do art. 829, § 1.º, que alude a “mandado de citação” – por oficial de justiça, mas nada pré-exclui, v.g., a citação postal ou a citação eletrônica, e, naturalmente, preenchidos os pressupostos legais, a citação por edital. Convém assinalar que há necessidade de citação do executado no cumprimento de sentença, a teor do art. 515, § 1.º, tanto que se baseie a execução na sentença penal, na sentença arbitral, na sentença ou decisão estrangeira e, apesar da omissão do texto, no autocomposição judicial homologada, por identidade de motivos.

Nula é a citação realizada em desacordo com o gabarito legal. Por exemplo, o mandado de citação não advertiu o executado quanto ao prazo para embargos, conforme exige o art. 250, II. Inexistente é a citação que, simplesmente, não se realizou, a exemplo do edital de citação jamais publicado.

A citação nula vicia todos os atos subsequentes do processo, sem que seja viável controlar os efeitos da moléstia como se se tratasse de focos de uma epidemia.²⁶¹ Cuida-se de elemento constitutivo da existência dos demais atos do processo executivo,²⁶² embora hipótese mais afeiçoada à ineficácia. Deverá o juiz, pronunciando a invalidade, ordenar a repetição da citação e dos atos subsequentes (art. 282, *caput*), fatalmente contaminados pelo vício do ato cronologicamente anterior.

3.3. Falta de verificação do termo ou da ocorrência de condição – Eventualmente, a obrigação subordina-se a termo, ou seja, a evento futuro e certo (v.g., *A* pagará *X* a *B* no dia *Y*), ou a condição, quer dizer, a evento futuro e incerto (v.g., *A* pagará *X* a *B* quando realizar a messe). A

verificação do termo ou a ocorrência da condição emprestam exigibilidade à obrigação prevista no título executivo. Sob tal aspecto, o art. 803, III, é tautológico, porque ambas as situações são enquadráveis no art. 803, I.

É ônus do exequente ministrar prova, na petição inicial, da verificação desses eventos (art. 798, II, c), se for o caso. É que o termo, na sua modalidade mais comum, constitui fato segundo as regras da experiência comum, bastando consultar o calendário gregoriano (v.g., a nota promissória emitida por B em favor de A venceu no dia 25.3, deduzindo A pretensão a executar em 27.4). Porém, a morte da pessoa natural é evento futuro e certo, cuja verificação é desconhecida, cabendo ao exequente ministrar a prova hábil – certidão de óbito – se pretender executar o contrato de seguro previsto no art. 784, VI. Já a condição, por sua própria natureza, subordina-se à produção de prova pré-constituída.

Execução proposta antes do advento do termo ou da condição é prematura. Eventual extinção, decretada nos próprios autos do processo executivo, ou no remédio pelo qual o executado se opôs à pretensão a executar (impugnação ou embargos), não impede a renovação da ação oportunamente.

4. Forma e momento do controle das nulidades – Dependendo o controle do vício do ato processual da iniciativa da parte, seja exclusiva (anulabilidade), seja supletiva (nulidade absoluta e relativa), há dois caminhos para o executar realizar a alegação: (a) os embargos à execução (ou, no cumprimento da sentença, por meio da impugnação dos arts. 525 e 535), em que assunto é implicitamente previsto; (b) simples requerimento, na própria execução, como sugere o art. 808, parágrafo único, *in fine*.

Esta última via, permitindo invalidar atos ou conjunto de atos na própria relação processual – e constitui excesso exigir a alegação por uma das modalidades de oposição do vício –, logrou exata afirmação pelo STJ:

Não se revestindo o título de liquidez, certeza e exigibilidade, condições basilares exigidas no processo de execução, constitui-se em nulidade, como vício fundamental, podendo a parte argui-la, independentemente de embargos do devedor, assim como cumpre ao juiz declarar, de ofício, a inexistência desses pressupostos formais contemplados na lei processual civil.²⁶³

Nos embargos, o valor formal do título, nos seus aspectos intrínseco (validade e eficácia) ou extrínseco (qualidade do documento), constitui uma das razões mais invocadas, e, hoje, expressamente prevista no art. 917, I.²⁶⁴ O vício reflexo, aquele derivado da nulidade do negócio jurídico antecedente ou causa da formação do título, é “o que revela maiores possibilidades e abertura sistemática”.²⁶⁵

É preciso considerar que, cuidando-se de nulidade relativa ou de anulabilidade, incumbe ao interessado alegá-la na primeira oportunidade (art. 278, *caput*), sob pena preclusão, sem prejuízo, no caso da nulidade relativa, da subsistência da possibilidade de atuação *ex officio* do órgão judiciário. Ora, qualquer que seja o caminho escolhido, a fixação de prazo para a oposição do executado (embargos ou impugnação, conforme a natureza do título) predetermina, correlatamente, a oportunidade da alegação. Vencido o interregno de quinze dias, prazo uniformemente previsto para os embargos e a impugnação, embora varie o termo inicial, ocorrerá preclusão, inclusive para a alegação na própria execução (art. 803, parágrafo único).

Do órgão judiciário espera-se que emita juízo de admissibilidade da pretensão a executar, porque o título reúne os atributos do art. 783, abrangendo, portanto, as hipóteses versadas no art. 803, I e III, desde o primeiro contato com a petição inicial. Também lhe cabe, realizada a citação por um dos meios admissíveis, conferir a validade do ato tão logo se encontre documentado no processo para os fins do art. 803, II, mandando repetir o ato se constatar vício. Esse é o quadro ideal. Nada impede que, passando despercebido o vício no primeiro momento, posteriormente reexamine o assunto. Não há, pois, oportunidade rígida para o controle oficial dos vícios do art. 803.

5. Preclusão no controle das nulidades – Exceção feita à nulidade absoluta, e dentre as hipóteses arroladas no art. 803 esse é o caso da inexistência ou da nulidade da citação, exigida no processo de execução e no cumprimento de determinados títulos judiciais (art. 515, § 1.º), desaparecerá a possibilidade de a parte alegar o vício, em virtude da preclusão desse poder processual. Como assinalado no item anterior, a primeira oportunidade para alegação do vício (art. 278, *caput*), exaure-se com o vencimento do prazo de embargos ou de impugnação, conforme a natureza do título, inclusive no tocante ao controle incidental (art. 518 e art. 803, parágrafo único).

Os poderes do juiz não precluem, exceto verticalmente (preclusão hierárquica, pois ao juiz não é dado modificar o julgado do órgão *ad quem*), razão por que poderá apreciar ou reapreciar nulidades que lhe tocam conhecer mesmo à falta de instância da parte, incluindo as nulidades do art. 803.

Art. 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado.

§ 1.º A alienação de bem objeto de promessa de compra e venda ou cessão registrada será ineficaz em relação ao promitente comprador ou ao cessionário não intimado.

§ 2.º A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído direito de superfície, seja do solo, da plantação ou da construção será ineficaz em relação ao concedente ou concessionário não intimado.

§ 3.º A alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado.

§ 4.º A intimação de imóvel sobre o qual tenha sido instituída enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso será ineficaz em relação ao enfiteuta ou ao concessionário não intimado.

§ 5.º A alienação de direitos do enfiteuta, do concessionário de direito real de uso ou de concessionário de uso especial para fins de moradia será ineficaz em relação ao proprietário do respectivo imóvel não intimado.

§ 6.º A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído usufruto, uso ou habitação será ineficaz em relação ao titular desses direitos reais não intimado.

1. Ineficácia da alienação coativa – A eficácia da alienação coativa, por quaisquer das modalidades previstas no art. 825, I e II, subordina-se à prévia intimação da penhora das pessoas arroladas no art. 799, I a XI. E, ademais, consoante o art. 899, hão de ser intimados, com cinco dias de antecedência, também (a) o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal (art. 899, II); e (b) a União, o Estado-membro, o Município, e, *a fortiori*, o Distrito Federal, recaindo a penhora sobre bem tombado (art. 889, VIII). O direito que compete ao terceiro preterido é heterogêneo. O credor real tem o direito de receber seu crédito no concurso especial de credores. Nos demais casos, há direito de preferência (= aquisição do bem em igualdade de condições com terceiro), como sucede no caso dos sócios da sociedade limitada ou da companhia de capital fechado, recaindo a penhora sobre quota ou ação (art. 861, § 7.º), geralmente tendente a consolidar a propriedade, como é o caso do usufrutuário, apesar de inexistir disposição inequívoca a esse respeito, e do superficiário ou o titular da nua propriedade (art. 1.373 do CC).²⁶⁶

Esse assunto já recebeu comentários no art. 799, inclusive destacando a circunstância de a intimação do concessionário, no caso de uso especial para fins de moradia, revelar-se supérflua, pois o terreno é de propriedade de pessoa jurídica de direito público, e, portanto, impenhorável.

O art. 804, c/c art. 903, § 1.º, II, declara ineficaz a alienação coativa perante o terceiro não intimado. Isso significa que o negócio jurídico existe, vale e produz efeitos entre seus participantes, o Estado, de um lado, que sub-rogou o poder de disposição do executado, alienando

o bem penhorado, e o arrematante. Em consequência, o direito do terceiro subsiste à alienação forçada e, se for o caso, especialmente no caso de preferência, poderá ser pleiteado por via de ação autônoma.

2. Meios da declaração da ineficácia – O art. 903, § 2.º, autoriza o órgão judiciário decidir acerca da ineficácia da alienação coativa perante o terceiro não intimado no prazo de dez dias após a assinatura do auto de arrematação (art. 903, § 2.º), e, por identidade de razões, do auto de adjudicação (art. 877, § 1.º) e do termo de alienação (art. 880, § 2.º). Em idêntico prazo, o arrematante poderá desistir da aquisição, alegando e provando “a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital” (art. 903, § 5.º, I). Desse modo, a ineficácia é causa de dissolução do negócio entre o Estado e o adquirente, restituindo as coisas ao estado anterior – o preço será imediatamente devolvido ao arrematante, reza o art. 903, § 5.º, *in fine* –, propiciando, então, o exercício do direito que toca ao terceiro.

Findo o prazo de dez dias, e expedida a carta de arrematação (ou de adjudicação e de alienação), ou a ordem de entrega do bem móvel, o art. 903, § 4.º, autoriza a invalidação da arrematação por meio de ação autônoma. Ora, a invalidação só tem cabimento no caso de vício, conforme estipula o art. 903, § 1.º, I. No caso da ineficácia do art. 903, § 1.º, II, cuidar-se-á de pretensão à declaração da ineficácia, e, se for o caso, cumulada com o exercício da preferência. Em todo o caso, o adquirente figurará como litisconsorte necessário e, perdido o bem, tem direito de reaver o preço do exequente e, subsidiariamente, recaindo este em insolvência, do Estado.

É singular a posição do credor real. Também no seu caso a alienação é ineficaz (art. 804, *caput*), movida a execução sobre o bem gravado por outro credor, quirografário ou não, e não sendo intimado previamente da penhora (art. 799, I), e, *in extremis*, da alienação (art. 889, V). O bem continua objeto do gravame real, e, portanto, o direito do respectivo titular não será prejudicado. Ao contrário, talvez lhe seja economicamente desvantajoso receber seu crédito antecipadamente. Assim, não é de se excluir a possibilidade de permanecer inerte, inexistindo interesse em mover qualquer ação em juízo. Interessará mais ao arrematante, que pagou pelo bem livre de gravame, haja vista o princípio da cobertura, desfazer o negócio, invocando o art. 903, § 1.º, II, no prazo de dez dias (art. 903, § 2.º), ou por meio de ação autônoma (art. 903, § 4.º).

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena da manutenção dos atos executivos já determinados.

1. Princípio da economia na execução – Em contraponto ao princípio de a execução realizar-se em proveito do exequente (art. 797, *caput*), porque sujeito o executado à eficácia do título executivo, art. 805, *caput*, institui o princípio da economia na execução. Incumbe ao órgão judiciário, reza o art. 805, *caput*, ordenar que a atividade executiva se desenvolva pelo modo menos gravoso ao executado. Cuida-se de dever do órgão judiciário.

Em princípio, a execução há de ser específica. Logra pleno sucesso a atividade executiva ao entregar ao exequente o bem da vida, objeto da prestação inadimplida. Realizará, então, máxima célebre, assim expressa: “O processo deve dar, quanto for possível praticamente, a quem tenha um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tenha direito de conseguir”.²⁶⁷

Em situações variadas, limitações de ordem prática se antepõem a esse objetivo. A operação dos meios executórios sofre injunções práticas e políticas. A falta de localização da coisa, por exemplo, constrange o exequente a contestar-se com o equivalente pecuniário (art. 809, *caput*), e o motivo é, nesse caso, prático. Embora o executado responda com seu patrimônio pelo cumprimento da obrigação (art. 789), razões políticas asseguram o mínimo existencial ao executado, estabelecendo extenso rol de bens impenhoráveis (arts. 833 e 834), subtraindo-os, por conseguinte, da responsabilidade patrimonial, e, nesse caso, o motivo é político.

Também responderá o executado por todas as despesas do processo.²⁶⁸ A máquina judiciária não se movimenta de graça e, caso o executado não arcasse com tais ônus, não se restauraria, integralmente, o direito do exequente. Em várias disposições, as despesas do processo e os honorários do advogado do exequente são carreados ao executado (v.g., art. 826, no caso de remição da execução). Só se admitem exceções explícitas (v.g., o art. 888, parágrafo único, carrega as despesas da nova publicação do edital de arrematação a quem deu causa, culposamente, ao adiamento do ato, indicando o escrivão ou chefe de secretaria e o leiloeiro).

Nada obstante, o art. 805, *caput*, declara que a execução haverá de impor ao devedor os menores sacrifícios.²⁶⁹ A enunciação do princípio da responsabilidade patrimonial (art. 789), dissociando a dívida (pessoal) da responsabilidade (patrimonial), representou o primeiro e maior passo no sentido de humanizar a atividade executória. Coerente à progressiva adequação do débito à responsabilidade do executado, a execução é hoje parcial, ou seja, limita-se ao necessário e suficiente para solver a dívida (art. 831). Nenhum ato inútil, a exemplo da penhora de bens de valor insignificante e incapaz de satisfazer o crédito (art. 836, *caput*), poderá ser consumado. Outro exemplo significativo, nas culminâncias da expropriação, consiste no veto à alienação dos bens penhorados por preço vil (art. 891, *caput*), embora seja discutível a fixação do percentual de cinquenta por cento do valor da avaliação. É preciso refrear o intento de executar bens, ponderava-se já no século XIX,²⁷⁰ e o art. 805, *caput*, adverte o órgão judicial para semelhante dever. O emprego do verbo em caráter imperativo, na disposição comentada, revela a possibilidade de o juiz agir de ofício.²⁷¹

Em síntese, o art. 805, *caput*, assenta em dois pilares autônomos: (a) a dignidade da pessoa humana, freando a atuação dos meios executórios; (b) o caráter patrimonial da execução.²⁷² Quer dizer, a execução há de realizar o direito do exequente de forma justa e equilibrada.

Como quer que seja, o princípio da economia, ressalva feita àquelas hipóteses em que a lei, explicitamente, previu a benesse, cede à necessidade de realizar o crédito. Exemplar mostra-se o julgado do STJ que entreviu o ponto de equilíbrio:

A determinação de que a execução se faça pelo modo menos oneroso para o devedor nada tem a ver com o valor do débito a ser ressarcido. O direito do credor há de ser integralmente satisfeito. Para isso, serão usados, tanto quanto possível, os meios menos gravosos.²⁷³

2. Aplicação do princípio da economia – O art. 805 aplica-se, unicamente, ao processo executivo. Neste sentido, decidiu o STJ que o princípio da menor onerosidade não interessa ao processo de conhecimento.²⁷⁴

A tutela do executado encontra-se, de ordinário, prevista em vários dispositivos legais, e, nesta contingência, caberá ao juiz velar pela sua observância. Esmerou-se a doutrina em identificá-los,²⁷⁵ valendo assinalar os seguintes exemplos, já adaptados à disciplina em vigor: (a) a proibição da penhora inútil, ou seja, aquela em que o produto da alienação será absorvido pelas despesas (art. 836, *caput*); (b) o direito de substituir o bem penhorado (art. 847); (c) a exigência de adequação da penhora, limitando-se ela aos bens suficientes à satisfação da dívida (art. 831); (d) a proibição da arrematação a preço vil (art. 891); (e) a interrupção da arrematação tão logo seu produto baste à satisfação do credor (art. 899); (f) a reunião, no edital de arrematação, de listas referentes a mais de uma execução (art. 887, § 7.º); e assim por diante.

Nada obstante, o art. 805, *caput*, incide, rigorosamente, quando “por mais de um modo puder ser realizada” a execução (art. 798, II, *a*). Existem créditos que dispõem de dois ou mais meios executórios, e, portanto, podem se realizar de vários “modos”. Por exemplo, executam-se alimentos através de desconto em folha (art. 912), coerção pessoal (art. 911) e expropriação (art. 913). É preciso que a opção do exequente considere os pressupostos de cabimento de cada meio executório.

E, de um modo mais geral, compete ao órgão judicial controlar “o modo de controlar cada espécie”.²⁷⁶ É verdade que o dispositivo incide a quaisquer atos executivos. Nesse caso, entretanto, o art. 805, parágrafo único, reclama a cooperação do executado para o bom desempenho do dever

do órgão judicial, indicando-lhe “outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Na realidade, constitui ônus do executado demonstrar, concretamente, o prejuízo advindo do ato executivo.²⁷⁷ Não basta alegação genérica. Dois casos são significativos nesse particular. Em primeiro lugar, o art. 829, § 2.º, autoriza o executado, antes de a penhora realizar sobre os bens porventura indicados pelo exequente na petição inicial (art. 798, II, c), indicar outros bens, demonstrando que “a constrição lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”. Por exemplo, o exequente indica ativos financeiros, reclamando a aplicação do art. 854, e o executado contrapõe-lhe a penhora de títulos da dívida pública com cotação no mercado (art. 835, II), penhora menos onerosa, porque não lhe prejudica a atividade econômica, e, por definição, igualmente satisfatória na perspectiva da célere realização do crédito. Ademais, o art. 835, § 2.º, repele a preferência da penhora de dinheiro, equiparando ao dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial. Adotou orientação condizente com a Súmula 417 do STJ, segundo a qual a penhora de dinheiro não é prioridade absoluta, contrapondo-se à orientação, seguidamente combatida com a invocação da regra predecessora ao art. 805, que rejeitava a substituição do dinheiro por essas garantias.²⁷⁸

É na substituição da penhora por iniciativa do executado (art. 847), portanto, que se evidencia a tensão entre o princípio da economia e o da efetividade da tutela executiva. E, geralmente, o executado não obtém sucesso, porque sua pretensão inviabiliza a realização do crédito. Por exemplo, a substituição do dinheiro penhorado, ou de outro bem, pelo contracrédito contemplado em precatório, em desacordo com a ordem legal do art. 11 da Lei 6.830/1980, não constitui direito do executado e a rejeição não viola o art. 805.²⁷⁹

É digno de registro o desdobramento do princípio da economia, internamente aos casos legalmente consagrados de *favor debitoris*. Invocou-se a regra, à guisa de exemplo, para impedir a penhora de outros bens além dos gravados por penhor.²⁸⁰ Esta orientação se harmoniza com a melhor aplicação do princípio previsto no art. 805.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo civil*, vol. 6, n. 1.399, p. 599.

2

Enrico Tullio Liebman, *Processo de execução*, n. 82, p. 184.

3

Peter Arens, *Zivilprozessrecht*, § 74, III, n. 610, p. 386-387.

4

Francesco Menestrina, *L'acessione nell'esecuzione*, p. 26.

5

José João Baptista, *Acção executiva*, n. 47, p. 147.

6

Sérgio Sahione Fadel, *Código de Processo Civil comentado*, vol. 2, p. 178.

7

Galeno Lacerda, *O novo Código de Processo Civil e os feitos pendentes*, n. 11, p. 61.

8

Antonio Dall'Agnol, *Concurso particular de preferências*, n. 5, p. 55.

9

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.414, p. 606.

10

Amílcar de Castro, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 8, n. 190, p. 136.

11

José Maria Tesheiner, *Do concurso especial de credores no Código de Processo Civil de 1973*, n. 1, p. 105.

12

Araken de Assis, *Concurso especial de credores no CPC*, n. 8, p. 70.

13

Em sentido contrário, Amílcar de Castro, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 8, n. 191, p. 136.

14

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 11. No direito português, Miguel Teixeira de Sousa, *Ação executiva singular*, p. 251.

15

Francisco Antonio de Oliveira, *A penhora erigida à posição de direito real*, n. 6, p. 251.

16

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.422, p. 611.

17

Athos Gusmão Carneiro, *Do interesse de agir no curso universal de credores*, p. 25-35.

18

STJ, REsp. 1.499-PR, 03.09.1989, 3ª Turma, Rel. Min. Waldemar Zveiter, *EJSTJ*, 3/175.

19

N. Doreste Baptista, *Do processo de execução*, n. 88, p. 140-141. Osvaldo Moreira Antunes, *O credor hipotecário e o concurso singular de credores*, n. 17, p. 273. Em sentido diverso, Arnaldo Marmitt, *A Penhora*, p. 183-188.

20

Humberto Theodoro Júnior, *Curso de direito processual civil*, vol. 3, n. 290, p. 393.

21

STJ, REsp. 11.657-SP, 19.08.1992, 2ª Turma, Rel. Min. Pádua Ribeiro, *RJSTJ*, 43/315.

22

STJ, Resp. 1.288.150-MG, 15.12.2011, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJE* 02.12.2012.

23

STJ, REsp. 280.871-SP, 05.02.2009, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, *DJE* 23.03.2009.

24

STJ, AgRg no REsp 1.491.126-RS, 18.12.2014, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJE* 19.12.2014.
STJ, REsp 1.678.879-SP, 03.10.2017, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, *DJE* 17.10.2017.

25

Araken de Assis, *Concurso especial de credores*, n. 17.7, p. 178-183.

26

STJ, AgRg 17.063-SP, 02.06.1992, 3ª Turma, Rel. Min. Nilson Naves, *DJU* 29.06.1992, p. 30.316.

27

Ovídio A. Baptista da Silva, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 11, p. 303-307; Galeno Lacerda e Carlos Alberto A. de Oliveira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, n. 106, vol. 8, t. 2, p. 79-80.

28

STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.190.055-MG, 11.10.2016, 4.^a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, *DJE* 21.10.2016; AgRg no REsp. 902.536-RS, 27.03.2012, 4.^a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, *DJE* 11.04.2012; STJ, REsp. 2.435-0-MG, 01.12.1994, 4.^a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, *DJU* 16.10.1995, p. 34.663.

29

STJ, REsp. 31.475-RN, 29.06.1993, 3.^a Turma, Rel. Min. Waldemar Zveiter, *RJSTJ* 51/260.

30

Antonio Dall'Agnol, *Concurso particular de preferências*, n. 6, p. 59.

31

STJ, AgInt no REsp 1.161.821-SP, 07.06.2016, 4.^a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, *DJE* 17.06.2016; REsp. 1.209.807-MG, 15.12.2011, 3.^a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, *DJE* 15.02.2012.

32

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 12; Amílcar de Castro, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 8, n. 194, p. 139.

33

Amílcar de Castro, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 8, n. 193, p. 138.

34

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.424, p. 612.

35

Francesco Menestrina, *L'accessione nell'esecuzione*, p. 41.

36

Idem, p. 49.

37

Ernane Fidélis dos Santos, *Manual de direito processual civil*, vol. 3, n. 1.259, p. 228.

38

Bernardo Teixeira de Moraes Leite Velho, *Monographia jurídica e prática das execuções de sentenças em processo civil*, p. 317, *in verbis*: “Labirinto lhe chamava os antigos reinícolas, e antiga legislação, e labirinto realmente é”.

39

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 255.

40

STJ, REsp. 42.878-5-SP, 25.10.1994, 3ª Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, *DJU* 28.11.1994, p. 32.615.

41

Rodrigo Benevides de Carvalho, *O concurso particular de credores na execução*, n. 23, p. 127.

42

Araken de Assis, *Concurso especial de credores no CPC*, n. 25.7.2, p. 264-267.

43

José Maria Rosa Tesheiner, *Considerações sobre o conceito de execução no processo civil*, p. 193-200.

44

Theodoro Jr., *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 4, n. 196, p. 268.

45

Araken de Assis, *Concurso especial de credores no CPC*, n. 17.7, p. 178-182.

46

Paulo Furtado, *Execução*, n. 187, p. 247; Amílcar de Castro, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 8, n. 193, p. 139; Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 13.

47

De Plácido e Silva, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 4, n. 2.694, p. 2.105.

48

Osvaldo Pinto do Amaral, *Código de Processo Civil comentado*, vol. 5, n. 383, p. 371.

Carvalho Santos, *Código de Processo Civil interpretado*, vol. 10, p. 303.

Leonardo Greco, *O processo de execução*, vol. 2, n. 8.5.3, p. 443; Rodrigo Benevides de Carvalho, *O concurso particular de credores na execução*, n. 24, p. 131.

Em sentido contrário, José Maria Rosa Tesheiner, *Do concurso especial de credores no Código de Processo Civil de 1973*, n. 3, p. 106.

STJ, CC 632-AL, 22.05.1990, 1ª Seção, Rel. Min. Jesus Filho, *RJSTJ* 13/67.

Ernane Fidélis dos Santos, *Manual de direito processual civil*, vol. 3, n. 1.259, p. 226-227.

No direito italiano, Giancarlo Giannozzi, *Appunti per un corso di diritto processuale civile*, n. 31, p. 96-97.

STJ, REsp. 978.522-SP, 02.02.2010, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrigli, *DJE* 25.02.2010.

Pleno do STF, CC 6.602-PR, 06.08.1986, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr., *RTJSTF* 119/609.

STJ, CC 1.246-PR, 13.03.1991, 2ª Seção, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, *DJU* 08.04.1991, p. 3.863.

STJ, CC 2.295-PR, 11.12.1991, 2ª Seção, Rel. Min. Athos Gusmão Carneiro, *RJSTJ* 31/93.

Milton Flaks, *Comentários à lei de execução fiscal*, n. 294, p. 284.

60

Araken de Assis, *Concurso especial de credores no CPC*, n. 23.1.1, p. 219.

61

Antônio Dall'Agnol, *Concurso particular de preferências*, n. 6, p. 57.

62

Frederico Marques, *Manual de direito processual civil*, vol. 4, n. 901, p. 210.

63

Francesco Menestrina, *L'accessione nell'esecuzione*, p. 94.

64

Antônio Dall'Agnol, *Concurso particular de preferências*, n. 6, p. 57.

65

STJ, AgRg no AREsp. 712.475-RS, 17.09.2015, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, *DJE* 26.09.2015.

66

STJ, REsp. 21.881-4-SP, 08.06.1992, 3ª Turma, Rel. Min. Dias Trindade, *DJU* 03.08.1992, p. 11.316.

67

STJ, REsp. 1.209.807-MS, 15.12.2011, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, *DJE* 15.02.2012; STJ, REsp. 2.258-0-RS, 30.06.1992, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, *DJU* 14.12.1992, p. 23.924.

68

Ernane Fidélis dos Santos, *Manual de direito processual civil*, vol. 3, n. 1.259, p. 225.

69

Trajano de Miranda Valverde, *Comentários à lei de falências*, vol. 2, n. 778, p. 165.

70

José Roberto dos Santos Bedaque, *Poderes instrutórios do juiz*, n. 3.3.1, p. 61-66; Vicente Miranda, *Poderes do juiz no processo civil brasileiro*, p. 147; Afrânio Silva Jardim, *Da publicização do processo civil*, p. 105; Antônio Dall'Agnol, *O princípio dispositivo no pensamento de Mauro Cappelletti*, p. 97-115.

71

Robert Winess Millar, *Los principios formativos del procedimiento civil*, p. 81.

72

STJ, REsp. 57.798-5-SP, 04.09.1995, 1ª Turma, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, *DJU* 25.09.1995, p. 31.078.

73

STJ, REsp. 940.274-MS, C. Especial, 07.04.2010, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, *RJSTJ*, 219/35.

74

Marcos Destefenni, *Curso de processo civil*, vol. 2, p. 101.

75

Leo Rosenberg, Eberhard Schilken e Hans Friedhelm Gaul, *Zwangsvollstreckungsrecht*, § 5.º, II, 1, p. 49.

76

Maria Elisabeth de Castro Lopes, *O princípio do contraditório na execução*, n. 4, p. 324.

77

Vide Fernando Amâncio Ferreira, *Curso de processo de execução*, n. 24, p. 79.

78

Miguel Teixeira de Souza, *Acção executiva singular*, § 4.º, II, 2.1, p. 39-40; J. P. Remédio Marques, *Curso de processo executivo comum*, n. 12.1, p. 136.

79

Zaiden Geraige Neto, *Reflexão sobre algumas alterações introduzidas pela Lei 11.232/2005*, n. 9, p. 923.

80

STJ, REsp. 547.317-RJ, 26.09.2006, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, *DJU* 18.10.2006, p. 228.

81

Cássio Scarpinella Bueno, *Curso sistematizado de direito processual civil*, vol. 3, p. 38-39.

82

Fernando Luso Soares, *Direito processual civil*, vol. 1, p. 242.

83

Evaristo Aragão Santos, *Anotações sobre os contornos da execução baseada em título extrajudicial, após a Lei 11.382/2006*, n. 3, p. 774.

84

Araken de Assis, *Processo civil brasileiro*, vol. 1, n. 247, p. 715-726.

85

Paulo Furtado, *Execução*, n. 139, p. 183; Theodoro Jr., *Processo de execução*, p. 145; Ernane Fidélis dos Santos, *Aplicação subsidiária de normas do processo de conhecimento no processo de execução*, n. 9, p. 44.

86

José Augusto Delgado, *Novos aspectos da execução fiscal*, n. 1, p. 198.

87

Daniel Roberto Hertel, *Curso de execução civil*, n. 12.2.1.1, p. 148.

88

Nelson Palaia, *Técnica da petição inicial*, n. 9, p. 21.

89

Petrucio Ferreira, *Aplicação subsidiária do art. 282 do CPC ao processo de execução*, p. 233.

90

STJ, REsp 13.810-DF, 01.09.1992, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, *DJU* 21.09.1992, p. 15.695.

91

Othmar Jauernig, *Zivilprozessrecht*, § 18, II, 1, p. 54.

92

STJ, REsp 879.113-DF, 01.09.2009, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrigli, *DJU* 11.09.2009.

93

STJ, REsp. 201.838-RS, 16.08.1999, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, *RJSTJ*, 127/276.

94

STJ, RMS 2.741-SP, 08.06.1994, 1ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, *DJU* 15.08.1994, p. 20.295.

95

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 4, p. 12.

96

Ernane Fidélis dos Santos, *Aplicação subsidiária de normas do processo de conhecimento no processo de execução*, n. 9, p. 44.

97

Juvêncio Vasconcelos Viana, *A causa de pedir nas ações de execução*, n. 3.6, p. 105.

98

Carlos Silveira Noronha, *A causa de pedir na execução*, n. 5, p. 35-36.

99

Luiz Rodrigues Wambier, *Sentença civil: liquidação e cumprimento*, n. 3.1.1, p. 112.

100

STJ, REsp. 31.164-RJ, 20.11.1995, 2ª Turma, Rel. Min. Hélio Mosimann, *DJU* 04.12.1995, p. 42.100.

101

Em sentido contrário, no regime anterior, Leonardo Greco, *O processo de execução*, vol. 1, p. 354–356.

102

Neste aspecto, diversamente, Flávio Yarshell, *A reforma da execução civil e a cobrança de prestações periódicas*, n. 2, p. 348.

103

José Miguel Garcia Medina, *Execução civil*, p. 94.

104

José Carlos Barbosa Moreira, *O novo processo civil brasileiro*, p. 18.

105

Luiz Caetano de Salles, *O valor da causa e seus reflexos no processo civil*, n. 16, p. 64.

106

José Miguel Garcia Medina, *Execução civil*, p. 96.

107

STJ, REsp. 36.687-BA, 11.10.1993, 4ª Turma, Rel. Min. Fontes de Alencar, *RJSTJ* 54/342.

108

Milton Flaks, *Comentários à lei da execução fiscal*, n. 166, p. 173-174; Costa e Silva, *Teoria e prática do processo executivo fiscal*, n. 86, p. 202-205.

109

Sergio La China, *L'esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di procedura civile*, p. 451.

110

TARS, Ag. 189078330, 3.ª Câm. Cív., 07.03.1990, Rel. Araken de Assis.

111

STJ, AgRg no REsp 1.559.824-MG, 03.12.2015, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, *DJE* 11.12.2015.

112

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 413, p. 173.

113

Werter Faria, *Ações cambiárias*, n. 76, p. 127-132.

114

Egberto Lacerda Teixeira, *A nova lei brasileira do cheque*, n. 113, p. 84-85.

115

STJ, EREsp. 431-RS, 25.10.2000, 2ª Seção, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, *DJU* 18.12.2000, p. 151.

116

STJ, REsp. 1.138.202-ES, 09.12.2009, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, *DJU* 01.02.2010.

117

STJ, EREsp. 442.087-RS, C. Especial, 04.08.2004, Rel. Min. Franciulli Netto, *DJU* 06.12.2004, p. 184.

118

STJ, EREsp. 442.637-RS, 23.04.2008, 3ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, *DJE* 07.08.2008.

119

STJ, REsp. 158.146-MG, 19.02.1998, 4ª Turma, Rel. Min. Ruy Rosado, *DJU* 20.04.1998, p. 96.

120

STJ, REsp. 469.677-RS, 18.05.2006, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, *DJU* 03.08.2006, p. 246.

121

STJ, AgRg no REsp. 848.025-MG, 04.12.2012, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo Filho, *DJE* 04.02.2013.

122

Artur Anselmo de Castro, *A acção executiva singular, comum e especial*, n. 82, p. 379.

123

STJ, REsp. 468.249-SP, 05.08.2003, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrigli, *DJU* 01.09.2003, p. 281.

124

Cláudio Zarif, *Questões relativas à citação com hora certa*, n. 3, p. 241-246. No mesmo sentido, Rogério Licastro Torres de Mello, *Notas sobre a citação na nova execução de título extrajudicial*, n. 2, p. 500-501.

125

Eduardo Fortunato Bim, *A admissibilidade da citação por hora certa no processo de execução*, n. 7, p. 75.

126

José Horácio Cintra Gonçalves Pereira, *Da citação ficta no processo de execução*, n. 7, p. 266.

127

STJ, REsp. 1.103.050-BA, 25.03.2009, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJE 06.04.2009.

128

Clito Fornaciari Jr., *Citação pelo correio*, p. 96-102; Alcides Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.435, p. 616.

129

Athos Gusmão Carneiro, *Da citação pelo correio na justiça comum*, p. 59-61.

130

TARS, Ag. 190088757, 3.ª Câm. Cív., 22.08.1990, Rel. Araken de Assis.

131

STJ, REsp. 44.756-9-RJ, 28.03.1994, 3ª Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 20.06.1994, p. 16.102.

132

Roger Perrot e Philippe Théry, *Procédures civiles d'exécution*, n. 328, p. 347.

133

A respeito das origens desse convênio, Fátima Nancy Andrigli, *A gênese do sistema “penhora online”*, p. 386-388.

134

Para uma crítica desse pormenor, Eduardo Cambi, *Apontamentos sobre a reforma da execução*, n. 2.4, p. 745.

135

Fernando Sacco Neto, *Bancos de dados de proteção ao crédito, execução civil e economia*, n. 4, p. 384. Em sentido diverso, preocupado com as consequências do bloqueio, Valton Pessoa, *O convênio Bacen-jud e o princípio da razoabilidade*, n. 7, p. 352.

136

Neste sentido, Carla Maria Krieger de Valle, *Meios coercitivos de execução – Penhora online*, n. 5.5, p. 56.

137

STJ, REsp. 1.112.943-MA, C. Especial, 15.09.2010, Rel. Min. Nancy Andrighi, *RJSTJ*, 221/169. No mesmo sentido, STJ, no AgRg no AREsp. 92.688-RJ, 04.09.2104, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, *DJE* 17.04.2014.

138

Bruno Freire e Silva, *O bloqueio online e a necessária aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade*, n. 4, p. 112.

139

Vide Alberto Caminã Moreira, *O Barão de Mauá e a segurança do juízo para oferecimento de embargos*, p. 3-5.

140

Guilherme Goldschmidt, *A penhora online no direito processual brasileiro*, n. 9.5, p. 77-79.

141

Por exemplo, Elaine Harzheim Macedo, *Penhora online: uma proposta de concretização da jurisdição executiva*, n. 5, p. 471-472.

142

Mantovanni Colares Cavalcante, *A penhora de parcela de faturamento de empresa e suas restrições*, n. 3, p. 312-313.

143

Roger Perrot e Philippe Théry, *Procédures civiles d'exécution*, n. 341, p. 360.

144

Nesse sentido, Márcio Manoel Maidame, *Impenhorabilidade e direitos do credor*, n. 8.3, p. 314.

145

Humberto Theodoro Júnior, *A penhora online e alguns problemas gerados pela sua prática*, n. 4, p. 20-22.

146

José João Baptista, *Processo civil – I*, n. 70, p. 369.

147

Carlos Alberto Garbi, *Relação jurídica de direito real e usufruto*, n.º 16.3, p. 204.

148

Ricardo Arcoverde Credie, *Bem de família*, n. 6.3, p. 45.

149

Pleno do STF, REsp 87.958-EDv/RJ, 17.11.1979, rel. Min. Cordeiro Guerra, DJU 16.12.1979, p. 1874. Vide, José Osório de Azevedo Júnior, *Compromisso de compra e venda*, n. 59, p. 92-95.

150

Vide, Paulo Dias de Moura Ribeiro, *Compromisso de compra e venda*, p. 74.

151

Araken de Assis, *Manual da execução*, n. 620.5, p. 1720-1721.

152

Rodrigo Mazzei, *Direito de superfície*, n. 8.2.1.5, p. 244-255.

153

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, *Direitos reais*, n. 3.1.2, p. 560.

154

Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*, vol. 18, § 2.179, p. 158.

155

Idem, p. 157.

156

Sérgio Iglesias Nunes de Souza, *Direito à moradia e de habitação*, n. 10.10, p. 316-318.

157

José dos Santos Carvalho Filho, *Manual de direito administrativo*, p. 744-745.

158

STJ, AgRg no REsp 345.392-SP, 13.03.2007, 4.^a Turma, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, *DJU* 02.04.2007, p. 274.

159

STJ, REsp. 7.862-SP, 10.06.1992, 1.^a Turma, rel. Min. Garcia Vieira, *RJSTJ* 36/309.

160

Eduardo Melo de Mesquita, *As tutelas de urgência na execução civil*, n. 5, p. 117-119.

161

Marcelo Abelha, *Manual de execução civil*, p. 164.

162

STJ, REsp 59.593-2-MG, 29.03.1995, 1.^a Turma, rel. Min. Garcia Vieira, *RJSTJ* 73/400.

163

Rita Quartieri, *Tutelas de urgência na execução civil*, p. 47-98.

164

STJ, REsp 1.737-MA, 14.03.1990, 2.^a Turma, rel. Min. Ilmar Galvão, *RJSTJ* 13/302.

165

STJ, REsp 1.935-MA, 20.02.1990, 3.^a Turma, rel. Min. Nilson Naves, *RJSTJ* 10/441. Na doutrina, Maria Lúcia L. C. de Medeiros, *Execução e embargos à execução*, p. 123.

166

STJ, REsp 547.317-RJ, 26.09.2006, 2.^a Turma, rel. Min. Humberto Martins, *DJU* 18.10.2006, p. 228.

167

Theodoro Jr., *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 4, n. 202, p. 273.

168

Júlio César Souza Rodrigues, *Medidas acautelatórias no processo de execução*, n. 3.5, p. 79.

169

170

Vide, Orlando Gomes, *Obrigações*, n. 32, p. 48.

171

José Carlos Barbosa Moreira, *A tutela específica do credor nas obrigações negativas*, p. 30-44.

172

Giuseppe Borrè, *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, p. 126-139. Em sentido contrário, Virgilio Andrioli, *Commento al Codice di Procedura Civile*, vol. 3, p. 325; Crisanto Mandrioli, *L'esecuzione forzata in forma specifica*, n. 14, p. 68.

173

Michele Giorgianni, *L'obbligazione*, p. 234-243.

174

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.693, p. 708.

175

Vide, Cândido Rangel Dinamarco, *Execução civil*, n. 193, p. 312-313.

176

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 48.

177

Idem, p. 79.

178

Orlando Gomes, *Obrigações*, n. 31, p. 47; Almeida Costa, *Direito das obrigações*, n. 61, p. 487-490.

179

Lacerda de Almeida, *Obrigações*, § 23, p. 98-109. Sobre os diferentes valores da moeda, Antunes Varela, *Das obrigações em geral*, vol. 1, n. 210, p. 706-709.

180

Orlando Gomes, *Obrigações*, n. 38, p. 58.

181

STJ, REsp 804.791-MG, 03.09.2009, Rel. Min. Nancy Andrighi, *DJE* 25.09.2009.

182

Segundo Vittorio Denti, *L'esecuzione forzata in forma specifica*, n. 61, p. 211, isto se deve à necessidade de determinar a qualidade e o modo de ser da prestação, ou seja, sua fungibilidade ou não.

183

Sobre a regra *nemo praecisecogi potestad factum*: Eugène Garsonnet e Charles Cézard-Bru, *Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale*, vol. 4, n. 8, p. 14-18; Charles Demolombe, *Cours de Code de Napoléon*, vol. 24, n. 488, p. 480-482; Charles Aubry e Frédérique-Charles Rau, *Cours de droit civil français*, vol. 4, § 299, p. 61-62; Charles Beudant, *Cours de droit civil français*, vol. 8, n. 438, p. 317-318. O domínio de aplicação da *astreinte* é destacado por René Demogue, *Traité des obligations en général*, vol. 6, n. 509, p. 544-547.

184

Contra, em termos, Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.792, p. 738.

185

Humberto Theodoro Jr., *Processo de execução*, p. 225.

186

Maria Helena Diniz, *Curso de direito civil*, vol. 2, p. 94.

187

João de Castro Mendes, *Acção executiva*, n. 10, p. 33.

188

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 375, p. 162.

189

STF, REsp 111.535-MG, 23.10.1987, 2.^a Turma, rel. Min. Francisco Rezek, *RTJSTF* 123/718.

190

Teori Albino Zavascki, *Título executivo e liquidação*, p. 152.

191

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 9, p. 124.

192

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 381, p. 164-165; Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 9, p. 124; José Frederico Marques, *Manual de direito processual civil*, vol. 4, n. 781, p. 63.

193

Teori Albino Zavascki, *Título executivo e liquidação*, p. 153.

194

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 9, p. 122.

195

Teori Albino Zavascki, *Título executivo e liquidação*, p. 154.

196

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 9, p. 121; Teori Albino Zavascki, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 8, p. 100.

197

Amílcar de Castro, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 8, n. 203, p. 143.

198

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.452, p. 622.

199

Giuseppe Chiovenda, *Instituições de direito processual civil*, vol. 3, n. 285, p. 12.

200

STJ, REsp. 156.116-MG, 05.06.1998, 3.^a Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter, DJU 08.06.1998, p. 97.

201

Calmon de Passos, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 3, n. 159, p. 219.

202

STJ, REsp 49.910-MT, 14.11.1995, 3.^a Turma, rel. Min. Nilson Naves, *DJU* 05.02.1996, p. 1384.

203

STJ, AgRg no REsp 1.053.201-RJ, 02.09.2008, 2.^a Turma, rel. Min. Humberto Martins, *DJE* 19.09.2008.

204

STJ, REsp 469.677-RS, 18.05.2006, 2.^a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, *DJU* 03.08.2006, p. 246.

205

Costa e Silva, *Teoria eprática do processo executivo fiscal*, n. 88.2, p. 210-211.

206

Ernane Fidélis dos Santos, Aplicação subsidiária de normas do processo de conhecimento no processo de execução, n. 12, p. 44.

207

Luiz Guilherme Paiva Vianna, O saneamento do processo de execução, n. 6, p. 649.

208

TARS, Ag 189090848, 01.11.1989, 3.^a Câ. Cív., rel. Araken de Assis.

209

TARS, Ap 191115260, 13.11.1991, 7.^a Câ. Cív., rel. Araken de Assis.

210

Neste sentido, porém, Willis Santiago Guerra, *Aspectos da execução forçada no sistema processual brasileiro*, n. 4, p. 64.

211

STJ, RMS 3.315-SP, 05.02.1996, 6.^a Turma, rel. Min. William Patterson, *DJU* 01.04.1996, p. 9941.

212

Calmon de Passos, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 3, n. 121, p. 169.

213

Costa e Silva, *Teoria e prática do processo executivo fiscal*, n. 86, p. 203.

214

Moniz de Aragão, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, n. 445, p. 335.

215

STJ, RMS 42-MG, 30.10.1989, 4.^a Turma, rel. Min. Athos Gusmão Carneiro, *EJSTJ* 1/149.

216

Em doutrina, Antonio Dall'Agnol, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 3, n. 65.7, p. 290.

217

STJ, AgRg 108-MG, 11.12.1991, 2.^a Seção, rel. Min. Nilson Naves, *RJSTJ* 39/17.

218

STJ, REsp. 409-RJ, 19.09.1989, 3.^a Turma, rel. Min. Cláudio Santos, *RJSTJ* 4/1.581. Contra o Estado, a prescrição da pretensão a executar é 5 anos: STJ, REsp. 15.213-SP, 01.03.1993, 1.^a Turma, rel. Min. Gomes de Barros, *RJSTJ* 47/186.

219

Marcos Destefenni, *A prescrição superveniente à sentença*, n. 5, p. 476-477.

220

Humberto Theodoro Júnior, *Ação de prestação de contas – força executiva da sentença – prescrição*, n. 8, p. 544-546.

221

STJ, REsp 93.250-PR, 26.08.1996, 4.^a Turma, rel. Min. Fontes de Alencar, *DJU* 04.11.1996, p. 42840.

222

STJ, REsp 1.102.554-MG, 27.05.2009, 1.^a Seção, rel. Min. Castro Meira, *DJE* 08.06.2009.

223

Ernesto José Toniolo, *A prescrição intercorrente na execução fiscal*, p. 112.

224

Arlete Inês Aurelli, *Uma revisita ao tema da prescrição intercorrente no âmbito do processo civil com ênfase no Código de Processo Civil projetado*, n. 2, p. 43.

225

José Carlos Barbosa Moreira, *O novoprocesso civil brasileiro*, p. 26.

226

Moniz de Aragão, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, n. 235, p. 179-180; José Maria Rosa Tesheiner, *Coisa litigiosa!*, p. 16.

227

Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, *Alienação da coisa litigiosa*, § 17, p. 132-140.

228

Moniz de Aragão, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, n. 236, p. 180-181.

229

Calmon de Passos, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 3, n. 151, p. 210.

230

TARS, Ag. 190120691, 24.10.1990, 3.ª Câ. Cív., rel. Araken de Assis.

231

Antonio Dall'Agnol, *Invalidades processuais*, n. 1.1, p. 14, e n. 5.2, p. 43.

232

Amílcar de Castro, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 8, n. 209, p. 147.

233

Galeno Lacerda, *Despacho saneador*, p. 69.

234

Vittorio Denti, *Nullità degli atti processuali civili*, n. 3, p. 470.

235

Antonio Dall'Agnol, *Invalidades processuais*, n. 2.1, p. 20; Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*, vol. 4, § 360, p. 20. Sobre as características do ato inexistente, Roque Komatsu, *Da invalidade no processo civil*, p. 164-165. Segundo a expressiva imagem de Maurino, *Nulidades procesales*, p. 25, o ato inexistente se sujeitaria a “una declaración de hipernulidad”.

236

Neste sentido, porém, Ovídio A. Baptista da Silva, *Curso de processo civil*, vol. 1, p. 169-170. A questão é metodológica, como explica Jorge P. Camusso, *Nulidades procesales*, p. 104-105, sendo inadmissível a “inexistência” para os adeptos da teoria pura do direito (Kelsen).

237

Antônio Dall'Agnol, *Invalidades processuais*, n. 2.1, p. 21.

238

Francesco Carnelutti, *Inesistenza dell'atto giuridico*, p. 208-210. No mesmo sentido, Theodoro Jr., *As nulidades no Código de Processo Civil*, n. 4, p. 41: “De qualquer maneira, a questão é puramente acadêmica, já que do ponto de vista prático os efeitos se equivalem, impedindo a formação da *res iudicata*”, em que o equívoco da equivalência é manifesto.

239

Enrico Redenti, *Diritto processuale civile*, vol. 1, n. 61, p. 226. Já Enrico Tullio Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. 1, n. 124, p. 214, diz que “si trovi di fronte ad una specie di fatto puramente illusoria”.

240

Francesco Carnelutti, *Sistema de derecho procesal civil*, vol. 3, n. 549, p. 561.

241

Neste sentido, Antônio Dall'Agnol, *Para um conceito de irregularidade processual*, n. 5, p. 99-100; Roque Komatsu, *Da invalidade no processo civil*, p. 168.

242

Antônio Dall'Agnol, *Invalidades processuais*, n. 5.2, p. 43.

243

Galeno Lacerda, *Despacho saneador*, p. 68; Moniz de Aragão, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, n. 346, p. 365-366; Hortencio Catunda de Medeiros, *Esquema de teoria geral do processo*, § 103, p. 84-85. Outra é a classificação de José Maria Rosa Tesheiner, *Elementos para uma teoria geral do processo*, n. 131-132. Vide, a crítica de Sálvio de Figueiredo Teixeira, *Prazos e nulidades em processo civil*, p. 38-40, que não distingue os planos de existência, de validade e de eficácia; e a de Aroldo Plínio Gonçalves, *Nulidades do processo*, p. 92, porque todas as normas processuais são de ordem pública, prevalecendo o interesse público em todas elas.

244

Galeno Lacerda, *Despacho saneador*, p. 72.

245

Idem, ibidem.

246

Idem, p. 73.

247

Antônio Dall'Agnol, *Invalidades processuais*, n. 6.1.2, p. 53, invocando nota de Galeno Lacerda, *Despacho saneador*, p. 72.

248

Neste sentido, porém, José Miguel Medina, *Execução. Nulidade. Inexistência de preclusão. Possibilidade de arguição dos vícios em embargos à arrematação*, p. 195.

249

Antônio Dall'Agnol, *Invalidades processuais*, n.º 8.1, p. 61; Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 3, p. 324-325.

250

Antônio Dall'Agnol, *Invalidades processuais*, n. 8.2, p. 62.

251

Antônio Dall'Agnol, *Invalidades processuais*, n. 8.3, p. 63-66. No mesmo sentido, Roque Komatsu, *Da invalidade no processo civil*, p. 212; Edson Ribas Malachini, *Das nulidades no processo civil*, n. 8, p. 22.

252

Antônio Dall'Agnol, *Invalidades processuais*, n. 8.3, p. 66.

253

Idem, n. 8.5.2, p. 72.

254

Ibidem, n. 8.5.2, p. 71.

255

Francesco Carnelutti, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. 1, n. 175, p. 271.

256

STJ, REsp 13.960-SP, 26.11.1991, 3.^a Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter, *RJSTJ* 40/447.

257

STJ, REsp 1.078.399-MA, 02.04.2013, 4.^a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, *DJE* 09.04.2013.

258

Theodoro Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 2, n. 774, p. 146-147.

259

STJ, AgRg no Resp 1.143.271-RS, 04.08.2015, 6.^a Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, *DJE* 20.08.2015.

260

STJ, REsp 38.471-MG, 07.03.1995, 3.^a Turma, rel. Min. Cláudio Santos, *DJU* 24.04.1995, p. 10404.

261

Enrico Tullio Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. 1, n. 121, p. 209.

262

Segundo Enrico Tullio Liebman, Nulidade da sentença proferida sem citação do réu, p. 179, “sem esse ato essencial não há verdadeiramente processo, nem pode valer a sentença que vai ser proferida”.

263

STJ, REsp 13.960-SP, 26.11.1991, 3.^a Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter, *RJSTJ* 40/447.

264

Francesco Bucolo, *La sospensione nell'esecuzione*, vol. 2, n. 133, p. 329.

265

Sergio La China, *L'esecuzione forzata e le disposizioni generali del Codice di Procedura Civile*, p. 464-465.

266

Humberto Theodoro Júnior, *Curso de direito processual civil*, vol. 3, n. 290, p. 393.

267

Giuseppe Chiovenda, *Instituições de direito processual civil*, vol. 1, n. 12, p. 84.

268

Enrico Tullio Liebman, *Processo de execução*, n. 48, p. 113.

269

José Frederico Marques, *Manual de direito processual civil*, vol. 4, n. 800, p. 85-86.

270

Édouard Bonnier, *Éléments de procédure civile*, vol. 1, n. 1, n. 1.294, p. 496.

271

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 43.

272

Sérgio Shimura, O princípio da menor gravosidade ao executado, n. 3, p. 539.

273

STJ, REsp. 62.327-SP, 10.12.1996, 3.^a Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, *RJSTJ*, 92/204.

274

STJ, REsp. 18.048-RJ, 26.10.1993, 4.^a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, *DJU* 29.11.1993, p. 25883.

275

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.502, p. 642-643.

276

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 42.

277

STJ, AgRg no REsp 1.526.305-SC, 21.05.2015, 2.^a Turma, rel. Min. Humberto Martins, *DJE* 29.05.2015.

278

STJ, AgRg no Resp 794.370-RJ, 15.12.2015, 3.^a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, *DJE* 03.02.2016.

279

STJ, REsp 1.337.790PR, 12.06.2013, 1.^a Seção, rel. Min. Herman Benjamin, *DJU* 07.10.2013.

280

STJ, REsp 87.878-MG, 21.05.1996, 3.^a Turma, rel. Min. Costa Leite, *RJSTJ*, 96/278.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. XIII - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO II - DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO

CAPÍTULO II. DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA

Capítulo II. Da execução para entrega de coisa

Seção I

Da entrega de coisa certa

Art. 806. O devedor da obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze dias), satisfazer a obrigação.

§ 1.º Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.

§ 2.º Do mandado de citação constará a ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfazer a obrigação no prazo que lhe foi designado.

1. Meios executórios na execução para entrega de coisa

A execução para entrega de coisa emprega o meio executório do desapossamento. É meio hábil para atingir o resultado prático almejado independentemente da participação do executado, inferindo-se do art. 806, § 2.º, seu emprego: o juiz ordenará, juntamente com a citação do executado para satisfazer a obrigação no prazo de quinze dias, a imissão na posse ou a busca e apreensão, respectivamente, da coisa imóvel e da coisa móvel visadas. Envolve operações relativamente simples, ao menos em contraste com a expropriação (art. 924), abrangendo quatro atividades diferentes, a saber: (a) procurar; (b) encontrar; (c) tomar; e (d) entregar a coisa ao exequente. No caso das coisas imóveis, simplifica-se a primeira atividade; relativamente às coisas móveis, entretanto, talvez se torne assaz árdua a primeira etapa, abstendo-se o executado de cooperar com o juízo da execução (v.g., não indicando a localização do veículo que, segundo as informações do departamento de trânsito, integra seu patrimônio e obrigou-se a entregar consoante a obrigação prevista no título executivo extrajudicial), senão a mais provável causa de frustração do desapossamento.

As atividades próprias do meio executório competem ao oficial de justiça (art. 782, *caput*). Ao menos no caso das coisas móveis, objeto de busca e apreensão, lícito cogitar-se da incidência do art. 536, § 2.º, exigindo-se a atuação, simultânea, de dois oficiais de justiça, aplicando-se, subsidiariamente, semelhante regra do cumprimento da sentença ao processo de execução, em virtude da integração das normas executivas.

O desapossamento apresenta abrangência mais larga do que deixa entrever o art. 806. É o meio próprio para a execução (ou cumprimento) das ações executivas (força executiva ou efeito executivo imediato), reais (v.g., a reivindicatória) ou pessoais (v.g., o despejo), adstritas ao procedimento comum ou previstas em procedimentos especiais. E, com efeito, as ações de reintegração de posse; de depósito; de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; de busca e apreensão de bem alienado com reserva de domínio; do comodante para reaver a coisa; de despejo; de nunciação de obra nova; de petição de herança; de imissão de posse; de divisão; e quaisquer outras em que o juízo de procedência já tem incluso o ato executivo. Essas ações, exemplificativamente arroladas, ostentam força executiva, e, não, simples efeito executivo, originando pretensão a execução. A distinção entre a ação executiva e ação condenatória não se

prende à realização dos atos executivos, inexistindo cumprimento voluntário, pelo vencido, *in simultaneo processu*. Do ponto de vista material – o que mais importa –, há força executiva porque o ato executivo recairá sobre coisa integrante da esfera jurídica do exequente.¹ Ao invés, nas ações de efeito executivo, porque sua força é condenatória, o ato executivo recairá sobre bens integrantes do patrimônio do executado, respeitado os limites e a função do princípio da responsabilidade patrimonial (art. 391 do CC).

A autonomia das ações de força executiva, relativamente ao seu cumprimento “forçado”, prescindindo da instauração de outro processo da natureza executiva e recaindo sobre bem integrante do patrimônio do exequente, consolidou-se em precedente do STJ: “Nas ações possessórias, a sentença de procedência tem eficácia executiva *lato sensu*, com execução mediante simples expedição e cumprimento do mandado”.²

Nas ações de força executiva também opera o meio executório do desapossamento, e, por isso, justifica-se a afirmação inicial, de que seu emprego não se limita às obrigações (de entrega de coisa) previstas em título extrajudicial. Por exemplo, o art. 65, *caput* e § 1.º, da Lei 8.245/1991 ao tratar do despejo, prevê o emprego da força, inclusive arrombamento, e a entrega dos móveis e utensílios ao depositário, “se não os quiser retirar o despejado”. Não se distinguem as ações de força executiva – v.g., a reintegração de posse – e ação executiva para entrega de coisa, nascida do efeito executivo de sentença condenatória ou de título extrajudicial, quanto ao mecanismo de cumprimento sub-rogatório. A diferença descansa na circunstância de o ato atingir o patrimônio do exequente (força executiva ou efeito executivo imediato) ou do executado (força condenatória ou efeito executivo mediato).

Em última análise, tudo dependerá do direito material litigioso: tratando-se de dever de prestar, convolar-se-á em condenação. E no caso das ações de força executiva, o ato encontra-se incluso no enunciado, prescindindo-se de qualquer iniciativa do exequente para o órgão judiciário expedir o mandado de imissão na posse ou de busca e apreensão, como sugere a redação do art. 538, *caput*. Em ambos os casos, o desapossamento ocorrerá dentro da relação processual originária, porque se cuida de “cumprimento” da sentença. É evidente, ainda, que tal efeito poderá ser antecipado, mediante tutela provisória antecipada, executando-se (“efetivando-se”) do mesmo modo.

Segundo a sistemática vigente, o “cumprimento” de todo e qualquer provimento, independentemente do direito material posto em causa, realizar-se-á no âmbito da própria relação processual originária. É lícito, por sem dúvida, o legislador reunir, *in simultaneo processu*, a cognição e a execução.³ Essa técnica não elimina a natureza do direito material. No caso de o vitorioso pôr em causa pretensão real, por exemplo, a penetração na esfera jurídica do vencido apanhará bem já individualizado, ilegitimamente na sua posse, e, nessa contingência, a tarefa do meio executório – idêntica à que desenvolveria no caso de um direito de crédito previsto em título extrajudicial – consiste em procurar, encontrar e tomar e entregá-lo ao vencedor. Ao invés, no direito de crédito, o bem perseguido integra o patrimônio do vencido, e, portanto, exige controles e sofre limitações (v.g. o automóvel que o réu se obrigou a alienar talvez sirva como instrumento indispensável à sua atividade profissional, exigindo intervenção do órgão judiciário para dilatar o prazo de cumprimento). Em vez de pôr ênfase no estudo do título executivo, “é pela análise da sentença exequível que se tem de começar.”⁴ E, deste exame, resulta que há ações executivas reais ou pessoais. Nesta última, alguém sofre a execução pela retirada de seu patrimônio, do “bem com que se satisfaz a pretensão oriunda do título executivo, extrajudicial ou judicial”.⁵

O prazo de quinze dias previsto no art. 806, *caput*, é característico da execução obrigacional, porque “o intervalo entre a emissão da ordem e o respectivo cumprimento é da natureza da obrigação, ou é o que sobrou da incoercibilidade da primitiva *obligatio*”.⁶

Convém realçar a reviravolta da orientação legislativa no tocante à versão originária do CPC/1973. Na concepção que lhe presidiu – a da “mercantilização”, ou seja, o confinamento da execução, em geral, às relações obrigacionais –,⁷ toda e qualquer pretensão real, e pessoal, para haver coisa exigiria a instauração de novo processo, no qual se realizariam os atos de cumprimento forçado. Baseava-se essa concepção em doutrina notória:

Indiferente é a natureza do direito do autor à coisa e da ação proposta inicialmente para conseguir a sentença: quer se trate de ação real ou pessoal, de ação petítória ou possessória; para o processo de execução só importa a existência de condenação a entregar o bem.⁸

O equívoco desse entendimento reside em ignorar a ação de força executiva (v.g., a possessória) e a ação cujo efeito executivo é diferido, porque o provimento não individualizou a coisa. Posteriormente, instituído o cumprimento da sentença, o risco de confusão tomou o rumo oposto, passando-se a entender como representativo da força executiva toda, e qualquer, execução para entrega de coisa fundada em título judicial. Ora, o único denominador comum é o meio executório. Nas ações de força executiva, o vencedor retoma bem que, segundo a sentença de procedência, integra seu patrimônio; nas ações de força condenatória, tomará bem que integra o patrimônio do vencido. Essa distinção descansa, como já afirmado, no direito material e a técnica processual não é capaz de desfigurá-la.

Assim definida a esfera de incidência do art. 806, formalmente restrito à ação executiva nascente do título extrajudicial, tendo por objeto a obrigação assumida pelo devedor, e mediante o emprego do meio do desapossamento, dúvida alguma há quanto à singeleza das atividades próprias do meio executório do desapossamento.

Nem sempre o meio executório do desapossamento atinge resultados satisfatórios. O art. 809, *caput*, aventa a possibilidade de a coisa não ser encontrada, dentre outras situações, oportunamente, analisadas, e a esse propósito adiantou-se exemplo clássico: o órgão da execução não localiza o veículo, todavia existente no patrimônio do devedor, e o executado descumpre com o dever de cooperação, abstendo-se de indicar sua localização. Em reforço ao mecanismo de sub-rogação, e sem embargo das sanções pela má-fé processual, o art. 806, § 2.º, prevê a faculdade de o órgão judiciário fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, podendo alterar o valor, revelando-se insuficiente ou excessivo. Cuida-se de cumulação de meios executórios, combinando-se a execução direta com a execução indireta, ou seja, acrescentando-se ao meio sub-rogatório a pressão psicológica expressa na incidência da multa.

2. Objeto do desapossamento na execução para entrega de coisa

A execução prevista no art. 806 recai sobre coisas integrantes do patrimônio do devedor, obrigado a entregá-las consoante a previsão do título executivo extrajudicial.

O art. 806, *caput*, menciona “coisa certa”. É certa a coisa – logo, bem corpóreo –, que exiba algum sinal particular, tornando-a diferente de todas as demais, ainda que da mesma espécie ou qualidade.⁹ Para essa finalidade, bastam “sinais distintivos”, naturais (v.g., o sinal de nascença do animal) ou impostos (v.g., a marca feita a fogo no pelo do animal) à coisa, características avessas ao que “em sua totalidade outras coisas têm.”¹⁰ Se A obriga-se a entregar a B, no prazo X, o automóvel Y, do modelo Z da montadora W, individualizado, no mínimo, pelo número da respectiva matrícula no departamento de trânsito, ou identificado pelo número de fábrica, obrigou-se a entregar coisa certa. Concebe-se que a coisa seja simples e composta, e até uma universalidade, desde que preenchido o requisito da cabal individualização (v.g., a biblioteca de B, individualizada pela relação dos autores e títulos da obra). Embora sejam substituíveis por outras da mesma espécie, nos termos do art. 85 do CC, as coisas fungíveis tornam-se certas, posteriormente à individualização, e, portanto, se inserem no âmbito desta execução.

A coisa certa abrange, para os efeitos do art. 806, bens corpóreos perfeitamente identificados, até mesmo em virtude de individualização em juízo (art. 812), pois se afiguraria impossível penetrar na esfera patrimonial do obrigado sem antes saber o que procurar exatamente.

O desapossamento atingirá, indiferentemente, coisa móvel ou imóvel. O dinheiro é bem genérico e infungível – cada cédula de papel-moeda recebe número próprio –,¹¹ mas adstrito a outro meio executório – expropriação, a teor do art. 824 –, e, portanto, subtrai-se da incidência do art. 806. E a palavra “coisa”, no tocante à coisa móvel, alude a bem corpóreo. As hipóteses em que ao exequente se afigura lícito pleitear a prestação pecuniária substitutiva, contempladas no art. 809, indicam, claramente, essa natureza. Em outras palavras,

las referencias a la entrega de la cosa, a su paradero, a su ocultación y hallazgo, son indicativas de que esta actividad ejecutiva no va referida a bienes muebles en general, sino a derechos sobre cosas corporales que tengan el carácter de muebles.¹²

É possível a pessoa humana ser objeto de apreensão e, conseqüentemente, sujeitar-se ao meio executório do desapossamento, como indica o art. 536, § 2.º, ao prever a realização do ato por dois oficiais de justiça. Em tal hipótese, entretanto, o direito até pode se originar de convenção das partes (v.g., a obrigação de entregar o filho menor ao outro cônjuge, em determinado dia, hora e local), mas não é direito de crédito, motivo por que, ao nosso ver, escapa da incidência do art. 808, restrito às coisas propriamente ditas.

3. Título executivo na execução para entrega de coisa

O art. 806, *caput*, alude à obrigação de entregar coisa prevista em título extrajudicial. Da análise do catálogo do art. 784, e por exclusão das hipóteses em que a obrigação pecuniária é intrínseca ao documento (v.g., os títulos de crédito do art. 784, I), a obrigação para entrega de coisa pode encontrar-se prevista: (a) em escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor (art. 784, II); (b) o instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (art. 784, III); e (c) a transação referendada pelo Ministério Público, incluindo o compromisso de ajustamento, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado pelo Tribunal. Valem, aqui, as considerações já feitas a respeito desses títulos executivos no lugar próprio.

Não constitui título hábil a carta de arrematação para haver a posse da coisa arrematada.¹³ Consoante enfatizou o STJ, com razão, o arrematante deverá imitar-se na posse, nos casos em que a coisa se encontra na posse imediata do depositário, via mandado do juiz, expedido nos próprios autos da execução.¹⁴ A carta de arrematação, e, *a fortiori*, a carta de adjudicação e o termo de alienação (art. 880, § 2.º), são expedidas para o adquirente provar o acordo de transmissão, incorporado no auto de adjudicação, no auto de arrematação ou no termo de alienação, entre o Estado e o arrematante, e presta-se, cuidando-se de imóvel, para adquirir o domínio ou, no caso dos bens móveis, provar a tradição ou possibilitar algum registro (v.g., no livro próprio da companhia, envolvendo ações nominativas). Não contém obrigação de entregar posse. Conforme reza o art. 901, § 1.º, “a ordem de entrega do bem imóvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse”, expedem-se após o pagamento do que for devido e de prestadas eventuais garantias, e é por meio da “ordem de entrega” e do “mandado de imissão na posse” que o adquirente haverá posse – na pior das hipóteses, a posse mediata, encontrando-se a posse imediata, legitimamente, com terceiro. Esse mandado do juízo em que se verificou a adjudicação, a alienação ou a arrematação pode revestir-se de alguma delicadeza, envolvendo diligências variadas – por exemplo, a retirada do bem móvel de cofre de segurança –, e respeitará, de toda sorte, a posse legítima alheia (v.g., a do locatário).¹⁵

4. Fase inicial da execução para entrega de coisa

A execução para entrega de coisa prevista em título extrajudicial começa por iniciativa do exequente, consubstanciada em petição inicial – o art. 811, parágrafo único, alude a esse ato postulatório pelo seu nome inteiro, instituindo o ônus de exequente realizar a escolha da coisa determinada pelo gênero e pela quantidade –, consoante se infere da menção abreviada à “inicial” no art. 806, § 1.º, guarneçada dos elementos gerais e especiais que lhe são próprios.

Essa petição submeter-se-á ao controle do órgão judicial e, se for o caso, abrir-se-á ao exequente o prazo de quinze dias, previsto no art. 801, a fim de que realize as correções apontadas, completando-a e juntando documentos (v.g., o título executivo) indispensáveis ou, porventura, negligenciados.

Revelando-se apta a petição inicial, à primeira vista, o órgão judiciário adotará três providências, duas obrigatórias e uma facultativa: (a) fixará os honorários advocatícios devidos ao advogado do exequente (art. 85, § 1.º), segundo o critério legal (art. 85, § 2.º) – no caso da execução de obrigação pecuniária, o art. 827, *caput*, estipula o percentual rígido de dez por cento, servindo a

regra como paradigma nesse caso –, o caso de imediato cumprimento, sem prejuízo de eventual aumento do valor, havendo atividades processuais posteriores, mas inexistindo possibilidade de redução por metade da verba inicialmente fixada, porque o art. 927, § 1.º, não se aplica à execução para entrega de coisa; (b) ordenará a expedição do mandado executivo (art. 806, § 2.º), a fim de citar o executado para satisfazer a obrigação no prazo de quinze dias, desde logo, constando a ordem de imissão na posse ou de busca e apreensão, se o executado não entregar a coisa tempestivamente; (c) fixará multa por dia de atraso (art. 806, § 1.º), premindo o executado para satisfazer a obrigação no prazo de cumprimento, cujo valor poderá ser aumentado ou diminuído posteriormente. Essa última providência é uma faculdade, como se infere da fórmula verbal do art. 806, § 1.º (“... o juiz poderá fixar...”).

É claro que o exequente, em lugar da execução sub-rogatória, poderá optar, desde logo, e exclusivamente, pelo mecanismo da coerção patrimonial, requerendo a fixação de multa. É de maior utilidade, entretanto, o emprego de ambos os meios executórios, *in simultaneo processu*, a requerimento do exequente, pedindo a fixação da multa; e a expedição da ordem de emissão na posse ou de busca e apreensão, conforme o caso. A imposição simultânea ao desapossamento da *astreinte* não perturba a marcha da execução sub-rogatória, pelas razões já explicadas: ou o executado entrega a coisa (art. 807), encerrando a execução para haver a coisa, ou não entrega, e, nessa hipótese, o exequente adquirirá pretensão para executar o crédito pecuniário, através de nova e autônoma execução, consoante o procedimento próprio da execução dos créditos pecuniários, aumentando a pressão sobre o executado. O objetivo da multa é o de constranger o executado a satisfazer a obrigação, e não tem o menor sentido em tornar a ameaça longínqua ou hipotética. É bem de ver que, no direito anterior, a Corte Especial do STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo, em decisão apta a configurar precedente para os fins do art. 927, III, admitiu a execução da multa pecuniária incidentalmente, mas fixou essa oportunidade no caso de decorrer de antecipação de tutela, após sua confirmação pela sentença, e desde que o recurso próprio não haja sido recebido com efeito suspensivo.¹⁶ Essa discutível orientação não se aplica, por óbvio, à multa do art. 808, § 1.º, salvo entendendo-se a necessidade de preclusão do recurso próprio (agravo de instrumento, a teor do art. 1.015, parágrafo único) ou de eventual “confirmação” pelo tribunal no respectivo julgamento, se o executado o interpor, nem sequer está claro se o STJ manterá o entendimento à luz do art. 537, § 3.º.

Fora desse aspecto, a disciplina da multa prevista no art. 806, § 1.º, é a comum, aplicando-se, *mutatis mutandis*, o regime do art. 537 (v.g., o valor da multa beneficiária ao exequente, conforme o art. 537, § 2.º). Em particular, o valor da multa insere-se na órbita dos poderes do juiz, nada importando eventual convenção das partes a respeito, no título executivo ou em instrumento posterior. Lícito às partes tão só dispor acerca do valor do crédito daí decorrente.

Tampouco parece possível repelir, categoricamente, a incidência do art. 536, § 1.º, ou seja, a adoção de quaisquer outras medidas de “apoio” ao desapossamento (v.g., a remoção física do executado, que dificulta ou impede o acesso à coisa objeto da execução). O art. 771, *caput*, manda aplicar as regras do processo de execução ao cumprimento da sentença, mas o intercâmbio é recíproco, porque jamais se entenderia que a atividade executiva se desenvolve com intensidades diferentes, consoante à natureza do título.

Em princípio, não se pré-exclui a citação pelos correios, a citação por via eletrônica e, preenchidos os pressupostos legais, a citação por edital no processo de execução, em geral, e na execução para entrega de coisa, em particular. Porém, o art. 806, § 2.º, indica como meio a citação por oficial de justiça, porque menciona o “mandado de citação”. Logo, a citação do executado realizar-se-á ordinariamente na forma dos artigos 250 a 255 e o prazo de quinze dias fluirá, da mesma forma, ordinariamente (art. 219, *caput*, c/c arts. 224 e 231, II). Por exceção, concebe-se a citação do executado por outro meio e, em seguida, a expedição do mandado do art. 806, § 2.º.

5. Prazo de cumprimento na execução para entrega de coisa.

O art. 806, *caput*, estipula o prazo de cumprimento de quinze dias. Esse é o prazo legal, ampliado em relação ao direito anterior e, consoante o *quod plerumque accidit*, cômodo e satisfatório para o cumprimento hábil e tempestivo. Pode suceder que outro esteja fixado no título

executivo. Não importa. Vencido o interregno de quinze dias, e subsistindo inerte o executado, o oficial de justiça cumprirá o mandado de imissão na posse ou de busca e apreensão.

Em caráter excepcional, admitir-se-á dilatação do prazo antes do vencimento, a teor do art. 139, VI, e parágrafo único, *ex officio* ou a requerimento de uma das partes, por razão plausível e com o intuito de possibilitar o cumprimento voluntário (v.g., *A* obrigou-se a entregar a *B* o caminhão *X*, mas o veículo encontra-se em trânsito, dependendo do desembaraço aduaneiro, ou transporta carga para região distante do juízo da execução, só retornando em vinte dias). O art. 806, § 2.º, *in fine*, implicitamente, acolhe a possibilidade, pois prevê o cumprimento imediato do mandado de desapossamento se o executado não satisfazer a obrigação “no prazo que lhe for designado”. Subentende-se que ao juiz seja dado designar prazo distinto do legal.

6. Atitudes do executado após a citação

Concebem-se três atitudes do executado no prazo do art. 806, *caput*, a saber:

(A) permanecer inerte, e, neste caso, certificado o transcurso do prazo pelo escrivão ou chefe de secretaria, o oficial de justiça cumprirá o mandado de imissão na posse, se a coisa for imóvel, ou de busca e apreensão, se for móvel (art. 806, § 2.º);

(B) entregar a coisa, equivalente a cumprimento voluntário da obrigação, em razão do que se lavrará termo de entrega (art. 809). Em vista disto, a execução atingiu sua finalidade, extinguindo-se por força do art. 924, I, ressalva feita ao seu prosseguimento por crédito acessório, a exemplo das despesas do processo e os honorários do advogado do exequente. Como quer que seja, a execução por desapossamento cessará, porque a realização do crédito pecuniário remanescente – custas e honorários, frutos ou perdas e danos – implicará a conversão do procedimento executivo para o meio executório hábil, que é a expropriação (art. 824);

(C) embargar a execução, no prazo de quinze dias (art. 915, *caput*, c/c art. 231), depositando ou não a coisa, mas livrando-se dos riscos mediante o depósito.

A fluência do prazo para embargos prescinde do depósito voluntário ou compulsório da coisa. Esse depósito só é imprescindível para o executado obter efeito suspensivo, a teor do art. 919, § 1.º. Assim, convém ao executado depositar voluntariamente a coisa, antecipando ao cumprimento do mandado previsto no art. 806, § 2.º, não só para forrar-se dos riscos, mas visando a suspensão da execução. Não é de se excluir que, inexistindo depósito voluntário e não localizada a coisa, por sinal, hipótese antevista no art. 809, *caput*, os embargos prossigam normalmente e, do ponto de vista do executado, sem a necessidade de efeito suspensivo. O efeito suspensivo importa quando houver o desapossamento voluntário ou compulsório: se o executado não preencher os requisitos do art. 919, § 1.º, ao exequente é dado levantar a coisa, independentemente de caução.

7. Desapossamento compulsório do executado

Abstendo-se o executado de satisfazer a obrigação, no prazo que lhe foi designado, cabe ao oficial de justiça cumprir, “de mediato”, o mandado de desapossamento. Faltou prever a possibilidade, todavia existente, de o executado depositar a coisa voluntariamente, visando preencher esse requisito para obtenção de efeito suspensivo aos seus embargos (art. 919, § 1.º). Em tal conjuntura ideal, cumpre ao escrivão lavrar o termo de depósito. É preciso deixar claro o sentido do ato processual, não se confundindo o depósito para embargar com a entrega da coisa para satisfazer a obrigação (art. 807).

Como já se observou, o mandado de citação já contempla a ordem de desapossamento, como era a prática do direito anterior; porém, realizada a citação por outro meio (v.g., citação postal), cabe ao juiz expedir mandado de imissão na posse ou de busca e apreensão, conforme o caso, vencido o interregno de quinze dias.

Segundo o art. 861, n.º 1, do CPC português de 2013, ao desapossamento compulsório aplica-se, subsidiariamente, o procedimento da penhora, realizando-se as buscas e outras diligências necessárias à localização do bem. A apreensão, ou a imissão na posse da coisa, nessa execução, não

têm, todavia, “a função nem os efeitos da penhora”.¹⁷ Em termos, porém: ao menos uma função é comum – a de preencher o requisito da garantia do juízo para obtenção de efeito suspensivo aos embargos (art. 919, § 1.º). O que não se produzem são os efeitos próprios da penhora (v.g., a preferência do art. 797, *caput*).

Embora sejam atos diferentes a penhora e o depósito, a localização da coisa, a cargo do oficial de justiça, segue o modelo da penhora, aplicando-se, por conseguinte, o art. 845, *caput*, e § 1.º, e o art. 846, no caso de resistência do executado. Não é possível realizar o depósito na forma do art. 846, § 2.º (v.g., a imissão na posse de imóvel ou a apreensão do veículo à luz do documento de registro no departamento de trânsito), porque o depósito é real. Lavrar-se-á, ainda, auto de depósito nos moldes do art. 838, incluindo a designação de depositário na forma do art. 840.

O êxito das buscas, cuidando-se de coisa móvel, dependerá da sua localização em poder do executado ou de terceiro. Pouco importa que o terceiro esteja na posse, na guarda ou na detenção da coisa. O mandado do art. 806, § 2.º, pode atingir terceiros, legitimamente ou não (art. 809). Nem sempre a busca é coroada de sucesso. Não sendo encontrada, ou encontrando-se na posse de terceiro, não desejando contra ele investir o exequente, converter-se-á a execução a obrigação de entregar coisa certa no seu equivalente pecuniário (art. 809, *caput*).

Em relação aos imóveis, ocorreu a liquidação prévia das benfeitorias e acessões (art. 810), mas acontece de existirem móveis, guarnições, equipamentos e utensílios não abrangidos na obrigação de entrega. Esses bens deverão ser removidos previamente, subsistindo na posse do executado.

Art. 807. Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver.

1. Entrega da coisa

Ao executado é lícito satisfazer a obrigação, conforme dispõe o art. 806, *caput*, entregando a coisa no prazo de quinze dias.

A fluência desse prazo não extingue o direito processual contemplado no art. 807. Admite-se a entrega posterior ao vencimento, atingindo, plenamente, a finalidade do art. 807, embora o retardamento exponha o executado ao desapossamento compulsório do art. 806, § 2.º.

2. Forma da entrega

A entrega cogitada no art. 807 poderá ocorrer (a) ao oficial de justiça, na oportunidade da citação ou do cumprimento do mandado do art. 806, § 2.º, ou (b) ao escrivão ou chefe de secretaria. Na prática, o ato material, em si, varia muito. Dependerá da natureza da coisa, por exemplo, a transferência manual ao órgão auxiliar do juízo, hipótese em que envolverá coisas móveis de pequeno porte (v.g., a tela pintada por X; o colar de pérolas). Em geral, o desapossamento é simbólico, operando-se mediante a entrega das chaves (do veículo ou do imóvel) ou de documentos (v.g., certificado de registro e licenciamento do veículo).

3. Documentação da entrega

Em princípio, o termo é ato privativo do escrivão ou chefe de secretaria (art. 208). Assim, dispondo-se o executado a entregar a coisa em juízo, competirá ao escrivão ou chefe de secretaria lavrar o termo a que alude o art. 807. Equivale ao recibo de pagamento nas prestações pecuniárias.¹⁸ O executado assinará o termo (art. 209), que descreverá, com todos os pormenores, a coisa entregue e seu atual estado.

É preciso extremo cuidado na elaboração deste ato, certificando-se o escrivão ou o chefe da secretaria da real intenção do executado, porque convém distingui-lo do depósito voluntário, cuja finalidade é a de cumprir o art. 919, § 1.º, assegurando um dos requisitos da obtenção de efeito suspensivo aos embargos.

Realizada a entrega ao oficial de justiça, tocará a esse auxiliar do juízo certificar o ato no mandado executado, restituindo-o em cartório, juntamente com a coisa, se for esse o caso, dispensando a lavratura de termo específico de entrega.

Não prevê o art. 808 a audiência prévia do exequente, nem sequer parece recomendável, porque realizando-se a entrega ao oficial de justiça, inexistirá oportunidade para tanto. Eventual divergência será resolvida posteriormente.

O lacunoso art. 808 ocupa-se da forma e dos efeitos da entrega, olvidando o destino da coisa. Fica subentendido que o escrivão providenciará a intimação do exequente, na pessoa do respectivo advogado, por um dos meios legais, preferencialmente eletrônico, para comparecer em juízo. Em seguida, investirá o exequente, formalmente, na posse do imóvel ou entregará a posse da coisa móvel, mediante termo de entrega.

Concebe-se que a coisa entregue não seja a efetivamente devida. Em tal hipótese, cumpre ao exequente impugnar o ato nos próprios autos e, ouvido o executado, ao órgão judiciário resolver o incidente de plano, considerando a individualização da coisa segundo o título executivo extrajudicial. Acolhida a impugnação, retoma-se o procedimento, por meio do cumprimento do mandado previsto no art. 806, § 2.º, tornando-se sem efeito a entrega e restituindo-se a coisa entregue ao executado.

Pode ocorrer depósito parcial, envolvendo a prestação duas ou mais coisas. Nesse caso, proceder-se-á como já descrito: de um lado, o escrivão ou chefe de secretaria providenciará a investidura do exequente na posse da coisa entregue; de outro, o oficial de justiça cumprirá o mandado quanto à coisa faltante.

4. Efeitos da entrega da coisa

Por força da entrega, encerra-se o desapossamento, satisfazendo-se, no todo ou em parte, a obrigação de entrega. Mas, a execução, em si, não se extinguirá fatalmente, como adianta o art. 807, *in fine*, prosseguindo-se para “o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver”. É incompleta a disposição: também remanescerá o crédito pecuniário relativo às custas e aos honorários advocatícios fixados no despacho inicial. Nada impede o executado de depositar essas verbas, no mesmo ato, hipótese em que, inexistindo frutos e prejuízos indenizáveis, então extinguir-se-á a execução (art. 924, I), mediante sentença (art. 925).

Pode coexistir à obrigação de entrega o dever de indenizar frutos e perdas e danos – o dispositivo utiliza a palavra “prejuízos”, mantida a locução “perdas e danos”, porém, no art. 809, *caput* –, consoante disposição explícita do título. Também surgirá idêntico dever em virtude do estado atual da coisa, apurado no momento da entrega, quicá, através de vistoria posterior, verificando-se que não se encontra íntegra e indene. É a hipótese prevista no art. 807, segunda parte. Omissa o título, o credor deverá pleiteá-lo em ação própria; porém, constando a obrigação do título, é lícito ao credor empregar a faculdade do art. 509, § 2º, e liquidar prévia ou posteriormente à entrega da coisa tal dívida. A liquidação simultânea à execução para a entrega de coisa não infringe o art. 780, “porque o processo de liquidação de sentença não é um processo de execução, senão um processo antecedente àquele”.¹⁹

No que tange à execução dessa obrigação pecuniária, liquidada da forma exposta, ocorrerá sucessivamente à execução para entrega de coisa. Execução simultânea dessas obrigações incide no veto do art. 780: há clara impossibilidade de se cumlarem dois procedimentos executivos diferentes, *in simultaneo processu*, sem provocar tumulto e confusão. Converter-se-á o procedimento, assim, passando-se para o meio da expropriação, não se mostrando necessário instaurar outro processo.

Art. 808. Alienada a coisa quando já litigiosa, será expedido mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-la.

1. Desapossamento da coisa litigiosa

O art. 809, *caput*, autoriza ao credor não reclamar a coisa em “poder de terceiro adquirente”. Fica subentendida a alienação da coisa já litigiosa (art. 109). Se o terceiro adquiriu a coisa antes da pendência do processo, “sobre ela não se estende o efeito da sentença”, decidiu o STJ, interpretando, corretamente, o alcance do art. 109, § 3º.²⁰ Como se trata de pretensão a executar fundada em título extrajudicial, a aquisição da coisa “quando já litigiosa”, como dispõe o art. 808, refere-se à pendência do processo de execução, porque a pretensão para entrega de coisa assume natureza reipersecutória.

Impende, portanto, distinguir alienação da coisa litigiosa (art. 109) da fraude contra execução (art. 790, I). Se o adquirente adquire a própria coisa, após a citação do executado, fraudava a execução; se, ao invés, o executado transfere-lhe a obrigação de entregar, adquire coisa litigiosa.

Em que pese o adquirente da coisa litigiosa se sujeitar à força da pretensão a executar, ao assumir a obrigação de entregar a coisa, ao exequente assiste a faculdade de não o envolver na atividade executiva, porque não convém ao seu próprio interesse. Tal não significa, evidentemente, que o mandado do art. 806, § 2.º, não possa atingi-lo, desde logo, ou que haja a necessidade de ordem específica do órgão judiciário para desapossá-lo *incontinenti*. Tudo dependerá da opção do exequente. Seja como for, o art. 809, *caput*, institui a faculdade de o exequente, ciente da posse do terceiro, não reclamar a coisa, contentando-se com a prestação pecuniária do equivalente. No entanto, as vantagens da execução específica talvez induzam a opção contrária, disciplinada no art. 808. É inteiramente livre a opção do credor.²¹

Por outro lado, ao terceiro se afigura lícito, igualmente, entregar a coisa, nos termos do art. 807, para livrar-se de quaisquer incômodos e, destarte, cumprir a obrigação assumida. Em tal hipótese, encerra-se a atuação do meio executório contra o terceiro. E, como não assumiu papel ativo, nem opôs resistência, também livrar-se-á da imposição dos ônus da sucumbência (despesas e honorários), porquanto não deu causa ao processo (princípio da causalidade).

Desejando o adquirente opor a aquisição da coisa ao exequente, reagirá através de embargos. Este é o real sentido da obscura expressão “será ouvido”, posta na parte final do art. 808. Essa disposição poderia ser corrigida na vigente lei processual, tornando mais clara a disposição nesse aspecto.

2. Embargos do adquirente

Legitima-se para opor os embargos à execução quem, legitimamente ou não, sofre a atuação dos meios executórios em seu patrimônio. Logo, o terceiro adquirente, uma vez depositada a coisa, voluntária ou compulsoriamente, tornou-se parte passiva na execução, cabendo-lhe controverter, por meio de embargos à execução, a justiça da sua submissão à pretensão a executar, alegando que não adquiriu a coisa “quando já litigiosa” (art. 808, primeira parte).

A respeito do remédio hábil para veicular a oposição do terceiro adquirente, ocorrem divergências. A opinião prevalecente, no direito anterior, era no sentido de não caberem os embargos de terceiro.²² Em sentido diverso, manifestou-se o STJ, segundo o qual quem adquire coisa litigiosa não é terceiro, e, conseqüentemente, não pode opor embargos como terceiro.²³ Esse é o entendimento correto, embora não se confunda alienação da coisa litigiosa com fraude contra a execução, não sendo aplicável, destarte, o art. 792, § 4.º para sustentar o cabimento dos embargos de terceiro.²⁴ É que o negócio fraudulento é ineficaz perante o exequente, é “como se” não existisse, e, assim, o bem alienado encontra-se no patrimônio do executado, figurando o adquirente como terceiro relativamente à execução. Porém, a alienação da coisa litigiosa prevista no art. 808 não se é fraudulenta, mas admitida no art. 109, passando a obrigação e, se for o caso, a própria coisa ao patrimônio do terceiro, submetendo-se o adquirente à força da pretensão a executar, como antes explicado.

O art. 808, *in fine*, exige o depósito da coisa para o adquirente embargar. Ora, o depósito é dispensável para oferecimento dos embargos, exigido apenas para obtenção de efeito suspensivo (art. 919, § 1.º). Nesse sentido, o dispositivo é incompatível com o regime dos embargos à execução, e, igualmente, com o dos embargos de terceiro, cuja função preventiva repele a exigência de

constrição patrimonial na esfera jurídica do terceiro.

Os embargos de terceiro e os embargos do executado diferem, substancialmente, quanto ao prazo. O prazo dos embargos do executado é fixo e peremptório, fluindo os quinze dias da citação (*rectius*: da juntada aos autos do respectivo mandado, a teor do art. 231, I), porventura, feita ao adquirente (art. 915, *caput*, c/c art. 231), enquanto os embargos de terceiro podem ser opostos em até cinco dias após o depósito, adaptando-se a letra do art. 675, *caput*, parte final, à situação da execução para entrega de coisa, sem prejuízo do uso preventivo desses embargos. Eis o motivo por que, oferecidos embargos no prazo do art. 915, *caput*, mostra-se possível aproveitá-los como “embargos de terceiro” consagrando relativa fungibilidade, em virtude de dois bons motivos: (a) não importa a designação do remédio processual, mas a natureza da pretensão deduzida; (b) o prazo dos embargos de terceiro, porque mais amplo, ainda não transcorreu.

A condição jurídica do adquirente, parte ou terceiro propriamente dito, interessa na hipótese dos embargos tardios, mas apresentados no interstício assinado no art. 675, *caput*. Em tal hipótese, os embargos serão rejeitados liminarmente, porque intempestivos.

Os embargos opostos pelo adquirente suspenderão, ou não, a execução fundada em título extrajudicial, conforme encontrem-se preenchidos os requisitos do art. 919, § 1.º. Se os embargos não forem recebidos com efeito suspensivo, ao exequente é lícito levantar a coisa, independentemente de caução.

A procedência da oposição do terceiro implicará, em qualquer hipótese, a liberação da coisa depositada, restituída ao adquirente por meio de termo nos autos. Restará ao exequente, nessa contingência, pleitear a conversão da execução para haver do executado (jamais do terceiro) o equivalente pecuniário e perdas e danos, nos termos do art. 809. Tal dever compete, exclusivamente, ao executado, porque a responsabilidade do adquirente se cinge à entrega da coisa.²⁵ É bom recordar que a falta de oposição dos embargos, nenhum reflexo produz quanto à existência do direito do adquirente, que poderá demandá-lo em ação autônoma.²⁶

Inversamente, julgados improcedentes os embargos em primeiro grau, recebidos ou não com efeito suspensivo, caberá ao exequente levantar a coisa, salvo a concessão de efeito suspensivo, *ope judicis*, à apelação do adquirente.

Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1.º Não constando do título o valor da coisa, e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

§ 2.º Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.

1. Frustração da execução específica

O meio executório do desapossamento se sujeita a inúmeras vicissitudes, frustrando a execução específica de entrega de coisa. O art. 809, *caput*, arrola as situações mais frequentes. Transformar-se-á a execução específica, ou seja, capaz de entregar ao exequente o objeto da prestação, na execução genérica, entregando o equivalente pecuniário, nas seguintes hipóteses em que a coisa: (a) não for encontrada; (b) não for entregue; (c) sofreu deterioração, prejudicando a respectiva integridade; ou (d) não for reclamada pelo terceiro adquirente.

Essas situações demonstram o malogro do meio executório, embora por motivos heterogêneos. Em princípio, apenas a última situação é opcional, cabendo ao exequente, a seu critério, investir contra o adquirente da coisa litigiosa ou haver o equivalente pecuniário do executado, assunto versado no art. 808. Nos demais casos, o evento é inelutável. Impende distingui-los. A rigor, coisa não localizada não pode ser entregue, e não se pode inferir que, inexistindo entrega voluntária, nos termos do art. 807, ao exequente se mostre lícito converter a execução específica no equivalente pecuniário. Forçoso admitir a redundância do art. 809, *caput*: não ocorreu o

desapossamento voluntário ou compulsório da coisa, porque não se conseguiu localizá-la. Presumivelmente, o executado contribuiu para esse resultado, não indicando ao órgão judiciário a localização da coisa. Porém, acontece de a localização ser realmente desconhecida, a exemplo do extravio. E parece claro que a situação se afeiçoa às coisas móveis, não se aplicando aos bens imobiliários. A deterioração da coisa torna inútil a prestação em *natura*. Ela deve ser significativa; do contrário, enseja perdas e danos, mas não impede a execução específica.

2. Conversão da execução específica

Em todas essas hipóteses, converter-se-á o procedimento *in executivis*, executando-se mediante expropriação a obrigação pecuniária substitutiva, salvo os casos em que, segundo o direito material, o evento exonera o devedor. Essa execução chama-se de subsidiária,²⁷ ou mais precisamente haverá conversão da execução, como designa o acontecimento o art. 867 do CPC português de 2013.²⁸

Antes de iniciar a execução expropriatória (art. 924), urge apurar o *quantum debeatur*. A dívida pelo equivalente pecuniário abrange o valor da coisa, mais perdas e danos, decorrentes da privação da posse, quiçá, contempladas no próprio título, judicial ou extrajudicial. O valor da coisa será o estipulado pelas partes no título executivo, a teor da parte inicial do art. 809, § 1.º. Não se dispondo desse valor, e não sendo possível avaliação, o art. 809, § 1.º, faculta ao exequente apresentar sua estimativa. Essa regra é tradicional,²⁹ mas relaciona-se, salvo engano, à sentença executiva – e, portanto, ao cumprimento da sentença –, porque o art. 952, parágrafo único, do CC, declara que o desaparecimento da coisa implica sua estimação pelo preço ordinário e pelo de afeição. Entende-se por preço ordinário o preço corrente, ou seja, o da aquisição de coisa equivalente, na data da estimativa.³⁰ Feita ou não a estimação, apura-se o valor corrente da coisa através de arbitramento, realizando-se perícia para adequar à realidade estimativa exagerada ou fantasiosa, a instâncias do executado ou por determinação do juiz.

As perdas e danos se apuram mediante pretensão à liquidação por arbitramento ou, mais raramente, por artigos.³¹ É um caso, portanto, de liquidação de título extrajudicial.³² Essa possibilidade não afeta a liquidez originária do título. Porém, é imprescindível a prévia liquidação do valor da coisa, haja ou não estimativa do exequente, e das perdas e danos (art. 809, § 2.º). Em seguida, resolvido esse incidente, do qual caberá agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único), proceder-se-á à nova citação do executado, agora, para os fins do art. 829, assinando-se o prazo de três dias para pagar do CPC/2015. Feito o chamamento, seguir-se-á o procedimento da expropriação (art. 824).

Art. 810. Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por terceiros de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória.

Parágrafo único. Havendo saldo:

I – em favor do executado ou do terceiro, o exequente o depositará ao requerer a entrega da coisa;

II – em favor do exequente, esse poderá cobrá-la nos autos do mesmo processo.

1. Liquidação obrigatória das benfeitorias

Liquidar-se-á, previamente à execução para entrega de coisa, as benfeitorias indenizáveis.

Às benfeitorias, mencionadas no art. 810, equiparam-se as acessões. Eventualmente, também haverá direito de retenção do executado ou do terceiro:

Muito embora não se confundam as construções e plantações com as benfeitorias propriamente ditas, sendo estas melhoramentos feitos na coisa, sem modificar sua substância, ao passo que aquelas são acessórios artificiais alterando a própria coisa, o direito de retenção conferido ao possuidor de boa-fé, no art. 516 do Código Civil, também o deve ser ao possuidor de boa-fé, no caso

do art. 547.³³

Em igual sentido decidiu o STJ.³⁴

Adaptando-se a lição ao CC vigente, se o possuidor está de boa-fé, o proprietário indeniza-lhe as acessões e tem, ainda, direito a indenização (art. 1.255, *caput*, do CC); se, porém, o possuidor está de má-fé, perdia o valor das construções em proveito do proprietário, mas, agora, somente o direito à indenização; ambos estando de má-fé, reza o art. 1.256, *caput*, do CC, o proprietário paga ao possuidor o valor das acessões.³⁵ Impende ressaltar, nesse último caso, o direito do superficiário.

É diferente, nesse aspecto, a execução de título judicial, pois a retenção e o direito à indenização não de ser alegados na contestação (art. 538, § 2.º), em nome do princípio da eventualidade (art. 336). Não havendo alegação, *opportuno tempore*, a omissão do julgado pré-exclui invocação posterior, considerando a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508). Era a orientação do direito anterior.³⁶ E dispõe a esse respeito, expressamente, o art. 860, n.º 3, do CPC português de 2013, não admitindo a oposição de embargos, na execução de sentença condenatória, se o executado não houver “oportunamente feito valer o seu direito a elas”. Porém, oferecida a exceção, na contestação, as questões relativas à existência, à natureza, e ao cabimento da indenização e da retenção já se encontrarão resolvidas no título judicial.

Essa última hipótese equivale à versada no art. 810, *caput*, relativamente ao título extrajudicial, derivando do título executivo a indenização das benfeitorias feitas na coisa, “de cujo poder houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória”. À primeira vista, parece que, antes da liquidação, há o desapossamento do executado ou do terceiro; porém, a prática desse ato ofenderia eventual direito de retenção. Logo, a liquidação é prévia ao desapossamento, haja ou não contracrédito do exequente, respeitante a perdas danos pela privação da coisa, passíveis de compensação, a teor do art. 1.221 do CC.

Em última análise, o art. 810, *caput*, veta a execução da obrigação líquida, a cargo do executado, em virtude da existência de obrigação ilíquida do exequente, exigindo a liquidação prévia desta última. Esse arranjo prende-se caráter dilatório da exceção,³⁷ “que como tal obstará à procedência do pedido executivo, com a particularidade, porém, de o fundamento da exceção cessar com o pagamento das benfeitorias”.³⁸ Logo, os embargos de retenção (art. 917, IV, e § 5.º), mostrar-se-ão necessários apenas no caso de o exequente descumprir o art. 810, *caput*.

Far-se-á a liquidação por arbitramento. É o que determina o art. 917, § 5.º, caso a questão seja aventada nos embargos, realizando-se, aí, remissão ao art. 464, presumivelmente, para abranger a audiência de especialista (art. 464, § 3.º). O perito avaliará o montante das benfeitorias ou das acessões pelo valor atual,³⁹ ou preço corrente, sem prejuízo da correção monetária. É cabível, na liquidação, compensar o valor das benfeitorias com os créditos relativos a frutos e a perdas e danos, conforme o art. 810, parágrafo único.

O art. 810, parágrafo único, ministra soluções quanto ao resultado final do arbitramento, admitida a compensação contemplada no direito material (art. 1.221 do CC): (a) existindo saldo favorável ao executado ou ao terceiro, o exequente depositará a importância respectiva, antes de requerer a entrega da coisa; (b) existindo saldo favorável ao exequente, poderá requerer o desapossamento, sem outros obstáculos, e, posteriormente, executará a dívida em dinheiro “no mesmo processo”. O art. 917, § 6.º, autoriza caução ou depósito de dinheiro, para levantar a coisa, aplicando-se a primeira medida ao caso, apesar de omissa o art. 810.

Não se desincumbindo o exequente do ônus de liquidar, previamente, as benfeitorias e as acessões indenizáveis, concebem-se dois termos de alternativa: (a) em decorrência do caráter obrigatório da liquidação prévia, faltaria exigibilidade à obrigação de entrega de coisa, permitindo ao executado embargar a execução sob este fundamento ou alegar o defeito por via de exceção de pré-executividade;⁴⁰ (b) deduzirá embargos com fundamento no art. 917, IV, ou seja, deduzindo a exceção de retenção. Ora, a prestação de coisa, enquanto tal, não se torna inexigível pela existência de contracrédito. Logo, o descumprimento da liquidação enseja, realmente, os embargos

de retenção, que, do contrário, mostrar-se-iam inúteis.

Eventual entrega da coisa, nos termos do art. 807, importará renúncia ao *jus retentionis*. Remanescerá, entretanto, o direito à indenização. Caberá reclamá-lo por via de ação própria.

2. Extinção da execução

Extinguir-se-á execução para entrega de coisa em três hipóteses: (a) ocorrendo a entrega da coisa e o pagamento das despesas do processo, além do crédito relativo aos frutos e prejuízos (art. 808, *in fine*), quando couber; (b) realizado depósito compulsório ou voluntário, satisfazendo a obrigação originária, e prosseguindo a execução para haver reparação pelos frutos não percebidos e prejuízos, atingiu a satisfação desse crédito por um dos meios do art. 904, I e II; (c) convertida a execução específica, nos termos do art. 809, e executada a prestação pecuniária equivalente, mais perdas e danos, atingiu-se a satisfação do exequente pela entrega do dinheiro ou adjudicação dos bens penhorados (art. 904, I e II).

Em qualquer hipótese, a extinção será declarada através de sentença (art. 924, I, c/c ar. 925). Tudo que começa, cedo ou tarde, há de acabar e, para semelhante finalidade, o juiz emitirá sentença.⁴¹

Seção II

Da Entrega de Coisa Incerta

Art. 811. Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha.

Parágrafo único. Se a escolha couber ao exequente, esse deverá indicá-la na petição inicial.

1. Execução para entrega de coisa incerta

O objeto da prestação, na hipótese versada nos artigos 811, *caput*, recai sobre “coisa determinada pelo gênero e pela quantidade”. Não se cuida de prestação indeterminada, mas genérica e, portanto, não pode ser duvidosa.⁴² Por exemplo, *A* obrigou a entregar a *B* dez cavalos da raça crioula, ou *C* obrigou-se a entregar a *D* duas pinturas figurativa do pintor *E*. Em geral, tais negócios são bilaterais, subentendendo-se a prévia satisfação do preço. A prestação a cargo do outro figurante define-se pelo gênero (cavalos e pinturas) e pela quantidade (dez e duas). À execução, propriamente dita, precederá a individualização da coisa. Também é chamado de incidente de concentração.⁴³

A coisa “incerta” não equivale a coisa fungível.⁴⁴ A fungibilidade significa substituir a coisa por outra “da mesma espécie, qualidade e quantidade” (art. 85 do CC). Uma tela do artista *Y*, que se obrigou a entregar em documento afeiçãoado ao art. 784, poderá ser “incerta”, ou seja, futuramente, individualizada na obra *X* ou na obra *Z*, mas é infungível, porque distinta de qualquer outra do mesmo pintor. Por outro lado, o papel-moeda revela-se fungível, na medida em que uma nota substitui outra, indiferentemente, mas é coisa certa, pois cada nota é distinta de todas as outras em razão da numeração. Seja como for, mostra-se imprescindível individualizar coisas fungíveis e incertas: o desapossamento recairá sobre coisa individualizada.

A regra básica da escolha, nas obrigações de gênero, decorre do art. 244, segunda parte, do CC, segundo o qual o obrigado “não poderá dar coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor”. Tal implica a possibilidade de as partes controverterem a individualização. Objeto de incidente específico (art. 812), semelhante controvérsia distingue os procedimentos das Seções I e II da execução para entrega de coisa: cumpre resolver o incidente antes de proceder à execução.

A obrigação de gênero comporta previsão em título afeiçãoado às classes do art. 784, II, III e IV. No agronegócio, é comum a obrigação de entregar determinada quantidade de grãos de certa qualidade. O direito brasileiro não assegura ao credor, na obrigação de gênero, uma faculdade análoga à do art. 817, *caput*, todavia prevista no art. 702, n.º1 da *Ley de Enjuiciamiento Civil*. E, de

fato, no caso de coisa incerta passível de aquisição no mercado, o direito espanhol permite ao exequente, não ocorrendo a entrega no prazo de cumprimento, adquiri-las à custa do executado.⁴⁵

2. Incidente de individualização

A individualização do objeto da prestação pressupõe que a um dos figurantes incumba a escolha. Nas obrigações de gênero, conforme estabelece o art. 244, primeira parte do CC, a escolha é do obrigado, salvo convenção em contrário, devendo constar cláusula, nesse sentido, no título executivo extrajudicial. Logo, o incidente começa com a identificação do parceiro a quem incumbe a escolha.

Competindo a escolha ao exequente, o art. 811, parágrafo único, institui o ônus de fazê-la na petição inicial. Eventual omissão implicará preclusão dessa faculdade, revertendo a escolha ao executado. Desnecessária a abertura de prazo para emendas (art. 801), subentendendo-se a renúncia, e inadmissível, ainda, o exequente reservar-se a escolha para outra oportunidade. Passando a escolha ao executado, há que obedecer ao art. 244, segunda parte, do CC. Seja quem for o titular da escolha, ela sempre se guiará pelo meio-termo da qualidade.

Ao invés, realizando o exequente indevidamente a escolha, o juiz mandará corrigir a petição inicial no prazo do art. 801. Se o órgão judiciário omitir a providência, o executado poderá realizar a escolha, exibindo sua boa-fé, e, assim, evitando a execução injusta.⁴⁶ Representará excesso de execução (art. 917, § 2.º, II), de toda sorte, a escolha errônea do exequente, cabendo ao executado opor embargos à execução com esse fundamento (art. 917, III, primeira parte). Porém, submeter-se-á ao desapossamento compulsório (art. 806, § 2.º), se pretender obter efeito suspensivo aos embargos (art. 919, § 2.º). É razão bastante para o órgão judiciário redobrar o controle sobre petição inicial, no tocante à titularidade da escolha.

De acordo com o art. 811, recaindo a execução sobre coisa incerta, “o executado será citado para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha”, omitindo referência ao prazo respectivo. Resulta daí que a escolha ocorrerá no prazo de quinze dias contados da juntada do mandado de citação ao processo (art. 231, II).⁴⁷ Se houver omissão do executado, nesse interregno, reverter-se-á a escolha ao exequente, por analogia do art. 800, § 1.º. E omitindo-se o exequente, por sua vez, incumbe ao exequente intimá-lo pessoalmente, transcorridos trinta dias, pois a execução realiza-se no seu interesse (art. 797, *caput*), e, subsistindo a inércia, extinguir o processo com fundamento no art. 485, III, e § 1.º.

Existe outra possibilidade concernente à escolha. Lícito aos figurantes designarem terceiro no título executivo. Em tal hipótese, o juiz mandará intimá-lo, pessoalmente, para essa finalidade, valendo-se da identificação e qualificação feita pelo exequente na petição inicial. Não sobrevindo qualquer manifestação do terceiro, a escolha passa ao juiz, a teor do art. 252, § 4º, do CC, aplicável subsidiariamente.

Art. 812. Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a escolha feita pela outra, e o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo perito de sua nomeação.

1. Impugnação à escolha

A qualquer das partes mostra-se lícito impugnar a escolha no prazo de quinze dias. É um interregno largo, demonstrando a preferência do CPC/2015 pela dilação dos prazos, em geral, e por esse quantitativo, em particular.

A impugnação há de ser motivada, talvez acompanhada de parecer técnico e documentos elucidativos, sendo admissível a incidência do art. 472. Eventual impugnação desprovida de fundamentação hábil, ou insuficientemente motivada, receberá indeferimento de plano.

O prazo de quinze dias variará segundo a titularidade da precedente escolha: (a) individualizando o exequente na petição inicial, a teor do art. 811, parágrafo único, contar-se-á o interregno da juntada do mandado de citação, ficando suspenso o quindênio para entrega (art.

806, *caput*) até a solução do incidente em primeiro grau;⁴⁸ (b) individualizando o executado, o prazo fluirá da intimação da entrega (art. 807) ou do depósito voluntário, feito para os fins do art. 919, § 1.º, ou compulsório (art. 806, § 2.º).

Inexistindo impugnação, no prazo de quinze dias, haverá aquiescência à escolha.⁴⁹ A execução prosseguirá pelo disposto na Seção I (art. 813).

2. Decisão e instrução do incidente

Consoante o art. 812, segunda parte, apresentada a impugnação, o “juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo perito de sua nomeação”. A expressão “de plano” recomenda a resolução sem qualquer atividade de instrução, valendo-se o órgão judiciário dos elementos constantes dos autos ou de presunção judicial. O juízo é, por óbvio, de verossimilhança. Não parece isenta de problemas, todavia, a subsunção (*rectius*: concretização, porque a norma é elástica ou flexível) do fato (conteúdo da escolha) à regra legal (art. 244 do CC). Se faltarem elementos de convicção, que há de ser exaustiva, nos termos do art. 489, § 1.º, o juiz poderá ouvir perito, talvez em audiência, a teor do art. 464, § 2.º, com a participação das partes (art. 722, I), inspecionar o bem, ou, nos casos mais graves e difíceis, ordenará a realização de perícia, observando o procedimento próprio à sua produção desse meio de prova. Em qualquer hipótese, a designação do experto recairá em pessoa natural ou jurídica constante no cadastro do Tribunal (art. 156, § 1.º). E, ordenada a perícia, a instrução deve ser a mais ampla possível.

A decisão do incidente rende agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único), e não suspenderá a execução, imprimindo-lhe, todavia, variante procedimental.

Art. 813. Aplicar-se-ão à execução para entrega de coisa incerta, no que couber, as disposições da Seção I deste Capítulo.

1. Prosseguimento da execução

Definido o incidente de individualização, a execução prosseguirá consoante o disposto na Seção I, reza o art. 813, e a razão é trivial: antes incerta, a coisa se tornou “certa”. Retoma-se o procedimento a partir do art. 806, cabendo ao órgão judiciário adotar as providências que lhe incumbem – a fixação de multa, no caso de atraso na entrega (art. 806, § 1.º); expedição do mandado executivo, contemplando a ordem de busca e apreensão ou de imissão na posse (art. 806, § 2.º); e, principalmente, a fixação de honorários advocatícios, cabíveis por força do art. 85, § 1.º). Fundamentalmente, observar-se-á o itinerário traçado para a execução de coisa certa.

2. Repercussões da escolha prévia

Entretanto, há reflexos quanto ao cabimento de algumas regras específicas do procedimento. Ocorrida escolha, localizou-se e individualizou-se o objeto da execução, motivo por que, salvo quanto à deterioração posterior, os eventos do art. 809, *caput*, não se revelam concebíveis. Não tem cabimento a indenização por benfeitorias, acessões e cômodos. Mas, poderão existir frutos, perdas e danos e, sobretudo, despesas e honorários advocatícios, passíveis de liquidação e de ulterior execução (art. 924), se o executado não satisfazer esse crédito.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Sérgio Muritiba, *Ação executiva lato sensu e ação mandamental*, n. 3.2, p. 187-204.

2

STJ, Resp. 739-RJ, 21.08.1990, 4ª Turma, rel. Min. Athos Carneiro, *RJSTJ*, 17/293.

3

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 9, p. 16.

4

Pontes de Miranda, *Tratado das ações*, vol. 6, § 1.º, p. 5.

5

Idem, ob. cit., vol. 6, § 5.º, p. 21.

6

Ovídio A. Baptista da Silva, *Execução obrigacional e mandamentalidade*, n. 15, p. 696.

7

Ovídio A. Baptista da Silva, *Jurisdição, direito Material e processo*, p. 195.

8

Enrico Tullio Liebman, *Processo de execução*, n. 93, p. 225.

9

Pasquale Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, n. 221, p. 556.

10

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 48.

11

Crisanto Mandrioli, *L'esecuzione forzata in forma specifica*, n. 12, p. 61.

12

Manuel Ortells Ramos, *La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, p. 111

13

Tercílio Pietroski, *A ação de imissão de posse*, n. 5.3, p. 61. Ovídio A. Baptista da Silva, *A ação de imissão de*

posse no direito brasileiro atual, n. 8.10, p. 188-189.

14

STJ, RMS 1.706-RJ, 24.11.1993, 2ª Turma, rel. Min. Pádua Ribeiro, *RJSTJ*, 58/159.

15

Fernando Redondo García, *La entrega de la posesión*, p. 65-79.

16

C. Especial do STJ, REsp. 1.200.856-RS, 01.07.2014, Rel. Min. Sidnei Beneti, *DJe* 17.09.2009.

17

José Lebre de Freitas, *A ação executiva*, n. 22.2, p. 304

18

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.574, p. 671.

19

Antonio Carlos Costa e Silva, *Tratado do processo de execução*, vol. 2, n. 126.2, p. 1.095.

20

STJ, REsp. 272.531-RJ, 21.11.2000, 4ª Turma, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, *DJU* 05.03.2001, p. 173.

21

José Carlos Barbosa Moreira, *O novo processo civil brasileiro*, p. 215.

22

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.590, p. 676.

23

STJ, REsp. 9.365-SP, 04.06.1991, 3ª Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter, *DJU* 01.07.1991, p. 9.193.

24

Esse sentido, porém, Humberto Theodoro Júnior, *Curso de direito processual civil*, vol. 3, n. 299, p. 403.

25

Humberto Theodoro Júnior, *Curso de direito processual civil*, vol. 3, n. 299, p. 403.

26

STJ, AgRg no AG 88.561-AC, 26.03.1996, 3ª Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter, *DJU* 17.06.1996, p. 21.448.

27

Wilard de Castro Vilar, *Processo de execução*, p. 99.

28

João de Castro Mendes, *Acção executiva*, n. 59, p. 226.

29

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.601, p. 679.

30

René Savatier, *Traité de la responsabilité civile en droit français*, vol. 2, n. 603, p. 379-380.

31

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.602, p. 679.

32

Rodrigo Mazzei, *A liquidação por arbitramento e a liquidação por artigos*, n. 5, p. 488.

33

Alvino Lima, *O direito de retenção e o possuidor de má-fé*, n. 22, p. 71.

34

STJ, REsp. 59.669-RS, 13.06.1995, 3ª Turma, rel. Min. Nilson Naves, *RJSTJ*, 17/293.

35

Alvino Lima, *O direito de retenção e o possuidor de má-fé*, n. 22, p. 70; Arnaldo Medeiros da Fonseca, *Direito de retenção*, n. 113a, p. 197.

36

STJ, REsp. 46.218-GO, 25.10.1994, 3ª Turma, rel. Min. Nilson Naves, *RJSTJ*, 75/357.

37

Arnoldo Medeiros da Fonseca, *Direito de retenção*, n. 163, p. 289.

38

José Lebre de Freitas, *A acção executiva*, n. 22.3.1, p. 308.

39

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 76-77.

40

Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, *Embargos de retenção por benfeitorias*, n. 8.2.5.3, p. 170.

41

Gelson Amaro de Souza, *Sentença na execução*, n.º 7.1, p. 214.

42

Amílcar de Castro, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 8, n. 238, p. 166.

43

Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, n. 20.2, p. 374.

44

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 79.

45

Vide, Andrés de La Oliva Santos, Ignacio Díez-Picazo Gimenez e Jaime Vega Torres, *Derecho procesal civil*, § 65, A, p. 315.

46

Cássio Scarpinella Bueno, *Curso sistematizado de direito processual civil*, vol. 3, p. 469.

47

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo civil*, vol. 6, n. 1.620, p.685.

48

José Carlos Barbosa Moreira, *O novo processo civil brasileiro*, p. 218.

49

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.628, p. 687.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. XIII - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO II - DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO

CAPÍTULO III. DA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER OU DE NÃO FAZER

Capítulo III. Da Execução das Obrigações de Fazer ou de não Fazer

Seção I

Disposições comuns

Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida.

Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo.

1. Execução das obrigações de fazer – As condutas segundo a boa-fé objetiva importam sobremaneira ao comércio jurídico contemporâneo. Essas condutas ou constituem objeto de prestação ou decorrem dos chamados deveres legais de abstenção, tanto os que correspondem a direitos absolutos e a direitos subjetivos públicos, quanto os que se encontram previstos em determinadas relações privadas (v.g., o dever de o locatário permitir a vistoria do imóvel, a teor do art. 23, IX, da Lei 8.245/1991).

Em tema de execução das obrigações de fazer e de não fazer, prevista no Capítulo III do Título II da Parte Especial do CPC/2015, interessa o primeiro grupo. Equiparam-se as duas situações, embora sejam posições passivas inteiramente diferentes, porque se mostram suscetíveis de receber idêntico tratamento no plano processual, quanto à sua execução.¹ Porém, o art. 814 ocupa-se, explicitamente, das obrigações de fazer e de não fazer “previstas em título extrajudicial”, e, portanto, os deveres legais de abstenção não de ser objeto de pronunciamento judicial e, consequentemente, de cumprimento definitivo ou provisório da sentença. A esse respeito, deve-se a lapso do legislador a manutenção, no art. 822, da menção à abstenção decorrente de lei e, portanto, alheia à obrigação contemplada em título extrajudicial.

Em relação aos direitos obrigacionais, o primeiro passo consiste em distinguir duas espécies: (a) obrigação positiva; (b) obrigação negativa. No primeiro caso, o obrigado prestará certo fato,² ou seja, determinada atividade,³ de variável complexidade; na outra, impõe-se ao obrigado comportamento omissivo. Uma divisão subsequente, nas obrigações negativas, separa a simples omissão ou não fazer (*non facere*) da obrigação de tolerância, um deixar fazer ou suportar (*pati*).⁴ Nessa última situação, quem há de tolerar também se obrigará a “remover, com ato positivo, o que obste ou dificulte” o adimplemento em natura.⁵

Sob diferente ponto de vista, classificam-se as prestações fazer em duas espécies: (a) fungíveis; e (b) infungíveis. Obrigações fungíveis, cuja tônica ainda reside na atividade do obrigado, admitem prestação satisfatória por terceiro. Ao invés, obrigações infungíveis são aquelas que “somente podem ser satisfeitas pelo obrigado, em razão de suas aptidões ou qualidades pessoais”.⁶ E, com efeito, diferem substancialmente a construção de um muro, exequível pelo obrigado e, igualmente, por várias outras pessoas com idêntica perfeição e sucesso, e a criação de obra artística, encomendada a escultor célebre.

O liberalismo do início do século XIX consagrou, no art. 1.142 do CC francês, a regra *nemo potest cogi ad factum*, originário do século XVI,⁷ que contaminou outras codificações. Em síntese, o cumprimento da obrigação de fazer infungível, ou *nuda facta*, cujo adimplemento útil se vincula, exclusivamente, ao próprio obrigado, resolver-se-ia em perdas e danos, porque é intangível a pessoa do executado pelo *imperium* do órgão judiciário.

Este frustrante resultado, na prática tornando inexigível a prestação *in natura*, inspirou a criação de expedientes destinados a superar o impasse.⁸ Desenvolveram-se três sistemas, baseados em pressão psicológica: (a) a *astreinte*, que é multa pecuniária caracterizada pela exorbitância, dotada do duplo objetivo de proteger o direito litigioso – na definição da Corte de Cassação francesa, “est une mesure destinée à vaincre la résistance opposée à l’exécution d’une condamnation” –,⁹ e resguardar a dignidade do ofício judiciário;¹⁰ (b) o regime misto alemão, condenando o executado ao pagamento de soma em dinheiro (*Zwangsgeld/Ordnungsgeld*) e, para o caso desta não se mostrar eficiente, a de prisão (*Zwangshaft/Ordnungshaft*), dentro de certos limites;¹¹ e (c) o *Contempt of Court*, próprio da *Common Law*, reputando desacato o descumprimento à ordem do órgão judiciário e implicando a prisão do desobediente até sua submissão.¹² Em qualquer hipótese, a execução consistirá na pressão exercida sobre a pessoa, frustrando-se, porém, revelando-se a ameaça pouco intimidativa, no caso particular – v.g., o obrigado não tem patrimônio, e, portanto, as penas pecuniárias lhe são indiferentes –, ou, malgrado tudo, o devedor incorre na sanção e suporta o castigo.

Essas limitações, em alguns casos políticas,¹³ como “no tradicional repúdio ao emprego da força contra a pessoa para constrangê-la”,¹⁴ em outras hipóteses derivadas de razões práticas, a exemplo da indiferença à pressão ou a insuficiência patrimonial, concorrem para a generalizada fuga da execução específica, substituída pelo equivalente pecuniário. São constitucionais, no que concerne ao direito brasileiro, tanto a pressão patrimonial (*astreinte*), quanto a pessoal (prisão do devedor de alimentos), porque suas consequências jurídicas encontram-se fixadas antecipadamente: no primeiro caso, cria-se crédito pecuniário a favor do exequente; no segundo, cumprido que seja o prazo prisão, o executado não pode ser preso pela mesma dívida, outra vez, mas subsiste a dívida pecuniária.

2. Evolução da execução das obrigações de fazer – Longa evolução histórica preside a execução específica ou em natura das obrigações de fazer ou de não fazer.

Inicialmente, no processo formulário, a *obligatio* romana não comportava execução específica, resolvendo-se em perdas e danos.¹⁵ Mais adiante, no processo da *extraordinaria cognitio*, difundiu-se o uso de interditos marcados pela coerção do *facere* imposto à parte.¹⁶ Essa atividade, porque importava o deslocamento forçado de pessoas e de coisas, por força da tutela interdital, inclui-se no âmbito executivo como hoje entendido.

O direito comum prodigalizou virulentos mecanismos de coerção para obter a conduta almejada, obrigacional ou não, visando o patrimônio (*mulcta*), a própria pessoa (*captura*) ou – no plano idealmente espiritual, mas com devastadores efeitos terrenos – a respectiva participação na comunidade religiosa (*excommunicatio*).¹⁷

A generalização da tortura como meio de investigação da veracidade dos fatos, em procedimentos variados, semeou a aspiração de tornar incólume a pessoa à força do Estado, provocando o desaparecimento dos mecanismos mais drásticos de coerção. O princípio da intangibilidade do obrigado firmou-se na Revolução Francesa, a partir de receita que exprime opção axiológica, jamais por razão universalmente válida,¹⁸ vetou esses meios compulsórios, resolvendo-se as obrigações de fazer infungíveis em perdas e danos, nos termos do art. 1.142 do CC francês. Posteriormente, a jurisprudência francesa reagiu por meio da *astreinte*, “meio indireto destinado a ameaçar o devedor de obrigação de fazer ou de não fazer a executar, realmente, sua obrigação”.¹⁹

O direito pátrio não ignorou diversos expedientes para obter a prestação *in natura*, a exemplo da vexatória prisão correcional do prestador de serviços para forçá-lo a “cumprir os seus

deveres”.²⁰ Era o que previa o art. 69 do Decreto 2.827, de 15.03.1879. Por meio da ação cominatória, prevista até o CPC/1939, buscava-se erradicar o “inadimplemento das obrigações de fazer ou não fazer”.²¹ Este remédio processual se caracterizava pelo preceito, também chamado de monitório, mandado, ordem ou cominação, através do qual o autor pede a imediata expedição de ordem para o réu cumprir a obrigação. Esse procedimento especial desapareceu no CPC/1973,²² passando-se ao regime da *astreinte*. O art. 537 do CPC/2015 consagra, atualmente, a disciplina da multa pecuniária, objeto do art. 814, relativamente às obrigações de fazer e de não fazer previstas em título executivo extrajudicial.

A execução específica das obrigações de fazer e de não fazer jamais ofuscou-se integralmente perante intangibilidade da pessoa do obrigado, apesar da delicadeza do assunto e da alta relevância dos valores envolvidos, como se percebe nesse breve esboço da evolução legislativa da matéria.

3. Fundamento da multa pecuniária – Conforme assinalado no item precedente, o CPC/1973 inovou a tradição do direito pátrio e, sobrelevando-se a outros ordenamentos que lhe eram contemporâneos,²³ consagrou a técnica executiva da multa pecuniária.

A multa pecuniária ou *astreinte* consiste na imposição ao obrigado ao pagamento de uma quantia, de regra por cada dia de atraso, mas que pode ser por outro interregno (semana, quinzena ou mês), como se infere do uso da palavra periodicidade no art. 537, § 1.º, e da expressão “por período de atraso” no art. 814, *caput*, no cumprimento da obrigação, livremente fixada pelo juiz e sem relação objetiva alguma com a importância econômica da obrigação ou da ordem judicial. A emissão do pronunciamento impondo a pena é acessória da resolução principal tomada pelo juiz, no processo de conhecimento ou no processo de execução, e o respectivo valor aumenta à medida que o tempo passa ou as infrações do executado se renovam e persistem.²⁴

Fato digno de registro é que derivava do consenso na interpretação das disposições do CPC/1973, senão da sua finalidade específica,²⁵ a atribuição da multa ao exequente,²⁶ embora a resistência do executado comprometesse, fundamentalmente, a autoridade judiciária, porque nada prescrevia o segundo estatuto processual unitário brasileiro a esse respeito.²⁷ Esta objeção não desmerecia a orientação geral e que se harmonizava com o sistema legislativo. De resto, manifestou-se no sentido que a *astreinte* aproveita ao exequente o Superior Tribunal de Justiça: “O valor referente à multa cominatória, prevista no art. 461, § 4.º, [do CPC de 1973] deve ser revertido para o credor, independentemente do recebimento de perdas e danos”.²⁸

Esse aspecto encontra-se resolvido no CPC/2015, pois o art. 537, § 2.º, atribui ao exequente, *expressis verbis*, a vantagem econômica proveniente da multa pecuniária. O art. 814 permanece silente, mas a primeira regra aplica-se subsidiariamente ao processo de execução.

O meio executório da multa pecuniária originou-se na jurisprudência francesa. Não é isenta de gênio.²⁹

O advento do CC francês de 1808 consagrou o adágio *nemo potest cogi ad factum*, princípio ideológico basilar naquele ordenamento, vedando, na execução do *facere*, o emprego de constrições pessoais sobre o devedor. Em consequência, a execução específica dessa classe de obrigações acabou comprometida. O inadimplemento do obrigado gerava apenas perdas e danos. Entre nós, seguiu a trilha o art. 880 do CC de 1916, segundo o qual o obrigado indenizaria perdas e danos pelo descumprimento de “prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível”. Como assinalava-se perante esse texto, “não tolera a lei que possa o devedor ser forçado, por qualquer meio de violência à sua pessoa, a cumprir a obrigação”.³⁰ Infelizmente, o art. 247 do CC vigente preservou a regra, ignorando a disciplina do processo, sacrificando a tutela específica do credor.

Contra as repercussões práticas dessa orientação, os tribunais franceses desenvolveram o expediente de aplicar, em casos tais, multa de valor extraordinário e extremamente gravosa, com o fito de premir a vontade do obrigado. Trata-se de sanção indireta ao inadimplemento, baseada numa lei psicológica que proclama a preferência da pessoa humana pelos comportamentos de menor esforço, e sua aplicação reiterada, na maioria das vezes, forçou o obrigado ao cumprimento

pontual.

Assiste razão, pois, ao alvitre de “a sanção pecuniária é instrumento executivo, meio e modo de forçar o cumprimento da obrigação”,³¹ em que pese cooptar a vontade do obrigado. Ela provoca intercâmbio patrimonial e, por isso, não apresenta natureza cautelar.³²

Segundo opinião haurida do direito francês, comentando a disciplina legal posteriormente outorgada à *astreinte*, ocorreu a incorporação das “soluções adquiridas na jurisprudência”.³³ E, aduziu-se, afinal se estabeleceu “elo oficial entre este importante meio de pressão e o conjunto das vias executivas”.³⁴ Em França, a *astreinte* é (a) definitiva – insuscetível de revisão – ou (b) provisória (cominatória), quer dizer, é ou não limitada no tempo e, portanto, tem valor final determinado, e é aplicada de ofício pelo juiz da execução. Liquidada-se a pena tão logo constatado o atraso ou o descumprimento, total ou parcial, do devedor. Se provisória a pena, o órgão judiciário poderá suprimi-la e moderá-la, adequando-a, assim, à expressão econômica da obrigação. Mas, sendo definitiva a *astreinte*, o obrigado somente se livrará do pesado ônus em virtude de força maior ou de caso fortuito, porque a pena possui valor adrede estabelecido, tenha ou não o credor obtido, entretantes, o adimplemento *in natura*.

A Corte de Cassação francesa, em 29.05.1990, aplicou *astreinte* para constranger o devedor ao adimplemento de obrigação pecuniária.³⁵ O precedente constitui notável avanço e ampliação do campo de atuação da técnica executiva. Por outro lado, o art. 36 da Lei (francesa) 91.650, de 09.07.1997, permite que, em certos casos, a multa beneficie instituições de caridade, em lugar do credor,³⁶ e seu valor definitivo poderá ser diminuído.³⁷ Esta última providência também se admite no direito brasileiro – o art. 814, parágrafo único, é expresso a esse respeito. Quanto ao destinatário, porém, o art. 537, § 2.º, enunciou, pela vez primeira, constituir crédito do exequente. O destinatário será o Estado-membro ou a União, conforme o caso, na multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2.º), ressalva feita à prática de atos considerados da mesma natureza, mas distintos dos contemplados no art. 77, § 2.º, na própria execução (art. 774, parágrafo único).

Como quer que seja, o emprego da *astreinte* como meio executivo, pressionando patrimonialmente o executado, coíbe “uma situação ilícita, p. ex., as precipitações poluentes de certa indústria em águas públicas (*non facere*)”, ou coage “o poeta a compor o prometido soneto (*facere*), mediante a virulência da pena pecuniária”.³⁸ Todavia, alcançado o adimplemento ou tornado possível esse resultado, ao juiz se faculta diminuir a pena, evitando o enriquecimento injustificado do credor. Uma progressiva dissociação das perdas e danos marcou o desenvolvimento da *astreinte*.³⁹ E, ademais, abandonou o campo restrito das obrigações de fazer, abrangendo também obrigações pecuniárias.⁴⁰

Mediante as reformas introduzidas na lei processual brasileira, a disciplina em vigor se aproximou do paradigma francês, no que tange ao aspecto da possibilidade de diminuição do valor da pena, evolução culminada na sistematização do assunto no art. 537.

Independentemente de regra nesse sentido, o STJ promovera a redução do valor da pena, com o fito de evitar o enriquecimento sem causa.⁴¹ Em sentido contrário, asseverou outro julgado do STJ:

A lei processual de 1973 não estabeleceu limites à fixação da pena pecuniária por dia de atraso no cumprimento de obrigações de fazer e de não fazer. Impossibilidade de aplicação analógica do art. 920 do CC/1916, porque aquele dispositivo visava coibir abusos nas penas convencionais, enquanto a cominação judicial objetiva garantir a efetividade do processo.⁴²

O art. 920 do CC de 1916, citado no precedente, corresponde, *verbum ad verbum*, ao art. 412 do CC em vigor.

Segundo o art. 537, § 1.º, I, o juiz poderá reduzir ou aumentar o valor e a periodicidade da multa, tornando-se “insuficiente ou excessiva”. Seus poderes compreendem as mudanças no valor diário e no montante geral, após a fluência da *astreinte*. Por esse motivo, concebe-se que, a despeito da fluência da multa, o executado dela seja exonerado posteriormente, haja vista seu

adimplemento tardio. De outro lado, o STJ reafirmou a possibilidade de a multa “ser modificada, pelo juiz da execução, quando venha a revelar-se insuficiente ou excessiva”.⁴³ Não parece razoável, apesar de o art. 814, parágrafo único, prever apenas a redução, pré-excluir a possibilidade da majoração do valor.

A *astreinte* representa meio executório poderoso, aplicável vantajosamente para executar de modo específico obrigação de fazer infungível. Somente indevida resistência a esta imprescindível técnica executiva pode deturpar e refrear sua aplicação.

4. Execução específica por meio da multa pecuniária – É preciso entender o funcionamento da multa pecuniária, prevista no art. 814 para promover a execução específica das obrigações de fazer e de não fazer, fungíveis ou não, paralelamente à transformação (art. 817, *caput*), e sem prejuízo da faculdade de o exequente pleitear a conversão da obrigação originária em perdas e danos (art. 816 e art. 821). A regra fundamental, disciplinando o emprego da *astreinte*, localiza-se no art. 537.

Uma vez extinto o procedimento especial da ação cominatória, prevista no CPC/1939, alterou-se a forma de aplicação do preceito (ordem, monitório, mandado). Na atual sistemática, a pressão psicológica sobre o devedor, derivada da *astreinte*, ocorrerá depois da emissão de provimento judicial (sentença ou decisão liminar na tutela provisória, *ex vi* do art. 537, *caput*), ou nos termos previstos no título extrajudicial (art. 814), mas depois de esaurido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação de fazer ou de não fazer (desfazer), a teor do art. 537, § 4.º.

O art. 537, § 5.º, declara aplicável a multa pecuniária na execução de sentenças de força mandamental, ou seja, baseadas em deveres legais de fazer ou de não fazer. A rigor, a repetição é desnecessária, porque a execução já abrange esses deveres, a teor do art. 536, § 5.º. Conforme já se assinalou, o título executivo extrajudicial contempla obrigação de fazer ou de não fazer, assumida pelo obrigado, reproduzindo, ou não, dever legal de abstenção. Por exemplo, o art. 23, IX, da Lei 8.245/1991, institui o dever de o locatário permitir a vistoria do imóvel, sob certas condições, e costuma-se reproduzir esse dever nos contratos de locação residencial. Em tal hipótese, o locador dispõe de título executivo extrajudicial, senão o previsto no art. 784, VIII, relativo ao crédito do aluguel, ao menos o do art. 784, III, incorporando-se a locação em instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Esse dispositivo não discrimina a espécie de obrigação, concebendo-se que seja a obrigação de tolerar a vistoria do imóvel locado.

4.1. Desnecessidade da iniciativa da parte – O art. 814, *caput*, declara que o órgão judiciário, ao despachar a petição inicial da execução fundada em título extrajudicial – provimento liminar positivo –, fixará multa por dia de atraso. O caráter imperativo da regra revela-se tratar-se de dever do órgão judiciário e, ademais, prescindir de pedido da parte, harmonizando-se com a sistemática do art. 537.

Com efeito, esse é o regime do cumprimento da sentença. A pena pecuniária poderá ser imposta na sentença ou na tutela provisória, integrando o conteúdo do provimento que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (força condenatória), ou que emita ordem ao vencido (força mandamental), e outorga título executivo ao vencedor (art. 515, I).

Lícito se afigura ao autor pleitear, desde logo, a condenação do réu sob pena de pagar multa pecuniária. Porém, a cominação de multa é meio executório, e, como tal, independe da iniciativa da parte, aplicando-se *ex officio*, como estabelece o art. 537. Entende-se, portanto, a proscrição do pedido cominatório, sem embargo – e é comum tal acontecer – de o autor ou o exequente formulá-lo na petição inicial. Na versão originária do CPC/1973, o pedido se afigurava obrigatório, se infungível o fazer, e facultativo, se fungível.⁴⁴ E ao juiz vedava-se impô-la de ofício.⁴⁵ Como se percebe, o preceito – imposição da *astreinte* – passou à órbita dos poderes do juiz, dispensando a iniciativa da parte.

Formulado o pedido cominatório, eventual acolhimento decorrerá fatalmente da procedência da postulação principal.⁴⁶ A única descrição judicial, neste caso admissível, respeita ao valor da pena. Ao juiz cabe estabelecê-lo ao julgar a demanda, e, se não lhe aprouver, relegar a tarefa para

o juízo da execução. Talvez assim seja melhor, de resto, porquanto o juiz da execução se encontrará teoricamente em melhores condições para avaliar os dados subjetivos que presidem semelhante fixação. Faltando a cominação no título, quiçá por omissão do órgão judiciário, que deixou de corrigi-la por via de embargos declaratórios, não cabia sua aplicação.⁴⁷ O art. 537, *caput*, enfatiza a possibilidade de o juiz fixá-la a despeito da omissão do título judicial. Por óbvio, omisso que seja o título extrajudicial, nada obsta a aplicação do art. 814, *caput*, máxime porque, havendo essa previsão, ao juiz incumbirá reduzi-la, se excessiva, a teor do art. 814, parágrafo único.

O sujeito passivo da multa pecuniária é o réu, quanto à imposta na “fase de conhecimento” e na tutela provisória, e o executado, no caso do art. 814, *caput*. Não é qualquer pessoa. No direito anterior, o STJ obstou a aplicação da *astreinte* ao gerente da empresa de banco, distinguindo semelhante pena da multa prevista por dolo processual, esta sim aplicável a quaisquer “participantes” do processo.⁴⁸ E, realmente, o art. 77, *caput*, autoriza o órgão judiciário a aplicar a sanção do art. 77, § 2.º, aos participantes do processo, no caso de descumprimento de decisões (art. 77, IV). Fora dessa hipótese, inexistiu base legal para semelhante restrição ao direito do terceiro. E o direito processual integral, por definição, o direito público, submetendo-se ao princípio da legalidade estrita.⁴⁹

Por sua vez, a *astreinte* beneficiará o exequente, e não, o Estado (art. 537, § 2.º).⁵⁰ Ao exequente acode a pretensão a executar o respectivo valor oportunamente, aumentando a pressão sobre o executado. Só a multa do art. 77, § 2.º, beneficia o Estado-membro ou, tratando-se de processo da competência da Justiça Federal comum ou especial, a União. Mas, a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça praticado no cumprimento da sentença ou processo de execução, reverterá em proveito do exequente (art. 774, parágrafo único). É digno de registro que a jurisprudência do STJ apontou o exequente como credor da multa no direito anterior.⁵¹

4.2. Valor da multa pecuniária – Segundo o art. 537, *caput*, parte final, na fixação da multa o juiz considerará valor “suficiente e compatível com a obrigação”. Evidentemente, a diretriz se aplica à multa do art. 814, *caput*.

Essa fórmula afigura-se insatisfatória, na sua literalidade, porque a característica da *astreinte* avulta, como ensinava-se na vigência do CPC/1973, no “exagero no algarismo” da multa.⁵² Portanto, inexistirá compatibilidade com o valor da obrigação, sob pena de a cominação não atingir seus objetivos de compelir o executado ao cumprimento voluntário. No entanto, o STJ estima que, na fixação da multa, o órgão judiciário observará os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,⁵³ o que justifica a dicção do art. 537, *caput*, devendo ser entendida em termos finalísticos.

O valor da *astreinte* deve ser fixado de molde a quebrar a vontade do obrigado ou do destinatário da ordem judicial, desvinculado dos limites ideais de indenização do dano. Neste sentido, já se manifestou o STJ.⁵⁴ Quer dizer, o órgão judiciário fixará a multa numa quantia “suficiente para constranger”.⁵⁵ Para tal mister, nenhum outro critério substitui o da discricionariedade judicial. O órgão judicial considerará o patrimônio do executado – quanto mais rico, maior o valor da pena – e a magnitude da provável resistência, e preocupar-se-á apenas em identificar e aplicar um valor exorbitante e despropositado, inteiramente arbitrário,⁵⁶ capaz de ensejar o cumprimento espontâneo pretendido pelo exequente, e, conseqüentemente, a execução em natura.

Embora haja o autor formulado o desnecessário pedido cominatório, indicando valor certo, o juiz não se encontra adstrito a essa postulação, inclusive na execução fundada em título extrajudicial, se for o caso, podendo reduzi-lo ou aumentá-lo, bem como alterar sua periodicidade, a teor do art. 537, § 1.º.⁵⁷ Esses poderes, intrínsecos ao ofício judicial, aplicam-se à multa do art. 814, *caput*.

A possibilidade de o órgão judiciário reduzir o montante da multa, após a respectiva incidência, e nada obstante o sujeito passivo não ter se dado por vencido, há de ser entendida nos devidos termos. É preciso que não tenha ocorrido preclusão, ou seja, haja a parte aviado recurso específico para impugnar o valor da multa. Eventualmente, o valor da multa assumirá montante expressivo,

como é da sua índole, e, embora aproveite ao exequente, rigorosamente inexistente enriquecimento sem causa: a causa reside na emissão do pronunciamento judicial e no descumprimento do preceito imputável ao executado.⁵⁸

Aqui calha uma ressalva: vencido o exequente na causa principal, cuidando-se de cumprimento da sentença, ou vitorioso o executado nos embargos quanto à subsistência da pretensão a executar (v.g., alegando a inexecutabilidade do título, a teor do art. 917, I), desaparecerá a causa da atribuição patrimonial do crédito relativo à multa, e, conseqüentemente, nada é devido a esse título.

Verdade que, talvez constrangido pelo vulto da dívida resultante da multa, o STJ já reduziu a multa, no curso da execução, sob o pretexto de torná-la razoável.⁵⁹ Pouco razoável, na verdade, é o estímulo implícito à atitude de desrespeitar a cominação da *astreinte*.

4.3. Duração da multa pecuniária – O art. 537, § 4.º, declara que a multa pecuniária, fixada no título executivo ou no provimento liminar do juiz, fluirá “desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão”. Flagrantemente, no cumprimento da sentença, fluirá a multa desde a intimação do vencido para cumprir a decisão (art. 513, § 2.º). O STJ declarou,⁶⁰ no direito anterior, *dies a quo* da pena é o dia imediatamente posterior ao vencimento do prazo de cumprimento.⁶¹ O entendimento subsiste na jurisprudência do STJ.⁶² É condição para a fluência da multa a prévia intimação do executado (Súmula 410 do STJ).

A *astreinte* apenas tenta compelir o obrigado ao cumprimento e não possui, entre nós, caráter retroativo.⁶³ Do mesmo modo, no direito francês, o juiz fixa, em geral, um prazo para o executado cumprir espontaneamente, não começando a *astreinte* a fluir senão após o vencimento do interregno.⁶⁴ É o escopo básico de constranger e premir a vontade do destinatário que recomenda esse termo inicial, e, de resto, cabe ao juiz estabelecer “prazo razoável” para o cumprimento do preceito, a teor do art. 537, *caput*, fórmula repetida no art. 815, *in fine* (“... no prazo que o juiz lhe designar...”).

Eis as razões de fundo, a despeito de o art. 814, *caput*, declarar que cumpre ao juiz fixar “a data a partir da qual será devida”, para o órgão judiciário cominar a multa a partir do vencimento do prazo de cumprimento, seja qual for, otimizando a pressão sobre o executado. Revela-se inadmissível fixá-la a partir da citação, seja aquela ocorrida no processo de conhecimento, baseando-se a execução em título judicial, seja a do processo executivo, se for o caso do art. 515, § 2.º (v.g., quando a obrigação derivar de sentença arbitral). O fim da *astreinte* não é o de criar crédito pecuniário favorável ao exequente, embora tal aconteça no caso de recalcitrância, mas o de premir o executado para realizar execução específica. E, para essa finalidade, convém possibilitar-lhe o cumprimento voluntário sem que, ao mesmo tempo, suporte a multa.

O juízo da execução fixará o prazo de cumprimento se omissa o título a respeito (art. 815, *in fine*).⁶⁵ Desnecessária, destarte, a cominação da multa no próprio título executivo judicial ou extrajudicial. Não há *dies ad quem*, a multa é infinita,⁶⁶ porque perdura enquanto o vencido não cumprir a obrigação ou a ordem judicial (art. 537, § 4.º, segunda parte), vencendo-se dia a dia (ou em outro interregno temporal), e seu curso somente se interromperá na ocasião do cumprimento, e, a requerimento do exequente, por meio do pedido de conversão da prestação em natura em perdas e danos (arts. 816, *caput*, e 821, parágrafo único). Segundo o art. 500, no cumprimento da sentença a multa é devida conjuntamente com as perdas e danos, e não parece razoável excluir essa cumulação na execução do título extrajudicial. Desejando executá-la, o credor liquidá-la-á mediante cálculo (art. 509, § 2.º) e, na inicial respectiva, provará a ocorrência do inadimplemento.⁶⁷ Essa execução por quantia certa aumenta a pressão sobre o executado.

Era admissível, na versão originária do CPC/1973, unicamente a multa diária,⁶⁸ lapso temporal de vinte e quatro horas, diversamente da *astreinte* francesa. Segundo se infere do art. 537, § 1.º, possibilitando o juiz alterar a periodicidade da multa, e do art. 814, *caput*, aludindo a “período de atraso”, outras grandezas de tempo (v.g., o minuto) podem ser utilizadas. Logo, qualquer grandeza temporal poderá ser adotada (minuto, hora, semana, mês, semestre). E, por força desse mesmo

dispositivo, a grandeza originária do título, ou fixada pelo juízo da execução, comporta infinitas mudanças, em todos os sentidos (redução ou ampliação).

4.4. Modificação e exclusão da multa pecuniária – O art. 537, § 1.º, ocupou-se da modificação e da exclusão da multa no cumprimento da sentença. É dado ao órgão judicial, *ex officio* ou a requerimento da parte (exequente ou executado), modificar o valor ou alterar a periodicidade da multa. Esse poder relaciona-se à duração da multa pecuniária. Resta enunciar a diretriz geral. A adequação da multa no curso da execução prende-se, sobretudo, à sua finalidade precípua: persuadir o executado a cumprir. Por um lado, o aumento da dose talvez induza o executado recalcitrante ao cumprimento; de outro, a redução do valor impagável, nas circunstâncias do caso concreto, por mais contraditório que pareça, também possibilita o cumprimento, antes evitado pelo temor de pagar multa enorme. Não impede a modificação do valor ou da periodicidade a existência de coisa julgada ou de preclusão das vias recursais quanto ao valor originário.⁶⁹

Conforme se infere da menção à “multa vincenda”, posta no final do § 1.º do art. 537, a modificação produzirá efeitos *ex nunc*. Não apaga o valor porventura acumulado até a oportunidade da decisão na qual o juiz altera o valor ou a periodicidade. Parece bem claro que alusão à “multa vincenda” respeita ao poder de “modificar o valor ou a periodicidade da multa”, e, não, à exclusão ulterior da multa, por força de um dos motivos legais.

O art. 814, parágrafo único, autoriza ao órgão judiciário reduzir o valor da multa prevista no título executivo extrajudicial. Dessa disposição resulta a possibilidade de as partes pactuarem multa pecuniária com as características da *astreinte*. Em tal hipótese, infere-se da disposição veto ao aumento, porque os figurantes do negócio jurídico, no âmbito da autonomia privada, já estipularam o *quantum* suficiente para induzir o obrigado ao cumprimento. A interpretação da regra dependerá da tendência autoritária ou liberal quanto às regras do processo. De acordo com a primeira concepção, cuidando-se de meio executório, aplicável *ex officio*, o órgão judiciário não se encontra adstrito às disposições das partes a esse respeito. Ao invés, preponderando o liberalismo e a manutenção da autonomia privada, aplicar-se-á literalmente o art. 814, parágrafo único. Não há resposta, *a priori*, mas lícito conjecturar que ao juiz seja dado empregar os meios técnicos da melhor maneira possível para atingir os fins próprios do processo de execução.

O art. 537, § 1.º, permite ao juiz, ademais, excluir a multa: (a) no caso de revelar-se insuficiente ou excessiva (inciso I); (b) o executado comprovar o cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o descumprimento (inciso II). Nesse último caso, também se afastará a multa por dolo processual e a responsabilidade penal antevista no art. 536, § 3.º. Esse regime aplica-se, por analogia, ao art. 814.

Não se confundem modificação e exclusão. Enquanto na modificação a pena subsiste, porque o ato decisório surtirá efeitos *ex nunc*, na exclusão a multa desaparece retroativamente, no todo ou em parte. É descabida a exclusão, em qualquer hipótese, subsistindo o descumprimento ante a recalcitrância do executado. Conforme decidiu o STJ,

a análise sobre o excesso da multada deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que a multa incidia, e com o grau de resistência do devedor. Não se pode analisá-la na perspectiva de quem, olhando os fatos já consolidados no tempo, depois de cumprida a obrigação, procura razoabilidade que, na raiz do problema, existe um comportamento desarrazoado de uma das partes.⁷⁰

Em primeiro lugar, o juiz excluirá a multa insuficiente, porque inútil, e a multa excessiva, porque vencido os limites do absurdo (art. 537, § 1.º, I). A avaliação reporta-se ao momento da fixação, e, não, na oportunidade em que o executado pleiteia a redução, porque o valor atingido é alto. Assim decidiu o STJ:

o valor total fixado a título de *astreinte* somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora ou da inércia do próprio devedor.⁷¹

A impossibilidade superveniente da prestação *in natura*,⁷² com ou sem culpa do obrigado, exclui a pena, apresentada a justificativa prevista no art. 537, § 1.º, II, *in fine*, porque inviável seu escopo, que é a execução específica. Por exemplo: A pleiteia o fornecimento do medicamento X do Estado-membro; B, porém antes do cumprimento da ordem do juiz o autor A falece, em virtude da moléstia. O art. 36, 3.ª parte, da Lei francesa de 03.07.1991 autoriza o juiz a suprimir a pena na ocorrência de evento alheio à vontade do obrigado.⁷³ Em tal sentido, decidiu o STJ,⁷⁴ haja vista o fato superveniente que reconheceu não existir ilicitude no comportamento do executado. Relativamente às vantagens atribuíveis ao exequente, juntamente com as perdas e danos porventura cabíveis, realizar-se-á o cômputo da pena do dia da sua incidência até aquele acontecimento que inviabilizou o cumprimento *in natura*, para os efeitos do art. 500. Na hipótese de o executado tomar medidas tendentes ao cumprimento (v.g., o Estado-membro B adquiriu o medicamento X antes da morte do autor A), ainda que haja culpa leve, não tem cabimento a multa.⁷⁵ É essa a justa causa que alude o art. 537, § 1.º, II, *in fine*.

Também se excluirá a pena, a critério do órgão judiciário, no caso de o executado cumpra, no todo ou em parte, mas com atraso a prestação ou a ordem judicial (art. 537, § 1.º, II, 1.ª parte), com o fito de evitar o enriquecimento do exequente. É o que se recomenda nas hipóteses de cominação da pena, ilegítimamente que seja, contra a Fazenda Pública. Não tem justificativa social e jurídica plausível realizar atribuição patrimonial expressiva em favor de um único necessitado, por exemplo, em detrimento do conjunto, ou seja, em desfavor da própria sociedade.

Por outro lado, o exequente há de se comportar com boa-fé (art. 5.º do CPC/2015) e, na medida do possível, cooperar no cumprimento do executado, impedindo que, em razão de ato imputável a ele, o valor da pena aumente consideravelmente. Por exemplo, aguardar longo tempo sem iniciar a execução da multa que incidiu, posto que descumprido o provimento favorável pelo adversário ou a obrigação.⁷⁶ Entenda-se que, nesse caso, parece razoável o vitorioso aguardar o julgamento da causa ou do recurso interposto contra o ato do art. 814 pelo tribunal, tornando mais estável o provimento de primeiro grau, na medida em que, revertido o julgamento de primeiro, a multa desaparecerá retroativamente, nada obstante sua incidência. Por sinal, o STJ entendeu que, no caso da decisão que concede medida de urgência (tutela provisória), o cumprimento provisório poderá ter lugar somente após a confirmação da sentença pelo tribunal de segundo grau.⁷⁷ Resta ver se assim o STJ interpretará o art. 537, § 4.º.

O valor global da pena pecuniária poderá ser reduzido, pois a seu respeito inexiste preclusão ou coisa julgada, consoante decidiu o STJ.⁷⁸

Essas discussões podem ocorrer nos embargos e na impugnação do art. 525 c/c art. 536, § 4.º,⁷⁹ ou, como decidiu o STJ, na exceção de pré-executividade.⁸⁰

Em qualquer hipótese, a decisão do juiz, modificando ou excluindo a multa nos termos do art. 537, § 1.º, há de ser tomada por decisão fundamentada, respeitando o contraditório (art. 10 do CPC/2015), e é passível de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único).

4.5. Cumulação da multa pecuniária e perdas e danos – Dado seu caráter provisório, ou seja, ilimitado,⁸¹ ao credor é lícito pleitear a liquidação paulatina da pena, geralmente subordinada a simples cálculos aritméticos (art. 509, § 2.º, e art. 786, parágrafo único), e promover a execução da quantia acumulada,⁸² sem prejuízo da ulterior conversão da prestação original em perdas e danos e, nesse entretempo, da própria execução específica. Optando pela prestação pecuniária substitutiva, o art. 500 assegura a cumulação ao valor das perdas e danos do valor da multa devido até esse momento. A disposição se aplica aos casos dos arts. 816, *in fine*, e 821, parágrafo único.

É inadmissível a cumulação da *astreinte* e perdas e danos no direito francês. O juiz possui a faculdade de reduzir a pena, ante o cumprimento, razão por que o exequente poderia ver-se na contingência de restituir a diferença ao obrigado.⁸³ O art. 500 do CPC/2015 adotou orientação oposta, sem prejuízo da possibilidade de redução e até de exclusão da multa (art. 537, § 1.º).

O exequente não pode haver o equivalente pecuniário da prestação de fazer ou de não fazer e

permanecer credor vitalício do valor da pena. A única finalidade da *astreinte* consiste em premir o executado para atingir a execução específica, não constituindo causa de atribuição patrimonial autônoma para o exequente.⁸⁴ e, como toda ameaça, para ser levada a sério, eventualmente necessita materializar-se, mas não é causa autônoma de atribuição patrimonial ao exequente. Assim, há de cessar sempre que inviabilizada a execução específica. Em outras palavras, ocorrendo o cumprimento, ainda que tardio e após a fluência da multa, ou a impossibilidade aventada no art. 499, soma-se o valor desta no cômputo das perdas e danos até a data do cumprimento, salvo redução pelo juiz (art. 537, § 1.º, I). O poder conferido ao órgão judiciário no art. 537, § 1.º, visa a subordinar, por razões de equidade, o montante da pena ao valor global das perdas e danos.

4.6. Opção por outro meio executório – Cuidando-se de obrigação fungível, a cominação da multa no título ou por ato do juiz na execução, jamais impedirá o exequente de optar pelo meio executório da transformação (art. 817), igualmente aplicável ao caso. Nesta hipótese, parece óbvio entender-se haver desistência da multa, fixada, aliás, no seu exclusivo interesse, e não poderá invocá-la mais adiante.

Seção II

Da Obrigação de Fazer

Art. 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.

1. Natureza da prestação de fazer – Em virtude de redação excelente, sem alteração digna de nota, ressalva feita à troca da palavra “devedor” por executado, a fim de harmonizar a terminologia, o art. 815 prevê a execução de obrigação de fazer na Seção II do Capítulo IV do Título II da Parte Especial do CPC/2015.

Ao âmbito do art. 815 escapa, conseqüentemente, a atividade executiva desenvolvida em cumprimento das eficácias mandamental e executiva, objeto de demanda, decisão e ulterior cumprimento da sentença. Típica ação executiva, a adjudicação compulsória, nascente do descumprimento dos deveres inerentes ao programa contratual da promessa de compra e venda, é objeto do art. 501.

Nenhuma relevância há, outrossim, na natureza da prestação. E isso porque, tanto a obrigação só pelo devedor exequível (art. 247 do CC), quanto a obrigação desprovida da tônica da personalidade exclusiva, inserem-se no Capítulo III do Título II. Neste último caso, o exequente empregará o meio da coerção patrimonial (art. 814), porque é o único cabível, apesar de seus percalços (v.g., o obrigado não dispõe de patrimônio e a multa pecuniária não o constrange), realizando postulação nesse sentido na petição inicial.

A personalidade [ou não] da obrigação subordina-se ao interesse do credor. Ele não é obrigado a aceitar a prestação de terceiro, rezava o art. 878 do CC de 1916, “quando for convencionado que o devedor a faça pessoalmente”. Nada obstante não se reproduzir a regra no CC vigente, o princípio permanece, e talvez se satisfaça, o credor com a prestação substitutiva do estranho. É o caso do cineasta, contratado para registrar certo evento, que manda em seu lugar o assistente. Existirá execução específica, sem invasão da esfera jurídica do obrigado.⁸⁵

O objeto da prestação, no caso do art. 815, é o mais amplo possível.⁸⁶ Ele abrange qualquer ato, obra e serviço a ser prestado.

2. Provimento liminar do juízo – O art. 814 prevê o provimento liminar do juiz com o fito de (a) fixar a multa por período de atraso e (b) a data a partir da qual será devida. Esses aspectos receberam análises anteriormente, invocando-se, destarte, a disciplina geral do art. 537 quanto à *astreinte*.

Cuida-se do provimento liminar positivo do órgão judiciário. Porém, o conteúdo desse

provimento é mais complexo do que deixam entrever os arts. 814 e 815. Ele englobará as seguintes deliberações: (a) o exame da aptidão da petição inicial, porque revestida dos requisitos gerais, especiais e formais cabíveis no caso, implicitamente que seja, e, portanto, superada a aplicação do art. 801; (b) a fixação dos honorários advocatícios a favor do exequente (art. 85, § 1.º), na espécie segundo as regras gerais (art. 85, § 2.º), porquanto inexistente regra especial estipulando percentual fixo, ao contrário do que sucede na execução por quantia certa (art. 827, *caput*), sem embargo da possibilidade de aplicação, por analogia, da redução do art. 827, § 1.º, e da majoração, caso haja atividade postulatória posterior (art. 827, § 2.º); (c) a determinação do prazo de cumprimento; e, por fim, (d) a ordem de citação do executado por um dos meios legalmente admissíveis. Relativamente a esse último aspecto, analisado sob o art. 798, remarque-se a admissibilidade da citação postal e da citação por meio eletrônico.

Dessas deliberações, a que mais importa, na execução de obrigações de fazer, consiste na determinação do prazo de cumprimento.

3. Fixação do prazo de cumprimento – A execução da obrigação de fazer começa, emitido o provimento liminar positivo, por meio da citação do executado para “satisfazê-la” no prazo assinado pelo juiz, se outro não constar do título (art. 815). No provimento liminar, ademais, o órgão judiciário fixará a multa pecuniária (art. 814, *caput*) e, se prevista no título executivo, exercerá controle sobre seu valor, podendo reduzi-lo, se excessivo (art. 814, parágrafo único). A respeito da *astreinte*, incide o art. 537.

Por conseguinte, antes de realizar a citação, na execução baseada em título extrajudicial, mostra-se indispensável estipular o prazo para o obrigado prestar voluntariamente. O fato “tem data e tem lugar”,⁸⁷ sem embargo do *facere* de consumação instantânea. É preciso, de qualquer sorte, ensejar o cumprimento voluntário em interregno razoável e adequado ao objeto da obrigação.

3.1. Indeterminação do prazo de cumprimento – O prazo de cumprimento contemplado no art. 815 se caracteriza pela sua ampla variabilidade. É intuitivo que não se completa uma ponte num só dia; e o pintor não apronta a aquarela num par de horas. Fatores de índole diversa influem no tempo justo para cumprimento e, em alguns casos, a fixação se revela tarefa árdua. Por exemplo: que prazo em semanas se assinará ao escritor para acabar a obra? Flaubert gastava dias emendando uma palavra, enquanto Balzac, premido por dívidas, completava um romance numa única noite de insônia. Em outros casos, o prazo é matemático: o obrigado gasta certo número de minutos para empilhar, rejuntar e rebocar certo número de tijolos, apurando-se a quantidade de dias prováveis para aprontar o muro na altura e extensão projetadas, ressalva feita às adversidades climáticas. Eis o motivo por que, ao contrário do que acontece na obrigação para entrega de coisa, em que há prazo rígido (art. 806, *caput*), no caso do art. 815 o prazo é, *a priori*, indeterminado.

Eventualmente, as partes previram, no título executivo extrajudicial, prazo de cumprimento, hipótese versada no art. 815, *in fine*. É preciso analisar, portanto, os modos de fixação do prazo de cumprimento.

3.2. Determinação do prazo de cumprimento – Vários elementos concorrem na atividade de fixação do prazo de cumprimento. Ele pode decorrer da lei, da convenção prevista no título executivo, ou, enfim, depender de fixação pelo órgão judiciário.

Na omissão do título, cabe ao juiz se valer do termo legal ou contratual. Na ausência de qualquer dado concreto e vinculativo, o juiz deve fixá-lo através de arbitramento,⁸⁸ em liquidação prévia e anterior ao chamamento do executado. Naqueles casos extremos, em que a produtividade do artesão interfere, o juiz deliberará discricionariamente – no sentido que esta possibilidade assume no direito processual. É preciso considerar, além da natureza da prestação, os respectivos aspectos intrínsecos (dificuldade, tempo necessário para obter o resultado, estágio atual da situação) e extrínsecos (condições climáticas, realizando a obra ao ar livre).⁸⁹

O prazo fixado há de permitir a realização de todo o *facere*. Convém recordar que sua

inobservância ensejará, talvez, a aplicação de virulenta *astreinte*. Em síntese, o prazo variará em conformidade às aptidões pessoais do condenado (imagine-se o artesão perfeccionista, mas lerdo) e a natureza extrínseca da própria prestação.⁹⁰

3.3. Prorrogação do prazo de cumprimento – Após seu início, o prazo de cumprimento comporta prorrogação em virtude de caso fortuito ou de força maior.⁹¹ Assim, o muro projetado para trinta dias sofrerá inevitável retardamento, provocado pela intensa e extemporânea precipitação pluviométrica. Em geral, os negócios privados já preveem tais acontecimentos e lhes atribuem efeito ampliativo do termo. Também se admite a prorrogação convencional.⁹²

3.4. Comunicação do prazo de cumprimento – É indispensável inserir o prazo de cumprimento no mandado executivo, sob pena de nulidade, a fim de vincular o executado ao interstício, tratando-se de execução fundada em título extrajudicial. No caso da execução fundada no título previsto no art. 515, I, subentende-se que o vencido há de ser intimado na pessoa do seu advogado (art. 513, § 1.º), fixando o juiz prazo razoável (art. 537, *caput*), não necessariamente o quinquênio previsto no cumprimento de prestações pecuniárias (art. 523, *caput*).

3.5. Recurso contra a determinação do prazo – O pronunciamento que fixa o prazo de cumprimento, porque resolve uma questão incidente – e, portanto, exige motivação suficiente (art. 489, § 1.º) –, constitui decisão interlocutória (art. 203, § 2.º), da qual cabe agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único). A subida imediata do agravo, único regime do recurso previsto no art. 1.015, justifica-se, ademais, na circunstância de se cuidar de decisão suscetível de causar danos às partes. O interesse em recorrer é bilateral: o exequente reclamará do prazo excessivo, o executado do prazo exíguo.

4. Delimitação do objeto da prestação – O art. 815 apresenta defeito nada desprezível, omitindo-se quanto à cabal determinação do *facere* positivo ou negativo. Decerto não basta acentuar que ao obrigado toca levantar ou desfazer o muro ou esculpir a pedra. É preciso adiantar como, onde e quando se consumarão tais empreitadas. O art. 815 deu atenção ao “quando”, mas pôs de lado o “onde” e o “como”, remetendo-os, talvez, aos incertos parâmetros do título.

Ora, não se pode supor a previsão no título das minúcias quanto ao comportamento do obrigado. Qual a altura e a extensão do muro? Qual a profundidade das fundações? Qual o acabamento? Qual a qualidade do material – na compra e na aquisição? Em outros sistemas, o órgão judiciário designará audiência preliminar para esclarecer esses pontos, seguida do acompanhamento dos trabalhos de campo no local da prestação.⁹³ Em realidade, semelhante aspecto constitui o ponto crítico dessa espécie de execução, porque sempre haverá uma área duvidosa entre o objeto real da prestação e o modo concreto de realizá-lo.

De ordinário, caberá ao credor, na forma do art. 798, II, *a*, indicar a espécie de execução, quando ela for realizável por vários modos, sob controle da autoridade judiciária. Sem embargo, as questões exemplificadas, e outros problemas difíceis, apresentam-se com frequência, clamando por resolução no cumprimento voluntário (art. 815), no cumprimento sub-rogado por terceiro (art. 817) e no cumprimento decorrente do exercício da preferência do credor (art. 820). Em cada pormenor insignificante se mostra necessário abrir o contraditório, ponderar as postulações das partes e prover acerca das dúvidas suscitadas.

O art. 536, *caput*, reza que o juiz determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Segundo aduz o art. 536, § 1.º do mesmo artigo, tais medidas podem consistir (a enumeração é exemplificativa) na imposição de multa, na busca e apreensão, na remoção de pessoas e coisas, no desfazimento de obras e no impedimento de atividade nociva, com ou sem requisição de força policial.

Por conseguinte, configura requisito da petição inicial, nesses casos, a teor do art. 798, II, *a*, do CPC/2015, o exequente indicar a “espécie” de execução. Ao juiz competirá controlar semelhante especificação, integrativa do comando do título, observando o princípio da adequação insculpido no art. 805, *caput*, sendo o executado onerado pelo ônus de demonstrar o meio menos gravoso (art. 805, parágrafo único). No sentido sempre aqui defendido, ponderou-se o seguinte:

É claro que o juiz poderá traçar alguns parâmetros para a obra realizada ou desfeita por diligência do credor, principalmente para evitar gastos e sacrifícios além dos necessários.⁹⁴

Tanto o exequente quanto o executado, este considerando que não está obrigado a prestar nada além do traçado no título, habilitam-se à impugnação do ato judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, mediante agravo de instrumento.

5. Atitudes do executado – Completada a citação, através de um dos modos admissíveis, o prazo, seja qual for, inicia com a juntada do mandado executivo (ou, mais amplamente, da prova da realização da citação por outro meio), na forma do art. 231, concebendo-se três atitudes fundamentais do executado: (a) cumpre voluntariamente a obrigação; (b) permanece inerte; (c) opõe-se à demanda executória.

5.1. Cumprimento voluntário total ou parcial – Em primeiro lugar, sensibilizado pelo ajuizamento da execução, o devedor poderá dispor-se a cumprir satisfatoriamente o julgado. Para tal arte, usufruirá do prazo assinado pelo juiz.

Cabe distinguir entre o cumprimento total, o qual, incontinenti, enseja o incidente de encerramento, a teor do art. 818, e o cumprimento parcial.

Na hipótese de o obrigado iniciar o adimplemento e interrompê-lo, imputavelmente – v.g., distribui as pedras de alicerce e, em seguida, abandona o canteiro de obras –, impende apurar se o inadimplemento se mostra relativo ou absoluto. Perante inadimplemento relativo, caracterizado pela utilidade ainda manifesta da prestação, o interesse do credor, e a ampla disponibilidade a ele facultada no art. 775, sugere a concessão de maior elastério ao obrigado, a fim de ultimar a obra, serviço ou atividade, caso se disponha a fazê-lo e requeira o exequente. Se houver reiteração do atraso, ao exequente é lícito requerer a fixação de termo essencial, a partir do qual se desinteressará da prestação. Seja como for, o obrigado responderá pelo dano provocado pelo retardamento.⁹⁵

O descumprimento absoluto torna inútil a prestação tardia. É situação irreversível, equivalente à inatividade total do executado no prazo de cumprimento, passando-se, então, à etapa seguinte do procedimento, conforme se trate de obrigação fungível, passível de execução por terceiro (art. 817), ou de obrigação infungível (art. 821), revelando-se inútil, ademais, a cominação da multa pecuniária consoante o art. 814.

5.2. Inércia do executado no prazo de cumprimento – Permanecendo o executado inerte no prazo de cumprimento, abrem-se opções ao exequente, adiante examinadas, e a principal delas consiste em requerer, seja a obrigação realizada “à custa do executado” (art. 817, *caput*), sendo fungível a obrigação.

Não se mostra imprescindível aguardar o término do prazo de cumprimento. Admite-se o inadimplemento antecipado, ou seja, antes do vencimento do prazo, o executado recusa-se a adimplir – hipótese antevista no art. 821, parágrafo único, mas aplicável às obrigações fungíveis – ou não toma providências tendentes ao cumprimento, tornando o inadimplemento inevitável. Antes mesmo do termo final do prazo de cumprimento, talvez fique evidente, pela falta de iniciativa e disposição dos meios hábeis ao tempestivo adimplemento, que o obrigado deixará de cumprir no prazo. Em tal contingência, o exequente requererá de logo a providência de seu interesse.

5.3. Oposição do executado – O prazo de cumprimento, ajustável à infinita variação do *tempus* do adimplemento na obrigação de fazer, e o prazo para o executado se opor à execução, mostram-se inconfundíveis. Este último é de quinze dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos (art. 915, *caput*, c/c art. 231).⁹⁶ Os embargos, preenchidos os requisitos do art. 919, § 1.º, podem ou não exibir efeito suspensivo.

Por meio da oposição, o executado deixa claro sua falta de disposição para cumprir o julgado. Fica prejudicado, pois, o cumprimento voluntário, embora o interregno ultrapasse os quinze dias

do art. 915, *caput*. Mas, removido esse obstáculo ao andamento da execução, o exequente poderá anuir com o cumprimento tardio, ainda útil, pleiteado pelo executado. Em tal conveniente hipótese, o procedimento retorna ao seu ponto inicial.

Art. 816. Se o executado não satisfazer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurada em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

1. Atitudes do exequente – Descumprida a obrigação, e superados eventuais embargos, ao exequente possui dois termos de alternativa: (a) a realização da prestação fungível por terceiro (art. 816, *caput*, 1.^a parte, c/c art. 817); ou (b) a conversão do procedimento, liquidando as perdas e danos para haver a prestação pecuniária substitutiva, e, a seguir, expropria bens do executado (art. 816, *caput*, 2.^a parte, e parágrafo único), sem prejuízo da cumulativa execução da multa pecuniária, aplicando-se, por analogia, o art. 500.

Admissível é sempre, a teor do art. 249, *caput*, do CC, o credor converter o *facere* no seu equivalente pecuniário. Incomum que seja, porque os credores em geral visam à tutela específica do seu direito, ao estatuto processual se mostraria descabido renegar tal possibilidade – daí por que a previu na segunda parte do art. 816, *caput*.

O inadimplemento do executado, vencido o prazo de cumprimento, talvez se revela absoluto. Em diversas circunstâncias essa consequência ocorrerá, consoante a utilidade remanescente da prestação tardia. Mesmo após a obtenção da sentença condenatória, mirando a execução específica do título judicial, evento superveniente às vezes aniquila a utilidade, fenômeno também verificado na execução de título extrajudicial. Por exemplo, o rebaixamento do modesto clube esportivo do interior, que contratara a instalação de grande arquibancada de tubos de aço para as temporadas anteriores na primeira divisão, gerará desinteresse ulterior na execução específica da prestação, pois o aumento do espaço para os aficionados não é necessário na divisão inferior.

O apelo ao complexo meio executório da transformação relaciona-se, de forma bastante íntima, à subsistência da utilidade da prestação e ao caráter insatisfatório do equivalente pecuniário. Nenhuma quantia substitui, por exemplo, a higidez das instalações sanitárias do lavatório comprometida pelas infiltrações provenientes do vizinho.

2. Conversão da execução – O exequente tem o direito de converter o procedimento, trocando de meio executório, se o inadimplemento for absoluto, desinteressante a execução específica ou para haver indenização pelos danos marginais ocasionados pela inexecução parcial. O art. 817, *caput*, 2.^a parte, assegura ao exequente, frustrado no objetivo primário da execução, haver perdas e danos, “hipótese em que se converterá em indenização”. Em relação à regra anterior, ocorreu ligeira (e para pior) mudança redacional.

Em cada hipótese específica, a conversão do rito subordina-se à iniciativa do exequente, depois de expirado o prazo de cumprimento ou verificada a irreversibilidade do descumprimento, e provimento do juiz; deste, aliás, cabe agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único).⁹⁷ Ao executado não compete opor-se à conversão, mas é-lhe lícito, invocando o prazo do art. 815, pleitear o cumprimento voluntário em prazo adicional.

O direito à indenização decorre da previsão do direito substancial (art. 389 do CC). Ele não precisa constar do título executivo, à guisa de prestação alternativa. Entretanto, na forma do art. 816, parágrafo único, do CPC/2015, “o valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa”.

A liquidação das perdas e danos se fará por arbitramento ou por artigos, aplicando-se, destarte, o art. 509.⁹⁸ Exclui-se a mesma se houver previsão de cláusula penal substitutiva (art. 410 do CC),⁹⁹ que, de ordinário, prescinde de acerto do *quantum debeatur*, bastando cálculos do exequente

(art. 786, parágrafo único).

Na apuração dos danos emergentes, ou do que o exequente efetivamente perdeu em decorrência do inadimplemento, e dos lucros cessantes, e do que “razoavelmente deixou de lucrar” (art. 402 do CC), vigora o princípio do amplo ressarcimento do devedor “sem vantagens imaginárias ou fantásticas”.¹⁰⁰ Em tema de liquidação do dano, vale recordar, inexistindo critério específico o valor da indenização se fixará por arbitramento, no qual assume extraordinário relevo a *finesse* do juiz, porquanto a amplitude da indenização do dano é *a matter of judicial politics*.¹⁰¹

Art. 817. Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiros, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado.

Parágrafo único. O exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado.

1. Disciplina da prestação fungível – Segundo o art. 817, *caput*, “é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, autorizar” que terceiro realize a prestação a que se obrigou o executado.

A execução por terceiro dependerá da iniciativa do exequente. Além disso, há de haver provimento do juiz acerca da possibilidade de o terceiro prestar o fato. Deverá o órgão judiciário ponderar a pessoalidade da obrigação. Se houver convenção a respeito, impossível se afigura a sub-rogação, porque interferiria no âmbito da autonomia privada; se a obrigação foi constituída considerando apenas as habilidades do obrigado, a sub-rogação, assim comandando o interesse do credor, mostrar-se-á cabível. Efetivamente, se alguém convencionou a pintura de uma natureza morta e o artista se recusa a entregá-la no prazo e forma combinados, nada veda obtenha idêntico proveito através da tela de outro mestre do pincel e da paleta. O obrigado não responde pelas imperfeições da obra do terceiro, conforme acentua o art. 819, *caput*.

Como quer que seja, o juiz apreciará a postulação do credor e emitirá uma decisão interlocutória,¹⁰² ao propósito, e passível de impugnação mediante agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único).

2. Execução por terceiro – A disciplina do meio executório da transformação, na versão originária do CPC/1973, caracterizava-se pela complexidade. Reforma legislativa posterior repeliu os resíduos históricos, objeto de censura já ao tempo do CPC/1939,¹⁰³ e promoveu simplificação, dispensando a morosa e complexa perícia prévia, a fim de apurar o custo, e a licitação para recrutamento do terceiro. Nada obstante, remanesce uma dificuldade: a forma de recrutamento do terceiro, e, de toda sorte, o laconismo do art. 817, parágrafo único, do CPC/2015, não sublima as dificuldades latentes do procedimento.

2.1. Realização extrajudicial da prestação – Há obrigações de fazer em que a sub-rogação por terceiro prescinde de interferência na esfera jurídica do obrigado – por exemplo: alguém contrata um traje de gala a um renomado alfaiate que, poucas horas antes da cerimônia, avisa não ter separado os forros e cetins, compelindo o credor a procurar outro artesão para confeccionar a roupa. A tutela específica permanece admissível, existindo interesse do credor, hipótese em que o obrigado responderá, concomitantemente, pelas perdas e danos (custo da outra roupa).

Transplantando esta situação para dentro do processo executivo, cumpre rememorar que, a despeito do laconismo atual do art. 817, na proposta que, ouvidas as partes, o órgão judiciário aprovar (art. 817, parágrafo único) subentende-se a avaliação dos custos do fato. Logo, não se confundem a execução extrajudicial, inclusive a sacramentada posteriormente à condenação do obrigado, e o cumprimento pelo exequente, sob visto do juiz (art. 820). Nesta hipótese, comparativamente ao que sucede no círculo da autonomia privada, há controle judicial dos custos: pode acontecer de novo alfaiate trabalhar com tecidos raros e seu preço usual é superior ao do executado

Mas, nada obscurece a existência, em algumas obrigações de fazer, de transformação sob auspícios do credor e sem o emprego da coerção estatal. E isso porque levantar o muro no terreno do próprio exequente, que poderá aviar-se sozinho, representa tarefa bem diversa da edificação no quintal do vizinho.

2.2. Recrutamento do terceiro – Deliberada positivamente a fungibilidade, a primeira providência reside na escolha da pessoa natural ou jurídica apta a prestar o fato.

O art. 817 nada esclarece acerca do procedimento quanto ao recrutamento do terceiro. É óbvio que o terceiro há de apresentar uma “proposta” e, acerca de seu conteúdo, o órgão judiciário colherá a manifestação das partes, antes de aprová-la ou rejeitá-la, atendendo ao direito fundamental ao contraditório, tão caro ao CPC/2015 (art. 10), apesar da omissão dessa providência no art. 817, parágrafo único. Evitou-se, assim, a realização da perícia prévia, como acontecia versão originária do CPC/1973, na qual o *expert* traçava o roteiro e definia o custo da obra, bem como a licitação pública para recrutar o terceiro. Apesar de se entrever a possibilidade de o juiz impor a realização de perícia, caberá ao proponente indicar, por sua conta, tanto o custo, quanto a especificação técnica da obra. Inspirou-se o legislador na rotina dos “orçamentos” para contratação da empreitada.¹⁰⁴ Sobreviveu, porém, o problema da escolha.

Ora, a designação de particulares para colaborar com a Justiça sempre recaiu na esfera de autoridade do juiz. Exemplo eloquente se localiza na designação do perito. Em geral, as pessoas legalmente habilitadas, a exemplo de engenheiros e contadores, credenciavam-se perante os diferentes juízos e, dentre os que apresentarem os melhores títulos ou experiência, o juiz realizava sua escolha. Atualmente, o cadastro prévio é mais amplo, organizados no âmbito do respectivo tribunal (art. 156, § 2.º), não havendo dúvida que, no caso sob exame, incidirá o art. 156, § 1.º, devendo a escolha recair sobre alguém cadastrado. Não parece razoável subtrair da autoridade judiciária o comando da atividade executiva, encarregando tão só o exequente do recrutamento e da confabulação acerca das condições da proposta.¹⁰⁵

Nada obsta, no entanto, que o exequente indique alguém habilitado profissionalmente ao juiz. O art. 156, § 1.º, exige que o perito seja pessoa “legalmente habilitada”, ou seja, encontre-se inscrito no órgão de classe competente. Não é necessária, porém, essa habilitação específica no caso do art. 817: o empreiteiro, em geral, é um prático licenciado pela experiência.

Em casos particularmente difíceis, haja vista o vulto do empreendimento e outras circunstâncias, nada impede o uso das modalidades de licitação contempladas no art. 22 da Lei 8.666/1993, por exemplo, o convite através de carta. Convém apenas substituir o complexo regime derogado por modalidade equivalente, mas simples e eficiente ao objetivo colimado.

2.3. Apresentação da proposta e contraditório – Apresentada(s) a(s) proposta(s) – porque nada impede mais de uma – o órgão judiciário, antes de aprová-la(s) ou rejeitá-la(s), ouvirá as partes (art. 817, parágrafo único). A lei não fixou prazo, mas ele é de cinco dias, a teor do art. 218, § 3.º. Aprovada a proposta, fluirá outro prazo de cinco dias para o exequente exercer a preferência assegurada no art. 820, *caput*. Em seguida, examinando o conteúdo das manifestações das partes, o juiz decidirá, aprovando ou rejeitando a proposta, e, se for o caso, adjudicará a obra ao exequente (art. 820, parágrafo único). Na hipótese de rejeição (v.g., porque o custo é excessivo), renova-se o procedimento de escolha, se o terceiro não adequar a proposta. A decisão tomada é passível de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único).

2.4. Preferência do exequente e formalização do negócio – Intimadas as partes da decisão do juiz que houver aprovado a proposta, tem-se o terceiro, não exercendo o exequente a preferência do art. 820, *caput*, como obrigado a prestar o fato. O art. 819 chama-o de “contratado”. O regime do art. 817 eliminou o termo pelo qual o terceiro se obrigava a prestar o fato, bem como a prestação de caução. Nenhuma dessas providências, atualmente, mostra-se necessária. A aprovação da proposta basta para formar o negócio jurídico entre o Estado, de um lado, e o terceiro, de outro.

2.5. Adiantamento do preço pelo exequente – Por óbvio, apesar da omissão do art. 817, parágrafo único, competirá ao exequente adiantar a quantia prevista na proposta, segundo o

cronograma nele estipulado. É o preço cobrado pelo terceiro para prestar o fato. Esse ônus constitui simples desdobramento da regra geral do art. 82 do CPC/2015. Deverá depositar tais importâncias, em conta vinculada ao juízo, que se encarregará de liberá-las e repassá-las ao terceiro, consoante o programa de pagamentos incluído na proposta (v.g., metade no início, o saldo no final).

Evidentemente, a responsabilidade final por todas as despesas incumbe ao executado. Vale lembrar que a prestação é realizada “à custa do executado” (art. 817, *caput*). Subentende-se do art. 817, parágrafo único, simples adiantamento, pressupondo a comodidade e a urgência do exequente, que, não dispondo de meios para este fim, poderá utilizar a execução de custeamento.

3. Retratação do exequente – É possível ao exequente que escolheu executar à custa do devedor a obrigação fungível (art. 816, *caput*, 1.^a parte) retratar-se, infletindo no rumo da expropriação (art. 816, parágrafo único), sob certas condições.

Tal questão se relaciona com a oportunidade da execução de custeamento. Em princípio, até a aprovação da proposta, o terceiro só ostenta uma expectativa, reversível mediante o exercício da prelação contemplada no art. 820. Por conseguinte, até a decisão do juiz o credor pode livremente se arrepender, liberando o terceiro e assumindo as despesas (v.g., o custo da elaboração da proposta); após o pronunciamento de aprovação da proposta, continua admissível a desistência, fundada no art. 775, *caput*, mas nessa hipótese o exequente indenizará o terceiro.¹⁰⁶ No direito português (art. 873 do CPC português de 2013), ao invés, após o início da prestação, é vedado ao credor optar pela prestação pecuniária substitutiva o que se infere da cláusula “no caso de não estar ainda iniciada” que marca a desistência;¹⁰⁷ entre nós, inexistente disposição análoga.

Mesmo após a execução de custeamento, o arrependimento revelar-se-á inevitável se, executado o obrigado, o produto da alienação de seus bens for insuficiente para atender o cronograma financeiro da proposta apresentada pelo terceiro. É livre o exequente para adiantar primeiro os recursos e executar por quantia certa em seguida, sabendo de antemão que desembolsa quantias indenizáveis pelo devedor.¹⁰⁸ O interesse na tutela específica da obrigação, a mais das vezes, revela-se tão intenso (ou a obra importante) que o exequente vai em frente e fecha os olhos à impossibilidade total ou parcial de reembolso.

4. Insucesso no recrutamento do terceiro – Concebe-se que nenhum terceiro se apresente para prestar o fato. À semelhança do que acontece com os demais particulares convidados a colaborar com a administração da Justiça, a exemplo do perito, ninguém pode ser constrangido ou compulsoriamente investido no encargo. Ao exequente só resta pleitear o reconhecimento de sua prelação (art. 820).

Nada exclui, porém, a renovação do procedimento em época mais oportuna de mercado e sob novas e melhores condições.¹⁰⁹

5. Execução de custeamento – O aspecto “mais saliente” da transformação radical,¹¹⁰ indubitavelmente, na possibilidade de surgir pretensão a executar a quantia necessária ao custeamento do empreendimento a cargo do terceiro. Tal execução seguirá o modelo expropriativo comum, e, à semelhança do disposto no art. 870, n. 2 do CPC português de 2013,¹¹¹ inexistente o direito de o executado nomear bens. O valor da dívida se apura em liquidação prévia, nos termos do art. 509, abrangendo toda a dívida.¹¹²

A execução da quantia necessária à prestação do fato por terceiro pode ser feita antes ou depois da transformação. Outra vez há omissão do estatuto processual. Por esse motivo, na vigência do CPC/1939 alguns estimavam que as execuções corriam “paralelamente”;¹¹³ outros alvitavam processável a execução de custeamento após a formação do negócio com terceiro;¹¹⁴ ou, da forma mais simples, defendia-se que ao credor cumpria aguardar o incidente de encerramento, a fim de executar os bens do obrigado,¹¹⁵ quando não teria de lidar com saldos ou complementações da obra. Esta última possibilidade se justificaria, no direito pátrio, ante a inexistência de regra expressa, como a decorrente do § 887 da ZPO alemã, que autoriza ao credor executar o devedor

antecipadamente, sem prejuízo de diferenças posteriores.¹¹⁶ É a firme posição defendida por arguto comentador da lei processual brasileira anterior.¹¹⁷

Em verdade, a primeira hipótese é a única conforme aos interesses prevalecentes na função executiva, embora todas sejam possíveis. O adiantamento previsto no art. 817, parágrafo único, respeita ao exequente e envolve somente o autor da proposta. Frente ao executado, o dispositivo representa *res inter alios*.¹¹⁸ Ademais, beneficiando ao exequente a gratuidade da justiça, a verba virá de poucos recursos orçamentários, raramente disponíveis, razão por que ninguém impugnará a exequibilidade imediata da quantia perante devedor quicá abonado.

Indispensável se afigura tão só a liquidez da dívida. É preciso o juiz aprovar a proposta. Como o recurso cabível não impede, salvo a concessão de efeito suspensivo *ope judicis*, o prosseguimento do processo, a pretensão a executar nasce deste pronunciamento e fornece ao exequente o título hábil. É uma decisão judicial que, ante a peculiaridade da situação, escapa inclusive da órbita do art. 523, no cumprimento da sentença. Existindo suplementação de recursos no curso da obra, ela se tornará exigível logo que arbitrada e empregada.

Art. 818. Realizada a prestação, o juiz ouvirá as partes no prazo de 10 (dez) dias e, não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação.

Parágrafo único. Caso haja impugnação, o juiz a decidirá.

1. Controle do cumprimento da obrigação – O encerramento do meio executório da transformação ultima-se com o controle sobre a perfeição da prestação forçada. Deverá ela corresponder aos parâmetros indicados na petição inicial, deferidos pelo juiz na delimitação da prestação e, se a execução coube a terceiro, constantes da respectiva proposta.

1.1. Cabimento do controle do cumprimento – Os atos materiais de execução do *facere* podem competir ao executado, no prazo de cumprimento, ao contratado para prestá-lo à sua custa (art. 817, *caput*) e ao próprio exequente, exercido o direito de preferência consagrado no art. 818. Infelizmente, a lei processual negligenciou a disciplina do acompanhamento dos atos pelo oficial de justiça, ao qual incumbe, na dicção do art. 782, efetivar os atos executivos comandados pelo juiz, motivo por que os acontecimentos surpreenderão, na maioria das vezes, o órgão de direção das atividades executivas.

Como quer que seja, uma vez comunicada a conclusão do ato, obra ou serviço pelo prestador – executado, contratado ou exequente –, abrir-se-á incidente de verificação da fidedignidade da prestação.

1.2. Procedimento do controle do cumprimento – “Realizada a prestação”, reza o art. 818, *caput*, o juiz ouvirá “as partes” no prazo de dez dias. A regra pressupõe comunicação do executor material do ato. Porém, a notícia pode chegar ao processo por qualquer meio e através de qualquer figurante da relação processual.

Não se afigura “inócua”, como pareceu a alguns,¹¹⁹ a manifestação do executado. É evidente, ao invés, seu grande interesse na regularidade da prestação do contratado,¹²⁰ e, *a fortiori*, a do exequente (v.g., se o muro de arrimo não lhe prejudicou, desnecessariamente, a paisagem ou a servidão de águas que lhe aproveita, ou se o desvio do cronograma financeiro não decorreu da incúria do prestador). Coexistem os interesses do exequente e do executado: o primeiro visa à satisfação cabal; o segundo, ao menor gravame da execução.

Advindo impugnação do interessado, no prazo preclusivo assinalado, instalar-se-á controvérsia entre o exequente e o executado, ou entre o exequente e o contratado, cuja solução, presumivelmente, dependerá da realização de vistoria,¹²¹ não sendo flagrante o caráter incompleto ou os efeitos da prestação. É ampla a cognição na matéria. Todos os meios de prova se mostram admissíveis. Em seguida, o juiz decidirá sobre a exatidão do ato, obra ou serviço prestado (art. 818, parágrafo único). Conforme acentuou o STJ:

Se o executado alega que prestou o fato, a que se achava obrigado, e o exequente discorda da afirmação, oferecendo impugnação formal a respeito, cabe ao juiz proferir decisão, dirimindo a controvérsia.¹²²

Por outro lado, “não havendo impugnação”, recorda a parte final do art. 818, *caput*, ou o impugnante deduziu sua alegação intempestivamente, o juiz “considerará satisfeita a obrigação”. Extinguir-se-á, portanto, o processo (art. 924, II), salvo havendo despesas e honorários de advogado pendentes, caso em que prosseguirá na forma da execução por quantia certa, realizada no mesmo processo.

2. Extinção da execução da obrigação de fazer fungível – O pronunciamento pelo qual o juiz resolve o incidente provocado pela impugnação ao cumprimento, disciplinado no art. 818, assumirá, conforme seu conteúdo, natureza de sentença ou de decisão.

Se o juiz acolher a impugnação realizada, o provimento contemplado no art. 818, parágrafo único, constituirá decisão: a execução prosseguirá, nos mesmos autos, para completar o custeamento, ou iniciá-lo, ou reparar a obra malfeita (art. 819). Contra tal ato cabe agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único).¹²³

Ao invés, rejeitando o juiz a impugnação, ou não ocorrendo nenhuma reclamação – hipótese em que, consoante o art. 818, *caput*, parte final, o juiz “considerará satisfeita a obrigação” –, ao órgão judiciário cumpre extinguir o processo mediante sentença (art. 925), impugnável através de apelação (art. 1.009, *caput*), porque solvida a obrigação (art. 924, II), salvo devendo o processo prosseguir para o exequente haver o reembolso das despesas e dos honorários do seu advogado, caso em que observar-se-á o procedimento da execução por quantia certa.

Art. 819. Se o terceiro contratado não realizar a prestação no prazo ou se o fizer de modo incompleto ou defeituoso, poderá o exequente requerer ao juiz, no prazo de 15 (quinze) dias, que o autorize a concluí-la ou a repará-la à custa do contratante.

Parágrafo único. Ouvido o contratante no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz mandará avaliar o custo das despesas necessárias e o condenará a pagá-lo.

1. Descumprimento do contratado – Aprovada a proposta, o terceiro se transforma em contratado. Assim o qualifica o art. 819, *caput*. Obrigou-se ao cumprimento da obrigação subrogando o obrigado originário, nos termos do cronograma por ele próprio elaborado.

Em tese, o contratado cumprirá a contento sua tarefa, porque assumiu obrigação afeita ao seu ofício, subentendendo-se a perfeição. Nessa contingência, o procedimento ingressa na fase final, apurando-se a exatidão do adimplemento, consoante estipula o art. 818. Não há como impedir, entretanto, o inadimplemento do contratado, total ou parcialmente, antecipado ou não, absoluto ou relativo, a prestação acompanhada de vícios ocultos ou aparentes. Seja qual for a causa e a extensão do inadimplemento, cabe ao exequente insatisfeito reclamar ao juiz.

1.1. Prazo de reclamação – O art. 819, *caput*, dilatou o prazo de reclamação para quinze dias, envolvendo o cumprimento defeituoso ou incompleto do contratado. É o prazo cabível para o caso de o contratado não realizar a atividade a que se obrigou. O art. 819, *caput*, deixa claro a faculdade de o credor concluir e reparar o empreendimento, por si ou através de terceiro, “por conta do contratante” (*rectius*: contratado).

Concebe-se a contagem do quinquênio previsto no art. 819, *caput*, do provimento que abre o contraditório sobre o cumprimento (art. 818, *caput*), e do esgotamento do prazo apresentado na proposta.¹²⁴ Certo é que, perante obra deteriorada ou incompleta, há irregularidade flagrante, dispensando maiores provas e discussões, motivo por que parece demasia inútil constranger o exequente inconformado a aguardar o término do prazo. Tratando-se de vício construtivo, porém, razoável se afigura esperar que o órgão judiciário o reconheça para, subsequentemente, pleitear a retificação.

Em suma, o exequente desencadeará o incidente de verificação do cumprimento a qualquer tempo, inclusive antes de findo o prazo de cumprimento, contado o quinquênio da data em que a prestação se tornou impossível ou desinteressante, ou até quinze dias após a decisão que admitiu a impugnação (art. 818, parágrafo único).

1.2. Contraditório na reclamação – Requerida a reparação ou a conclusão, na forma do art. 819, *caput*, o parágrafo único do dispositivo manda ouvir o contratado no prazo de quinze dias. Deverá ser intimado pessoalmente. Concebem-se três atitudes do terceiro: (a) impugnar a postulação do exequente, porque inverídica e abusiva, sustentando a rigorosa conformidade da prestação ao cronograma; (b) admitir a reclamação; (c) ficar inerte.

Em qualquer das hipóteses alvitadas, o juiz determinará a realização de vistoria e avaliação,¹²⁵ ou seja, apurará “o custo das despesas necessárias e o condenará a pagá-lo” (art. 819, parágrafo único, *in fine*), se procedente a reclamação, o que se deduz do reconhecimento, explícito ou não, do contratado instado a manifestar-se. Controvertido o pleito do exequente, a vistoria dará razão a quem a tiver.

O “custo das despesas necessárias”, a ser obtido mediante avaliação, subentende a atualização do cronograma financeiro primitivo e todos os recursos ínsitos ao acabamento e à correção da obra. Ele não exclui pretensão autônoma as perdas e danos mediante ação autônoma.

O provimento judicial que condenar o contratante constitui decisão interlocutória,¹²⁶ porque resolve o incidente, e é agravável (art. 1.015, parágrafo único).

1.3. Renovação do custeamento – Desaparecida a caução que, na versão originária do CPC/1973, o terceiro prestava, assegurando a boa execução do fato, resta ao exequente, apurado o inadimplemento, executar o contratante, que é “condenado” (art. 819, parágrafo único, *in fine*).

Esta execução constitui verdadeira operação de custeamento. Por esse motivo, a ela se aplica o que já foi dito a propósito deste assunto. Ela se processará nos próprios autos da execução original.¹²⁷

1.4. Responsabilidade subsidiária do executado – Em última análise, o executado remanesce responsável pelo cumprimento da obrigação, entregue a terceiro “à custa do executado”, reza o art. 817, *caput*. Embora sua responsabilidade se restrinja à obrigação em si, não se exacerbando pelo fato imputável ao contratante inadimplente, exigir-se-á o concurso do executado nas despesas, subsidiariamente, se o contratante se revelar insolvente, por exemplo. Nessa hipótese, do valor originário da prestação descontar-se-ão os elementos porventura aproveitáveis da prestação parcial, incompleta e defeituosa (v.g., as fundações do muro e os dutos do sistema elétrico).

1.5. Extinção imprópria da execução – Cogita-se da possibilidade de o exequente, confrontado pela prestação incompleta ou defeituosa do contratado, abandonar a execução específica ou aceitar a prestação nessas condições. Impõe-se a resposta afirmativa, no alvitre de que ao exequente é dado desistir de quaisquer medidas executivas (art. 775, *caput*). Neste caso, extinguir-se-á a execução, reputando-se cumprida a obrigação (art. 924, II). Daí por que acertou o STJ, no direito anterior, quando decidiu que o art. 819 consagra “mera faculdade, que ao credor é lícito desprezar”.¹²⁸

Art. 820. Se o exequente quiser executar ou mandar executar, sob suba direção e vigilância, as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, terá preferência, em igualdade de condições de oferta, em relação ao terceiro.

Parágrafo único. O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 5 (cinco) dias, após aprovada a proposta do terceiro.

1. Preferência do exequente – O titular do direito é quem melhor avalia a exatidão do adimplemento. Por isso, o art. 820 do CPC/2015 faculta ao exequente realizar o fato, por si ou

através de terceiro da sua livre escolha, alheio ao controle direto do juiz. Há, porém, o contrapeso decorrente de o valor da obra constar da proposta do terceiro.

1.1. Prazo do exercício da preferência – Segundo dispõe o art. 820, parágrafo único, o credor possui o prazo de cinco dias, “após a aprovada a proposta do terceiro”, para exercer o direito de preferência. Não se encontra especificado o termo inicial do prazo, mas ele começará a correr da intimação porventura feita da aprovação, tomando o exequente conhecimento das condições do futuro contratado.

1.2. Despesas da execução da prestação – A preferência outorgada no art. 820, *caput*, pressupõe o prévio levantamento do custo e do cronograma da prestação pelo terceiro. Fica o credor dispensado de prestar contas até o limite aprovado pelo juiz. Também poderá ingressar na esfera jurídica do obrigado,¹²⁹ à semelhança do que aconteceria com o terceiro, salvo se o *facere* realizar-se na sua própria esfera jurídica (v.g., o executado B obrigou-se a consertar o piso da cozinha do exequente A).

1.3. Prazo de execução da prestação – O prazo para realizar o fato é o que restou estabelecido na proposta do terceiro. Responderá o exequente pelos danos derivados do retardamento. Tem o obrigado, ao propósito, interesse legítimo em se liberar da forma mais cômoda e menos dispendiosa.

1.4. Custeamento da execução da prestação pelo exequente – O executado custeará a execução do fato pelo próprio exequente. Calha à hipótese tudo quanto se afirmou a respeito do adiantamento das despesas e da execução de custeamento. De regra, a obtenção dos recursos necessários ao cumprimento precederá sua realização prática, pois, “caso a quantia obtida pela execução de custeamento seja igual ou superior à fixada pelos peritos na avaliação, o credor fará os contratos que quiser para efetuar a prestação”.¹³⁰

1.5. Controle do cumprimento pelo exequente – Submeter-se-á o exequente ao incidente de encerramento (art. 818, *caput*). O obrigado possui legitimidade e interesse em questionar a exatidão do cumprimento, o seu valor excessivo e os custos suplementares, talvez inúteis, provocados pelo excesso de diligência do credor.

Art. 821. Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que lhe assine prazo para cumpri-la.

Parágrafo único. Havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que se observará o procedimento da execução por quantia certa.

1. Execução da obrigação infungível – Infungível é a prestação *faciendi* insuscetível de sub-rogação por terceiro. Segundo o art. 638, *caput*, isto ocorre “quando for convencionado que o executado a satisfaça pessoalmente”. A norma retrata a disposição do direito material (art. 247 do CC).

A infungibilidade aproveita apenas o exequente. É quem dispõe, portanto, de ampla disposição do elemento concernente à personalidade, e pode acolher a prestação de terceiro, dá-la por satisfatória, se aprouver ao seu interesse. Cabe exclusivamente ao exequente permitir ao assistente do célebre cirurgião plástico realizar ou não, em lugar do titular, a cirurgia no seu nariz aquilino. Em tal hipótese, sujeitar-se-á o exequente aos imprevisíveis resultados da sub-rogação.

Dispõe o exequente da coerção patrimonial para executar de forma específica a obrigação de fazer infungível. O STJ admitiu a fixação de multa pecuniária na execução da obrigação personalíssima de prestar serviços artísticos.¹³¹ Assim, no provimento liminar, deferindo a citação do executado, ao juiz incumbe fixar honorários a favor do advogado do exequente, e, ainda, a multa pecuniária.

Interessa, preliminarmente, estabelecer em que condições o fazer adquire a conotação da infungibilidade.

1.1. Pessoalidade na prestação de fazer – Não há rol explícito de obrigações de fazer infungíveis. É preciso considerar o interesse do credor, interpretando o negócio jurídico, mas analisado objetivamente e à luz da boa-fé.¹³²

Inicialmente, a questão relevante consiste na cooperação ou participação de terceiros no cumprimento – v.g., o fotógrafo que se comprometeu a retratar a atriz sensual e misantropa para admirador fanático. Não logrando surpreendê-la, descumpre imputavelmente a obrigação? Desde logo se pré-exclui, porque o vínculo é dessa natureza, a execução específica?

Ora, poucas obrigações de fazer se desprendem do contexto social, pois a interação humana torna o comportamento do obrigado um dominó de interdependência. Tal circunstância não exclui a execução específica:¹³³ a colaboração do terceiro é problema inserto nos poderes dispositivos do obrigado, que a projeta ou a planeja antes de vincular-se. Constitui inadimplemento imputável, assim, o retardamento das obras do centro comercial, porque o especialista atrasou os cálculos das estruturas de concreto. O executado poderá alegar e provar a ausência da colaboração pontual do terceiro e pedir a prorrogação do prazo, exceto se o “fazer” do terceiro, estranho ao próprio processo, também se revelar insuscetível à sub-rogação.

Por outro lado, há obrigações de fazer que, objetivamente, só o obrigado consegue prestar.¹³⁴ Por exemplo, o fornecimento de serviços públicos de água, luz e gás, ou apresentar as contas reclamadas judicialmente, ou exhibir documentos, e tais fatos personalíssimos,¹³⁵ em geral, timbram pela pessoalidade. Os exemplos revelam que nem sempre a pessoalidade descansa na convenção das partes, com aventa o art. 821, *caput*. Nessas hipóteses, antecipando as dificuldades ulteriores, o credor já pede na ação condenatória o equivalente pecuniário, caso não almeje utilizar, ou o mecanismo não lhe assegura, *a priori*, a execução específica, o meio executório da coerção patrimonial (*astreinte*).

1.2. Licença administrativa – Em certas hipóteses, o cumprimento do obrigado se subordina à licença administrativa da autoridade pública – por exemplo, a aprovação do projeto arquitetônico no contrato de empreitada para construir a casa do cliente. É claro que o credor passa a ter legitimidade para pleitear, no campo próprio, a licença.¹³⁶ Todavia, se a autorização é negada, porque ilegal, dispensável se torna controverter com a autoridade, pois, conforme notou-se acertadamente,¹³⁷ a obrigação se resolve em perdas e danos.

1.3. Prazo de cumprimento da obrigação infungível – O prazo assinado ao obrigado para cumprir (art. 821, *caput*) é variável e segue o traçado na obrigação de fazer fungível. O art. 537, *caput*, alude a “prazo razoável” no mesmo sentido.

1.4. Oposição do executado – O prazo para embargar a execução é de quinze dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação (art. 915, *caput*), não se confundindo com o de cumprimento, no caso da execução de título extrajudicial. Mas, esgotado este, o procedimento da execução sofrerá, de plano, o “desvio” de rumos,¹³⁸ procedendo-se à liquidação do equivalente pecuniário do fazer infungível, sem prejuízo da pendência paralela dos embargos. Rejeitada a oposição do executado em primeiro grau, a execução correrá definitivamente, salvo concessão de efeito suspensivo *ope judicis* à apelação.

2. Liquidação e execução das perdas e danos – Se o executado não acudir à citação, imprescindível na execução fundada em título extrajudicial, realizando a obrigação no prazo de cumprimento, ou, ainda, se recusou cumpri-la, ao exequente toca requerer a conversão da execução. Descabem impugnações ao requerimento. O caráter imperativo do art. 821, parágrafo único, indica a caráter compulsório da conversão.

Realizada a conversão, observar-se-á o procedimento da execução por quantia certa, feita a liquidação das perdas e danos por um dos meios legalmente admissíveis (art. 509). A execução por quantia certa processar-se-á nos próprios autos. Ao equivalente pecuniário o exequente cumulará, ou não, perdas e danos e o montante da pena pecuniária que, entretanto, incidiu contra o executado (art. 500).

Seção III

Da Obrigação de Não Fazer

Art. 822. Se o executado praticou ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo.

1. Execução específica das obrigações negativas – A prestação que se almeja do devedor, em algumas obrigações, consiste num comportamento omissivo. Tais obrigações se designam de negativas. Elas abrangem rol razoavelmente amplo de deveres, incluindo os que resultam diretamente da lei, segundo se conclui dos exemplos tradicionais neste assunto. Destarte, alguém pode se encontrar obrigado:

(a) a não fazer algo (v.g., ao locatário toca “não modificar a forma externa ou interna do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador”, *ex vi* do art. 23, VI, da Lei 8.245/1991);

(b) a tolerar fato natural ou atividade alheia (v.g., “receber as águas que correm naturalmente” do prédio superior, nos termos do art. 1.288 do CC);

(c) a consentir a prática de certo ato dependente de autorização (v.g., “permitir a vistoria do imóvel pelo locador”, a teor do art. 23, IX, da Lei 8.245/1991).¹³⁹

Embora do ponto de vista técnico sejam discerníveis das obrigações, os deveres legais de abstenção comungam da problemática inerente àquelas.¹⁴⁰ Por isso, o art. 536, § 4.º, prevê a aplicação do cumprimento da sentença de obrigação de fazer e de não fazer aos deveres legais dessa natureza. Porém, em determinados casos, sem pejo da previsão legal, o figurante de relação jurídica incorporada em título executivo extrajudicial (art. 784), assume obrigação de idêntico alcance. É o caso, v.g., do locatário. O contrato de cláusulas predispostas obriga o locatário a permitir a vistoria do locador e proíbe-o de modificar a fachada do prédio. Essa obrigação convencional comporta execução segundo o art. 822.

Ressalva feita a esse aspecto, a menção à “lei” no art. 822 é imprópria. A invocação do art. 822 necessita de previsão da obrigação negativa em título executivo extrajudicial.

O procedimento *in executivis* contemplado nos arts. 822 e 823 do CPC/2015, precipuamente endereçado às “obrigações de não fazer”, não prevê a tutela específica do exequente. Bem por isso o credor opta por constituir título judicial, buscando amparo na tutela inibitória; porém, os meios executórios do art. 536, § 1.º, aplicáveis à execução fundada em título extrajudicial, especialmente a *astreinte*, por sua vez prevista no art. 814 e objeto de amplo estudo anterior, possibilitam a obtenção da prestação em natura, superando a disciplina do art. 823.

O art. 822 inicia com a sugestiva cláusula “se o executado praticou o ato”, revelando, de forma indubitável, o caráter repressivo da terapia aí predisposta. Da leitura dos dispositivos avulta que eles tratam, exclusivamente, de desfazer os efeitos materiais de eventual transgressão do obrigado. E isto, decerto, quando o ilícito produz efeitos dessa natureza, porque nas mais diversas situações a imaterialidade e o caráter instantâneo das consequências impossibilitam a *reductio in pristinum*.

Dois motivos básicos inspiraram essa frustrante terapêutica, baseada no art. 251, *caput*, do CC.

Em primeiro lugar, a própria exequibilidade específica do *facere*, a partir da leitura pobre e reacionária do brocardo *nemo ad factum*, parecia questionável, notadamente porque rejeitado o emprego da coerção. Ademais, faltou consciência mais nítida da distinção entre o fazer de consumação instantânea ou transeunte (v.g., dever de preservar informações “a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo” – art. 388, II, do CPC/2015) e duradoura (v.g., dever de não ocupar terreno acima de certos índices construtivos). Entendia-se inviável “desfazer o que foi feito”,¹⁴¹ o que só se mostra verdadeiro em relação ao primeiro grupo de obrigações.

Indubitável, portanto, a pretensão a executar do art. 822 “não tem o objetivo de compelir à abstenção”.¹⁴² Faltaria até a oportunidade hábil para o executado cumprir após a citação, no

perspicaz argumento de quem deparou-se com problema análogo no direito português.¹⁴³

A execução específica das obrigações negativas dependerá, ao fim e ao cabo, da extensão outorgada à tutela preventiva em certo sistema jurídico.¹⁴⁴

Entre nós, reza o art. 5.º, XXXV, da CF/1988 que a lei não excluirá a apreciação de “ameaça a direito”, frisando a possibilidade abstrata deste tipo de tutela. No âmbito infraconstitucional, pródiga sucessão de regras aponta no mesmo rumo. O art. 497, parágrafo único, do CPC/2015 abstrai a existência de dano ou a de culpa quanto a tutela específica consistir na inibição da prática, a continuação ou a reiteração de ilícito. E o art. 84, *caput*, da Lei 8.078/1990 consagra a “tutela específica da obrigação”, que poderá consistir no “impedimento de atividade nociva” (art. 84, § 5.º).

Por conseguinte, *de lege lata*, através de tutela provisória, e na suposição de que o obrigado não tenha praticado ofensa ao dever de abstenção, ou cuidando-se de *facere* de consumação duradoura – em tal hipótese, para fazê-la cessar e evitar-lhe a repetição –, o direito pátrio outorga tutela específica aos deveres negativos. O meio executório principal é a coerção patrimonial (art. 537).

Seja como for, o contexto dos arts. 822 e 823 é outro. A execução das obrigações de não fazer previstas em título extrajudicial transforma-se em simples atuação de obrigação positiva (desfazer). Faz o art. 823, parágrafo único, ressalva à impossibilidade de desfazer-se o ato. Mas, nessa hipótese, consoante preceitua o parágrafo, “a obrigação resolve-se em perdas e danos”, convertido o procedimento *in executivis*.

1.1. Título executivo da obrigação negativa – Deflui do catálogo do art. 784 que a execução da obrigação de fazer negativa poderá se fundar no título previsto no art. 784, III, no caso de o inquilino obrigar-se a permitir a vistoria do locador e recusar seu ingresso no imóvel. Nada obsta, e o art. 785 o autoriza, *expressivis verbis*, o locador deduzir pretensão pelo procedimento comum, obtendo tutela provisória e “efetivando” essa medida na forma do art. 536.

1.2. Objeto da obrigação negativa – O art. 822 menciona abstenção derivada da lei ou do contrato. Criticando a primeira parte do dispositivo, no direito anterior, ponderou-se não se situar o contrato em pé de igualdade com a lei, nem a obrigação negativa decorre, *tout court*, do texto legal, mas da incidência de alguma norma sobre determinado esquema de fato.¹⁴⁵ Seja como for, não basta a infração ao dever legal. O exequente há de exhibir título executivo, e, portanto, a pretensão a executar do art. 822 só pode derivar do contrato. E “contrato abrange qualquer negócio bilateral ou unilateral”.¹⁴⁶ Presumivelmente, o tipo do art. 784, III, é o que mais se afeiçoa ao caso, mas não se afasta a possibilidade de transação referendada (art. 784, IV) possibilitar idêntica pretensão.

Mas, como já visto, a execução governada pelos arts. 822 e 824 é a decorrente de “inadimplemento de obrigação de não fazer com prestação permanente”. O parágrafo único do art. 823 indica o fato de a obrigação negativa com prestação instantânea ter sido descumprida.¹⁴⁷ Em tal caso, a despeito da convergência no pressuposto do inadimplemento, a lei apenas contempla a conversão do procedimento para realizar o sucedâneo das perdas e danos.

Em síntese, nenhuma passagem consagra a tutela específica da obrigação negativa.

2. Comprovação do fato indébito – Incumbe ao demandante comprovar o fato antevisto no art. 822,¹⁴⁸ ou seja, a prática do fato indébito.

Em geral, essa prova não exsurge do próprio título, cabendo ao exequente ministrá-la na petição inicial, conquanto esteja ausente do rol do art. 798, I. Por exemplo, recusando-se o inquilino a permitir a vistoria do locador, o exequente poderá comprovar o fato através de ata notarial (art. 384, *caput*).

3. Procedimento da execução para desfazer – Como a obrigação negativa, infringida pelo inadimplemento, transformou-se em positiva (desfazer), em virtude de elemento material

derivado do descumprimento, que perpetua aquele no mundo, o rito segue as linhas gerais do apropriado para o *facere*. Tudo aquilo que não deveria acontecer e estava proibido realizou-se e, nesta contingência, só resta dismantelar as consequências da transgressão.

A execução de título extrajudicial começa por meio da demanda do exequente e do provimento liminar do juiz, fixando honorários de advogado, estipulando multa pecuniária (art. 814), de resto adstrita ao regime do art. 537, e o prazo para desfazer, segundo as peculiaridades do caso concreto, seguindo-se a citação pessoal do executado. Ele terá, então, direito de embargar a execução, no prazo de quinze dias (art. 915, *caput*). Determinados aspectos merecem destaque.

3.1. Prazo de desfazimento – Cumpre ao exequente, a par de promover a citação do executado, requerer seja assinado ao mesmo prazo razoável para o desfazimento das consequências materiais da transgressão (art. 822). Este prazo, adequado à natureza do desfazer, é essencialmente variável. Mas, à primeira vista, mostrar-se-á inferior ao do hipotético prazo para fazer, porque sempre se revelará mais fácil destruir do que construir. Essa diretriz firme e clara, e que é retirada da experiência comum, afigura-se da maior importância, considerando a discricionariedade judicial na fixação deste interregno.

3.2. Delimitação do desfazimento – O exequente explicitará na petição inicial, administrando todos os pormenores, a extensão e o conteúdo do fato indêbito. Esses dados delimitarão o desfazer que compete ao executado. Esta relativa indeterminação, natural ao *facere*, de modo algum atinge a liquidez do título. Ele não poderia antever um entre os infinitos atos que o obrigado empregaria para infringir seu dever negativo, disciplinando, desde logo, a respectiva terapia. O juiz controlará, no entanto, a exatidão do postulado retorno ao *statu quo ante*.

4. Atitudes do executado – Embora omissos os arts. 822 e 823, imprescindível afigura-se, na execução fundada em título extrajudicial, a citação do executado.¹⁴⁹ Esse chamamento realizar-se-á por um dos meios legalmente admissíveis, preferencialmente através de oficial de justiça. Em virtude da sua convocação, ao executado abrem-se três atitudes: (a) o desfazimento; (b) resistência ao desfazimento; (c) inércia.

O desfazimento voluntário, patrocinado pelo próprio executado ou por terceiro, sob suas instruções e comando, submeter-se-á ao incidente de verificação, a fim de apurar se o retorno ao estado prístino se revela satisfatório. Nada obstante a objeção digna de registro,¹⁵⁰ eventual resistência explícita do executado, denotando descumprimento antecipado, provoca o desencadeamento imediato da transformação (art. 823, *caput*). Ao exequente é lícito, nessa circunstância, abrir a execução de custeamento contra o devedor renitente, com o fito de obter recursos para desfazer a transgressão. Valem, aqui, as considerações já expendidas ao propósito do custeamento.

Art. 823. Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, que responderá por perdas e danos.

Parágrafo único. Não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento da execução por quantia certa.

1. Execução da obrigação negativa por transformação – O art. 823 prevê, havendo recusa ou mora do exequente, pretensão ao desfazimento dos efeitos materiais do descumprimento, sem prejuízo das perdas e danos – e, acrescente-se, da multa pecuniária, a teor do art. 500 –, mediante transformação, ou seja, por intermédio de terceiro. Valem, ao propósito, os comentários feitos ao art. 817.

2. Manutenção dos efeitos materiais – Excepcionalmente, manter-se-ão os efeitos materiais da ofensa ao dever negativo.

Considerando interesses peculiares, como o da economia nacional,¹⁵¹ e a equação entre os encargos a serem suportados pelo executado e os benefícios hauridos pelo exequente, resolverá o

juiz se a manutenção de todas ou de algumas consequências do descumprimento não se revela mais adequada. Não se olvidem, neste passo, o princípio traçado no art. 805, *caput*, que veda execução excessivamente gravosa, e, de resto, o art. 823, parágrafo único, autoriza ao órgão judiciário emitir juízo acerca da “impossibilidade” do desfazimento do ato.

Em tal hipótese, o procedimento *in executivis* converter-se-á, apurando-se perdas e danos, sem prejuízo da multa pecuniária, e seguindo-se o procedimento da execução por quantia certa (art. 823, parágrafo único).

3. Conversão da execução da obrigação negativa – Segundo o art. 823, parágrafo único, “não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos”. E, ainda, explicitou-se a necessidade de liquidação, nos termos do art. 509, e o prosseguimento da execução segundo o procedimento da expropriação (art. 824).

De ordinário, os domínios da regra se subordinam ao *facere* de consumação instantânea. Qualquer descumprimento de obrigação negativa inviabiliza tutela específica e provoca a irreversibilidade do ato.

Todavia, ofensa a dever negativo que se traduza em *facere* de consumação duradoura, de trato sucessivo ou não, também poderá convolar-se em perdas e danos. Assim, a manutenção dos efeitos materiais do fato indébito, porque de interesse público ou da conveniência do exequente, fornece a primeira hipótese. Ademais do desfazimento do fato indébito, ao exequente assiste pretensão a ver-se indenizado do dano conexo porventura apurado.

A execução expropriatória incluirá, igualmente, o montante da multa aplicada ao executado,¹⁵² ao despachar o juiz a petição inicial (art. 814), e cumulável com as perdas e danos (art. 500) até o momento da conversão.

4. Extinção da execução da obrigação negativa – Extinguir-se-á o processo executivo, ora em foco, tão logo desfeitas as consequências materiais da transgressão ao dever negativo ou percebido o valor integral das perdas e danos. A sentença se fundará no art. 924, II

É inconcebível uma relação processual perpétua. Se o executado, no caso de *facere* de consumação duradoura de trato sucessivo, renovar a ofensa depois de extinto o processo, ao credor assiste ao direito de deduzir nova pretensão a executar, fundada na prática renovada do ato.

NOTAS DE RODAPÉ

1

José Carlos Barbosa Moreira, *A tutela específica do credor nas obrigações negativas*, n. 1, p. 31.

2

José Alberto dos Reis, *Processo de execução*, vol. 1, n. 18, p. 48.

3

Enrico Tullio Liebman, *Processo de execução*, n. 96, p. 231.

4

Mário Júlio de Almeida Costa, *Direito das obrigações*, n 58, p. 465.

5

Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*, vol. 20, § 2.699, p. 117. No mesmo sentido, Judith Martins-Costa, *Comentários ao novo Código Civil*, vol. 3, t. 2, p. 165.

6

Moacyr Amaral Santos, *Primeiras linhas de direito processual civil*, vol. 3, n. 20, p. 98.

7

Chantal Català Comas, *Ejecución de condenas de hacer y no hacer*, p. 29.

8

Darci Guimarães Ribeiro, *A concretização da tutela específica no direito comparado*, p. 125-146.

9

Marc Donnier e Jean-Baptiste Donnier, *Voies d'exécution* n. 315, p. 132.

10

François Chabas, *L'astreinte en droit français*, n. 4, p. 56.

11

Leo Rosenberg, Hans Friedhelm Gaul e Eberhard Schilken, *Zwangsvollstreckungsrecht*, § 9, III, 2, p. 96; Jürgen Baumann e Wolfgang Brehm, *Zwangsvollstreckung*, § 27, p. 309-414.

12

Jack Friedenthal, Mary Kay Kane e Arthur R. Miller, Friedenthal-Kane-Miller, *Civil Procedure*, § 15.8, p. 752; John F. Dobbryn, *Injunctions*, n 7, p. 216-227; Roberto Molina Pasquel, *Contempt of Court*, §§ 38-52, p. 78-103.

13

Cândido Rangel Dinamarco, *Execução civil*, n. 184, p. 297-298.

14

Humberto Theodoro Jr., *Processo de execução*, p. 218.

15

Giuseppe Borrè, *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, p. 3-8.

16

Giuseppe Gandolfi, *Contributo allo studio del processo interdittale romano*, p. 2; Galeno Lacerda, Tutela antecipatória e tutela interdital, p. 183-188.

17

Giuseppe Borrè, *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, p. 11

18

Sergio Chiarloni, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, n. 7, p. 59.

19

Louis Crémieu, *La justice privée*, p. 263.

20

Ramalho, *Praxe brasileira*, § 303, p. 450-451.

21

Moacyr Amaral Santos, *Ações cominatórias*, vol. 1, n. 57, p. 185.

22

Severino Muniz, *Ações cominatórias à luz do art. 287 do CPC*, p. 43.

23

Por exemplo, ao direito espanhol anterior a 2000, como explica Chantal Català Comas, *Ejecución de condenas de hacer y no hacer*, p. 142-143. O art. 709, n. 1, da *Ley de Enjuiciamiento Civil*, de 2000, prevê a multa coercitiva mensal, pelo prazo de até um ano, mas subordinada a percentual máximo: vide Manuel Ortells Ramos, *La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, p. 309-312.

24

Roger Perrot e Philippe Théry, *Procédures civiles d'exécution*, n. 68, p. 73.

25

26

No sentido do texto, por todos, Asdrúbal Franco Nascimbeni, *Multa e prisão civil como meios coercitivos para a obtenção de tutela específica*, n. 6.4, p. 162-163. Em sentido contrário, Sérgio Cruz Arenhart, A doutrina brasileira da multa coercitiva, n. 4, p. 539-545; Vicente de Paula Ataíde Jr., Novas luzes sobre a destinação da multa prevista no art. 461, § 4., do CPC, n. 7, p. 1.592. Este último aponta o Estado, por analogia com o art. 14, parágrafo único, como titular do crédito.

27

É a observação de Juvêncio Vasconcelos Viana, *Tutela específica*, n. 10, p. 43.

28

STJ, REsp. 1.063.902-SC, 19.08.2008, 1.^a Turma, rel. Min. Francisco Falcão, *DJE* 01.09.2008.

29

Eduardo J. Couture, *Fundamentos del derecho procesal civil*, n. 302, p. 461.

30

J. M. Carvalho Santos, *Código Civil brasileiro interpretado*, vol. 11, p. 88.

31

José Frederico Marques, *Manual de direito processual civil*, vol. 4, n. 840, p. 134.

32

Amílcar de Castro, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 8, n. 250, p. 186.

33

Jean Vincent, *Voies d'exécution et procédures de distribution*, n. 10, p. 22.

34

Marc Donnier, *Voies d'exécution et procédures de distribution*, n. 214, p. 71.

35

Roger Perrot, La coercizione per dissuasione nel diritto francese, n. 11, p. 665.

36

Idem, n. 15, p. 669.

37

Idem, n. 14, p. 667.

38

René Savatier, *Traité de la responsabilité civile en droit français*, vol. 2, n. 598, p. 173.

39

Arruda Alvim, *Obrigações de fazer e não fazer – Direito material e processo*, p. 39.

40

Michele Taruffo, A atuação executiva dos direitos: perfis comparatísticos, n. 4, p. 83.

41

STJ, REsp. 13.416-0-RJ, 17.03.1992, 4.^a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, *RJSTJ* 37/428.

42

STJ, REsp. 43.389-4-RJ, 22.03.1994, 3.^a Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter, *RJSTJ* 63/438.

43

STJ, REsp. 130.375-SP, 19.08.1997, 3.^a Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, *DJU* 22.09.1997, p. 46.468.

44

Calmon de Passos, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 3, n.43, p. 249.

45

Ernane Fidélis dos Santos, *Manual de direito processual civil*, vol. 2, n. 1.170, p. 126.

46

Em sentido contrário, Theodoro Jr., *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 4, n. 261, p. 341.

47

Neste sentido, Theodoro Jr., *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 4, n. 258, p. 339; Sérgio Sahione

Fadel, *Código de Processo Civil comentado*, vol. 2, p. 417; Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 4, n. 1.781, p. 734.

48

STJ, REsp. 679.048-RJ, 03.11.2005, 1.^a Turma, rel. Min. Luiz Fux, *DJU* 28.11.2005, p. 204.

49

Em sentido contrário, Sérgio Cruz Arenhardt, *A doutrina brasileira da multa coercitiva*, n. 3, p. 359.

50

Guilherme Puchalski Teixeira, *Tutela específica dos direitos*, n. 7.1.5, p. 177-180.

51

STJ, REsp. 1.063.902-SC, 19.08.2008, 1.^a Turma, rel. Min. Francisco Falcão, *DJE* 01.09.2008.

52

Amílcar de Castro, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 8, n. 253, p. 188.

53

STJ, AgRg no REsp. 1.411.760-PR, 24.04.2014, 3.^a Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, *DJE* 19.05.2014.

54

STJ, REsp. 43.389-4-RJ, 22.03.1994, 3.^a Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter, *RJSTJ* 63/438.

55

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 156.

56

Marc Donnier e Jean Baptiste Donnier, *Voies d'exécution et procédures de distribution*, n. 323, p. 134.

57

Roberto Eurico Schmidt Jr., *O novoprocesso civil*, p. 142.

58

Alexandre Freitas Câmara, Redução do valor da *astreinte* e efetividade do processo, n. 5, p. 1.567.

59

STJ, REsp. 793.441-RN, 26.09.2006, 4.^a Turma, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, *DJU* 06.11.2006, p. 337. No mesmo sentido, STJ, REsp. 700.245-PE, 26.05.2008, 6.^a Turma, rel. Min. Nilson Naves, *DJE* 04.08.2008.

60

STJ, REsp. 6.644-MG, 12.03.1991, 3.^a Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, *RJSTJ* 19/550.

61

Amílcar de Castro, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 8, n. 251, p. 187; Theodoro Jr., *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 4, n. 257, p. 338; Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 156; Sérgio Bermudes, *Direito processual civil*, n. 65, p. 150.

62

STJ, REsp. 1.179.628-RS, 18.05.2013, 5.^a Turma, rel. Min. Jorge Mussi, *DJE* 12.06.2013.

63

Em sentido contrário, Alcides Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.807, p. 753.

64

Roger Perrot e Philippe Théry, *Procédures civiles d'exécution*, n. 79, p. 87.

65

Wilard de Castro Villar, *Processo de execução*, p. 155; Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.802, p. 741. Na jurisprudência, STJ, REsp. 11.368-DF, 03.10.1991, 4.^a Turma, rel. Min. Sálvio Figueiredo, *RJSTJ* 30/465.

66

Frederico Marques, *Manual de direito processual civil*, vol. 4, n. 840, p. 134; Theodoro Jr., *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 4, n. 259, p. 339.

67

Ernane Fidélis dos Santos, *Manual de direito processual civil*, vol. 3, n. 1.171, p. 127.

68

Em sentido contrário, Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.801,

p. 741.

69

STJ, AgRg no REsp. 1.167.276-MA, 20.06.2013, 3.^a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, *DJE* 28.06.2013.

70

STJ, REsp. 1.135.824-MG, 21.09.2010, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrigli, *DJE* 14.03.2011.

71

STJ, AgRg nos Edcl no REsp. 1.277.152-RS, 06.08.2015, 3.^a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellize, *DJE* 21.08.2015.

72

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.808, p. 743.

73

Marc Donnier e Jean-Baptiste Donnier, *Voies d'exécution et procédures de distribution*, n. 361, p. 150.

74

STJ, REsp. 445.905-DF, 13.05.2003, 2.^a Turma, rel. Min. Franciulli Netto, *DJU* 08.09.2003, p. 286.

75

STJ, REsp. 1.151.505-SP, 07.10.2010, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrigli, *DJE* 22.10.2010.

76

Fredie Didier Júnior, Multa coercitiva, boa-fé processual e *supressio*: aplicação do *duty to mitigate the loss* no processo civil, p. 46-48.

77

STJ, REsp. 1.200.856-RS, 01.07.2104, C. Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, *DJE* 17.09.2014.

78

STJ, REsp. 1.333.988-SP, 09.04.2014, 2.^a Turma, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, *DJE* 11.04.2014.

79

Fabiano Aita Carvalho, *Multa e prisão civil*, n. 3.1.5.3, p. 59.

80

STJ, AgRg no REsp. 1.391.145-SE, 25.06.2013, 3.^a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, *DJE* 28.06.2013.

81

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.789, p. 738.

82

Amaral Santos, *Primeiras linhas de direito processual civil*, vol. 3, n. 968, p. 376.

83

Jean Vincent, *Voies d'exécution et procédures de distribution*, n. 11, p. 25.

84

STJ, Rcl. 7.861-SP, 11.09.2013, 2.^a S. rel. Min. Luis Felipe Salomão, *DJE* 06.03.2014.

85

João de Castro Mendes, *Acção executiva*, n. 64, p. 240-241.

86

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.646, p. 694.

87

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 90.

88

Amílcar de Castro, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 8, n. 232, p. 169; Amaral Santos, *Primeiras linhas de direito processual civil*, vol. 3, n. 958, p. 359; Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.654, p. 697.

89

Manuel Ortells Ramos, *La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, p. 225.

90

José de Moura Rocha, *Sistemática do novo processo de execução*, n. 65, p. 265.

91

Alcides Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.654, p. 697.

92

Sérgio Bermudes, *Direito processual civil*, n. 62, p. 143.

93

Giuseppe Borrè, *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, p. 310.

94

Theodoro Jr., *A reforma da execução do título extrajudicial*, n. 15, p. 40.

95

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 88; Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.655, p. 697.

96

José Frederico Marques, *Manual de direito processual civil*, vol. 4, n. 829, p. 122.

97

José Carlos Barbosa Moreira, *O novoprocesso civil brasileiro*, p. 206.

98

José Frederico Marques, *Manual de direito processual civil*, vol. 4, n. 830, p. 122.

99

Amaral Santos, *Primeiras linhas de direito processual civil*, vol. 3, n. 959, p. 361.

100

Theodoro Jr., *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 4, n. 241, p. 361.

101

Clóvis do Couto e Silva, *O conceito de dano no direito civil brasileiro e comparado*, n. 1.4, p. 11.

102

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.672, p. 703.

103

Jorge Americano, *Processo civile comercial brasileiro*, n. 63, p. 302.

104

Sidney Palharini Jr., *Nova execução de título extrajudicial*, p. 61.

105

Neste sentido, porém, Theodoro Jr., *A reforma da execução do título extrajudicial*, n. 15, p. 40; Cássio Scarpinella Bueno, *Curso sistematizado de direito processual civil*, vol. 3, p. 438; Daniel Carnio Costa, *Execução no processo civil brasileiro*, p. 139; Elpídio Donizetti, *O novo processo de execução*, p. 252.

106

João de Castro Mendes, *Acção executiva*, n. 65, p. 251.

107

José Lebre de Freitas, *A acção executiva*, n. 23.2.3, p. 323.

108

Idem, n. 65, p. 250.

109

Em sentido contrário, no CPC de 1939, Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 102.

110

João de Castro Mendes, *Acção executiva*, n. 65, p. 246.

111

Na vigência do CPC português anterior, Eurico Lopes Cardoso, *Manual da acção executiva*, n. 260, p. 692.

112

Paulo Furtado, *Execução*, n. 128, p. 169.

113

Alcides Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.689, p. 706-707.

114

Moacyr Amaral Santos, *Primeiras linhas de direito processual civil*, vol. 3, n. 960, p. 364.

115

José Frederico Marques, *Manual de direito processual civil*, vol. 4, n. 831, p. 124.

116

Jürgen Baumann e Wolfgang Brehm, *Zwangsvollstreckung*, § 27, I, p. 390-394.

117

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 104.

118

Jorge Americano, *Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil*, vol. 4, p. 358.

119

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.699, p. 710; Sérgio Bermudes, *Direito processualcivil*, n. 62, p. 146; Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 106.

120

Neste sentido, Amílcar de Castro, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 8, n. 237, p. 175.

121

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.700, p. 710.

122

STJ, REsp. 39.268-SP, 13.11.1995, 4.^a Turma, rel. Min. Barros Monteiro, DJU 29.04.1996, p. 13.420.

123

Neste sentido, Sérgio Bermudes, *Direito processualcivil*, n. 62, p. 146.

124

Em termos, Sérgio Bermudes, *Direito processualcivil*, n. 62, p. 145.

125

Alcides Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.704, p. 711.

126

Em sentido contrário – “sentença” –, Sérgio Bermudes, *Direito processualcivil*, n. 12, p. 145; José da Silva Pacheco, *Tratado da execuções*, vol. 2, n. 479, p. 420.

127

Neste sentido, Ulderico Pires dos Santos, *O processode execução*, n. 349, p. 269; em sentido contrário, Sérgio Bermudes, *Direito processualcivil*, n. 61, p. 145; Wilard de Castro Villar, *Processo de execução*, p. 108.

128

STJ, REsp. 9.584-SP, 09.03.1992, 4.^a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, *EJSTJ* 5/10.

129

James Goldschmidt, *Zivilprozessrecht*, § 110, 3, a, p. 315.

130

João de Castro Mendes, *Acção executiva*, n. 64, p. 250.

131

STJ, REsp. 482.094-RJ, 20.05.2008, 3.^a Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, *DJE* 24.04.2009.

132

Manuel Ortells Ramos, *La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, p. 244.

133

Em sentido contrário, Silva Pacheco, *Tratado das execuções*, vol. 2, n. 481, p. 422.

134

Manuel Ortells Ramos, *La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, p. 246.

135

Lopes da Costa, *Direito processual civil brasileiro*, vol. 4, n. 360, p. 203.

136

Giuseppe Borrè, *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, p. 340.

137

Idem, p. 342.

138

Artur Anselmo de Castro, *A acção executiva singular, comum e especial*, n. 83, p. 381.

139

José Carlos Barbosa Moreira, *A tutela específica do credor nas obrigações negativas*, n. 1, p. 30.

140

Idem, n. 1, p. 31.

141

Francesco Carnelutti, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. 3, n. 804, p. 137; depois voltou atrás: *Diritto e processo*, n. 199, p. 321.

142

José Frederico Marques, *Manual de direito processual civil*, vol. 4, n. 835, p. 128.

143

João Castro Mendes, *Acção executiva*, n. 67, p. 128.

144

Sobre o assunto, Clóvis do Couto e Silva, *Tutela preventiva*, p. 293-300.

145

José Carlos Barbosa Moreira, *O novoprocesso civil brasileiro*, p. 214.

146

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 10, p. 151.

147

José Carlos Barbosa Moreira, *O novoprocesso civil brasileiro*, p. 215.

148

Artur Anselmo de Castro, *A acção executiva singular, comum e especial*, n. 85, p. 385.

149

Amílcar de Castro, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 8, n. 248, p. 184.

150

José Frederico Marques, *Manual de direito processual civil*, vol. 4, n. 836, p. 129.

151

Pasquale Castoro, *Il processodi esecuzione nel su aspetto pratico*, n. 230, p. 594; Giuseppe Borrè, *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare* p. 124. No direito português, Artur Anselmo de Castro, *A acção executiva singular, comum e especial*, n. 84, p. 284.

152

Alcides Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, n. 1.777, p. 732; Amílcar de Castro, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 8, n. 249, p. 185.

© desta edição [2018]

Referências Bibliográficas

- ABELHA, Marcelo. *Manual de execução civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.
- ALMEIDA COSTA, Mário Júlio de. *Direito das obrigações*. 4. ed. Coimbra: Coimbra Ed., 1984.
- AMARAL, Osvaldo Pinto do. *Código de Processo Civil Comentado*. vol. 5. São Paulo: Saraiva, 1941.
- AMARAL SANTOS, Moacyr. *Primeiras linhas de direito processual civil*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1977.
- _____. *Ações cominatórias no direito brasileiro*. 5. ed. São Paulo: Max Limonad, 1973.
- AMERICANO, Jorge. *Processo civil e comercial brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 1932.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil*. vol. 4. São Paulo: Saraiva, 1941.
- ANDRIGHI, Fátima Nancy. *A gênese do sistema “penhora on line”*. In: SANTOS, Ernane Fidélis dos; WAMBIER, Luiz Rodrigues; NERY JUNIOR, Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. *Execução civil – Estudos em homenagem ao Professor Humberto Theodoro Júnior*. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- ANDRIOLI, Virgilio. *Commento al Codice di Procedura Civile*. 2. ed. Nápoles: Jovene, 1945.
- ANTUNES, Osvaldo Moreira. O credor hipotecário e o concurso singular de credores. *Revista dos Tribunais*, vol. 599. São Paulo: Ed. RT, 1985.
- ANTUNES VARELA, João de Matos. *Das obrigações em geral*. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1974.
- ARENHART, Sérgio Cruz. *A doutrina brasileira da multa coercitiva – Três questões ainda polêmicas*. In: MEDINA, José Miguel Garcia; CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo; CERQUEIRA, Luís Otávio Sequeira de; GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel. *Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais – Estudos em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim Wambier*. São Paulo: Ed. RT, 2008.
- ARENS, Peter. *Zivilprozessrecht*. 4. ed. Munique: C. H. Beck'sche, 1988.
- ARRUDA ALVIM. Obrigações de fazer e não fazer – Direito material e processo. *Revista de Processo*, vol. 99. São Paulo: Ed. RT, 1999.
- ASSIS, Araken de. *Manual da execução*, 18. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- _____. *Processo civil brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- _____. *Concurso especial de credores no CPC*. São Paulo: SP, 2003.
- ATAÍDE JÚNIOR, Vicente de Paula. *Novas luzes sobre a destinação da multa prevista no art. 461, § 4.º, do CPC*. In: MEDINA, José Miguel Garcia; CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo; CERQUEIRA,

Luís Otávio Sequeira de; GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel. *Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais – Estudos em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim Wambier*. São Paulo: Ed. RT, 2008.

AUBRY, Charles; RAU, Frédérique-Charles. *Cours de droit civil français*. 6. ed. de Étienne Bartin. Paris: Éditions Techniques, 1942.

AURELLI, Arlete Inês. *Uma revisita ao tema da prescrição intercorrente no âmbito do processo civil com ênfase no Código de Processo Civil projetado*. In: ARRUDA ALVIM; Eduardo; BRUSCHI, Gilberto Gomes; LARSEN CHECHI, Mara; COUTO, Mônica Bonetti. *Execução civil e temas afins: do CPC/1973 ao novo CPC – Estudos em homenagem ao Professor Araken de Assis*. São Paulo: Ed. RT, 2014.

AZEVEDO JÚNIOR, José Osório de. *Compromisso de compra e venda*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986.

BAPTISTA, José João. *Acção executiva*. Lisboa: Lusíada, 1988.

_____. *Processo civil – I* (parte geral e processo declarativo). Coimbra: Coimbra Ed., 2006.

BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. *Curso de processo civil*. Porto Alegre: Fabris, 1987-1990.

_____. *A ação de imissão de pessoa no direito brasileiro atual*. São Paulo: Saraiva, 1981.

_____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. vol. 11. Porto Alegre: Lejur, 1985.

_____. *Jurisdição, direito material e processo*. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

_____. *Execução obrigacional e mandamentalidade*. In: TESHEINER, José Maria Rosa; MILHORANZA, Mariângela Guerreiro; PORTO, Sérgio Gilberto. *Instrumentos de Coerção e outros Temas de Direito Processual Civil – Estudos em Homenagem aos 25 Anos de Docência do Professor Dr. Araken de Assis*. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *O novo processo civil brasileiro*. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

_____. *A tutela específica do credor nas obrigações negativas. Temas de direito processual – 2.^a série*. São Paulo: Saraiva, 1980.

BAUMANN, Jürgen; BREHM, Wolfgang. *Zwangsvollstreckung*. 2. ed. Bielefeld: Gieseking, 1982

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. *Poderes instrutórios do juiz*. São Paulo: Ed. RT, 1991.

BERMUDES, Sérgio. *Direito processual civil*. São Paulo: Saraiva, 1983.

BEUDANT, Charles. *Cours de droit civil français*. 2. ed. de Robert Baudant, Paul Lerebours-Pigeonnière e Gaston Lagarde. Paris: Rousseau, 1936.

BIM, Eduardo Fortunato. A admissibilidade da citação por hora certa no processo de execução. *Revista Dialética de Direito Processual*. vol. 11. São Paulo: Oliveira Rocha, 2004.

BONNIER, Édouard. *Éléments de procédure civile*. Paris: Plon, 1853.

BORRÈ, Giuseppe. *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*. Nápoles: Jovene, 1966.

BOURGUIGNON, Álvaro Manoel Rosindo. *Embargos de retenção por benfeitorias*. São Paulo: Ed. RT, 1999.

BUCOLO, Francesco. *La sospensione nell'esecuzione*. 2. ed. Milão: Giuffrè, 1972

- BUENO, Cássio Scarpinella. *Curso sistematizado de direito processual civil*. São Paulo: Saraiva, 2008.
- CALMON DE PASSOS, José Joaquim. *Comentários ao Código de Processo Civil*. vol. 3. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.
- CAMBI, Eduardo. *Apontamentos sobre a reforma da execução de títulos extrajudiciais (Lei 11.382, de 06.12.2006)*. In: SANTOS, Ernane Fidélis dos; WAMBIER, Luiz Rodrigues; NERY JUNIOR, Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. *Execução civil – Estudos em homenagem ao Professor Humberto Theodoro Júnior*. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- CÂMARA, Alexandre Freitas. *O novo processo civil brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2015.
- CÂMARA, Alexandre Freitas. *Redução do valor da astreinte e efetividade do processo*. In: ASSIS, Araken de; ARRUDA ALVIM, Eduardo; NERY JUNIOR, Nelson; MAZZEI, Rodrigo; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; ALVIM, Thereza. *Direito civil e processo – Estudos em homenagem ao Professor Arruda Alvim*. São Paulo: Ed. RT, 2008.
- CAMUSSO, Jorge P. *Nulidades procesales*. 2. ed. Buenos Aires: Ediar, 1983.
- CARDOSO, Eurico Lopes. *Manual da acção executiva*. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1992.
- CARNEIRO, Athos Gusmão. Do interesse de agir no concurso universal de credores. *Revista Brasileira de Direito Processual*. vol. 15. Uberaba, Vitória, 1978.
- _____. Da citação pelo correio na justiça comum. *Revista da Ajuris*. vol. 9. Porto Alegre: s/e, 1977.
- CARNELUTTI, Francesco. *Instituzioni di diritto processuale civile*. 5. ed. Roma: Il Foro Italiano, 1956.
- _____. *Sistema de derecho processual civil*. Trad. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo e Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Uteha, 1944.
- _____. *Diritto e processo*. Nápoles: Jovene, 1958.
- _____. Inesistenza dell'atto giuridico. *Revista di Diritto Processuale*. vol. 10. Pádua: Cedam, 1955.
- CARVALHO, Fabiano Aita. *Multa e prisão: o Contempt of Court no direito brasileiro*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.
- CARVALHO, Rodrigo Benevides de. *O concurso particular de credores na execução*. São Paulo: Atlas, 2008.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de direito administrativo*. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999.
- CARVALHO SANTOS, J. M. *Código Civil brasileiro interpretado*. Rio de Janeiro: Calvino Filho, 1936.
- _____. *Código de Processo Civil interpretado*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1941.
- CASTORO, Pasquale. *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*. 5. ed. Milão: Giuffrè, 1980.
- CASTRO, Amílcar. *Comentários ao Código de Processo Civil*. vol. 8. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1975.
- CASTRO, Artur Anselmo de. *A acção executiva singular, comum e especial*. 3. ed. Coimbra: Coimbra Ed., 1977.

- CATALÀ COMAS, Chantal. *Ejecución de condenas de hacer y de no hacer*. Barcelona: Bosch, 1998.
- CAVALCANTE, Mantovanni Colares. *A penhora de parcela de faturamento de empresa e suas restrições*. In: LOPES, João Batista; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. *Execução civil (aspectos polêmicos)*. São Paulo: Dialética, 2005.
- CHABAS, François. L'astreinte en droit français. *Revista de direito civil*. vol. 69. São Paulo: Ed. RT, 1994.
- CHIARLONI, Sergio. *Misure coercitivi e tutela dei diritti*. Milão: Giuffrè, 1980.
- CHIOVENDA, Giuseppe. *Instituições de direito processual civil*. Trad. Benvindo Aires. São Paulo: Saraiva, 1942.
- COSTA, Daniel Carnio. *Execução no processo civil brasileiro*. Curitiba: Juruá, 2007.
- COSTA E SILVA, Antonio Carlos. *Tratado do processo de execução*. 2. ed. Rio de Janeiro: Aide, 1986.
- _____. *Teoria e prática do processo executivo fiscal*. Rio de Janeiro: Aide, 1981.
- COUTO E SILVA, Clovis. O conceito de dano no direito civil brasileiro e comparado. *Revista dos Tribunais*. vol. 667. São Paulo: Ed. RT, 1991.
- _____. Tutela preventiva. *Digesto de Processo*. vol. 5. Rio de Janeiro: Forense, 1988
- COUTURE, Eduardo J. *Fundamentos del derecho procesal civil*. 3. ed. Buenos Aires: Depalma, 1977.
- CREDIE, Ricardo Arcoverde. *Bem de família*. São Paulo: Malheiros, 2000.
- CREMIEU, Louis. *La justice privée*. Paris: Sirey, 1928.
- DALL'AGNOL, Antonio. *Comentários ao Código de Processo Civil*. vol. 2. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- _____. *Invalidades processuais*. Porto Alegre: Lejur, 1989.
- _____. Concurso particular de preferências. *Revista da Ajuris*. vol. 8. Porto Alegre: s/e, 1976.
- _____. O princípio dispositivo no pensamento de Mauro Cappelletti. *Revista da Ajuris*. vol. 46. Porto Alegre: s/e., 1989.
- _____. *Para um conceito de irregularidade processual*. In: OLIVEIRA, Carlos A. A; ASSIS, Araken de. *Estudos em homenagem ao Prof. Galeno Lacerda*. Porto Alegre: Fabris, 1989.
- DE LA OLIVA SANTOS, Andrés; DíEZ-PICAZO GIMENEZ, Ignacio; VEGA TORRES, Jaime. *Derecho procesal civil*. 3. ed. Madri: Ramón Areces, 2005.
- DELGADO, José Augusto. Novos aspectos da execução fiscal (Lei 6.830, de 22.9.1980). *Revista de Processo*, vol. 25. São Paulo: Ed. RT, 1982.
- DEMOGUE, René. *Traité des obligations en général*. Paris: Arthur Rousseau, 1931.
- DEMOLOMBE, *Cours de Code de Napoléon*. Paris: Imprimerie Générale, 1877.
- DENTI, Vittorio. *L'esecuzione forzata in forma specifica*. Milão: Giuffrè, 1953.
- _____. *Nullità degli atti processuali civili*. *Novissimo Digesto Italiano*. vol. 11 Turim: Utet, 1968.
- DE PLÁCIDO E SILVA. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 3. ed. Curitiba: Guaíra, 1949.

- DESTEFANNI, Marcos. *Curso de processo civil*. São Paulo: Saraiva, 2006.
- _____. *A prescrição superveniente à sentença*. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes; SHIMURA, Sérgio. *Execução civil e cumprimento da sentença*. vol. 3. São Paulo: Método, 2009.
- DE VALLE, Carla Maria Krieger. *Meios coercitivos de execução – penhora on line*. In: TESHEINER, José Maria; MILHORANZA, Mariângela Guerreiro; PORTO, Sérgio Gilberto. *Instrumentos de coerção e outros temas de direito processual civil – Estudos em homenagem aos 25 anos de docência do Professor Dr. Araken de Assis*. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
- DIDIER JÚNIOR, Fredie. Multa concercitiva, boa-fé processual e *supressio*: aplicação do *duty to mitigate the loss* no processo civil. *Revista de Processo*, vol. 171, São Paulo: Ed. RT, 2009.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *Execução civil*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1993.
- DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1990.
- DOBBYN, John F. *Injunctions*. Saint Paul: West Publishing, 1974.
- DONIZETTI, Elpídio. *O novo processo de execução*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
- DONNIER, Marc. *Voies d'exécution et procédures de distribution*. 4. ed. Paris: Litec, 1996.
- _____; DONNIER, Jean Baptiste. *Voies d'exécution et procédures de distribution*. 7. ed. Paris: Litec, 2003.
- DORESTE BAPTISTA, N. *Do processo executivo no sistema do Código de 1973*. Rio de Janeiro: Forense, 1975.
- FADEL, Sérgio Sahione. *Código de Processo Civil comentado*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981.
- FARIA, Werter. *Ações cambiárias*. Porto Alegre: Fabris, 1987.
- FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
- FERREIRA, Fernando Amâncio. *Curso de processo de execução*. Coimbra: Almedina, 1999.
- FERREIRA, Petrucio. Aplicação subsidiária do art. 282 do CPC ao processo de execução. *Revista de Processo*, vol. 96. São Paulo: Ed. RT, 1999.
- FLAKS, Milton. *Comentários à lei de execução fiscal*. Rio de Janeiro: Forense, 1981.
- FONSECA, Arnaldo Medeiros da. *Direito de retenção*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1944.
- FORNACIARI JÚNIOR, Clito. Da citação pelo correio. *Revista da Ajuris*. vol. 6. Porto Alegre: s/e, 1976.
- FREIRE E SILVA, Bruno. *O bloqueio on line e a necessária aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade*. In: BRUSCHI, Gilberto. *Execução civil e cumprimento da sentença*. São Paulo: Método, 2006.
- FREITAS, José Lebre. *A acção executiva*. Coimbra: Coimbra Ed., 1993.
- FRIEDENTHAL, Jack; KANE, Mary Kay; MILLER, Arthur. *Civil procedure*. 4. ed. Saint Paul: Thompson-West, 2005.
- FURTADO, Paulo. *Execução*. São Paulo: Saraiva, 1985.
- GANDOLFI, Giuseppe. *Contributo allo studio del processo interdittale romano*. Milão: Giuffrè, 1955.

- GARBI, Carlos Alberto. *Relação jurídica de direito real e usufruto*. São Paulo: Método, 2008.
- GARSONNET, Eugène; CÉZAR-BRU, Charles. *Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale*. 3. ed. Paris: Sirey, 1913.
- GERAIGE NETO, Zaiden; SANTOS, Ernane Fidélis dos; WAMBIER, Luiz Rodrigues; NERY JUNIOR, Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. *Execução civil – Estudos em homenagem ao Professor Humberto Theodoro Júnior*. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- GIANNOZZI, Giancarlo. *Appunti per un corso di diritto processuale civile*. Milão: Giuffrè, 1980.
- GIORGIANNI, Michele. *L'obbligazione*. Milão: Giuffrè, 1951.
- GOLDSCHMIDT, Guilherme. *A penhora on line no direito processual brasileiro*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
- GOLDSCHMIDT, James. *Zivilprozessrecht*. Berlim: Julius Springer, 1929.
- GOMES, Orlando. *Obrigações*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1972.
- GONÇALVES, Aroldo Plínio. *Nulidades do processo*. Rio de Janeiro: Aide, 1993.
- GRECO, Leonardo. *O processo de execução*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999-2001.
- GUERRA, Willis Santiago. Aspectos da execução forçada no sistema processual brasileiro. *Revista de Processo*, vol. 83. São Paulo: Ed. RT, 1996.
- JARDIM, Afrânio Silva. *Da publicização do processo civil*. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1982.
- JAUERNIG, Othmar. *Zivilprozessrecht*. 26. ed. Munique: C. H. Beck, 2000.
- KOMATSU, Roque. *Da invalidade no processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 1991.
- HERTEL, Daniel Roberto. *Curso de execução civil*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
- LACERDA, Galeno. *O novo Código de Processo Civil e os feitos pendentes*. Rio de Janeiro: Forense, 1974.
- _____. *Despacho saneador*. Porto Alegre: La Salle, 1953.
- _____. Tutela antecipatória e tutela interdita. *Estudos de direito processual em memória de Luiz Machado Guimarães*. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- LACERDA, Galeno; OLIVEIRA, Carlos Alberto A. *Comentários ao Código de Processo Civil*. vol. 8., tomo 2, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991.
- LACERDA DE ALMEIDA, Francisco de Paula. *Obrigações*. 2. ed. Rio de Janeiro: RT, 1916.
- LA CHINA, Sergio. *L'esecuzione forzata e le disposizioni generali del Codice di Procedura Civile*. Milão: Giuffrè, 1970.
- LIEBMAN, Enrico Tullio. *Processo de execução*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1980.
- _____. *Manuale di diritto processuale civile*. 3. ed. Milão: Giuffrè, 1973.
- _____. Nulidade da sentença proferida sem citação do réu. *Estudos sobre o processo civil brasileiro*. São Paulo: José Bushatsky, 1976.
- LEITE VELHO, Bernardo Teixeira de Moraes. *Monographia jurídica e prática das execuções de sentenças em processo civil*. Rio de Janeiro: A. Guimarães, 1885.

- LIMA, Alvino. *O direito de retenção e o possuidor de má-fé*. 2. ed. São Paulo: Lejus, 1995.
- LOPES, Maria Elisabeth de Castro. *O princípio do contraditório na execução*. In: LOPES, João Batista; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. *Execução civil: (aspectos polêmicos)*. São Paulo: Dialética, 2005.
- LOPES DA COSTA, Alfredo Araújo. *Direito processual civil brasileiro*. 2. ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 1948.
- MACEDO, Elaine Harzheim. *Penhora on line: uma proposta de concretização da jurisdição executiva*. In: SANTOS, Ernane Fidélis dos; WAMBIER, Luiz Rodrigues; NERY JUNIOR, Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. *Execução civil – Estudos em homenagem ao Professor Humberto Theodoro Júnior*. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- MAIDAME, Márcio Manoel. *Impenhorabilidade e direitos do credor*. Curitiba: Juruá, 2007.
- MALACHINI, Edson Ribas. Das nulidades no processo civil. *Revista Brasileira de Direito Processual*. vol. 12. Uberaba, Vitória, 1977.
- MANDRIOLI, Crisanto. *L'esecuzione forzata in forma specifica*. Milão: Giuffrè, 1953.
- MARMITT, Arnaldo. *A penhora*. 2. ed. Rio de Janeiro: Aide, 1992.
- MARQUES, José Frederico. *Manual de direito processual civil*. São Paulo: Saraiva, 1974.
- _____. *Instituições de direito processual civil*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1971.
- MARQUES, J. P. Remédio. *Curso de processo executivo comum à face do Código revisto*. Coimbra: Almedina, 2000.
- MARTINS-COSTA, Judith. *Comentários ao novo Código Civil*. vol. 3. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
- MAURINO, Alberto Luis. *Nulidades procesales*. Reimpressão. Buenos Aires: Astra, 1985.
- MAZZEI, Rodrigo. *Direito de superfície*. Salvador: JusPodivm, 2013.
- _____. *A liquidação por arbitramento e a liquidação por artigos alguns pontos relevantes sob a ótica das Leis 11.232/2005 e 11.382/2006*. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes; SHIMURA, Sérgio. *Execução civil e cumprimento da sentença*. vol. 2. São Paulo: Método, 2007.
- MEDEIROS, Hortêncio Catunda de. *Esquema de teoria geral do processo*. Rio de Janeiro: Renovar, 1991.
- MEDEIROS, Maria Lúcia L. C. de. Execução e embargos de terceiro. *Revista de Processo*, vol. 84. São Paulo: Ed. RT, 1996.
- MEDINA, José Miguel Garcia. *Execução civil – Princípios fundamentais*. São Paulo: Ed. RT, 2002.
- _____. Execução. Nulidade. Inexistência de preclusão. Possibilidade de arguição dos vícios em embargos à arrematação. *Revista de Processo*, vol. 112, São Paulo: Ed. RT, 2003.
- MENDES, João de Castro. *Ação executiva*. Lisboa: AAFDL, 1980.
- MENDONÇA LIMA, Alcides de. *Comentários ao Código de Processo Civil*. vol. 6. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987.
- MENESTRINA, Francesco. *L'acessione nell'esecuzione*. Reimpressão. Milão: Giuffrè, 1962.
- MESQUITA, Eduardo Melo de. *As tutelas de urgência na execução civil*. In: LOPES, João Batista; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. *Execução civil (aspectos polêmicos)*. São Paulo: Dialética, 2005.

- MILLAR, Robert Winess. *Los principios formativos del procedimiento civil*. Trad. Eduardo J. Couture. Buenos Aires: Ediar, 1945.
- MIRANDA, Vicente. *Poderes do juiz no processo civil brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 1993.
- MOLINA PASQUEL, Roberto. *Contempt of court*. México: Fondo de Cultura Económica, 1954.
- MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. *Comentários ao Código de Processo Civil*. vol. 2. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.
- MOURA RIBEIRO, Paulo Dias de. *Compromisso de compra e venda*. São Paulo: Juarez Oliveira, 2002.
- MUNIZ, Severino. *Ações cominatórias à luz do art. 287 do Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 1987.
- MURITIBA, Sérgio. *Ação executiva lato sensu e ação mandamental*. São Paulo: Ed. RT, 2005.
- NASCIMBENDI, Adsrúbalo Franco. *Multa e prisão civil como meios coercitivos para a obtenção da tutela específica*. Curitiba: Juruá, 2006.
- NORONHA, Carlos Silveira. A causa de pedir na execução. *Revista de Processo*, vol. 75. São Paulo: Ed. RT, 1994.
- OLIVEIRA, Carlos Alberto A. *Alienação da coisa litigiosa*. Rio de Janeiro: Forense, 1984.
- OLIVEIRA, Francisco Antonio de. A penhora erigida à posição de direito real. *Revista dos Tribunais*. vol. 498. São Paulo: Ed. RT, 1977.
- ORTELLS RAMOS, Manuel. *La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento civil*. Madri: La Ley, 2005.
- PACHECO, José da Silva. *Tratado das execuções*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1976.
- PALAIA, Nelson. *Técnica da petição inicial*. São Paulo: Saraiva, 1995.
- PALHARINI JÚNIOR, Sidney; CERQUEIRA, Luís Otávio Sequeira de; SACCO NETO, Fernando; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; HOFFMAN, Paulo; MELLO, Rogério Licastro Torres de. *Nova execução de título extrajudicial*. São Paulo: Método, 2007.
- PEREIRA, José Horácio Cintra Gonçalves. *Da citação ficta no processo de execução*. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes. *Execução civil e cumprimento da sentença*, São Paulo: Método, 2006.
- PERROT, Roger. La coercizione per dissuasione nel diritto francese. *Rivista di Diritto Processuale*. vol. 51. Pádua: Cedam, 1996;
- _____; THÉRY, Phillipe. *Procédures civiles d'exécution*. 2. ed. Paris: Dalloz, 2005.
- PESSOA, Valton. *O convênio Bacen-jud e o princípio da razoabilidade*. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie. *Execução civil – Estudos em homenagem ao Professor Paulo Furtado*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
- PIETROSKI, Tercílio. *A ação de imissão de posse*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990.
- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1974-1978.
- _____. *Tratado das ações*. São Paulo: Ed. RT, 1971-1978.
- _____. *Tratado de direito privado*. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsó, 1971.

- QUARTIERI, Rita. *Tutelas de urgência na execução civil*. São Paulo: Saraiva, 2009.
- REDENTI, Enrico. *Diritto processuale civile*. 2. ed. Milão: Giuffrè, 1957.
- REDONDO GARCÍA, Fernando. *La entrega de la posesión en los procesos de ejecución de inmuebles*. Barcelona: Marcial Pons, 2002.
- REIS, José Alberto dos. *Processo de execução*. 2. ed. Coimbra: Coimbra Ed., 1982.
- RIBEIRO, Darci Guimarães. *A concretização da tutela específica no direito comparado*. In: TESHEINER, José Maria; MILHORANZA, Mariângela Guerreiro; PORTO, Sérgio Gilberto. *Instrumentos de coerção e outros temas de direito processual civil – Estudos em homenagem aos 25 anos de docência do Professor Dr. Araken de Assis*. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
- ROCHA, José de Moura. *Sistemática do novo processo de execução*. São Paulo: Ed. RT, 1978.
- RODRIGUES, Júlio César Souza. *Medidas acautelatórias no processo de execução*. São Paulo: Saraiva, 2002.
- RODRIGUES NETTO, Nelson. *Tutela jurisdicional específica mandamental e executiva lato sensu*. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
- ROSENBERG, Leo; GAUL, Hans Friedhelm; SCHILKEN, Eberhard. *Zwangsvollstreckungsrecht*. 11. ed Munique: C. H. Beck'sche, 1997.
- SACCO NETO, Fernando. *Bancos de dados de proteção ao crédito, execução civil e economia*. In: SANTOS, Ernane Fidélis dos; WAMBIER, Luiz Rodrigues; NERY JUNIOR, Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. *Execução civil – Estudos em homenagem ao Professor Humberto Theodoro Júnior*. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- SALLES, Luiz Caetano de. *O valor da causa e seus reflexos no processo civil*. São Paulo: Iglu, 2000.
- SANTOS, Ernane Fidélis dos. *Manual de direito processual civil*. São Paulo: Saraiva, 1985-1989.
- SANTOS, Ernane Fidélis dos. Aplicação subsidiária de normas do processo de conhecimento no processo de execução. *Revista de Processo*, vol. 29. São Paulo: Ed. RT, 1983.
- SANTOS, Evaristo Aragão. *Anotações sobre os contornos da execução baseada em título extrajudicial, após a Lei 11.382/2006*. In: SANTOS, Ernane Fidélis dos; WAMBIER, Luiz Rodrigues; NERY JUNIOR, Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. *Execução civil – Estudos em homenagem ao Professor Humberto Theodoro Júnior*. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- SANTOS, Ulderico Pires dos. *O processo de execução*. Rio de Janeiro: Forense, 1982.
- SAVATIER, René. *Traité de la responsabilité civile en droit français*. 2. ed. Paris: LGDJ, 1951.
- SCHMIDT JÚNIOR, Roberto Eurico. *O novo processo civil*. Curitiba: Juruá, 1995.
- SHIMURA, Sérgio. *O princípio da menor gravosidade ao executado*. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes; SHIMURA, Sérgio. *Execução civil e cumprimento da sentença*. vol. 2. São Paulo: Método, 2007.
- SOARES, Fernando Luso. *Direito processual civil*. Coimbra: Almedina, 1980.
- SOUSA, Miguel Teixeira. *Acção executiva singular*. Lisboa: Lex, 1998.
- SOUZA, Gelson Amaro. *Sentença na execução – Art. 795 do CPC*. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes. *Execução civil e cumprimento da sentença*. São Paulo: Método, 2006.
- SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. *Direito à moradia e de habitação*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2008.

- TARUFFO, Michele. A atuação executiva dos direitos: perfis comparatísticos. *Revista de Processo*, vol. 59. São Paulo: Ed. RT, 1990.
- TEIXEIRA, Egberto Lacerda. *A nova lei brasileira do cheque*. São Paulo: Saraiva, 1985.
- TEIXEIRA, Guilherme Puschalski. *Tutela específica dos direitos*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.
- TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. *Prazos e nulidades no processo civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1987.
- TESHEINER, José Maria Rosa. *Coisa litigiosa!* Porto Alegre: Corag, 1973.
- _____. *Elementos para uma teoria geral do processo*. São Paulo: Saraiva, 1993.
- _____. Do concurso especial de credores no Código de Processo Civil de 1973. *Revista da Ajuris*. vol. 3. Porto Alegre: s/e, 1975.
- _____. Considerações sobre o conceito de execução no processo civil. *Revista do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: s/e., 1976
- THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de direito processual civil*. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- _____. *Processo de execução*. 7. ed. São Paulo: Leud, 1987.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. vol. 4. Rio de Janeiro: Forense, 1978.
- _____. *A reforma da execução do título extrajudicial*. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
- _____. As nulidades do Código de Processo Civil. *Revista de Processo*, vol. 30. São Paulo: Ed. RT, 1983.
- _____. A penhora *on line* e alguns problemas gerados pela sua prática. *Revista de Processo*, vol. 176. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- _____. *Ação de prestação de contas – força executiva da sentença – prescrição*. In: ARRUDA ALVIM; ARRUDA ALVIM, Eduardo; BRUSCHI, Gilberto Gomes; LARSEN CHECHI, Mara; COUTO, Mônica Bonetti. *Execução civil e temas afins: do CPC/1973 ao novo CPC – Estudos em homenagem ao Professor Araken de Assis*. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- TONIOLO, Ernesto José. *A prescrição intercorrente na execução fiscal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
- TORRES DE MELLO, Rogério Licastro. *Notas sobre a citação na nova execução de título extrajudicial*. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes; SHIMURA, Sérgio. *Execução civil e cumprimento da sentença*. vol. 2. São Paulo: Método, 2007.
- VALVERDE, Trajano de Miranda. *Comentários à lei de falências*. Rio de Janeiro: Forense, 1948.
- VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Tutela específica. *Revista Dialética de Direito Processual*. vol. 3. São Paulo: Oliveira Rocha, 2004.
- _____. *A causa de pedir nas ações de execução*. In: CRUZ E TUCCI, José Rogério; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. *Causa de pedir e pedido no processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2002.
- VIANNA, Luiz Guilherme Paiva. *O saneamento do processo de execução*. In: ARRUDA ALVIM; ARRUDA ALVIM, Eduardo; BRUSCHI, Gilberto Gomes; LARSEN CHECHI, Mara; COUTO, Mônica Bonetti. *Execução civil e temas afins: do CPC/1973 ao novo CPC – Estudos em homenagem ao Professor Araken de Assis*. São Paulo: Ed. RT, 2014.

- VILAR, Wilard de Castro. *Processo de execução*. São Paulo: Ed. RT, 1975.
- VINCENT, Jean. *Voies d'exécution et procédures de distribution*. 14. ed. Paris, Dalloz, 1981.
- ZAVASCKI, Teori Albino. *Título executivo e liquidação*. São Paulo: Ed. RT, 1999.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. vol. 8. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- ZARIF, Cláudio. Questões relativas à citação com hora certa. *Revista de Processo*, vol. 63. São Paulo: Ed. RT, 2002.
- WAMBIER, Luiz Rodrigues. *Sentença civil: liquidação e cumprimento*. São Paulo: Ed. RT, 2006.
- YARSHELL, Flávio. *A reforma da execução civil e a cobrança de prestações periódicas*. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes; SHIMURA, Sérgio. *Execução civil e cumprimento da sentença*. vol. 3. São Paulo: Método, 2009.

© desta edição [2018]

Índice Alfabético-remissivo

Acessões

–liquidação obrigatória na execução para entrega de coisa, **810**, 1

Alienação coativa

–ineficácia perante o terceiro, **804**, 1

Atitudes

–executado na execução para entrega de coisa, **806**, 6

–executado na execução da obrigação de fazer, **815**, 5

–cumprimento voluntário total ou parcial, **815**, 5.1

–inércia do executado, **815**, 5.2

–oposição do executado, **815**, 5.3

–executado na execução para desfazer, **822**, 3

–exequente na execução da obrigação de fazer, **816**, 1

Averbação da execução

–ônus do exequente, **799**, 6

Autenticação

–petição inicial da execução, **798**, 7.3

Bens penhoráveis

–indicação na petição inicial da execução, **798**, 6.3

Benfeitorias

–liquidação obrigatória na execução para entrega de coisa, **810**, 1

Casos

–especiais de preferência, **797**, 6

–pré-penhora, **797**, 6.1

–penhora de crédito, **797**, 6.4

- penhora de crédito a coisa determinada, **797**, 6.5
- penhora registrada, **797**, 6.2
- substituição da penhora, **797**, 6.3
- particulares de escolha nas obrigações alternativas, **800**, 4

Causa de pedir

- petição inicial da execução, **798**, 4.3

Classificação

- invalidades, **803**, 3
- obrigações na lei processual, **800**, 1

Coisa litigiosa

- desposamento do adquirente, **808**, 1
- embargos do adquirente, **808**, 2

Competência

- reunião das execuções, **797**, 8.4

Conhecimento

- penhora anterior sobre idêntico bem, **797**, 8.3

Constituição

- mora, **802**, 7

Construção

- ônus de averbação, **799**, 6

Contratado

- descumprimento na execução de obrigação de fazer, **819**, 1

Controle

- cumprimento da obrigação de fazer, **818**, 1
- cabimento, **818**, 1.1
- procedimento, **818**, 1.2
- cumprimento da obrigação pelo exequente, **820**, 1.5
- forma e momento do controle das nulidades, **803**, 4
- preclusão, **800**, 5

Conversão

- execução específica para entrega de coisa, **809**, 2

–execução da obrigação de fazer fungível, **816**, 2

–execução da obrigação negativa, **823**, 3

Correção

–petição inicial da execução, **801**, 1

Cumulação

–multa pecuniária e perdas e danos, **814**, 4.5

Custeamento

–execução, **817**, 5

–renovação, **819**, 1.3

Datação

–petição inicial da execução, **798**, 7.2

Decisão

–incidente de individualização da coisa, **812**, 2

Deferimento

–petição inicial da execução, **801**, 3

Delimitação

–desfazimento, **822**, 3.2

–objeto da prestação de fazer, **815**, 4

Demanda

–parte na execução, **798**, 1

Desapossamento

–coisa litigiosa, **808**, 1

–compulsório na execução para entrega de coisa, **806**, 7

–objeto, **806**, 2

Descumprimento do contratado

–contraditório na reclamação, **819**, 1.2

–extinção imprópria da execução, **819**, 1.5

–renovação do custeamento, **819**, 1.3

–responsabilidade subsidiária do executado, **819**, 1.4

Desnecessidade

–iniciativa da parte na fixação da multa pecuniária, **814**, 4.1

Despesas

–em proveito comum no concurso especial, **797**, 8.6

Destinatários

–intimação de terceiros titulares de direito real, **799**, 3

Destino

–execuções singulares reunidas, **799**, 8.7

Documentação

–entrega da coisa, **807**, 3

Documentos

–produção na petição inicial da execução, **798**, 7.5

Duplicação

–petição inicial da execução, **798**, 7.6

Duração

–multa pecuniária, **814**, 4.3

Economia

–aplicação do princípio, **805**, 2

–execução, **805**, 1

Efeito(s)

–entrega da coisa, **807**, 4

–interruptivo da prescrição, **802**, 2

–litispendência, **802**, 1

–preterição da intimação de terceiros titulares de direito real, **799**, 4

–sucessividade de penhoras, **797**, 5

Embargos

–adquirente de coisa litigiosa, **808**, 2

Endereçamento

–petição inicial da execução, **798**, 4.1

Entrega

–coisa na execução, **807**, 1

–documentação da entrega, **807**, 3

–efeitos da entrega, **807**, 4

–forma da entrega, **807**, 2

Escolha

–execução de obrigações alternativas, **800**, 3

–impugnação na execução para entrega de coisa incerta, **812**, 1

Espécies de execução

–indicação na petição inicial da execução, **798**, 6.1

Exclusão

–multa pecuniária, **814**, 4.4

Execução específica

–conversão, **809**, 2

–frustração, **809**, 1

Execução da obrigação de fazer fungível

–atitudes do executado, **815**, 5

–cumprimento voluntário total ou parcial, **815**, 5.1

–inércia do executado, **815**, 5.2

–oposição do executado, **815**, 5.3

–atitudes do exequente, **816**, 1

–controle do cumprimento da obrigação de fazer fungível, **818**, 1

–cabimento do controle, **818**, 1.1

–procedimento do controle, **818**, 1.1

–conversão da execução, **816**, 2

–delimitação do objeto da prestação, **815**, 4

–descumprimento do contratado, **819**, 1

–contraditório na reclamação, **819**, 1.2

–extinção imprópria da execução, **819**, 1.5

–renovação do custeamento, **819**, 1.3

–responsabilidade subsidiária do executado, **819**, 1.4

–disciplina da obrigação fungível, **817**, 1

–execução de custeamento, **817**, 5

–execução por terceiro, **817**, 2

–adiantamento do preço pelo exequente, **817**, 2.5

- apresentação da proposta e contraditório, 817, 2.3
- preferência do exequente e formalização do negócio, 817, 2.4
- recrutamento do terceiro, 817, 2.1
- realização extrajudicial da prestação, 817, 2.1
- extinção da execução da obrigação de fazer fungível, **818**, 2
- fixação do prazo de cumprimento, **815**, 3
- comunicação do prazo de cumprimento, **815**, 3.4
- determinação do prazo de cumprimento, 815, 3.2
- indeterminação do prazo de cumprimento, 815, 3.1
- prorrogação do prazo de cumprimento, 815, 3.3
- recurso contra o prazo de cumprimento, **815**, 3.5
- insucesso no recrutamento do terceiro
- natureza das prestações de fazer, **815**, 1
- preferência do exequente, **820**, 1
- controle do cumprimento pelo exequente, **820**, 1.5
- custeamento da execução da prestação pelo exequente, **820**, 1.4
- despesas da execução da prestação, **820**, 1.2
- prazo de execução da prestação, 820, 1.3
- prazo do exercício da preferência, 820, 1.1
- provimento liminar do juízo, 815, 2
- retratação do exequente, **817**, 3
- Execução da obrigação de fazer infungível
- atitudes do executado, 822, 4
- conversão da execução da obrigação negativa, 823, 3
- execução específica das obrigações negativas, 822, 1
- objeto da obrigação negativa, 822, 1.2
- título executivo, 822, 1.1
- execução da obrigação negativa por transformação, 823, 1
- extinção da execução da obrigação negativa, 820, 1
- manutenção dos efeitos materiais, 823, 2
- procedimento da execução para desfazer, 822, 3

–delimitação do desfazimento, 822, 3.2

–prazo de desfazimento, **822**, 3.1

Execução da obrigação de fazer por terceiro

–adiantamento do preço pelo exequente, 817, 2.5

–apresentação da proposta e contraditório, 817, 2.3

–preferência do exequente e formalização do negócio, 817, 2.4

–recrutamento do terceiro, 817, 2.1

–realização extrajudicial da prestação, **817**, 2.1

Execução das obrigações de fazer

–evolução, 814, 2

–execução específica por meio de multa pecuniária, 814, 4

–cumulação com perdas e danos, 814, 4.5

–desnecessidade de iniciativa da parte, 814, 4.1

–duração da multa pecuniária, **814**, 4.3

–modificação e exclusão da multa pecuniária, 814, 4.4

–opção por outro meio pecuniário, 814, 4.6

–valor da multa pecuniária, 814, 4.2

–fundamento da multa pecuniária, 814, 3

–generalidades, **814**, 1

Execução para entrega de coisa certa

–atitudes do executado, 806, 6

–conversão da execução específica, 809, 2

–desapossamento compulsório, 806, 7

–desapossamento da coisa litigiosa, 808, 1

–documentação da entrega, **807**, 3

–efeitos da entrega, 807, 4

–embargos do adquirente, 808, 2

–entrega da coisa, **807**, 1

–extinção, **810**, 2

–fase inicial, **806**, 4

–forma da entrega, **807**, 2

- frustração da execução específica, **809**, 1
- liquidação obrigatória das benfeitorias, **810**, 1
- meios executórios, **806**, 1
- objeto do desapossamento, **806**, 2
- prazo de cumprimento, **806**, 5
- título executivo, **806**, 3

Execução para entrega de coisa incerta

- decisão e instrução do incidente de individualização, **812**, 2
- generalidades, **811**, 1
- impugnação à escolha, **812**, 1
- incidente de individualização, **811**, 2
- prosseguimento da execução, **813**, 1
- repercussões da escolha prévia, **813**, 2

Extinção

- execução para entrega de coisa, **810**, 2
- execução da obrigação de fazer fungível, **818**, 2
- execução da obrigação negativa, **823**, 4

Fase

- inicial da execução para entrega de coisa, **806**, 4

Fato indébito

- comprovação na execução da obrigação negativa, **822**, 2

Forma

- controle das nulidades, **803**, 4
- entrega da coisa, **807**, 4
- intimação do terceiro titular de direito real, **799**, 2
- petição inicial da execução, **798**, 7.1

Frustração

- execução específica para entrega de coisa, **809**, 1

Fundamento

- multa pecuniária, **814**, 4

Identificação

–partes na petição inicial da execução, **798**, 4.2

Impugnação

–individualização da coisa incerta, **812**, 1

Incidente

–escolha nas obrigações alternativas, **800**, 3

–individualização na execução para entrega de coisa incerta, **811**, 2

Indeferimento

–petição inicial da execução, **801**, 3

Indicação

–bens penhoráveis na petição inicial, 798, 6.3

–endereço do advogado na petição inicial, 798, 7.4

–espécies de execução na petição inicial, **798**, 6.1

Indisponibilidade

–patrimonial relativa, **802**, 6

Ineficácia

–alienação coativa perante o terceiro não intimado, 804, 1

–meios de declaração, **804**, 2

Iniciativa

–oficial na execução, **798**, 2

Instrução

–incidente de individualização, 812, 2

–petição inicial, 798, 5

–ônus da exibição do demonstrativo do débito, 798, 5.4

–ônus de exibição do título executivo, 798, 5.1

–prova da prestação nas obrigações bilaterais, 798, 5.3

–prova do termo e da condição, **798**, 5.2

Insucesso

–recrutamento do terceiro na execução da obrigação de fazer, **817**, 4

Intimação

–destinatários, **799**, 3

–direito real de garantia e credor fiduciário, **799**, 3.1

- direito real de usufruto, de uso ou de habitação, **799**, 3.2
- promitente vendedor e promitente comprador de promessa, **799**, 3.3
- proprietário do terreno e de direito real limitado sobre coisa alheia, **799**, 3.4
- sociedade limitada e companhia de capital fechado, **799**, 3.5
- efeitos da preterição, **799**, 4
- forma, **799**, 2
- momento, **799**, 2
- terceiro titular de direito real, **799**, 1

Invalidades

- classificação, **803**, 2

Lage

- intimação do titular, **799**, 3.6

Liquidação

- obrigatória na execução para entrega de coisa, **810**, 1

Litigiosidade

- processo executivo, **802**, 6

Litispêndência

- proceso executivo, **802**, 5

Manutenção

- efeitos materiais do descumprimento da obrigação negativa, **823**, 2

Medidas de urgência

- executado, **799**, 5.2
- momento da concessão, **799**, 5.3
- objeto, **799**, 5.1
- recurso próprio, **799**, 5.4

Meios

- declaração da ineficácia, **804**, 2
- executórios na execução para entrega de coisa, **806**, 1

Meios de prova

- indicação na petição inicial da execução, **798**, 4.6

Modificação

–multa pecuniária, **814**, 4.4

Momento

–concessão de medidas de urgência, 799, 5.3

–controle das nulidades, 803, 4

–intimação do terceiro titular de direito real, **799**, 2

Multa pecuniária

–fundamento, 814, 3

–execução, 814, 4

–cumulação com perdas e danos, 814, 4.5

–desnecessidade de iniciativa da parte, 814, 4.1

–duração da multa pecuniária, 814, 4.3

–modificação e exclusão da multa pecuniária, 814, 4.4

–opção por outro meio pecuniário, 814, 4.6

–valor da multa pecuniária, **814**, 4.2

Natureza

–preferência da penhora, **797**, 3

–prestação de fazer, **815**, 1

Nulidades cominadas

–execução, 803, 3

–citação inexistente ou nula, 803, 3.2

–falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título, 803, 3.1

–falta de verificação do termo ou ocorrência da condição, **803**, 3.3

Objeto

–desapossamento na execução para entrega de coisa, 806, 2

–obrigação negativa, **822**, 1

Obrigação

–alternativa, 800, 2

–execução específica da obrigação negativa, **822**, 1

Obrigações

–classificação na lei processual, **811**, 1

Obrigatoriedade

–reunião das execuções, **797**, 8.2

Ônus

–averbação da propositura da execução e da constrição, **799**, 6

–exibição de demonstrativo do débito, **798**, 5.4

–exibição do título executivo, **798**, 5.1

Opção

–outro meio executório na execução por multa pecuniária, **814**, 4.6

Pedido

–formulação na petição inicial da execução, **798**, 4.4

–medidas de urgência na execução, **799**, 5

Penhora

–pluralidade de penhoras sobre idêntico bem, **797**, 7

Petição inicial

–correção, **801**, 1

–deferimento, **801**, 3

–execução, **798**, 3

–indeferimento, **801**, 2

Poderes

–das partes na reunião das execuções, **797**, 8.5

Posição

–credor real no concurso especial, **797**, 4.2.1

–credores privilegiados no concurso especial, **797**, 4.2.2

Prazo

–cumprimento na execução para entrega de coisa, **806**, 5

–cumprimento na execução da obrigação de fazer, **815**, 3

–comunicação do prazo de cumprimento, **815**, 3.4

–determinação do prazo de cumprimento, **815**, 3.2

–indeterminação do prazo de cumprimento, **815**, 3.1

–prorrogação do prazo de cumprimento, **815**, 3.3

–recurso contra o prazo de cumprimento, **815**, 3.5

–execução da prestação de fazer pelo exequente, **820**, 1.4

–exercício da preferência pelo exequente, 820, 1.1

–desfazimento, **822**, 3.1

Preclusão

–controle das nulidades, **803**, 5

Preferência

–casos especiais, **797**, 6

Preferência do exequente na execução da obrigação de fazer

–controle do cumprimento pelo exequente, 820, 1.5

–custeamento da execução da prestação pelo exequente, 820, 1.4

–despesas da execução da prestação, 820, 1.2

–prazo de execução da prestação, 820, 1.3

–prazo do exercício da preferência, **820**, 1.1

Prescrição

–efeito interruptivo, **802**, 2

–pretensão a executar, **802**, 3

Prevenção

–processo executivo, **802**, 4

Princípio

–economia na execução, **805**, 1

–interesse do exequente, **797**, 1

–prevenção, **797**, 2

–natureza, **797**, 3

–pressupostos, **797**, 3

–inexistência de prelação, **797**, 4.2

–posição do credor real, **797**, 4.2.1

–posição dos credores privilegiados, **797**, 4.2.2

–solvência do executado, **797**, 4.1

Pressupostos

–princípio da prevenção, **797**, 4

–reunião das execuções, **797**, 8

Procedimento

–controle do cumprimento da obrigação de fazer, 818, 1.2

–execução para desfazer, 822, 3

Produção

–documentos indispensáveis na petição inicial, 798, 7.5

Prosseguimento

–execução para entrega de coisa após individualização, 813, 1

Prova

–prestação nas obrigações bilaterais, 798, 5.3

–termo ou condição, 798, 5.2

Provimento

–liminar do juízo na execução da obrigação de fazer, 815, 2

–liminar do juízo na execução para entrega de coisa, 806, 4

Qualificação

–partes na petição inicial da execução, 798, 4.2

Recurso

–contra fixação do prazo de cumprimento, 815, 3.5

–contra medidas de urgência, 799, 5.4

Repercussões

–escolha prévia da coisa incerta, 813, 2

Requerimento

–benefício da gratuidade na petição inicial, 800, 3.5

–citação do executado na petição inicial, 798, 6.2

–investigação de ativos financeiros na petição inicial, 798, 6.4

Requisitos especiais da petição inicial

–indicação da espécie de execução, 798, 6.1

–indicação de bens penhoráveis, 798, 6.3

–requerimento de citação do executado, 798, 6.2

–requerimento do benefício da gratuidade, 798, 6.5

–requerimento de investigação de ativos financeiros, 798, 6.4

Requisitos formais da petição inicial

–autenticação, 798, 7.3

- datação, 798, 7.2
- duplicação, 798, 7.6
- forma, 798, 7.1
- indicação do endereço do advogado, 798, 7.4
- produção dos documentos indispensáveis, 798, 7.5

Requisitos gerais da petição inicial

- causa de pedir, 798, 4.3
- endereço, 798, 4.1
- identificação e qualificação das partes, 798, 4.2
- meios de prova, 798, 4.6
- pedido, 798, 4.4
- valor da causa, 798, 4.5

Retratação

- exequente pela execução do fazer por terceiro, 817, 4

Reunião das execuções

- despesas em proveito comum, 797, 8.6
- destino das execuções singulares, 797, 8.7
- competência, 797, 8.4
- conhecimento da penhora anterior, 797, 8.3
- obrigatoriedade, 797, 8.2
- poderes das partes, 797, 8.5
- pressupostos, 797, 8.1

Título executivo

- execução para entrega de coisa, 806, 3
- obrigação negativa, 822, 1.1
- ônus de exibição na petição inicial, 798, 5.1

Terceiros

- intimação na petição inicial da execução, 799, 1

Transformação

- execução da obrigação de fazer fungível, 817, 1
- execução da obrigação negativa, 823, 1

Valor

–multa pecuniária, **814**, 4.2

Valor da causa

–petição inicial da execução, **798**, 4.5

© desta edição [2018]